

**الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
للحد من سلطة الإدارة التقديرية
وموقف مجلس الدولة المصري منها**

الدكتور

رمضان بطيخ

أستاذ ورئيس قسم القانون العام

مدير مركز الدراسات القانونية والاقتصادية (س)

كلية الحقوق جامعة عين شمس

عضو الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور المصري

المستشار القانوني والخبير الدستوري لمجلس الأمة الكويتي

(٢٠١٦ – ٢٠٢٣)

المحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا

المحكم الدولي

الناشر

دار النهضة العربية

٣٢ ش عبد الخالق ثروت - القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

"قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ"

صدق الله العظيم

(سورة آل عمران: آية رقم ٢٦ ، ٢٧)

مقدمة

لم يعد هناك جدل أو نقاش من جانب رجال الفقه والقضاء حول ضرورة تمتع الإدارة - وهي تباشر معظم اختصاصاتها ومسئولياتها القانونية - بسلطة تقديرية، أو بقدر من حرية التصرف. فالجميع معترف في واقع الأمر بأن هذه السلطة أو ذلك القدر من الحرية يعد بمثابة الشرط الأول لحياة وبقاء كل إدارة، خاصة بعد أن تعاضم الدور الذي أصبحت تضطلع به في الوقت الراهن نتيجة تشعب وتداخل مجالات ومسئوليات الدولة الحديثة . .

إلا أن الجميع مجمع في ذات الوقت كذلك على أن هذه السلطة التقديرية لا يجب أن تباشر خارج إطار القانون. بمعنى أن الإدارة حينما تباشر اختصاصاتها التقديرية - إيجابية كانت أم سلبية - فإنه يجب عليها أن تلتزم في هذا الشأن ، دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في المجتمع، لما في ذلك من كفالة وضمانة لحماية حقوق الأفراد وحررياتهم، ولما في ذلك أيضا من إقرار بأن الدولة التي بها تلك الإدارة دولة قانونية يسودها مبدأ المشروعية. إذ مهما قيل في ضرورة السلطة التقديرية للإدارة، ومهما قيل في تبريرها... فإن هذه السلطة لا يمكن أن تظهر في نظام لا يأخذ بنظام الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون، فحيث لا تكون الدولة قانونية وحيث لا يكون للقانون من سيادة، فلا معنى للتكلم عن السلطة التقديرية للإدارة ، ذلك لأن سلطتها ستكون عندئذ سلطة تحكمية لا تقديرية^(١).

هناك إذن ارتباط وتلازم بين أن يكون للإدارة سلطة تقديرية، وبين أن

(١) دكتور/ ثروت بدوى، الدولة القانونية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الثالث، السنة الثالثة، ١٩٥٩، ص ٢٨؛ دكتور/ عصام عبد ال وهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، دكتوراه، دار النهضة العربية، ١٩٧١، ص ١.

تكون الدولة التي تباشر فيها الإدارة هذه السلطة دولة قانونية، ولكن كيف نضمن خضوع الإدارة للقانون في هذه الدولة القانونية؟ أو بمعنى آخر كيف يمكن حث الإدارة وإجبارها على ضرورة الالتزام - حينما تباشر اختصاصاتها التقديرية - دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في المجتمع؟

يجمع الفقه في الواقع على أن الرقابة الإدارية أو الذاتية، والرقابة السياسية سواء أكانت رقابة برلمانية أم رقابة رأى عام وإن كانت تلعب دوراً هاماً في هذا الصدد، إلا أن الرقابة القضائية تعد من أنجح وأفضل السبل لذلك، لما تكفله للأفراد من ضمانات وامتنيازات تفتقر إليها كافة صور الرقابة الأخرى. فالرقابة القضائية كما تقول المحكمة العليا "هي المظهر العملي الفعال لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون، كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود"^(١).

(١) المحكمة الدستورية العليا الآن، الحكم الصادر بتاريخ ١٩٧٦/٤/٣، الدعوى رقم ١٣ لسنة ٥ دستورية، المجموعة الأولى، القسم الأول، ص ٤٤٢.

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجهة القضائية التي تباشر مثل هذه الرقابة إنما تختلف باختلاف النظام القضائي في الدولة وعما إذا كان يقوم على أساس وحدة القضاء أمام على أساس ازدواجيته، ففي الحالة الأولى، أي حالة وحدة القضاء وهي التي تنقسم بها - بصفة عامة - الدول الأنجلوسكسونية وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، تباشر المحاكم العادية الرقابة على وحدات الإدارة العامة، ولهذا تخضع هذه الوحدات - شأنها شأن الأفراد أو الهيئات الأخرى - لذات القواعد القانونية فيما يتعلق بهذه الرقابة؛ أما في حالة الدول التي تأخذ بمبدأ ازدواجية القضاء، أي الدول التي يوجد بها قضاء إداري بجانب القضاء العادي، فإن الذي يباشر الرقابة على الهيئات الإدارية هو القضاء الإداري، وهو قضاء متخصص في مجال الإدارة، ومن ثم لا تخضع وحدات الإدارة لذات القواعد التي يخضع لها الأفراد أو الهيئات الأخرى في هذا الخصوص، وإنما تنفرد بقانون خاص يسمى القانون الإداري Droit Administratif.

ولما كان البحث الذي نحن بصددته يتعلق فقط بتطور هذه الرقابة في قضاء كل من مجلس الدولة في فرنسا، ومجلس الدولة في مصر وهما من الدول التي تأخذ بمبدأ

من هنا يمكن القول أن الرقابة القضائية لمختلف أعمال أو أنشطة الإدارة التقديرية تمثل مطلباً ملحا وأساسيا في الدولة القانونية لحماية حقوق الأفراد وحياتهم ضد التعسف أو التسلط المحتمل من جانب الإدارة حين مباشرتها تلك الأعمال.

ومع ذلك يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي امتنع تماما، طوال القرن الماضي وحتى بداية هذا القرن، عن بحث مسألة السلطة التقديرية للإدارة أو بسط رقابته على الأنشطة التي تباشرها بمقتضى ما تتمتع به من سلطة تقديرية معتبرا أن هذه السلطة مما يدخل في إطلاقات الإدارة، دون أدنى رقابة عليها من جانب القضاء.

هذا المسلك من جانب مجلس الدولة وإن كان راجعا بصفة أساسية لأسباب سياسية، وهي الأسباب التي قد توقف أو على العكس قد تدفع بخطى واسعة الوظيفة القضائية في طريق النمو والتطور^(١)، إلا أنه كان مع

ازدواجية القضاء، لذا فإننا لن نتطرق بالحديث إلى الرقابة القضائية في النظم الأنجلوسكسونية إلا إذا لزم الأمر.

انظر مؤلفنا بعنوان "الرقابة على أداء الجهاز الإداري دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية والإسلامية، دار النهضة العربية، ١٩٩٣.

(١) فقد قيل بأن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية تمثل إفتئاتا على استقلال الإدارة المقرر لها بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك لأن القاضي في رقابته على سلطة الإدارة التقديرية إنما يقوم بإحلال تقديره الشخصي محل تقدير جهة الإدارة، أو أنه في رقابته على هذا التقدير يقوم بإحلال نفسه محل رجل الإدارة ويمارس أحد اختصاصاته وبهذه المثابة فإنه يخرج عن دوره كقاضى مشروعية ليصبح رئيسا أعلى للإدارة.

كما قيل كذلك بأن هذا المجلس نتيجة إدراكه أنه وجد كبديل للمحاكم العادية للنظر في أفضية الإدارة، تلك المحاكم التي كان يطلق عليها آنذاك "البرلمانات القضائية" والتي منعت من مباشرة تلك المهمة لما كانت تتسم به من سمعة سيئة، سواء لدى المواطنين أو لدى رجال الثورة الفرنسية أنفسهم، نتيجة تدخلها الدائم في أعمال الإدارة، والحد بالتالي من استقلالها وحيثيتها في التصرف، بل ونتيجة وقوفها حجر عثرة في وجه أي إصلاح يراد إدخاله على الجهاز الإداري، وترى أنه ينتقص من امتيازاتها، فقد خشى أن يؤدي تدخله في أعمال الإدارة ومحاسبتها على كل كبيرة وصغيرة، أن يعيد للأذهان تلك الصورة السيئة، الأمر الذي قد يعصف بوجوده ذاته. لذلك فقد فضل أن يكتسب ود وثقة

ذلك مسلکا متلائماً ووظائف الدولة البسيطة أو المتواضعة، وظائف الدولة الحارسة آنذاك، ولكن عندما تطورت تلك الوظائف نتيجة سيادة مذهب التدخل، وظهور الإدارة بالتالي كعنصر هام وأساسي في حياة الأفراد، أصبح مسلک مجلس الدولة السابق منتقدا لما فيه من إضرار بمصالح المتقاضين وانتقاص من الضمانات التي تكفل لهم حماية حقوقهم وحرياتهم، بل ولما فيه من تشجيع على التعسف والتحكم الإداري.

الإدارة والقائمين عليها وذلك عن طريق امتناعه عن أية رقابة تؤدي إلى الانتقاص من حريتها، واستقلاليتها فيما تباشره من أنشطة تقديرية، مكتفيا في هذا الصدد برقابة مشروعية تلك الأنشطة دون ملاءمتها.

إضافة إلى ذلك فقد قيل بحجتين أخرتين تبريرا لهذا المسلک:

- **الحجة الأولى:** تتمثل في النظر إلى مجلس الدولة على أنه مماثل لمحكمة النقض من حيث كونها محكمة قانون فقط، ومن ثم فقد كان على القاضي الإداري - كما يفعل قاضي محكمة النقض - أن يمتنع عن رقابة الوقائع التي استندت إليها الإدارة في قرارها مكتفيا في هذا الشأن بإنزال حكم القانون عليها. ومعنى ذلك أن مجلس الدولة كان يحترم سلطة الإدارة حينما تبحث في الوقائع وتقديرها، فلا يناقشها صحة هذه الوقائع ولا حتى وجودها المادي، تماما كما يحترم قضاء النقض هذه السلطة لمحكمة أو لقاضي الموضوع. فكلهما إذن قاضي قانون لا قاضي وقائع. وفي هذا المعنى يقول VEDEL أن قاضي تجاوز السلطة بالنسبة للقرارات الإدارية ليس إلا قاضي نقض Juge de cassation ، ومن ثم فإنه ينبغي عليه أن ينظر إلى تقدير الوقائع الذي باشرته الإدارة على أنه عمل نهائي ومفروق منه ومن ثم فلا تعقيب له عليه.

والحجة الثانية: حجة عملية تتمثل في عجز القاضي عن رقابة الجانب التقديري من نشاط الإدارة لأنه مهما وضع أمامه من معلومات ومهما قام بأبحاث وتحريات حول موضوع النزاع فإنه يكون عادة بعيدا عن المكان الذي تتم فيه الوقائع التي تستلزم تدخل رجل الإدارة ، كما أنه يصدر حكمه عادة بعد مضي زمن على حدوث تلك الوقائع، إضافة إلى عدم وجود الخبرة الكافية لديه لمواجهة الحالات التي تعرض للإدارة.

LODOVICI, l'évolution de la notion de pouvoir discrétionnaire, Thèse, lille, 1937, p.14 etss., LA FERRIERE {E} traité de la juridiction administrative et de recours contentieux, 1887, T.I, P.155 etss, KESSLER, le conseil d'Etat, 1968, p.20 etss., PEISER, Le recours en cassation en droit administratif, 1957, p.110 etss., VEDEL, Essai Sur la notion de cause en droit administratif th, p. 63 etss.

من هنا فقد عدل المجلس عن هذا المسلك وانتهج مسلكا آخر، أقر به لنفسه الحق في رقابة كافة وقائع القرارات الإدارية، سواء تلك التي يعتبرها القانون شرطا لاتخاذ هذه القرارات، أو التي لا يعتبرها كذلك، وهي الوقائع التي تدعيها الإدارة بناء على سلطتها التقديرية. وهكذا يصبح القرار الإداري - بناء على هذا المسلك الجديد - واجب الإلغاء كلما ثبت أن الإدارة قد استندت في تبريره إلى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية "Fait matériellement inexact"، يستوى في ذلك أن تكون الإدارة حسنة النية، أو لم تكن كذلك بأن كانت عالمة بانعدام هذه الوقائع. وهذا يعد في الواقع أول قيد يحد به مجلس الدولة من سلطة الإدارة التقديرية.

ثم ما لبث مجلس الدولة أن وسع من نطاق رقابته هذه، وذلك بأن أخضع تلك الوقائع بعد رقابة وجودها المادي والتأكد من صحتها، أخضعها لحكم القانون ليقرر ما إذا كانت تتفق مع ما قصد إليه المشرع من عدمه، أي أصبح يراقب مدى تبريرها للقرار الذي يستن إليها، وهو ما يعرف برقابة التكييف القانوني للوقائع: Le contrôle de la qualification juridique de faits.

بحيث أنه إذا ثبت له عدم تبريرها لذلك القرار، قضى بعدم صحة الوصف القانوني المعطى لها مع إحلال تقديره في هذه الحالة محل تقدير رجل الإدارة. وبذلك يكون قد أضاف قيда آخر يضاف إلى القيد السابق للحد من سلطة الإدارة التقديرية.

ولم يمض وقت طويل على ظهور واستقرار رقابة التكييف القانوني حتى بادر مجلس الدولة باتخاذ خطوة جريئة إلى الأمام، وضع بها قيда أو حدا جديدا على سلطة الإدارة التقديرية. إذ بعد أن انتهى إلى وجوب فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع التي ادعتها الإدارة سببا لقرارها، وصحة

تكييفها قانونا، بحث في تقدير الإدارة لأهمية وخطورة تلك الوقائع، ومدى التناسب بينها وبين الإجراء المتخذ على أساسها، وهو ما يقال له رقابة التناسب أو رقابة الملاءمة le contrôle de l'opportunité.

هذا ويلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي لم ينتهج سياسة موحدة تجاه مختلف القيود التي حد بها من سلطة الإدارة التقديرية، فقد غير بينها تبعا لمدى أهمية المجالات التي تباشر فيها هذه السلطة، ومدى الحرية الواجب تركها للإدارة في تلك المجالات، إذ بينما جعل من القيد الأول (رقابة الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة في حالة عدم النص على هذه الوقائع) مبدأ عاما يطبق في جميع الحالات، فقد جعل من القيد الثاني لرقابة التكيف القانوني للوقائع السابقة أصلا ترد عليه استثناءات، وأخيرا اعتبر القيد الثالث (رقابة التناسب أو الملاءمة) استثناء من أصل عام يتمثل في عدم رقابة هذا التناسب أو تلك الملاءمة.

ومع ذلك ورغم هذه القيود التي أقامها مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية، إلا أنها لم تكن في الواقع قيودا كافية لكبح جماح الإدارة، أو كافيته بدرجة تتحقق معها حماية حقيقية وفعالة لحقوق الأفراد وحياتهم، إذ كانت - رغم تعددها - تترك حالات كثيرة وهامة لمطلق حرية تقدير الإدارة، تباشرها دون أية رقابة عليها من جانب القضاء.

إضافة إلى ذلك فإن القيود السابقة وإن كانت تتلاءم مع المنازعات التي تثور في المجالات التقليدية للإدارة كمنازعات الوظيفة العامة أو الضبط الإداري، إلا أنها لم تعد تتلاءم وفردها مع المنازعات التي تدور في المجالات الحديثة، كالمجالات الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية - العمرانية.... الخ، على أساس أن هذه المجالات إما تتسم بالمرونة والحركة، أي تتسم بسرعة التغيير والتبديل، بل وتتمتع الإدارة حيالها بحرية أوسع

وسلطة أكبر في التقدير والتقييم، الأمر الذي قد يؤدي إلى اتساع وكبر حجم المخاطر والتهديدات التي تحيط بحقوق الأفراد وحياتهم.

أمام ذلك ولمواجهة هذا الوضع فقد خطا مجلس الدولة الفرنسي في الآونة الأخيرة وعلى وجه التحديد منذ عام ١٩٦١ خطوات هامة وجادة في هذا المجال، خطوات لم يكن الفقه الإداري متوقعا إياها أو مبادرا بمحتواها، خطوات تشكل في حقيقتها ثورة في مجال القضاء الإداري على سلطة الإدارة التقديرية، ثورة لا للقضاء على هذه السلطة، أو لتجريد الإدارة من حق مباشرتها، أو لتقييد مجالات أعمالها، وإنما فقط ثورة لضبط وإحكام التوازن الذي من أجله منحت تلك السلطة للإدارة، أو كما يقول لوبادير: من أجل تطييف وعقلنة استعمالها "Pour modérer ou rationalizer son usage"، التوازن بين تمكين الإدارة من مباشرة مرافقها بما يحقق صالح المجتمع ويصون النظام العام فيه، وبين حماية حقوق الأفراد وحياتهم.

لقد ظهرت أولى تلك الخطوات - كما ذكرنا - في عام ١٩٦١، أي في تاريخ حديث نسبيا، وذلك فيما انتهجه مجلس الدولة أولا من سياسة قضائية إزاء الحالات التي استثنائها في السابق من رقابة التكييف القانوني للوقائع، حيث ابتدع ما يسمى رقابة الخطأ البين "l'erreur manifeste" ٩ لكي يتمكن من بسط رقابته على تلك الحالات، ولهذا فقد أطلق على الرقابة في هذه الحالة "رقابة الخطأ البين في تكييف الوقائع" "le contrôle de l'erreur manifeste de qualification des faits"؛ ثم سرعان ما عمل المجلس هذه السياسة القضائية الجديدة بالنسبة لما تجريه الإدارة من تقدير أو تقييم لمدى أهمية وخطورة الوقائع التي تدعيها، ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها، والتي كان يمتنع القاضي الإداري - كقاعدة عامة - عن أعمال رقابته في خصوصها. وقد أطلق على هذا الوجه الجديد

من أوجه الرقابة اسم "رقابة الخطأ البين في التقييم" le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.

إن رقابة الخطأ البين بشقيها على هذا النحو، تشكل في الواقع خطوة هامة وأساسية للحد من سلطة الإدارة التقديرية وذلك لما تفرضه على رجل الإدارة من التزام بضرورة التحلي بالمنطق والمعقولية عند إجراء عملية التكييف أو التقييم للوقائع التي يستند إليها في قراره التقديري. أو بمعنى آخر تفرض هذه الرقابة على رجل الإدارة التزاماً بأن يكون حذراً عند مباشرة سلطته التقديرية، وذلك بالألا يرتكب في خصوص تكييف أو تقييم الوقائع خطأ جسيماً une erreur grave أو خطأً بديهياً une erreur évidente.

وما أن استقرت رقابة الخطأ البين على هذا النحو، كاتجاه حديث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حتى ظهر اتجاه قضائي آخر لا يقل عنه أهمية وجرأة، يتمثل في رقابة الاختيار الحر أو التقديري le choix discrétionnaire من قبل رجل الإدارة، لمضمون القرار أو لأنماط هذا القرار "le contenu ou les modalités de la décision" وهو ما يقال له "رقابة الموازنة بين التكاليف والمزايا" le contrôle du Bilan advantages، أي التكاليف والمزايا المترتبة على القرار التقديري للإدارة، إذ يعتبر هذا القرار معيباً ومن ثم جديراً بالإلغاء - طبقاً لهذا القضاء - إذا كان مشتملاً على عيوب أو أضرار تخل بالتوازن السابق الإشارة إليه. ففي مجال نزع الملكية للمنفعة العامة مثلاً l'expropriation أو في مجال الاستثناءات التي قد ترد على التنظيمات العمرانية la dérogations durbanisme أو في مجالات التدخل الاقتصادي بصفة عامة l'interventionnisme économique حيث يلعب هذا القضاء دوراً

أساسيا، لم يعد قاضي تجاوز السلطة يكتفى - كما كان الحال في السابق - من التحقق من مجرد وجود منفعة عامة للقرار الإداري، وإنما أصبح يباشر إضافة إلى ذلك تقييما حقيقيا لتلك المنفعة في ضوء كافة المعطيات أو الظروف التي تحيط بالقرار مثل: التكاليف المالية - الأضرار التي قد تلحق بالملكيات الخاصة - الأضرار البيئية. المساوىء الاجتماعية... إلخ، لكي يقرر بعد ذلك ما إذا كانت المنفعة العامة التي تدعيها الإدارة لقرارها تعد فعلا منفعة حقيقية، ومن ثم جديرة بالحماية، أم أنها لا تتناسب البتة مع ما قد يترتب على هذا القرار من أضرار ومساوىء مالية أو اجتماعية أو بيئية أو غيرها.

فالقاضي الإداري يضع - طبقا لهذا القضاء - المزايا المترتبة على القرار الإداري في أحد كفتي ميزان العدالة، ويضع في الكفة الأخرى المساوىء أو العيوب التي ينطوى عليها، وذلك بطبيعة الحال - وكما ذكرنا - بالنظر إلى كافة المعطيات أو الظروف التي تحيط به، أي أنه يباشر تقييما حقيقيا لذات التقييم الذي أجرته الإدارة في هذا الشأن ليقرر بعد ذلك ما إذا كان هذا التقييم معقولا Raisonable أو غير معقول Deraisonable.

أما عن مجلس الدولة المصري فقد اكتفى منذ نشأته عام ١٩٤٦ وحتى الآن بتبني الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حيث يقتصر على رقابة وقائع القرارات الإدارية حينما تصدر عن سلطة تقديرية، ورقابة مدى صحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، وأخيرا على رقابة التناسب بين أهمية وخطورة الوقائع وبين الإجراء المتخذ على أساسها وذلك بصفة استثنائية.

أما عن الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والتي بينها فيما سبق، فإننا نبادر إلى القول بأنه بمراجعة أحكام مجلس الدولة

المصرى

سواء في ذلك الاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو تلك الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، لم نجد لتلك الاتجاهات تطبيقات توحى بتبنى ذلك المجلس لها.

حقيقة أن هناك تطبيقاً قضائياً فريداً في تلك الأحكام، قيل بأنه تطبيق قريب أو متشابه إلى حد ما مع نظرية الخطأ البين وهو ما يطلق عليه في الفقه والقضاء المصريين "قضاء الغلو"؛ وحقيقة أيضاً أن هذا القضاء قد ظهر في أحكام مجلس الدولة المصرى قبل أن يعرف نظيره الفرنسي نظرية الخطأ البين، الأمر الذي جعل كثيراً من رجال الفقه يتفاخر بسبق قضائنا في هذا الخصوص. إلا أنه رغم تلك الحقائق فلا زال هناك فرق واضح بين قضاء الغلو وهذه النظرية الأخيرة كما سنبينه في موضعه من هذه الدراسة، إضافة إلى ذلك فإن العبرة ليست بمن سبق الآخر في ظهور نظريته، وإنما العبرة بمن سبق الآخر في تطوير وتجديد هذه النظرية أو تلك. إذ يلاحظ أن القضاء الإدارى المصرى ورغم سبقه في تبني نظرية قضاء الغلو إلا أنه لا زال يحصر نطاق تطبيقها في المجال التأديبي فقط، وهو مجال محدود إذا ما قيس ببقية مجالات العمل الإداري الأخرى، في حين أن مجلس الدولة الفرنسي ورغم حداثة تبنيه لنظرية رقابة الخطأ البين إلا أنه جعل منها نظرية عامة في فقه وقضاء القانون العام، فقد أصبحت تطبق بالنسبة لسائر القرارات الإدارية بل وأياً كان المجال الذي تصدر فيه تلك القرارات.

أما عن نظرية الموازنة بين التكاليف والمزايا، فإن مجلس الدولة المصرى لم يعرفها حتى الآن وإن كانت هناك بعض الأحكام القليلة التي قد توحى بعدم تجاهل قضاؤنا الإداري، كل معنى لهذه النظرية.

من هنا كان البحث الذي نحن بصدد، إذ نهدف من ورائه إلى الوقوف

على مضمون ومركزات الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية، إضافة إلى كيفية أعمال تلك الاتجاهات، وكذلك المجالات التي تطبق في خصوصها، كي نضعها أمام مجلس دولتنا الفتى، حيث نأمل أن يجري فيها نظيره الفرنسي، خاصة أن هذه الاتجاهات أصبحت مطلبا ملحا لمواجهة ما يثور من نزاعات إدارية في الواقع المصرى، والتي برزت على أثر ما أصاب هذا المجتمع من تطورات على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية... وغيرها. وهذا هو ما خصصنا له الباب الثاني من تلك الدراسة.

أما الباب الأول فقد خصصناه لبحث الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وموقف مجلس الدولة المصرى منها. وإذا كان البعض قد يرى في موضوع هذا الباب نوعا من التكرار غير المفيد؛ فإن حقيقة الدوافع التي أملت علينا ذلك هو أنه يثير قضية هامة وأساسية وهي مدى اختصاص قاضى تجاوز السلطة برقابة ملاءمة القرارات الإدارية وذلك فيما يتعلق بوجود الأسباب أو بصحة تكييفها القانوني، إذ يذهب كثير من رجال الفقه إلى أن القاضي الإداري كان وما زال قاضي مشروعية لا قاضى ملاءمة، وهو ما لا نعتقه. حيث نرى أن دوره لا يقتصر فقط على رقابة مشروعية القرارات الإدارية وإنما يتناول أيضا ملاءمة تلك القرارات . لذلك وإستكمالا للفائدة من الدراسة التي نحن بصددتها. فقد خصصنا بابا مستقلا لهذا الموضوع، وهو الباب الأول كما ذكرنا.

بل ولمزيد من الفائدة أيضا فإننا خصصنا فصلا تمهيديا نتناول فيه الأفكار الرئيسية التي تدور حول موضوع السلطة التقديرية محور وأساس الدراسة التي نحن بصددتها.

وترتبيا على ذلك تصبح خطة الدراسة كالأتى :

فصل تمهيدي: أحكام عامة حول السلطة التقديرية للإدارة.

الباب الأول: الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها.

وقسمته ثلاثة فصول:

الفصل الأول: رقابة ماديات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها (القيد الأول للحد من سلطة الإدارة التقديرية).

الفصل الثاني: رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها (القيد الثاني للحد من سلطة الإدارة التقديرية).

الفصل الثالث: رقابة تقدير أهمية وتناسب الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها (القيد الثالث للحد من سلطة الإدارة التقديرية).

الباب الثاني: الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها.

وقسمته فصلين:

الفصل الأول: رقابة الخطأ البين في التقدير (القيد الرابع للحد من سلطة الإدارة التقديرية).

الفصل الثاني: رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار (القيد الخامس للحد من سلطة الإدارة التقديرية)

هذا ونسأل الله العز والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير.

دكتور/ رمضان محمد بطيخ

فصل تمهيدى
أحكام عامة حول السلطة
التقديرية للإدارة

فصل تمهيدي

أحكام عامة حول السلطة التقديرية للإدارة

لما كان الهدف الأساسي من هذه الدراسة ليس بحث السلطة التقديرية في ذاتها، حيث أجريت حول هذه السلطة العديد من الأبحاث والدراسات التي تغطي كافة الجوانب القانونية والفنية لها سواء في الفقه الأجنبي أم في الفقه العربي^(١)، لذا فإننا سنقتصر في هذا الفصل التمهيدي على إعطاء فكرة موجزة عن أهم هذه الجوانب باعتبار أن ذلك يعد بمثابة المدخل الطبيعي للدراسة التي نحن بصددتها. تلك الدراسة التي تتسم بكونها دراسة متجددة ومتطورة نظرا لتعلقها بالمدى الذي وصل إليه القضاء الإداري للحد

(١) حول موضوع السلطة التقديرية انظر:

VENEZIA, le pouvoir discrétionnaire, L.G.D.J., Paris 1959
MICHOU, Étude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration, R.G.A., 1914, P.5, CHATLAIN, De la compétence discrétionnaire du gouvernement dans l'application des lois et jugement, thèse, Paris, 1942, LODOVICI, L'évolution de la notion de pouvoir discrétionnaire, thèse, 1937, RICCI (J.C.), le pouvoir discrétionnaire de l'administration Fiscale, Aix Marseille, 1978, Koutoupa-Rengakos [E.], le pouvoir discrétionnaire de l'administration inter ventionniste en droit Français, Paris, 1987, Lebreton (G.), le pouvoir discrétionnaire exercé par l'administration sur ses agents thèse, Paris, 1988, HAURIOU {A.}, le pouvoir discrétionnaire et sa justification, Mélanges carré de Malberg, 1933, GIRAUD, Étude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration, R.G.A., 1924, P.28, MERLKOSKI, Le pouvoir discrétionnaire de l'administration, I.I.S.A., Bruxelles, 1958.

الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية والرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دكتوراه، حقوق القاهرة، ١٩٧١؛ الدكتور/ محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية، دكتوراه، حقوق عين شمس، ١٩٧٤؛ الدكتور/ سليمان الطماوى، السلطة التقديرية والمقيدة، مجلة الحقوق، ١٩٥٠؛ الأستاذ/ محمد عبد الجواد حسن، بين سلطة الإدارة التقديرية واختصاصها المقيد، مجلة مجلس الدولة، السنة الرابعة، ١٩٥٣.

من تلك السلطة التقديرية، إذ لا يكاد أن ينتهى هذا القضاء من وضع قيد يحد به من هذه السلطة، إلا وابتدع قيذا ثان ثم ثالث... وهكذا. الأمر الذي يتطلب متابعة دائمة ومستمرة وذلك على ما سنبينه فيما بعد.

لذا نتناول بإيجاز الموضوعات التالية مخصصين لكل موضوع منها مبحثا مستقلا.

- مراحل ظهور السلطة التقديرية في المجالات الإدارية.
- تعريف السلطة التقديرية للإدارة والأساس القانوني لها.
- مبررات السلطة التقديرية للإدارة وموضعها في القرار الإداري.

المبحث الأول

مراحل ظهور السلطة التقديرية في المجالات الإدارية

لم تظهر السلطة التقديرية في المجالات الإدارية طفرة واحدة، وإنما مرت في الواقع بمراحل عديدة تشكل فيما بينها حلقات متصلة، بحيث تبدو كل مرحلة من هذه المراحل بمثابة مقدمة أو تمهيد للمرحلة التالية لها، وذلك إلى أن اتضحت معالم تلك السلطة وتحددت سماتها وضوابطها على النحو الذي هي عليه الآن.

وتبدأ هذه المراحل بانعدام أو اختفاء كل تقدير للإدارة، ثم باختفاء كل تقييد للإدارة مع ظهور فكرة القرارات الإدارية البحتة، ثم باختفاء هذه القرارات الأخيرة مع ظهور القرارات التقديرية، وأخيرا باختفاء القرارات التقديرية هذه مع ظهور السلطة التقديرية.

وهذا ما نبينه بإيجاز كما يلي.

- مرحلة اختفاء كل تقدير للإدارة.
- مرحلة اختفاء كل تقييد للإدارة مع ظهور القرارات الإدارية البحتة.
- مرحلة اختفاء القرارات الإدارية البحتة مع ظهور القرارات التقديرية للإدارة.
- مرحلة اختفاء القرارات التقديرية للإدارة مع ظهور السلطة التقديرية.

المطلب الأول

مرحلة اختفاء كل تقدير للإدارة

عند قيام الثورة الفرنسية، ومع صدور إعلان حقوق الإنسان عام ١٧٨٩، تقرر خضوع الإدارة للقانون أو لمبدأ سيادة القانون، بشكل يجعل منها هيئة خاضعة وتابعة للسلطة التشريعية، بحيث لا تستطيع أن تبشر أي عمل أو تخذ أي إجراء، إلا إذا كان مطابقاً للقانون، وذلك انطلاقاً من أن السلطة التشريعية إنما تعبر عن الإرادة العامة للشعب صاحب السيادة، ومن ثم يجب أن يخضع الجميع حكماً ومحكومين لما تسنه من قواعد قانونية، الأمر الذي يتحقق معه مبدأ سيادة القانون أو مبدأ الدولة القانونية، من هنا فقد أصبح كل عمل يصدر من جانب الإدارة لا يمكن أن يكون إلا تنفيذاً للقانون المعبر عن الإرادة العليا للشعب، وهذا الخضوع لم يكن مقتصرًا في الواقع على ما كان متعلقاً بأعمال الإدارة التي تنتج آثاراً خاصة تجاه الأفراد، بل كان يمتد إلى جميع الإجراءات الإدارية بما في ذلك الإجراءات التي كانت تخص مجرد التنظيم الداخلي للمرافق الإدارية والتي لا تتعدى آثارها نطاق الجهاز الحكومي^(١).

وهكذا يمكن القول باختفاء كل تقدير للإدارة في هذه المرحلة، إذا لم تكن تتمتع في تلك الأثناء بأية سلطة في تقدير أو وزن أعمالها، وإنما كانت تتصرف بشكل شبه آلي، وبما يضمن فقط تنفيذ القانون، أو ما يعبر عن امتثالها لأوامر المشرع ونواهيه، أي أن اختصاصها كان من قبيل الاختصاص المقيد، وهذا ما يؤكد نص المادة الثانية من القسم الثاني من مرسوم ١٤-١٦ فريمير، السنة الثالثة حيث كانت تقضى بأن "يتمتع مطلقاً

(١) الدكتور/ ثروت بدوي، الدولة القانونية، مقال سبق ذكره، ص ٥٦.

على كل سلطة أو موظف عام أن يتخذ قرارات يخالف بها المعنى الحرفي للقانون سواء بحجة تفسيره أو سد ثغراته، إذ يجب الرجوع دائما في هذا الشأن إلى الجمعية الوطنية صاحبة الحق في إعطاء التفسيرات أو سد الثغرات" هذه الجمعية التي وصفتها المادة الأولى من القسم الثاني من ذات المرسوم بأنها تمثل المركز الوحيد لتسيير الحكومة.

وإمعانا في تحقيق مبدأ سيادة القانون أن قيام دولة القانون l'Etat droit حسب مفهوم رجال الدورة الأوائل فقد تم تفسير مبدأ الفصل بين السلطات بشكل يحقق تلك النتيجة أو ذلك المفهوم. ولهذا فقد قيل أن هذا المبدأ يعني استقلال السلطة الإدارية عن السلطة القضائية، استقلالا يحول دون خضوع أى منهما للأخرى، ولا خشية من ذلك - يقول رجال الثورة - طالما أن السلطتين خاضعتين تماما لأحكام القانون، تلك الأحكام التي لم تترك لأى منهما قدرا من حرية التقدير.

وعلى ذلك أصبح محرما - طبقا لهذا التفسير - على السلطة القضائية أن تباشر أية رقابة على أعمال الجهاز الإداري، وتأكيدا لذلك فقد صدر قانون ١٦ - ٢٤ أغسطس لسنة ١٧٩٠ ناصا في القسم الثاني منه على منع القضاة من التصدى لأعمال الإدارة، أو استدعاء الموظفين لأسباب تتعلق بوظائفهم^(١).

بل لقد حرص رجال الثورة الفرنسية على التمسك بهذا الفصل لما كانت تحيط بالمحاكم القضائية آنذاك، والتي كانت تعرف باسم "البرلمانات

(1) "les Fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des Fonctions administratives, les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratif ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur Fonctions".

القضائية" من سمعة سيئة نتيجة سوء استعمالها لسلطاتها تجاه الإدارة وعمالها، ووقوفها حجر عثرة أمام ما كانت تصبوا إلى تحقيقه ممن إصلاحات وتطورات.

المطلب الثاني

مرحلة اختفاء كل تقييد الإدارة مع صدور قرارات الإدارة البحتة

إذا كان رجال الثورة الفرنسية قد نادوا بمبدأ الفصل الصارم بين السلطات، خاصة بين الإدارة والقضاء، وكذلك بانعدام كل تقدير للإدارة، وذلك للاعتبارات السابق بيانها، إلا أنه نظرا لأن هذه الاعتبارات لم تكن سوى مجرد اعتبارات نظرية بعيدة عن الواقع العملي، فقد ساد الجهاز الإداري مبدأ آخر على خلاف أو على عكس ذلك الذي كان يهدف إليه رجال الثورة الفرنسية.

فمن ناحية، لقد أظهر الواقع العملي للجهاز الإداري استحالة تقييد الإدارة بحرفية ما يصدر عن المشرع من قوانين وأحكام، نظرا لما قد يطرأ في الحياة العملية من مستجدات وأحداث، تتطلب تفسيراً مرناً لهذه القوانين وتلك الأحكام، أو تتطلب إكمالاً لنصوصها التي تظهر عجزاً في معالجة مختلف هذه المستجدات والأحداث. إضافة إلى أن أكثر النصوص القانونية ذاتها لم تكن ممكنة التطبيق بذاتها حيث كانت تتطلب لذلك صدور لوائح تنفيذية تبين كيفية وشروط هذا التطبيق. من هنا فقد أصبح ضروريا أن يترك للسلطة التنفيذية قدر من الحرية لاتخاذ ما تراه ملائماً من قرارات تواجه به تلك التطورات أو المستجدات العملية، بل وأن تعتبر هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توضيح وتفسير وإعادة صياغة تلك القرارات. وقد كان من نتيجة ذلك أن بدأت الإدارة تتحرر من الخضوع الضيق للقانون.

ومن ناحية أخرى، فإن إصرار رجال الثورة على منع القضاء العادي من نظر كافة منازعات الإدارة، أو التدخل في أعمالها، قد أدى إلى تمتع الإدارة بحرية واسعة في التقدير، حرية لا يحد منها سوى قيد احترام الحقوق الشخصية للأفراد، خاصة أنها هي ذاتها التي كانت تتولى الفصل في المنازعات التي تكون طرفا فيها، ومن ثم فقد أصبحت خصما وحكما في ذات الوقت.

إن سيادة القانون أو دولة القانون التي كان يهدف إليها رجال الثورة الفرنسية من خلال ما نادوا به من مبادئ أو ما صاغوه من قوانين، قد أصبحت والحال هكذا، مجردة من أية حماية أو ضمانة فعالة. حقيقة أنه تم إنشاء مجلس الدولة وذلك بمقتضى المادة رقم ٥٢ من دستور السنة الثانية في عهد نابليون بونابرت، ليفصل في منازعات الأفراد مع الإدارة، إلا أن دور هذا المجلس في الحد من حرية الإدارة في التقدير، أو في ضمان حقوق وحریات المواطنين، كان في البداية دورا محدودا ومتواضعا للغاية. فقد كان في بادئ الأمر بمثابة هيئة استشارية يقتصر عمله على مجرد إبداء الرأي والمشورة للإدارة، لدرجة أنه وصف بأنه مجرد واجهة أو ستار لاستمرار التحكم الإداري بشكل أو بآخر. إذ يقول أستاذنا الدكتور/ ثروت بدوي في هذا الخصوص: أنه "ليس ثمة شك في حقيقة الدوافع التي أدت بنابليون إلى إنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم، فإن النزعة الدكتاتورية لذلك الرجل لم تكن لتجعله يقدم على إنشاء محاكم مستقلة تحاسب رجاله وتنظر في تصرفاتهم، ولم يكن من المتصور أن يقبل نابليون أن يترك الإدارة تحت رحمة قضاء مستقل يفصل في إشكالات الإدارة وفقا لقواعد عامة نظرية أو معايير موضوعية. ولكن نابليون أراد أن يضع حدا لشكوى المواطنين في عدم وجود قضاء يفصل في منازعاتهم مع الإدارة، فأنشأ

مجلس الدولة وجعله خاضعا له^(١).

وهكذا انقلب وضع الإدارة الفرنسية رأسا على عقب، إذ بعد أن كانت مقيدة في تصرفاتها وممنوعة حتى من مجرد إصدار لوائح تنفيذية أو تفسيرية للقوانين التي ترغب في تطبيقها أو تنفيذها، أصبحت طليقة من كل قيد حرة في تقديرها للأمور، لها أن تتخذ أو ألا تتخذ ما تشاء من قرارات أو تصرفات، بل وغدت هي ذاتها - كما ذكرنا - الجهة القضائية ذات الاختصاص العام في المنازعات الإدارية. ومعنى ذلك أن اختصاصها بعد أن كان من قبيل الاختصاص المقيد *la compétence liée* أصبح اختصاصا تقديريا *une compétence discrétionnaire*.

ولقد ظل وضع الإدارة على هذا النحو حتى بعد صدور قانون بتاريخ ٢٤ مايو ١٨٧٢ يمنح مجلس الدولة سلطة البت النهائي في المنازعات الإدارية، الأمر الذي كان يعني أن هذا المجلس أصبح محكمة قضائية بمعنى الكلمة، وانتقاله بالتالي من مرحلة القضاء المحجوز *justice retenue*، إلى مرحلة القضاء البات أو المفوض *justice déléguée* إضافة إلى دوره في مجال الإفتاء وصياغة التشريعات، ذلك أن مجلس الدولة ظل رغم تلك التطورات وحتى أواخر القرن التاسع عشر مقيدا بما كان يسمى "نظرية الوزير القاضي" *la théorie du ministre juge*، والتي كان من مقتضاها عدم إمكانية لجوء أصحاب الشأن بدعواهم إلى مجلس الدولة مباشرة وإنما عن طريق الإدارة إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها القانون صراحة.

ورغم أنه قد صدر بتاريخ ١٣ ديسمبر ١٨٨٩ حكم شهير لمجلس

(١) مبادئ القانون الإداري، المجلد الأول، القاهرة، ١٦٦، ص ٦١.

الدولة cadot يجوز قبول الدعوى المرفوعة من أحد الأفراد مباشرة دون إلزامه بضرورة الالتجاء أولاً إلى الوزير المختص، مما كان يعني أن هذا المجلس قد اعتبر نفسه قاضياً للقانون العام، ومن ثم مختصاً بنظر كافة المنازعات الإدارية إلا ما أشتت منها بنص صريح، وكذلك رغم أن التقييد الذي أتى به مرسوم ٣٠ سبتمبر ١٩٥٣ بتحديد اختصاص مجلس الدولة في نظر المنازعات الإدارية على سبيل الحصر لم يكن تقييداً لصالح الإدارة بقدر ما كان لصالح مجالس المحافظات التي أطلق عليها فيما بعد "المحاكم الإدارية" نقول رغم كل ذلك إلا أن الإدارة بقيت طليقة من كل قيد في هذا المضمار، وذلك لصعوبة وضع أو إيجاد معيار مميز لتلك المنازعات في ذلك الوقت^(١)، أي معيار يحدد المواد التي تقبل المنازعة أمام مجلس الدولة وتلك التي لا تقبل مثل هذه المنازعة حيث بقي الاختصاص بالنظر فيها للإدارة العاملة نفسها عن طريق التظلم، وكذلك لحرص مجلس الدولة - الذي نشأ في أحضان الإدارة وبمناخ امتياز لها - على عدم إساءة الظن به ومن ثم استمراره وبقائه، كل ذلك أعطى للإدارة في الواقع إمكانية الاستقلال باتخاذ كثير من القرارات بعيداً عن رقابة القضاء، وقد أطلق على تلك القرارات في بادئ الأمر "قرارات الإدارة البحتة" "les actes de pure administrative" وكانت تعد في الواقع عنواناً وتجسيدا للسلطة الواسعة

(١) يقول la ferrière في هذا الصدد:

على الرغم من استعمال كافة القوانين التي صدرت تقريباً في بداية القرن التاسع عشر لتنظيم القضاء الإداري وتحديد اختصاصاته، مصطلحات عدة للتعبير عن فكرة واحدة وهي فكرة المنازعات الإدارية مثل:

Contentieux de l'administration, Contentieux administratif, affaires contentieuses.

إلا أن كافة هذه القوانين لم تتضمن أي نص سواء لتعريف معنى المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري أم لتحديد المسائل التي يمكن أن تكون محل منازعة قضائية.

Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, lere éd.1887 T. I. P.3.

أو المطلقة التي كانت تتمتع بها الإدارة آنذاك، حيث لم يكن من الجائز أن تكون محلا لأية مخاصمة قضائية، أو بمعنى آخر لم يكن يقبل في خصوصها أي طعن قضائي، فقد كانت محصنة أو ذات عصمة من كل رقابة قضائية *exemption de tout contrôle juridiction*، بل ومما زاد من حرية واستقلال الإدارة في هذا الشأن أن كافة القرارات التي كانت تصدر عنها في تلك الفترة كانت معتبرة من قبيل قرارات الإدارة البحتة، إلا ما كان منها ماسا بحق شخصي أو حق مكتسب، إذ كان يجوز لصاحب الشأن في هذه الحالة حق الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري^(١). بل لقد تم التجاوز عن هذا القيد في حالة ما إذا كان القرار متعلقا بمصلحة عامة *intérêt général* تهدف الإدارة إلى تحقيقها أو حمايتها، ومعنى ذلك أن القرارات الإدارية التي تهدف الإدارة من ورائها تحقيق مصلحة عامة، كانت تعد من قبيل قرارات الإدارة البحتة، ومن ثم لا يجوز الطعن عليها قضائيا بأي شكل من الأشكال حتى وإن كانت تمس حقوقا شخصية أو مكتسبة^(٢).

وهكذا ظلت الإدارة وحتى الربع الأول من القرن التاسع عشر تتمتع بحرية واسعة بل ومطلقة في كثير من الأحيان في تقدير وملاءمة أعمالها دون معقب أو رقيب عليها^(٣).

(١) حول معيار الحق الشخصي أو المكتسب انظر:

Vivien, *Études administratives*, 1845 t.I, P.125, Ducrocq (T.H.)
cours de droit administratif et de législation Française des finances
avec principes du droit public, 1897 T.2, P.17 etss.; Lion Diquel,
op.cit. p.24.

(٢) يقول Lodovici في هذا الصدد:

"Quand la considération de l'intérêt général entre en jeu et justifie
une mesure, l'acte qui en découle à le caractère discrétionnaire et il
échappe à tout recours contentieux" op. cit . p.55.

(٣) إلا أن ذلك لا يعني من ناحية أخرى عدم وجود رقابة إدارية على هذه الأعمال. فقد أنط

المطلب الثالث

مرحلة اختفاء قرارات الإدارة البحتة مع ظهور قرارات الإدارة التقديرية

لقد ترتب على الوضع السابق أن بقيت حقوق الأفراد وحياتهم دون حماية فعالة بل وعرضة لخطر التجاوز دائماً، خاصة أنه لم يكن هناك أية التزامات قانونية على عاتق الإدارة تجاه قرارات الإدارة البحتة، كما لم تكن هناك أية قيود تشريعية تحد من السلطة الواسعة المعترف بها للهيئات الإدارية في هذا الشأن.

من هنا فقد بدأ مجلس الدولة يبتدع الحلول للتطيف من تلك الآثار أو على الأقل للحد من حالات إنكار العدالة، فاتجه صوب فكرة "الاختصاص" وجعل منها سبباً شرعياً لإلغاء قرارات الإدارة البحتة، وذلك بطبيعة الحال دون أن يتدخل في مجال الإدارة العامة، أي دون أن يتدخل بالبحث في مضمون القرار أو فحواه، إذ كان يكتفى في هذه الحالة، بإلغاء القرار الإداري كلما ثبت له أنه مخالف للقوانين واللوائح المتعلقة بموضوع الاختصاص فقط^(١).

ثم أخذ مجلس الدولة يوسع من نطاق هذا العيب (عيب الاختصاص)

مثلاً قانون ١٤/٧ أكتوبر سنة ١٧٩٠ برئيس الجمهورية والوزراء كل فيما يخصه الاختصاص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة المركزية بسبب نشاط إداري، وكذلك الأمر بالنسبة للمنازعات التي تنور بين الأفراد والإدارات المحلية والإقليمية حيث عهد بالنظر فيها لمدراء الأقاليم قانون ١١/٦ لسنة ١٧٩٠، مع ملاحظة أن هذه الرقابة كانت تحرك بتوجيه أصحاب الشأن التماسات إلى ذات الموظف المسؤول عن التصرف أو إلى رئيسه الأعلى وكان يطلق على هذا النظام آنذاك نظام الإدارة القاضية l'administrateur-juge.

Laferrière (E) traité de la juridiction administrative, op. cit. p.155.

(1) C.E, Landrin, 4 mai 1826, Rec., P. 256.

ويجعله شاملا أيضا لعيب الشكل، مبررا قضاءه في هذا الشأن بأن الإدارة لا تكون مختصة بإصدار قرار ما إلا إذا راعت قواعد الشكل والإجراءات. بمعنى أن رجل الإدارة حينما يمنح اختصاصا معيناً، فإنه يكون ملزماً بأن يباشر هذا الاختصاص وفقاً لقواعد الشكل والإجراءات المحددة قانوناً لذلك وإلا اعتبر خارجاً على حدود هذا الاختصاص. وهكذا يمكن القول إن عيب الشكل ظهر مشتقاً من عيب عدم الاختصاص.

ومع ذلك وأياً كان الأمر، فإن قبول دعوى الإلغاء ضد قرارات الإدارة البحتة، وإلغاء هذه القرارات على أساس مخالفتها لقواعد الاختصاص أو الشكل والإجراءات، وإن كان يعد خطوة هامة في سبيل تحقيق عدالة أكبر للأفراد وصيانة أفضل لحقوقهم وحرياتهم إلا أن ما كان يعيب هذا الاتجاه ويقلل من فعاليته، اشتراط مجلس الدولة لقبول الطعن على تلك القرارات أن تكون قد مست حقاً شخصياً أو مكتسباً لصاحب الشأن.

ولهذا لم يتردد مجلس الدولة، عندما سنحت له الفرصة خاصة بعد أن رسخت دعائمه بزوال الملكية وعودة الإمبراطورية الثانية أن يوسع من مجال الطعن أمامه في القرارات الإدارية، وذلك بتنازله أو بتخليه عن شرط المساس بحق مكتسب *Droit acquis* كعنصر أساسي لقبول دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة، واكتفى فقط بشرط المصلحة الشخصية المباشرة، أو المصلحة البسيطة، معممًا قضاءه هذا على كافة القرارات الإدارية دون استثناء، أي سواء أكانت قرارات إدارية بحتة أم غير ذلك.

ومن ثم يمكن القول إن فكرة القرارات الإدارية البحتة بمفهومها الأول والذي كان يجعل منها - كما ذكرنا - قرارات محصنة أو معصومة من كل طعن أو بحث قضائي قد زالت أو اختفت؛ فقد أصبحت في الواقع كغيرها من القرارات الإدارية الأخرى محلاً للطعن عليها أمام القضاء الإداري لتجاوز

السلطة إذا شابها عيب في الاختصاص أو في الشكل، حتى ولو لم يؤد هذا العيب إلى الإضرار بحقوق شخصية أو مكتسبة.

من هذه اللحظة تحولت أنظار الفقه إلى فكرة القرارات أو الأعمال التقديرية "actes discretionnaires" لتحل محل فكرة قرارات الإدارة البحتة. ويشير lino-Di Qual في هذا الصدد إلى أن هذا التحول إنما تم واستقر في الفترة ما بين عامي ١٨٦٤م، ١٨٦٨م وذلك على أثر إعلان مفوضي الدولة رغبتهم في الاكتفاء للطعن بالإلغاء، تحقق مصلحة بسيطة لصاحب الشأن، وقبول مجلس الدولة لهذا الإعلان^(١).

وإذا كان المشرع الفرنسي قد اعترف بهذا القضاء وسجله صراحة في المادة التاسعة من قانون ٢٣ مايو ١٨٧٢، إلا أن مجلس الدولة لم يتوقف عند هذا الحد وإنما بدأ يطور رقابته على القرارات الإدارية في اتجاه آخر وذلك بأن اعترف لنفسه بالحق في تجاوز الرقابة الشكلية أو الخارجية لتلك القرارات والمتعلقة بعيب الاختصاص والشكل، وهي ما يقال له رقابة الشرعية الشكلية extrinseque أو الشرعية الخارجية légalité externe ليمد يده إلى الرقابة الموضوعية أو ما يقال له الشرعية الداخلية légalité interne للقرارات الإدارية، فتبنى أولاً عيب الانحراف بالسلطة معتبراً أن كل قرار تقديري ينبغي أن يستهدف به مصدره تحقيق المصلحة العامة، لأن هذه المصلحة هي غاية كل عمل إداري، فإن انحراف عنها كان القرار باطلاً^(٢).

(1) La compétence liée, L.G.D.J., 1964, P. 32.

(٢) يعرف Auby et Drago عيب الانحراف كالآتي:

"le détournement de pouvoir est un vice de l'acte administratif qui se rencontre lorsqu'une autorité administrative a utilisé volontairement

ومع ذلك يلاحظ أن مجلس الدولة تشدد في قبول الطعن بهذا الوجه الجديد من أوجه الإلغاء، حيث لم يكن يعد يكتفى في هذا الشأن بمجرد توافر المصلحة الشخصية أو البسيطة، وإنما اشترط لذلك ضرورة أن يكون هناك حق مضار . لصاحب الشأن^(١).

ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés".

Traité de contentieux administratif, L.G.D.J. 1975, P.405.

هذا وقد اعتبر هذا العيب، وحتى عام ١٨٧٠، أنه عيب مشتق كما هو الشن بالنسبة لعيب الشكل – من عيب عدم الاختصاص على أساس أن استهداف رجل الإدارة لغرض معين ليس له الحق في استهدافه يعد تجاوزاً منه لحدود اختصاصه. وبعبارة أخرى يصف laferrière الانحراف بالسلطة في هذه الأثناء قائلاً:

"l'illégalité qui résulte de ce que l'administrateur poursuit un but qu'il n'a pas le droit de poursuivre par les moyens qu'il emploie, ou qui lui est même complètement interdit comme étant en dehors des attributions de l'administration".

Traite de la juridiction administrative, 1896, T.II, P. 548.

ومن ثم فقد اعتبر عيباً شكلياً يتعلق بالشرعية الكلية أو الخارجية المشار إليها سابقاً. ولهذا كان طبيعياً أن يقبل مجلس الدولة دعوى الانحراف لتجاوز السلطة كما هو الشأن في دعوى عدم الاختصاص لمجرد توافر مصلحة شخصية للمدعي، ودون تطلب ضرورة توافر حق مكتسب مضار.

ولم يتغير هذا الوضع إلا منذ صدور حكم مجلس الدولة في قضية Bouchardon عام ١٧٨٠ حيث تميزت دعوى الانحراف بالسلطة منذ هذا التاريخ عن دعوى عدم الاختصاص وأصبحت بالتالي وجهاً جديداً أو مستقلاً للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة أمام القضاء الإداري.

C.E., 2 août, 1870, Rec. P. 871.

(١) ويرجع ذلك في الواقع إلى أنه كان هناك - في ذات الوقت - دعوى أخرى لإلغاء القرارات الإدارية على أساس مخالفة القانون، وكان يطلق عليها دعوى الإلغاء لمخالفة القانون، تمييزاً لها عن دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة، وكان يشترط لقبولها ضرورة توافر حق مكتسب مضار لصاحب الشأن. ولما كانت كل من دعوى الإلغاء للانحراف ودعوى الإلغاء لمخالفة القانون تهدفان إلى حماية الشرعية الداخلية للقرار الإداري، فقد روى ألا يكون هناك سبب للتمييز بين شروط قبول كل من هاتين الدعوتين. من هنا فقد أصبح يشترط لقبول دعوى الانحراف بالسلطة - كما هو الحال بالنسبة لدعوى الإلغاء لمخالفة القانون - ضرورة توافر حق مضار لصاحب الشأن. وهكذا يمكن القول أن دعوى الانحراف بالسلطة تميزت عن دعوى الطعن لعدم الاختصاص ليس فقط بحمايتها للشرعية الداخلية في القرار الإداري فحسب وإنما أيضاً بشروط قبولها أمام

ولهذا يمكن القول أن دعوى الطعن للانحراف بالسلطة لم تغير كثيرا من نظرية القرارات التقديرية، إذ كان يترتب على اشتراط الحق المكتسب المضار لصاحب الشأن عدم خضوع العناصر الداخلية لكافة القرارات التقديرية التي لا تمس حقوقا مكتسبة لأية رقابة قضائية. فما دامت قد صدرت تلك القرارات من مختص، بعد اتباع الإجراءات والأوضاع التي نص عليها القانون، فإنها تعد سليمة وصحيحة. ولا يفيد بعد ذلك للطعن عليها أن يقع خطأ في الغايات أو الأغراض التي استهدفها مصدر القرار ، أو في الوقائع التي استند إليها، لأن هذه الأغراض أو تلك الوقائع هي مما يندرج في إطار السلطة المطلقة للإدارة، وبالتالي لا يرد عليها عيب مجاوزة السلطة. من هنا فقد كان مجلس الدولة يقضى دائما بعدم قبول الدعاوى المؤسسة على تلك العيوب.

حقيقة أنه تم في عام ١٨٦٤، وعلى أثر صدور مرسوم بتيسير إجراءات دعوى مجاوزة السلطة أمام مجلس الدولة، أن أدمجت دعوى الإلغاء المؤسسة على مخالفة القانون في دعوى مجاوزة السلطة، بحيث أصبح عيبا مخالفة القانون وجها جديدا لهذه الدعوى الأخيرة، إلا أن هذا الدمج وإن كان قد وسع من سلطة القاضي الإداري في الرقابة^(١)، إلا أنه لم يغير من الأمر شيئا فيما يتعلق بالحق المكتسب المضار كشرط أساسي لقبول تلك الدعوى، مما أبقى القرارات التقديرية بمثابة امتياز في يد الإدارة تباشر عن طريقه اختصاصات إدارية مطلقة، دون أن يكون للأفراد أية

مجلس الدولة، إذ يجب أن يكون سبب القبول – كما ذكرنا – توافر حق مكتسب مضار وليس فقط مجرد مصلحة شخصية كما هو الحال في الطعن لعدم الاختصاص.

(1) De laubadère, traité de droit Administratif, L.G.D.J., 10ème éd., Paris, 1988 P.309 etss, Ducrocq, Op. cit., P.29, Hauriou {M} précis de droit administratif et de droit public, 1927 P.408.

ضمانة لحماية مصالحهم في مواجهتها.

المطلب الرابع

مرحلة اختفاء القرارات التقديرية مع ظهور السلطة التقديرية للإدارة

لقد ظلت نظرية القرارات التقديرية على النحو السابق تلعب دورا أساسيا في المجالات الإدارية وذلك حتى بداية القرن العشرين، حينما تخلى مجلس الدولة نهائيا عن شرط الحق المكتسب المضار، واكتفى لقبول الطعن في تلك القرارات الإدارية - أيا كان وجه الطعن - مجرد توافر مصلحة شخصية مباشرة وكان أول حكم تقرر فيه هذا التغيير الجوهري، الحكم الذي صدر في قضية Nollet بتاريخ أول فبراير ١٩٠١، إذ قبل مجلس الدولة الطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة في هذه القضية لمجرد توافر المصلحة الشخصية لصاحب الدعوى، دون أن يشترط لهذا القبول أن يكون هناك حق مكتسب أصابه القرار المطعون فيه بضرر^(١).

وقد تأكد هذا الاتجاه بصدور حكم مجلس الدولة في قضية Grazietti^(٢) والخاصة بجل أحد المجالس البلدية بمرسوم صادر من رئيس الدولة، إذ اكتفى المجلس لقبول الطعن بغياب الانحراف بالسلطة في هذا المرسوم، مجرد توافر

(١) يقول مجلس الدولة في هذا الحكم:

"considérant que les requérants sont propriétaires d'habitations situées a bord de la mer, qu'ils pourraient être privés des avantages inhérents à la situation actuelle de leurs immeubles si le décret attaqué était maintien qu'ainsi ils ont un intérêt et sont récévable à constater sa régularité...". Rec., P. 118.

(2) C.E. 31-1-1902, Note Hauriou, S. 1903-3-113.

شرط المصلحة الشخصية المباشرة للطاعن. ذلك الشرط الذي تحقق بانتماء هذا الطاعن إلى عضوية المجلس البلدي الذي مسه مرسوم الحل. وذات الحل تبناه مجلس الدولة أيضا بالنسبة لعيب مخالفة القانون، إذ اكتفى لقبول الطعن لهذا السبب بشرط المصلحة المضارة *intérêt lésé* دون تطلب ضرورة وجود حق مكتسب مسه القرار المطعون فيه. وقد كان ذلك بمناسبة حكمه في قضية *Alcindor et autres* الصادر في أول يونية ١٩٠٦^(١).

وبهذا الحكم والأحكام السابقة عليه تستطيع القول أن مجلس الدولة الفرنسي وسع من رقابته للقرارات الإدارية بشكل ينتفي معه ألا تكون هناك قرارات تنأى بطبيعتها عن رقابة مشروعية عناصرها الداخلية، الأمر الذي حدى بالفقيه *Duguit* إلى القول: بأنه لم يعد، توجد في فرنسا اليوم أعمال تقديرية أو أعمال إدارية خالصة، أي لم تعد توجد أعمال إدارية غير قابلة للطعن عليها بالإلغاء أمام مجلس الدولة^(٢).

"qu' aujourd'hui, en France, il n'ya plus d'actes discrétionnaires ou de pure administration, c'est-a-dire d'actes pour lesquels l'intéresse ne serait pas recevable à demander l'annulation au conseil d'Etat".

أو كما يقول *Hauriou*: لم تعد توجد هناك قرارات تقديرية خالصة، وإنما توجد فقط سلطة تقديرية للإدارة. وهذه السلطة يمكن أن تباشر بشكل أو بآخر في كل تصرف إداري^(٣).

(1) Rec. P.516.

(2) *Traité de droit constitutionnel*, 3é, éd., T.11, P. 384.

(3) Note sous C.E., *Grazietti*, Précité, S.1903-3-113.

"il n'ya pas d'actes discrétionnaires, il ya un certain pouvoir discrétionaire, de l'administration que se retrouve plus ou moins dans tous les actes"

وهو ذات القول لكل من Auby et – Di Qual – Bonnard وDrago؛ وما قال به من قبل كذلك الفقيه النمساوي Kelsen حين أشار إلى أنه ليس ثمة مجل منفصل لكل من السلطة التقديرية والاختصاص المقيد على حدة، بل توجد السلطان معا في كل عمل إداري، وأن التمييز بين التقدير والتقييد في سلطات الإدارة العامة هو مسألة نسبية وأن الفارق بينهما هو فارق في الكم لا في الكيف^(١).

وهكذا في الوقت الذي تم فيه تأبين نظرية القرارات التقديرية، فقد تم تدشين نظرية السلطة التقديرية للإدارة، ولانتقال بالتالي من مرحلة قضائية معينة إلى مرحلة قضائية جديدة، ينظر فيها إلى التقدير الإداري للإدارة على أنه ليس تقديرا مطلقا يتناول كافة العناصر الداخلية للقرار الإداري، وإنما فقط بعض تلك العناصر، الأمر الذي يقلل من خطر التحكم والاستبداد الإداري من ناحية، ويزيد من ضمانات صيانة أو حماية حقوق وحرمان الأفراد من ناحية أخرى.

(١) دكتور/ سليمان الطماوى، نظرية التعسف في استعمال السلطة (الانحراف بالسلطة)، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار الفكر العربى، القاهرة، ١٩٦١، ص ٥٧.

المبحث الثاني

تعريف السلطة التقديرية للإدارة والمساس القانوني لها

المطلب الأول

تعريف السلطة التقديرية للإدارة

اختلف الفقه حول تعريف السلطة التقديرية للإدارة، أو بمعنى آخر حول المعيار المميز لهذه السلطة. ويرجع السبب في هذا الاختلاف إلى عدم اتفاقهم حول مصدر التقدير الإداري وما إذا كان يكمن في إرادة المشرع، حيث يأخذ تعريف السلطة التقديرية مفهوما إيجابيا أم في إرادة القاضي الإداري، ومن ثم يأخذ هذا التعريف مفهوما سلبيا.

هذا ما نبينه تباعا فيما يلي ثم نعقبه برأينا في الموضوع .

أولا

التعريف الإيجابي للسلطة التقديرية

Définition positive du pouvoir discretionnaire

لقد ذهب جانب من الفقه^(١) إلى القول بأن مصدر التقدير الإداري للإدارة إنما يكمن في إرادة المشرع وحدها، مما يعني أن المشرع في نظرهم

(1) J. HAMSON, Pouvoir discrétionnaire et contrôle juridictionnel de l'administration, L.G.D.J., 1958 P. 169 etss., M.Waline, Étendue et limites du contrôle du juge administratif sur les actes de l'administration, E.D.C.E., 1956,P. 25., M. NICOLAS, observations au sujet du pouvoir discrétionnaire de l'administration, Recueil d'études en l'honneur d'E. LAMBERT, L.G.D.J., 1939, T.II, P.361.

هو صاحب القول الفصل فيما إذا كان للإدارة تجاه نشاط معين قدر من حرية التقدير من عدمه، وذلك بتدخله أو عدم تدخله بتنظيم ذلك النشاط أو بتحديد عناصره تحديدا دقيقا. من هنا فقد أعطى هذا الجانب الفقهي للسلطة التقديرية تعريفا إيجابيا معتبرا إياها - والحال هكذا - بمثابة حق للإدارة un droit l'administration معترف لها به من قبل المشرع الذي قد يجد نفسه في وضع يستحيل معه أن يبين للإدارة الأسلوب أو المسلك الذي تباشر به نشاطا مهينا، أو الذي قد يرى أنه من الأفضل أن يترك لها قدر من الحرية والاستقلالية في مباشرة أعمالها، حتى تتمكن من أداء دورها في المجتمع على أكمل وجه وبما يحقق فعالية وكفاءة هذا الدور.

لذلك فقد ربط هذا الرأي بين السلطة التقديرية للإدارة وبين مبدأ المشروعية principe de l'égalité الذي يحكم النشاط الإداري في مجموعه، مقررًا أن هذه السلطة لا توجد أو لا تتمتع بها الإدارة إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي يحكم المسألة محل القرار الإداري، أو عند عدم التحديد الدقيق لكثير من المسائل أو الطوائف القانونية التي يعمل النشاط الإداري في إطارها مثل طوائف المصلحة العامة - المنفعة العامة - الحاجات العامة - النظام العام... الخ.

وهكذا لم يلتفت أنصار هذا الجانب الفقهي عند تعريف السلطة التقديرية، أو عند وضع معيار لها إلا إلى الحالة التي يكون عليها التشريع تجاه مسألة معينة وذلك كما يلي:

فمن ناحية، لا تكون هناك سلطة تقديرية للإدارة إلا في حالة عدم وجود تشريع خاص بهذه المسألة. وهنا يقال أن للإدارة سلطة تقديرية بالترك

أو الإغفال^(١) pouvoir discrétionnaire par omission .

ومن ناحية أخرى، إذا كان هناك تشريع خاص بتلك المسألة، فإن الإدارة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية في خصوصها، إلا إذا كان هذا التشريع متسماً بعدم التحديد indéterminé، أو بأنه غير ملزم للإدارة وهو يكون كذلك إذا ترك لها الحرية في أن تقدم أولاً تقدم على التصرف، أو في اختيارها لمضمون هذا التصرف، أو في كيفية مباشرته.... وهنا يقال أن للإدارة سلطة تقديرية بالإنابة pouvoir discrétionnaire par .commission

ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر الفقيه STASSINOPOULOS الذي يرى أن السلطة التقديرية تتحقق للإدارة في كل مرة تكون لها إمكانية الاختيار بين عدة حلول شرعية، أو يكون لها حرية تحديد معنى من المعاني لفكرة تركت من قبل القانون دون تحديد^(٢). كما أن Michoud يقرر أن السلطة التقديرية لا توجد إلا إذا كانت الإدارة تتمتع تجاه تصرف ما بحرية تامة وذلك بألا تكون هناك قاعدة قانونية قد أملت عليها أو حددت لها سلفاً كيفية إجراء هذا التصرف^(٣). وذات الاتجاه نجده أيضاً لدى GIRAUD حيث يقول: "إن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية عندما لا تكون ملزمة قانوناً بإتيان تصرف محدد، أو بالتصرف على نحو معين"^(٤). ومن جانبه يرى العميد Bonnard "أن سلطة الإدارة تكون تقديرية حينما يترك لها القانون،

(1) S. RIALS, Pouvoir discrétionnaire, in Encyclopedie Dalloz contentieux administrative, T.11, 1985, P. 3.

(2) Traité de actes administratifs, Sirey, 1973, P. 155 etss.

(3) "il n'ya pas pouvoir discretionnaire que lorsque l'action administrative n'est pas dictée à l'avance par une règle de droit". Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration, R.G.A., 1914, III P. 21.

(4) Etude sur la notion de pouvoir discrétionnaire, R.G.A., 1924, P. 193 etss.

الذي يمنحها اختصاصات معينة بصدد علاقاتها مع الأفراد، الحرية في أن تتدخل أو أن تمتنع عن التدخل، ووقت هذا التدخل وطريقته، ومضمون القرار الذي تصدر في هذا الشأن^(١).

وهكذا يمكن القول أن السلطة التقديرية للإدارة تتمثل طبقا للاتجاه الذي نحن بصده في حرية التقدير التي يعطيها المشرع للإدارة لكي تحدد ما الذي ترى أن تفعله وما الذي ترى أن تتخلى عنه، دون أن يحدد لها المبررات التي تلتزم بممارسة اختصاصاتها على أساسها، بمعنى أن الإدارة تتمتع في حالة السلطة التقديرية بحرية شرعية في ممارسة نشاطها، حيث لا تكون خاضعة في خصوص هذا النشاط لأي التزام قانوني، ومن ثم لا يمكن أن توصم عند إجرائه بعدم الشرعية.

يترتب على ذلك، أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يتعرض بالرقابة على ما تتمتع به الإدارة من تقدير ملاءمة نشاطها، إلا استثناء وفي نطاق ضيق، ذلك لأن مهمة القاضي أساسا هي رقابة جانب المشروعية من نشاط الإدارة دون التعرض لجانب الملاءمة الذي هو مجال محجوز للإدارة^(٢).

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتجاه يمثل رأى غالبية فقه القانون العام في مصر، حيث تربط تلك الغالبية - عند تعريف السلطة التقديرية - بين هذه السلطة وبين القانون، ولهذا فقد قيل مثلا: إن السلطة التقديرية هي "أن يترك القانون للإدارة العامة الحرية في مباشرة نشاطها دون أن يفرض عليها وجوب التصرف على نحو إلزامي معين"^(٣)، أو "أن سلطة الإدارة

(1) Le pouvoir discrétionnaire des autorités administrative, et le recours pour excès de pouvoir, R.D.P., 1923, P. 382.

(2) Ibid, P. 385.

(٣) دكتور/ محسن خليل، دكتور/ سعد عصفور، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص ٨٨.

تكون تقديرية إذا خول القانون الإدارة العامة حرية الاختيار هنا إجراء عمل إداري

معين...^(١)، أو أنه " مادام لا توجد قواعد قانونية تحدد مسلك الإدارة، فمعنى هذا أننا بعيديون عن السلطة المقيدة وعلى الإدارة إذن أن تقرر وحدها أن هذا الإجراء ملائم أو غير ملائم، أعنى أن لها أن تزن وحدها ملائمة قراراتها للظروف الواقعية"^(٢).

ثانيا

التعريف السلبي للسلطة التقديرية

Définition négative du pouvoir discrétionnaire

لقد اتجه جانب آخر من الفقه إلى القول بأن تعريف السلطة التقديرية يجب أن يرتبط أساسا بالقيود التي يضعها القضاء الإداري على نشاط الإدارة وهو بصدد رقابته لهذا النشاط، أي في إطار ما هو معترف به للقضاء من دور في إنشاء قواعد قانونية جديدة ومستقلة عن إرادة المشرع الصريحة أو المفترضة^(٣). ولهذا فإنهم ينتهون إلى تعريف تلك السلطة بطريقة سلبية بالنسبة لهذا الدور ، أي بالنسبة لما يباشره القضاء الإداري من رقابة لأعمال الإدارة على أساس أنها - أي السلطة التقديرية - لا تتحقق أو لا يعترف بها للإدارة إلا فيما لا يخضع من تصرفاتها لرقابة هذا القضاء^(٤). وهذا ما قرره

(١) دكتور/ بكر القباني، دكتور/ محمود عاطف البناء، الرقابة القضائية لأعمال الإدارة، المجلد الأول، الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة الحديثة، ١٩٧٠، ص ٥٨.

(٢) دكتور/ مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الخامسة، ص ٣٧٨.

(3) De laubadère, le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire da la jurisprudence récente du conseil d'Etat, Mélange Waline, 1974 p.535; VEDEL, droit administratif, P.U.F., Paris, 1982 p.437 etss.

(4) Stavroula Ktistaki, l'évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l'acte Administratif, L.G.D.J. 1991, P. 328.

الأستاذ Kahn حينما ذكر أن سلطة الإدارة لا تكون تقديرية إلا في الحالات التي تستقل فيها الجهة الإدارية وبمعزل من الرقابة القضائية، بتقدير تناسب الواقعة مع قاعدة القانون، وتوقف هذه السلطة عن كونها تقديرية متى خضعت الإدارة عند إجرائها لهذا التقدير للرقابة القضائية^(١).

وهكذا يربط أنصار هذا الاتجاه وجود أو عدم وجود سلطة تقديرية للإدارة بوجود أو عدم وجود رقابة قضائية، بمعنى أن السلطة التقديرية لا توجد للإدارة إلا فيما لا يراقبه القاضي من اختصاصات. فالقاضي الإداري ليس له - في نظرهم - إلا أن يراقب الاختصاصات المقيدة للإدارة، تلك الاختصاصات التي تتحدد في ذاتها بما يراقبه القاضي، أما فيما عدا ذلك من اختصاصات فهي في الواقع من قبيل الاختصاصات التقديرية للإدارة.

وترتيباً على ما سبق يمكن القول - طبقاً لهذا الاتجاه - أن تدخل القاضي الإداري بما يجريه من رقابة على النشاط الإداري، إنما يؤدي - من ناحية - إلى استبعاد فكرة السلطة التقديرية والتي وصفها لوبادير بكونها قسط من الحرية يتمتع على القاضي فرض رقابته عليه^(٢) la marge de liberté sur la quelle le juge se refuse à faire parler هذا التدخل - من ناحية أخرى، وعلى أقل تقدير - إلى تضيق حدود تلك السلطة؛ وهذا ما أشار إليه الفقيه lodovici حينما قال : لكي تعرف الحدود الحقيقية لسلطة الإدارة التقديرية، ينبغي أن نعرف حدود الرقابة القضائية، ذلك أن السلطة التقديرية لا تبدأ في الواقع إلا من حيث تنتهي تلك الرقابة، ومن ثم فإن أي اتساع في دور القاضي يقابله في الجانب الآخر تقييد

(1) Le pouvoir discrétionnaire et le juge administrative, colloque du 5 mars, 1977, P. 11 etss.

(2) Traité de droit administratif, op. cit., P. 290.

لنطاق السلطة التقديرية^(١).

ثالثا

رأينا في تعريف السلطة التقديرية

ومن جانبنا نرى أنه لا يجب أن نأخذ - عند تعريف السلطة التقديرية أو عند بيان معيار تمييزها - بأى من الاتجاهين السابقين على إطلاقه.

ففيما يتعلق بالاتجاه الأول: فإنه ليس صحيحا أن يقال بأن السلطة التقديرية ترتبط بالقواعد التشريعية فقط، أو بمبدأ المشروعية، لما في ذلك من إنكار لدور القضاء الإداري في هذا الشأن خاصة الدور الإنشائي له والذي يكاد أن يجمع عليه فقه القانون العام سواء في فرنسا أم في مصر. فالقاضي الإداري يجهد ذاته داما - بمناسبة النزاعات التي لا يجد لها حلا في التشريعات القائمة - من أجل أحيانا لتحديد كثير من الأفكار أو المفاهيم القانونية الفضفاضة، أو التي تحتل أكثر من معنى، مثل مفهوم المصلحة العامة - المنفعة العامة - الاحتياجات العامة - النظام العام... الخ، مستلهما في ذلك بالمبادئ العامة للقانون أو السوابق القضائية أو روح التشريعات سواء كانت دستورية أم عادية... أو غير ذلك.

وعلى هذا الأساس يمكن القول، إن القضاء الإداري يعتبر في كثير من الأحيان مصدرا لتقييد التقدير الإداري، إذ لا يشترط - كما يقول الدكتور مهنا: التقييد سلطة الإدارة في كل حالة أن يتم ذلك بمقتضى نص قانوني لأن القضاء الإداري يملك إنشاء القواعد القانونية، وهو إذا أنشأ قاعدة تقييد سلطة الإدارة في موضوع معين فإن سلطتها تتحول طبقا لهذه القاعدة من

(1) L'évolution de la notion de pouvoir discrétionnaire, these, op. cit., P. 11.

سلطة تقديرية غير خاضعة لرقابة القضاء إلى سلطة مقيدة تخضع لرقابة القضاء...^(١).

وكما يعتبر القضاء الإداري مصدرا للتقييد على هذا النحو، فإنه يعد أيضا مصدرا للتقدير الإداري، إذ لا يكفي أن تتخلف النصوص القانونية الأمرة حتى نكون أمام اختصاص تقديري، بل يلزم فوق ذلك أن يعتمد القضاء مسلك هذه النصوص، فلا يضيف من عنده قيودا جديدة يراها لازمة لتحقيق العدالة ولكفالة حسن سير المرافق العامة، لأنه إن فعل القضاء ذلك، فإنه يكون قد أضاف شروطا معتمدة شرعا تضيق من نطاق هذا الاختصاص التقديري^(٢).

أما عن الاتجاه الثاني والذي يقرر مفهوما سلبيا للسلطة التقديرية، إذ يرى أن هذه السلطة لا توجد إلا عند تخلف الرقابة القضائية، أو أن وجودها بدور وجودا وعدما مع هذه الرقابة، فإنه اتجاه يؤدي في الواقع إلى الاعتقاد بأن كلا من فكرتي الرقابة القضائية والسلطة التقديرية تستبعد الواحدة منها الأخرى. فحيث توجد الرقابة القضائية، تنتفى السلطة التقديرية، والعكس صحيح أي عندما توجد السلطة التقديرية تنتفى الرقابة القضائية. ومعنى ذلك أن هذا الاتجاه يقر بأن تعريف كل من هاتين الفكرتين إنما يتحدد على أساس وجود أو عدم وجود الفكرة الأخرى، وهذا يتنافى في الواقع مع التعريف العلمي السليم الذي يجب أن يجسد مضمون الفكرة في ذاتها لا

(١) القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، ١٩٦٧، المجلد الأول، ص ٧٠. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كنا نتفق مع سيادته في تحول سلطة الإدارة التقديرية إلى سلطة مقيدة، إلا أننا نختلف معه في عدم خضوع هذه السلطة التقديرية لرقابة القضاء، وهذا ما نبينه تفصيلا فيما بعد.

(٢) دكتور/ طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، القاهرة، ١٩٦٣، ص ١٣١.

بأمر خارج عنها، إذ لا يمكن أن يقال أن السلطة التقديرية هي ما لا يخضع للرقابة القضائية، وأن الرقابة القضائية هي ما لا علاقة لها بالسلطة التقديرية، خاصة أن تصفح أحكام مجلس الدولة الفرنسي الصادرة في هذا الخصوص تبين أن القضاء الإداري يضع في كثير من الأحيان حدودا للرقابة التي يباشرها على اختصاصات الإدارة، كما يبين كذلك القدر الواجب تركه من هذه الاختصاصات لحرية تقدير الإدارة. ذلك القدر الذي يختلف - بطبيعة الحال - باختلاف المجال الذي تباشر فيه تلك الحرية وذلك كما سنرى فيما بعد، الأمر الذي يعني عدم انضباط هذه التعريفات ، ومن ثم عدم إحاطتها بكافة المسائل التي تندرج في إطار السلطة التقديرية للإدارة. كما قيل أيضا - وبحق "أن هذا الاتجاه يصادر على المطلوب، لأن هدم خضوع الإدارة لرقابة القضاء بمناسبة ممارسة اختصاص ما، إنما هو نتيجة لكون هذا الاختصاص تقديريا وليس العكس. وعلى هذا الأساس يجب أن يحدد مقدما نوع الاختصاص لمعرفة ما إذا كان مقيدا فتخضع الإدارة في ممارسته للقضاء، أو تقديريا فتمارسه الإدارة دون معقب من القضاء"^(١).

لذلك نرى أنه لكي نعرف أو نضع معيارا دقيقا للسلطة التقديرية، يجب أن تأخذ في الاعتبار مضمون كل من الاتجاهين السابقين وهو ما يعبر عنه بمعيار التنظيم القانوني *la réglementation juridique* ، ذلك المعيار الذي يجسد في ذات الوقت كلا من القواعد الشرعية والقواعد القضائية كمصدرين متكاملين للسلطة التقديرية. وعلى ذلك نستطيع القول أننا لا نكون أمام سلطة تقديرية إلا إذا كانت القواعد التشريعية والقواعد القضائية مجتمعة، لم تقيد حرية الإدارة في التصرف. ومعنى ذلك أن السلطة التقديرية للإدارة لا

(١) دكتور/ سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، ١٩٩١، مطبعة جامعة عين شمس، ص ٤٧.

توجد إلا إذا امتنع المشرع من ناحية والقاضي من ناحية أخرى عن التدخل في تقييد النشاط الإداري تقييدا كاملا، أي أنها لا توجد إلا في حالة تخلف التنظيم القانوني بالمعنى السابق الإشارة إليه. فلا يكفي إذن للاعتراف بالسلطة التقديرية للإدارة أن تكون النصوص التشريعية غير محدودة أو مشحونة بالثغرات أو النواقص، بل لابد كذلك من النظر فيما إذا كان القضاء قد وضع من القواعد ما حد بها من إطلاق النصوص التشريعية وسد بها ما وجد من ثغرات أو نواقص أو لم يضع من ذلك شيء^(١).

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يعني أن الإدارة خارج تلك القيود التشريعية والقضائية، طليقة من كل قيد ، تفعل ما تشاء دون ضابط أو رابط ، بحجة أنها تتمتع بسلطة تقديرية، فهذا لا نكون في الواقع أمام سلطة قانونية وإنما أمام سلطة استبدادية مطلقة، وهذه لا وجود لها ولا يمكن الاعتراف بها لأية جهة ولا للمشرع نفسه ولا للأفراد العاديين في تنظيم علاقاتهم الخاصة، فعندما تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في تطبيق القانون، فإنها لا تباشر في ذلك سلطة مطلقة، ولكنها تخضع لمبدأ المشروعية، وتخضع كذلك لرقابة القضاء وهو الأمين على احترام وصيانة هذا المبدأ^(٢).

وهكذا نستطيع أن نعرف السلطة التقديرية بأنها مكنة تتيح للإدارة الاختيار الحر للإجراء الذي تراه مناسبا للوقائع التي تبرر اتخاذ ذلك في غير الحالات التي تلتزم بما يقرره كل من المشرع والقاضي من قيود في خصوصها.

(١) دكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية والرقابة القضائية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٠٩.

(٢) الدكتور/ سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٢، ص ٣١ وما بعدها.

المطلب الثاني

الاساس القانوني للسلطة التقديرية

ذكرنا في مقدمة البحث أن السلطة التقديرية باقية ما بقيت الإدارة، فهي ظاهرة تلازم النشاط الإداري في جميع مستوياته وكافة أشكاله، وما الرقابة القضائية - أيا كان مداها - إلا أسلوب لتحقيق التوازن الأمثل بين تمكين الإدارة من إدارة مرافقها بما يحقق الصالح العام وبين حماي حقوق الأفراد وحياتهم.

فإذا كان الأمر كذلك، أي إذا كانت السلطة التقديرية ضرورة لا غنى عنها، فما هو الأساس القانوني الذي يستند إليه قيام تلك السلطة؟.

لقد ظهرت في هذا الشأن عد اتجاهات نبين أهمها بإيجاز فيمايلي:

أولاً: فكرة تدرج القواعد القانونية^(١):

وترجع إلى المدرسة النمساوية بزعامة الفقيه كلسن. وتعنى هذه الفكرة أن القواعد القانونية في المجتمع إنما تتدرج فيما بينها في مراتب مختلفة، بحيث تقيد القاعدة الأعلى القاعدة الأدنى منها درجة، وهذه الأخيرة تتضمن تخصيصاً للقاعدة الأولى. وبمعنى آخر أن كل قاعدة قانونية في التدرج القانوني بالدولة تتخذ لها صفتين: فهي قاعدة منفذة ومخصصة للقاعدة الأعلى منها درجة من ناحية، ومنشئة في ذات الوقت للقاعدة الأدنى منها

(١) حول هذه الفكرة انظر:

VENEZIA (J.C.), le pouvoir discrétionnaire, paris, 1958, L.G.D.J., P.99 etss., CHATELAIN la compétence discrétionnaire du gouvènement dans l'application des lois et des jugements, thèse paris , 1942, p.273, BONNARD, le pouvîr discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir, R.D.P. 1923, P. 368.

مرتبة من ناحية أخرى.

ولما كان اختصاص رجل الإدارة - حين ينفذ القاعدة القانونية - يعد اختصاصا مقيدا إذا وقف بقراره عند حد التنمية الحرفي للقاعدة القانونية، ويعد اختصاصا تقديريا إذا أضاف إلى هذه القاعدة عناصر جديدة، فإنه يمكن القول أن السلطة التقديرية للإدارة إنما تجد أساسها في التدرج التنازلي للقواعد القانونية، إذ غالبا ما تكون القاعدة الأعلى متسمة بالعمومية والتجريد وتتطلب بالتالي نوعا من التحديد والتقييد من جانب رجل الإدارة، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان لهذا الأخير سلطة تقديرية.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تقصر حالات السلطة التقديرية فقط على مجرد تخصيص أو تقييد رجل الإدارة للقاعدة القانونية مع أن هناك حالات أخرى عديدة يتمتع رجل الإدارة في خصوصها بسلطة تقديرية دون أن يضيف إلى القاعدة القانونية التي يتولى تنفيذها أية عناصر جديدة، مثل الاختيار الحر بين قرارين أو أكثر، أو التقرير الحر لاتخاذ القرار من عدمه، أو تحديد الوقت الملائم لاتخاذ هذا القرار... الخ. ولهذا لا تصلح مثل هذه الفكرة لبيان الأساس القانوني للسلطة التقديرية^(١).

ثانيا: نظرية الحقوق الشخصية^(٢):

ذهب جانب من الفقه إلى أن الأساس القانوني للسلطة التقديرية يكمن في انتفاء أو عدم وجود حقوق شخصية للأفراد تجاه الإدارة. إذ مع وجود

(1) HAURIOU (A.), Le pouvoir discrétionnaire et sa justification, Mélanges carré de Malberg, S. 1933, P. 233.

(٢) حول هذه النظرية انظر:

Barthélemy, Essai d'une théorie des droits subjectifs des administrés thèse toulouse, 1899, p.106, Bonnard, les droits publics subjectifs des administrés, R.D.P., 1932, P.695

هذه الحقوق الشخصية *droit subjectifs* تصبح سلطة الإدارة سلطة مقيدة. وأساس ذلك أنه في حالة وجود الحقوق الشخصية، وهي تلك المنافع والمزايا التي يمكن ضمان احترامها وحمايتها بالدعوى القضائية^(١) *l'action en justice*، يستطيع الأفراد مطالبة الإدارة بعمل ما، أو الامتناع عن هذا العمل بوصفه التزاما يقع على عاتقها، ومن ثم يصبح اختصاص الإدارة هنا اختصاص مقيد. أما في حالة عدم وجود حقوق شخصية فإنه لا يمكن لهؤلاء الأفراد إلزام الإدارة بعمل ما أو الامتناع عنه، أو أنه لا يمكنهم مخاصمة الإدارة أمام القضاء لانتفاء الإلتزام أو الرابطة القانونية بطبيعة الحال بينهم وبين الإدارة، ومعنى ذلك أن هذه الأخيرة تستطيع أن تباشر اختصاصاتها بحرية تامة ومن ثم يوصف الاختصاص بأنه اختصاص تقديري.

فقدرة الأفراد إذن على المطالبة بطريق الدعوى القضائية - تلك القدرة التي لا تثبت إلا إذا كانت لهم حقوق شخصية تجاه الإدارة - قدرتهم لضمان وحماية هذه الحقوق، هي التي تميز السلطة المقيدة للإدارة عن السلطة التقديرية التي تتعدم في خصوصها هذه القدرة. ولهذا فقد قيل - كما ذكرنا - إن الأساس القانوني للسلطة التقديرية هو انتقاء أو عدم وجود حق

(١) يعرف بونار، المرجع السابق، ص ٧٠٧، الحق الشخصي بأنه "قدرة الشخص على المطالبة بشيء له فيه مصلحة، على أساس من قاعدة قانونية موضوعية، عن طريق الدعوى القضائية. أما مضمون هذا الحق المطالب به، فينبغي أن يكون محددا مباشرة إما بالقانون الموضوعي أو قانوني فردي".

"le droit subjectif est le pouvoir d'exiger de quelqu'un, en vertu d'une règle de droit objectif, quelque chose à laquelle on a intérêt, sous la sanction d'une action en justice, le contenu de la chose exigible étant Fixé immédiatement soit par le droit objectif, soit par un acte juridique individuel".

وانظر أيضا الدكتور/ عصام عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ١٨٩؛ الدكتور/ محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية، مرجع سبق ذكره، ص ٦٥ وما بعدها.

شخصى للفرد تجاه الإدارة^(١).

ويؤخذ على هذه النظرية^(٢) أنه يربطها بين الحقوق الشخصية والاختصاص المفيد للإدارة، تكون قد تجاهلت ما هو معترف به للإدارة من حق وضع القيود المختلفة على تمتع الأفراد بحقوقهم الشخصية، من ذلك مثلا منع أصحاب أملاك من البناء في أملاكهم قبل الحصول على رخصة بالبناء من الجهة الإدارية المختصة، وإن كانت لا تهدف من وراء ذلك سوى تحقيق المصلحة العامة. إضافة إلى أن هناك حالات كثيرة من حالات الاختصاص المقيد لا تجد مصدرها في الحقوق الشخصية، كحالة اختصاص الإدارة المقيد بإدراج اسم كل مواطن توفر فيه شروط الناخب في قوائم الناخبين، كما أن النصوص التشريعية التي ترد عامة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية في مجال الضبط الإداري وفي مجال تنظيم الحياة الاقتصادية يبدو عليها أن المشرع يخول الإدارة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال واضعا في اعتباره المصلحة الجماعية والعامة للمنطقة.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الاختصاص المقيد يكون أيضا مع قيام المصلحة دون الحق وهذا ما يفسره قبول الطعن بتجاوز السلطة اكتفاء بقيام هذه المصلحة، فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه النظرية تتصل بمجال السلطة التقديرية وليس بأساسها القانوني، لاتضح لنا عدم إمكانية

(1) Goldenberg, le conseil d'Etat juge de fait, Paris, 1932, P. 42 etss.

(٢) حول النقد الذى وجه إلى نظرية الحقوق الشخصية انظر:

Lino Diquel, la compétence licé, op. cit., p. 405 etss; Sandevour etudes sur le recours de pleine juridiction, paris, 1964, p.418; Bonnard, précis de droit administratif, 4ème éd, 1943, R74.

الدكتور/ سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ٤٧؛ الدكتور/ عصام عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ١٩١ وما بعدها؛ الدكتور/ سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة...، مرجع سبق ذكره، ص ٣٦؛ الدكتور/ مصطفى حسن، المرجع السابق، ص ٦٧.

اتخاذها أساسا كافيا لتفسير السند القانوني للسلطة التقديرية المعترف بها للإدارة وهي تباشر مختلف أوجه نشاطها.

ثالثا : فكرة المشروع^(١):

تقوم هذه الفكرة على أساس أن الإدارة بما تباشره من أنشطة متعددة لا تختلف كثيرا عن مشروعات الأفراد الخاصة. بمعنى أن الإدارة العامة بهيئاتها المختلفة عبارة عن مشروع يشبه إلى حد كبير المشروعات الخاصة للأفراد. وطالما أن هؤلاء الأفراد يتمتعون عند إدارتهم لتلك المشروعات بسلطة تقديرية ، فإنه يجب الاعتراف للإدارة كذلك بمثل هذه السلطة.

ففكرة المشروع إذن هي العامل المشترك الذي يجسد نشاط كل من الإدارة والأفراد، ومن ثم فهي أساس تمتع كل منهم بقدر من حرية التصرف عند إدارته النشاط الخاص به. ويوضح العميد هوريو هذه الفكرة قائلا: إن الهيئات الإدارية كالأفراد هم بمثابة رؤساء مشروع ولهم لهذا السبب أن يقيدوا أنفسهم بقيودا ذاتيا، كما لهم أن يقدروا ملائمة أعمالهم، بل إن صفة رؤساء المشروع تظهر في الهيئات الإدارية بشكل أكبر مما تظهر عليه بالنسبة للأفراد، ذلك لأن الهيئات الإدارية كمؤسسات تعمل لمصلحة الأفراد والدولة إنما هي في حقيقتها مشروع كبير للنظام العام والمنفعة العامة^(٢).

(١) حول هذه الفكرة انظر:

M. HAURIOU, Précis de droit administratif, 12ème éd., 1933, p351 etss; A.HAURIOU, le pouvoir discrétionnaire et sa justification, op. cit., p.233; VENEZIA, le pouvoir discrétionnaire, op. cit, P. 105 Rivero, les mesures d'ordre intérieur administratives, thèse, paris, 1934 p 260 etss; Giraud, Étude sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration, R.G.A.1924, p.28.

الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ٦٨٠ وما بعدها؛ الدكتور، عصام عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ١٩٦ وما بعدها.

(2) A. Hauriou, op. cit., P. 233.

وهكذا تمثل صفة المشروع بالنسبة للنشاط الإداري مصدر السلطة التقديرية وأساسها القانوني، وهو ما ذهب إليه كذلك فينيزيا إذ يقول: أن صفة المشروع للنشاط الإداري تعد مصدر السلطة التقديرية للإدارة، وقد استشهد لتأكيد هذه الصفة بالمبادئ الدستورية السائدة وتفسيرها من قبل الدولة وينتهي من ذلك إلى أن السلطة التقديرية للإدارة ترتبط بالتقييد الذاتي وهو ضروري لكل مشروع كمقابل وموازن لفكرة المسؤولية التي تقع على عاتق من يتولى إدارة هذا المشروع بقصد الوصول إلى نتائج وغايات يستهدف تحقيقها^(١).

ورغم الاختلاف بين المشروع الخاص الذي يسعى أساسا لتحقيق الربح والمشروع العام الذي لا يهدف سوى تحقيق النفع أو الصالح العام، إلا أن فكرة المشروع هذه تعد في واقع الأمر من أنجح الأفكار التي تفسر الأساس القانوني السليم لما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية. ذلك أننا إذا نظرنا إلى النشاط الإداري في مجموعه، فسوف نجده فعلا لا يختلف بدرجة كبيرة عن مشروعات الأفراد الخاصة. فالمرافق العامة، والضبط الإداري مثلا ما هي في حقيقتها إلا من قبيل المشروعات التي تتغيا الإدارة من ورائها تحقيق أهداف تتدرج في إطار المصلحة العامة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن دور الإدارة العامة اليوم يختلف جذريا عن دورها في الماضي، حيث كانت مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ الأهداف والسياسات التي تضعها السلطة السياسية العليا في الدولة، فقد صارت الإدارة اليوم تساهم بشكل رئيسي في تحديد الأهداف وتشكيل السياسات ومن ثم صنع القرارات وتنفيذها. بمعنى أن دور الإدارة تحول من مجرد التنفيذ إلى الإسهام في صنع السياسة العامة للدولة بل وفي وضع الاستراتيجية اللازمة لتحويل هذه السياسة إلى قرارات تحقق

(1) op. cit., P. 105.

أهداف الدولة في كافة المجالات^(١).

ومما لا شك فيه أن هذا الدور يعني ويتطلب أن يكون للإدارة قدر أكبر من حرية التقدير في إصدار قراراتها الإدارية على النحو الذي يكفل تحقيق هذه السياسة العامة وتطويرها بما يتلاءم وظروف المستقبل المتغيرة. كما يتطلب أيضا رؤية متطورة للنشاط الإداري باعتباره بمثابة مشروع أو مرفق يتعين أن يؤدي نشاطه أو عمله على أكمل وجه ، ومن ثم ضرورة الاعتراف للإدارة في خصوصه بسلطة تقديرية. ففكرة المشروع إذن هي الأساس القانوني لهذه السلطة الأخيرة.

(١) الدكتور/ سامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٠، ص ١٠ وما بعدها، والمرجع السابق، ص ٣٩.

المبحث الثالث

مبررات السلطة التقديرية للإدارة وموضعها

في القرار الإداري

المطلب الأول

مبررات السلطة التقديرية للإدارة

إذا كانت السلطة التقديرية تتيح للإدارة طبقاً للتعريف السابق حرية في الاختيار والتصرف، فإنها تعد، والحال هكذا جوهر الإدارة ذاتها، وامتياز أساسي ورئيسي من امتيازاتها، بل وسمة من السمات المميزة لها، إذ تمارس الإدارة في الواقع نشاطاً إنسانياً يستعصي بطبيعته على أن يقيد تقييداً تاماً بقواعد قانونية محددة وموضوعة سلفاً، من هنا يجمع الفقه على ضرورة الاعتراف بها للإدارة ويبررون ذلك بمبررات أخرى عديدة نذكر من بينها مايلي:

- عجز المشرع من أن يحيط مقدماً بكل دقائق الأمور أو بكل تفاصيل العمل الإداري، خاصة في الدولة الحديثة ذات الاتجاهات الاشتراكية الاجتماعية، وهي ما يقال لها الدولة المتدخلة l'Etat interventionniste والتي غزت مختلف مجالات النشاط الخاص بما فيه من مفاجآت ومواقف غير متوقعة، من هنا فإن المشرع غالباً ما يكتفى بصياغة قواعد التشريع بشكل عام ومجرد تاركاً مواجهة دقائق الأمور وتفصيلاتها للإدارة صاحبة الاختصاص الأول في التنفيذ، والمسئولة الأولى أيضاً من هذا التنفيذ. بل وحتى في حالة ما إذا وضع المشرع قواعد قانونية تفصيلية لكيفية مباشرة نشاط معين، فإن التطورات المتلاحقة والتغيرات الدائمة التي تطرأ - وهذا أمر حتمي - على هذا النشاط، تباعد في الواقع

كثيرا بينه وبين تلك القواعد القانونية التي وضعت لتحكمه في زمن معين أو في ظل ظروف معينة، والتي يصعب كذلك أن تعدل وتغير بشكل دائم ومستمر، لما في ذلك من تنافس مع ما يجب أن يتسم به التشريع من ثبات واستقرار، لذلك فإنه يصبح حتمى الاعتراف للإدارة بقسط من الحرية تواجه مثل هذه التطورات أو تلك التغيرات، أي الاعتراف لها بسلطة تقديرية تواجه بها متطلبات الموقف الجديد، وتسدد عن طريقها ما يعتور التشريع القائم من ثغرات وفجوات دون انتظار لإجراءات صدور تشريع آخر، وهى إجراءات - كما نعلم - صعبة ومعقدة تستغرق في الغالب وقتا طويلا، وخاصة في الحالات العاجلة التي تتطلب فيها المصلحة العامة ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على أمن الدولة، أو على النظام العام، أو لمواجهة أية ظروف طارئة لم تكن في الحسبان^(١). وهذا ما يؤكد مجلس الدولة الفرنسي في الحكم الصادر في قضية Doublie بتاريخ ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٥٩، حيث يقرر في هذا الحكم أن على الإدارة - عند حدوث موقف خطير أو غير متوقع - التزام بالعمل والتصرف لمواجهة هذا الموقف، وذلك بما يحقق ويصون النظام العام^(٢).

- إن خبرة الإدارة وتجاربها المكتسبة في إدارة المشروعات العامة، نتيجة احتكاكها الدائم بالعمل وظروفه المتغيرة، يجعلها في الواقع أقدر من غيرها على تقدير مناسبة الأعمال المختلفة، وكذلك على استنباط الضوابط

(١) دكتور/ أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة في الأحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي ١٩٧٠ - ١٩٨٠، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، ديسمبر ١٩٨٢، ص ٤٩.

(2) "L'administration à l'obligation d'agir à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité au salubrité publique", Rec., P.540

الإدارية الملائمة لتلك الأعمال، الأمر الذي يبرر الاعتراف لها بقدر من حرية التصرف والتقدير عند مباشرة مختلف أوجه نشاطاتها، خاصة أن معظم النصوص التشريعية لا تحدد بطريقة صريحة ومحددة وسيلة وكيفية تنفيذها، تاركة مثل هذه المسائل للإدارة صاحبة الإمكانيات الفنية والخبرة العملية في هذا المجال^(١).

- إن السلطة التقديرية هي وسيلة لإحياء روح العدالة والإنسانية في التطبيق الفردي للقاعدة القانونية. ذلك لأن هذه القاعدة - وهي وسيلة المشرع في مباشرة نشاطه بحكم أنها قاعدة عامة مجردة وأنها تعالج حالات يصعب التنبؤ بظروفها - إنما تقرر في الواقع نفس المبادئ والأحكام لعدد لا نهائي من الحالات الفردية المستقبلية التي لا تتطابق حتما مطابقة تامة، بل هي في الغالب تتفاوت وتختلف عن بعضها البعض بشكل أو بآخر. وهذا التفاوت والاختلاف يظهر في كثير من الأحيان عدم ملائمة القاعدة القانونية بل وقسوتها . أحيانا . في التطبيق الفردي. ولذلك فإن الإدارة تستطيع عن طريق سلطتها التقديرية أن تبعث في التطبيق الفردي للقاعدة القانونية تلك الروح الإنسانية والعدالة التي فقدتها بسبب تجريدها

(1)"pour M. Giraud, la raison d'être du pouvoir discrétionnaire est double : c'est, tout d'abord, la difficulté pour le législateur d'adapter les règles générales qu'il formule à l'extrême variété de la vie sociale, sans cesse changeante, et la nécessité de laisser l'administration mieux placée pour connaître et pour juger, procéder sans entrave aux constatations techniques et générales à la suite desquelles elle prendra les mesures nécessaires pour assurer la marche des services publics et l'exécution des lois. c'est, en second lieu, l'expérience, les moyens d'information et l'esprit pratique de l'administrateur supérieurs à ceux du juge." M.waline, le pouvoir discrétionnaire de l'administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel, R.D.P., 1930, p.204.

وتعميمها^(١).

- إن الصالح العام ذاته يقتضى أن يكون للإدارة سلطة تقديرية تواجه بها- في حالات معينة - كافة الاحتمالات المتوقعة أو غير المتوقعة، وذلك حتى لا يصاب المجتمع في مثل تلك الحالات بالشلل والارتباك، الأمر الذي لا يجدي معه أي احترام للقوانين القائمة أو التقيد بأحكامها. ولهذا فقد قيل - بحق - أن دور الإدارة لا يمكن أن يقتصر على مجرد أن تكون تابعا للقانون، أو أن تكون بمثابة آلة صماء أو أداة لتنفيذه تنفيذًا حرفيًا، بل يتعين منحها القدرة على الاختيار ، والاعتراف لها بقدر من حرية التصرف، حتى لا توصم بالجمود، وحتى تنمو لديها ملكة الابتكار والتجديد، مما يكفل في النهاية ليس فقط حسن سير المرافق العامة وما يعود على المجتمع من جراء ذلك من نفع وخير، وإنما أيضا النهوض والارتقاء بالمصلحة العامة للجماعة^(٢).

وهكذا أصبحت فكرة السلطة التقديرية الآن من أهم الأفكار الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري لدرجة أن Waline ربط تعريف هذا القانون بتلك الفكرة إذ يقول^(٣):

"s'il fallait donner en quelques mots une définition du droit administratif, je dirais, essentiellement l'étude du pouvoir

(1) M. Decencière Ferrandière, Quelques réflexions touchant le règlement des conflits internationaux, cité par M. waline, idid, p.205.

(٢) دكتور/ محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٦٧، ص ٤٨؛ دكتور/ احمد حافظ نجم، السلطة التقديرية....، مرجع سبق ذكره، ص ٥٠.

(3) Etendue et limites du contrôle du juge administratif sur les actes de l'administration, E.D.C.E., 1956, p.25.

discrétionnaire des autorités administratives et de sa limitation en vue de la sauvegarde des droits des tiers"

المطلب الثاني

موضع السلطة التقديرية في القرار الإداري

إذا كنا قد انتهينا إلى أن السلطة التقديرية لا تثبت للإدارة تجاه جانب أو أكثر من جوانب تصرف قانوني معين، إلا إذا تخلف التنظيم القانوني بالمعنى المشار إليه آنفاً، عن تحديد هذا الجانب أو تلك الجوانب ، فإنه لنا أن نتساءل عن الجانب أو الجوانب التي من الممكن أن يتخلى التنظيم القانوني عن تحديدها، بحيث يصبح للإدارة في خصوصها سلطة تقديرية، إذ من المعروف أن لكل تصرف قانوني أو قرار إداري خمسة جوانب أو أركان هي: الاختصاص - الشكل - الغاية - السبب - المحل؟

السائد فقها وقضاء أن الإدارة لا تتمتع فيما يتعلق بركن الاختصاص والذي يجسد الصلاحية القانونية لموظف معين أو لجهة إدارية معينة أن تتخذ قراراً إدارياً معيناً ، بأية سلطة تقديرية ، ذلك أن القانون يحدد على وجه الدقة الشخص الإداري المختص بإصدار هذا القرار أو ذلك، بحيث يؤدي صدوره من غيره دون أن يسمح القانون بذلك إلى بطلانه، مع ملاحظة أنه إذا تخلى القانون عن تنظيم اختصاص إداري معين بأن لم يعهد بأمر مباشرته لجهة إدارية معينة أو موظف معين ، فإن القضاء مستقر على أن الجهة التي تختص بذلك هي الجهة أو الموظف الذي يباشر أعمالاً من جنس هذا الاختصاص أو يتفق مع طبيعته واجبات وظيفته.

أما فيما يتعلق بركن الشكل والذي يقصد به المظهر الخارجي الذي تبدو أو تتجسد فيه إرادة الإدارة، أو المظهر الذي يتضمن ما أفصحت به

الإدارة عن إرادتها، فإنه يلاحظ أن القضاء الإداري مستقر على أن جهة الإدارة غير مقيدة بشكل معين تفصح فيه عن إرادتها الملزمة ، ما لم يحتم القانون اتباع شكل خاص بالنسبة لقرار معين^(١).

وترتباً على ذلك يمكن القول أنه إذا لم يكن المشرع قد ألزم الإدارة بضرورة إفراغ إرادتها في شكل معين فإنه يكون لها (وهذا هو الأصل) مطلق الحرية في كيفية التعبير عن هذه الإرادة، أي يكون لها سلطة تقديرية في هذا الخصوص، أما إذا نص القانون على ضرورة إتباع شكل معين كأن يتطلب مثلاً أن يأخذ القرار شكلاً مكتوباً أو مشتملاً على أسبابه، فإن سلطة رجل الإدارة في هذه الحالة تصبح سلطة مقيدة ومن ثم يتحتم عليه الالتزام بذلك وإلا كان قراره معيباً بعبء عدم المشروعية وكان بالتالي باطلاً

وركن الغاية في القرار الإداري والذي يقصد به الهدف أو النتيجة النهائية التي يسعى مصدر القرار إلى تحقيقها^(٢)، فإن رجل الإدارة لا يملك

(١) المحكمة الإدارية العليا في ١٩٧٠/٣/٢٢، القضية رقم ٣٢١ لسنة ٩٩ق، المجموعة، السنة ١٥، ص ٢٤٤؛ وفي ١٩٦٦/٣/٢٦، القضية رقم ٤٤٤ لسنة ٧ق، المجموعة، السنة ١١، ص ٥٦٥؛ وكذلك محكمة القضاء الإداري في ١٩٤٨/١٢/٧، القضية رقم ١٩٤ لسنة ٢ق، المجموعة، السنة ٣، ص ١٣٧.

(٢) وقد يثور لبس أو خلط بين ركن الغاية على هذا النحو وركن المحل على أساس أن المقصود بهذا الركن الأخير - كما ذكرنا - الأثر القانوني الذي يهدف إليه مصدر القرار. فقد يقال أنه لا فرق بين الركنين طالما أن كلا منهما يهدف إلى تحقيق ذات الأثر. ومنعاً لمثل هذا اللبس أو ذلك الخلط، يجب أن نوضح أن الهدف أو الأثر المقصود من ركن المحل هو النتيجة المباشرة التي تترتب على القرار، أي الأثر القانوني المتمثل في إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين فالقرار الصادر بهدم منزل آيل للسقوط يترتب أثر قانونياً مباشراً هو إزالة هذا المنزل (ركن المحل) أما النتيجة التي يهدف إليها متخذ مثل هذا القرار إنما تتمثل في حماية أرواح الناس أي فقط الأمن أو الصحة العامة (ركن الغاية).

وكذلك القرار الصادر بتعيين شخص في الوظيفة العامة يترتب أثراً قانونياً مباشراً هو إسناد الوظيفة العامة إلى هذا الشخص (ركن المحل) أما النتيجة النهائية لهذا القرار فتتمثل في ضمان سير المرفق بانتظام واضطراد (ركن لغاية). وعلى ذلك يمكن القول أن الآثار القانونية التي تترتب مباشرة على القرارات الإدارية

حياله - كقاعدة عامة - أية سلطة تقديرية، ذلك أن السلطات الممنوحة له والتي من بينها سلطة إصدار القرارات ليست هدفا أو غاية في ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق غاية معينة. هذه الغاية تتحدد إما عن طريق المشرع، بمعنى أن هذا الأخير هو الذي يحدد بذاته للإدارة هدفا معيناً يجب عليها أن تلتزم به وتعمل على الوصول إليه وهو ما يسمى بمبدأ تخصيص الأهداف *spécialité du but* وهنا يجب على رجل الإدارة أن يلتزم بتحقيق تلك الغاية في كافة القرارات التي تصدرت، بحيث أنه إذا خرج أو حاد عنها كانت قراراته باطلة، حتى ولو كان يقصد من وراء ذلك تحقيق الصالح أو النفع العام *l'intérêt l'utilité publique*.

أما إذا لم يحدد الشرع الإدارة هدفا مخصصا أو غرضا محددا كان لها مطلق الحرية في تحديد هذا الهدف أو ذلك الغرض بشرط أن يدور في فلك أو في الدار المصلحة العامة. ومعنى ذلك أنه أيا كانت الحرية أو السلطة التقديرية التي يتمتع بها رجل الإدارة في هذا الخصوص، إلا أنه ملزم أو يجب أن يكون علما بأن يكون الهدف من قراره دائما هو ابتغاء المصلحة العامة. وإلا كان هذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها^(١) *le détournement de pouvoir*.

حاصل القول إذن أن ركن الغاية في القرار الإداري لا يمكن أن يكون محلا للسلطة التقديرية أو كما يذهب الفقه الإداري في مجموعه تقريبا، أن سلطة الإدارة بالنسبة للهدف هي دائما سلطة مقيدة ولا يمكن أبدا أن

والتي يعبر عنها بركن المحل لا تعتبر أهدافا لهذه القرارات، ذلك أن هذه الأهداف إنما تتمثل فيما انصرفت إليه نية مصدر القرار وما اتجه إليه في ذهنه وتفكيره قبل أو عند اتخاذ القرار وهذا هو المقصود بركن الغاية.

(١) دكتور/ سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، الطبعة الثالثة، ١٩٧٦، ص ٧٤.

تكون سلطة تقديرية تخرج عن رقابة مجلس الدولة^(١).

وهكذا تستطيع القول أن سلطة الإدارة التقديرية لا تلعب دورا أساسيا أو هاما، بل وتكاد أن تكون منعدمة، في إطار كل من الأركان الثلاثة السابقة وهي ركن الاختصاص وركن الشكل وركن الغاية، وذلك على عكس الحال فيما يتعلق بركني السبب والمحل حيث تتجسد فيها مظاهر تلك السلطة، كما نبيله فيمايلي:

أولاً: السلطة التقديرية وركن السبب في القرار الإداري:

السبب في القرار الإداري هو مجموعة العناصر الواقعية أو القانونية التي تبرر تدخل رجل الإدارة، وتسمح لها باتخاذ القرار^(٢). فالسبب إذن عنصر خارجي عن القرار الإداري وسابق عليه^(٣).

(١) دكتور/ مصطفى أبو زيد، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الخامسة، ص ٨٤٣. ومن ذات الرأي أيضا نظر دكتور/ محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، بيروت، ١٩٧٠، ص ٢٠٧؛ دكتورة/ سعاد الشرقاوي، دروس في دعوى الإلغاء، ١٩٨٠، ص ١١١.

(2) es motifs de l'acte administratif sont constitués par les éléments de droit et de fait qui ont conduit l'administration à agir Auby et Drago, traité de contentieux administratif, paris, 1962 p.37.

ويعرف الدكتور/ سليمان الطماوي السبب "بأنه حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته، تتم فتوحى له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ قراراً". النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، ١٩٩١، مطبعة جامعة عين شمس، ص ٢٠٠. كما يعرفه الدكتور/ محمد فؤاد مهنا بأنه "الحالة الواقعية (الوقائع والظروف المادية) أو القانونية (الوضع القانوني) التي تبرر إصدار القرار" القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، المجلد الثاني، ص ١٠٣٣، وتعرفه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ١٢/٧/١٩٥٨، مجموعة أبو شادي، ١٩٧٦، ص ١٧٠٥، بأنه "حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني ه محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار".

(٣) ولكن ليس معنى أن السبب عنصر خارجي عن القرار الإداري وسابق عليه، أنه لا يمثل — كما يذهب جانب من الفقه الفرنسي — أحد أركانه، ومن ثم لا يمكن أن يكون له أي تأثير على صحته أو مشروعيته.

ومثال الحالات الواقعية motifs de fait الاضطرابات التي تهدد النظام العام - الأخطاء التأديبية - طلب الإذن بعقد اجتماع عام... الخ ففي هذه الحالات وأمثالها تتمتع الإدارة في الواقع بسلطة واسعة في تقدير

Duguit, traité de droit constitutionnel 3ème éd. T.I, 1927 p.316
Reglade, Du prétendu contrôle juridictionnel de l'opportunité en matière de recours pour excès de pouvoir, R.D.P., 1925 p.413.

ذلك أن السبب والذي يطلق عليه الفقيه Duguit الباعث الملهم motif impulsive لا يقتصر دوره في الواقع على مجرد الإيحاء بفكرة القرار الإداري، وإنما يمثل في ذات الوقت أساس القرار الإداري وسبب وجوده، إذ يلزم لتدخل رجل الإدارة لمباشرة اختصاصه بإصدار القرار. أن يكون مستندا إلى حقائق موضوعية هي الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على قراره، وذلك حتى يتحقق له الهدف أو الغاية المحددة لقراره. ولذلك فإن الرأي الراجح والمتفق عليه سواء في فرنسا أم في مصر هو الاعتراف بعيب السبب باعتباره عيبا مستقلا عن أوجه إلغاء القرار الإداري الأخرى ذات العلاقة به مثل عيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة.

Bonnard, le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir, R.D.P., 1923 p.263.

دكتور/ محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٧١، ص ٩٢.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن صفة أسبقية السبب على القرار لا تتنافى مع إمكانية اتخاذ الإدارة لقرار ما على أساس من توقعها لحدوث أسباب أو وقائع معينة في المستقبل، ذلك لأن الأسبقية المطلوبة بالنسبة للسبب لا تعني أسبقيته التاريخية على القرار بل أسبقيته القانونية. دكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية، مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٣.

مع ملاحظة أن تغير الظروف التي لا يست صدور القرار لا ينبغي أن يكون له تأثير في تغيير وجه القرار الذي اتخذ على أساسها. وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا: "ينظر في تقدير مشروعية القرار إلى الملايسات التي أحاطت به وقت صدوره ومدى تأثيرها في تصرف الإدارة حين ذلك، فإن كانت تبرر هذا التصرف وتفضي ماديا وقانونيا إلى النتيجة التي انتهت الإدارة إليها. كان القرار سليما وقائما على سببه الصحيح وإلا كان معيبا. ولا ينال من صحة القرار المنظور إليه في ظل ما لا يسه من ظروف أن تتطور هذه الظروف أو يجد عليها فيما بعد ما يغير وجه الحكم عليه فيه، ولو كانت قائمة وقت صدوره، لأن العبرة في تقدير ما إذا كان القرار صحيحا أو غير صحيح هي بكونه كذلك وقت صدوره لا بما قد يجد بعد ذلك من أحداث من شأنها أن تغير وجه الحكم عليه، إذ لا يسوغ في مقام الحكم على مشروعية القرار وسلامته جعل أثر الظروف اللاحقة المستجدة يعطف على الماضي لإبطال قرار صدر صحيحا أو تصحيح قرار صدر باطلا في حينه" الحكم الصادر بتاريخ ١٠/١١/١٩٦٢، مجموعة أبو شادي، مبدأ ١٦٧٧، ص ١٧٥١.

مدى الخطورة التي يمكن أن تنجم عنها باعتبار أنها أقدر من غيرها على إجراء مثل هذا التقدير، والذي يجب أن تستند في خصوصه على وقائع مادية ثابتة.

ومعنى ذلك أن الإدارة وإن كانت تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم وتقدير مدى أهمية وخطورة الوقائع المادية إلا أنها لا تملك حيال الوجود المادي لتلك الوقائع أية سلطة في التقدير. فاختصاصها في هذا الشأن، إنما هو اختصاص مقيد تخضع في خصوصه لحكم القانون واللوائح المنظمة، ومن ثم لرقابة القضاء الإداري^(١).

ففيما يتعلق مثلاً بالاضطرابات، فإن الإدارة وإن كانت تتمتع بسلطة تقدير مدى خطورتها ومدى تهديدها للنظام العام باعتبارها في وضع يسمح لها أكثر من أية هيئة أخرى بإجراء مثل هذا التقدير، إلا أنها ملزمة في ذات الوقت بأن تكون مستندة في خصوصها إلى وقائع ثابتة وصحيحة مادياً. وأيضاً فيما يتعلق باستعمال جزء من المال العام استعمالاً خاصاً فإن الإدارة وإن كانت تملك رفض أو منح الترخيص بمثل هذا الاستعمال، بحيث لا يمكن أن تجبر على ذلك باعتبار أنها هي الأقدر على تقدير مدى ملائمة القرار في هذه الحالة إلا أنها ملزمة في ذات الوقت - وكما ذكرنا - بأن تكون مستندة في هذا الخصوص إلى وقائع ثابتة وصحيحة مادياً؛ وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٥ نوفمبر سنة ١٩٥٥ "أنه وإن كان القرار... يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة.. إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وللقضاء الإداري

(١) تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإدارة تخضع كذلك لرقابة القضاء الإداري في خصوص ما تتمتع به من سلطة تقديرية لمدى أهمية وخطورة الوقائع المادية، ضماناً لعدم الانحراف أو التعسف في استخدامها وذلك كما سنرى فيما بعد.

أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني، إلا أن للإدارة حرية تقدير أهمية هذه الحالة والخطورة الناجمة عنها..."^(١).

أما عن الحالات القانونية motifs de droit والتي تشكل أساسا قانونيا للقرار الإداري فمن أمثلتها مدة الخدمة فيما يتعلق بالترقية على أساس الأقدمية المطلقة، والشروط المطلوبة للحصول على رخصة معينة فإذا ما حدد القانون هذه المدة أو تلك الشروط كان على الإدارة أن تلتزم بترقية الموظف عند استكمال المدة المحددة أو منح الترخيص المطلوب إذ تحققت الشروط القانونية. ومعنى ذلك أن سلطة الإدارة إزاء هذه الحالات سلطة مقيدة ومن ثم لا تملك حيالها أية سلطة في التقدير.

ومع ذلك يجب أن نشير إلى أن الإدارة وإن كانت سلطتها مقيدة في خصوص هذه الحالات، إلا أنها تتمتع مع ذلك بحرية اختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار الإداري. ففي حالة منح الرخصة مثلا، فإن الإدارة تملك - رغم توافر كافة الشروط التي حددها القانون لذلك، والتي يصبح الاختصاص معها اختصاصا مقيدا - تأجيل منح هذه الرخصة إلى وقت تراه هي أكثر ملاءمة، ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها لم تتحرف أو تتعسف في استعمال تلك السلطة.

وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ ١٥ مايو سنة ١٩٥٥ "أن الإدارة بما لها من سلطة تقدير مناسبات القرار الإداري، تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصداره بلا معقب عليها في هذا الشأن من المحكمة... وبشرط ألا يكون القانون قد عين لها ميعادا يحتم إصدار القرار فيه، وإلا كان إصداره بعد الميعاد المحدد لذلك مخالفا

(١) السنة الأولى، ص ٤٣، وراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٢٨ فبراير سنة ١٩٥٩، السنة الرابعة، ص ٩٠٠، ص ٩٠١.

للقانون^(١).

ثانيا: السلطة التقديرية وركن المحل في القرار الإداري:

يقصد بالمحل موضوع القرار الإداري أو مضمون الأثر القانوني الذي ينتجه هذا القرار فورا ومباشرة^(٢). وهنا تتجلى سلطة الإدارة التقديرية بل يمكن القول كما ذهب البعض بحق إلى أن السلطة التقديرية ليست في حقيقتها سوى تقدير مناسبة الإجراء المتخذ للوقائع التي دفعت إلى اتخاذه أي تناسب المحل مع السبب^(٣). فما لم يحدد المشرع للإدارة على وجه الدقة مضمون القرار الإداري الواجب اتخاذه تمتعت في هذا الخصوص بسلطة تقديرية واسعة بشرط أن يكون ممكنا وجائزا قانونا^(٤).

(١) مجموعة أحكام المجلس، السنة التاسعة، ص ١٠٢٢.

(٢) وهو ذات التعريف الذي أورده كل من Eismann و Bonnard، حيث يقول الثاني: "L'objet est l'effet produit immédiatement et directement par l'acte" précis de droit administratif, 4ème, éd., 1943, P. 29.

ويقول الأول:

L'objet de l'acte administratif est l'effet qu'il produit immédiatement et directement" cour de droit administratif, 1949-1950, P. 355.

وبذلك يتميز القرار الإداري عن العمل المادي الذي يكون محله دائما متمثلا بنتيجة من الواقع un certain résultat de fait.

وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري أن من "الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل، وهو المركز الذي تنتج إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا ومباشرة، وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها. وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي الذي يكون داما نتيجة مادية واقعية". الحكم الصادر في ١٦/١/١٩٥٤، مجموعة السنة الثانية، ص ٤٠١.

(٣) دكتور/ سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سبق ذكره، ٨٦.

(٤) وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا أن "القرار الإداري بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ممكنا و جائزا قانونا، أو متى أصبح كذلك...". الحكم الصادر في ٩/٣/١٩٥٧، مجموعة أبو شادي، مبدأ ٦٦٦، ص ١٧٤٢.

ولهذا فإن القرارات الإدارية التي تكون معلقة على شرط ، تكون غير نافذة ، ولا تترتب آثارها إلا إذا تحقق ذلك الشرط ، وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا: "إنه ولئن كانت القاعدة هي نفاذ القرارات الإدارية من تاريخ صدورها، فإنه يجدر التمييز في هذا الصدد بين القرارات الإدارية البسيطة من جهة ، والقرارات الإدارية المعلقة على شرط من جهة

ومعنى ذلك أن رجل الإدارة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بمحل القرار الإداري وذلك :

- كلما كانت قاعدة القانون قد تركت له حرية في هذا الشأن؛ كحرية الاختيار مثلا بين عدة حلول ، إذ يستطيع بذلك أن يحدد بحرية محل القرار الذي منحه القانون حق إصداره؛ ففيما يتعلق بالجزاءات التأديبية مثلا، تملك الإدارة سلطة اختيار الجزاء المناسب بحرية تامة من بين الجزاءات التي حددها المشرع، وأيضا فيما يتعلق بمواجهة الاضطرابات التي تهدد الأمن، يكون للإدارة حرية اختيار الوسيلة الملائمة لمثل هذه المواجهة... إلخ.

- أو كلما كانت قاعدة القانون قد تخلت تماما عن بيان هذا المحل. كما لو تخلت عن تحديد ما يمكن للإدارة أن ترتبه من الآثار القانونية، مكتفية في هذا الخصوص، بتحديد الغاية أو الهدف من القرار، إذ تستطيع الإدارة في مثل هذه الحالة أن تحدد بحرية محل القرار الذي خولتها القاعدة القانونية حق إصداره، على أساس أن كافة الحلول التي يمكن أن تختارها السلطة الإدارية تعد جائزة ومشروعة قانونا^(١).

أخرى، فالقاعدة لا تصدق على إطلاقها إلا بالنسبة للأولى من تلك القرارات. أما المتعلقة على شرط موقف أو فاسخ *suspension ou resolutoire* فإن نفاذ هذا النوع من القرارات، وتحقق آثارها يكون مرهونا بتحقق الشرط الذي علق عليه القرار.... وغنى عن البيان أن لجهة الإدارة أن تؤجل آثار قراراتها شريطة أن يكون رائدها في ذلك تحقيق الصالح العام. الحكم الصادر في ١٧/١١/١٩٦٢، مجموعة أبو شادي، مبدأ ١٦٧٣، ص ١٧٤٧.

(١) فمثلا إذا قرر القانون أن للإدارة سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الآداب العامة إذا ما تعرضت لأي تهديد بالإخلال، فإنه بذلك يكون قد ترك للإدارة سلطة تقديرية كاملة في ترتيب الآثار القانونية الكفيلة بحماية الآداب العامة من أي إخلال، دون خوف من أن يشوب قرارات عيب مخالفة القانون، وذلك إزاء تخلي القانون عن تحديد هذه الآثار أو تقييد الإدارة في شأنها بأي قيد.

دكتور/ سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٢، ص ٢١٣ وما بعدها.

خلاصة القول إذن أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق
بركني السبب والمحل مالم يتدخل المشرع ويحدد كل منهما على وجه الدقة،
أو يتدخل القاضي ويفرض رقابته على اختيار السبب أو المحل لاعتبارات
يقدرها هو كما سنرى فيما بعد.

السبب الأول،

**الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة
الفرنسي، للحد من سلطة الادارة التقديرية
وموقف مجلس الدولة المصري منها**

- ۷۰ -

الباب الأول

الاتجاهات التقليدية فى قضاء مجلس الدولة الفرنسي

للمحد من سلطة الإدارة التقديرية

وموقف مجلس الدولة المصري منها

لقد كانت رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة خلال القرن الماضي وبداية القرن الحالي رقابة مشروعية، حيث لم يكن يقضى مجلس الدولة بإلغاء تلك الأعمال إلا إذا كان هناك عيب في الاختصاص أو الشكل أو كان هناك انحراف بالسلطة أو مخالفة للقانون.

فرقابة مجلس الدولة لم تكن خلال تلك الفترة إذن إلا رقابة قانونية وذلك للأسباب السابق بيانها، ثم بدأ المجلس بعد أن اشتد عوده وثبتت أركانه، يقر لنفسه تدريجيا سلطة فحص الوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتها المطعون عليها أمام ؛ خاصة - وهذا هو ما يهمنا في هذا المقام - تلك الوقائع التي لم تكن شرطا يستلزمه القانون لجواز تدخل الإدارة، أي الوقائع التي تدخل ضمن حالات الاختصاص التقديرى للإدارة ، إذ كان يقضى بإلغائها كلما ثبت له عدم صحتها أو تبين له وجه الخطأ فيها.

وهكذا برز للوجود أول قيد قضائي للمحد من سلطة الإدارة التقديرية.

ثم ما لبث مجلس الدولة أن وسع من نطاق رقابته هذه، وذلك بأن أخضع تلك الوقائع، بعد رقابة وجودها المادي والتأكد من صحتها، أخضعها لحكم القانون ليقرر ما إذا كانت تتفق مع ما قصد إليه المشرع أم لا، أي أصبح يراقب مدى تبريرها للقرار الذي يستند إليها، وهو ما يعرف برقابة التكييف القانوني للوقائع، حيث يستطيع القاضي من خلال تلك الرقابة - وكما سنرى - مراجعة الإدارة في تقديرها للوصف القانوني الذي خلعتة على

تلك الوقائع، وقد يقرها على هذا الوصف، وقد ينتهي إلى عدم صحته مع إحلال تقديره هو محل تقدير الإدارة.

إن مثل هذه الرقابة إنما تمثل في الواقع قيда آخر يضاف إلى القيد السابق للحد من سلطة الإدارة التقديرية.

هذا ولم يمضى وقت طويل حتى بادر مجلس الدولة باتخاذ خطوة جريئة إلى الأمام وضع بها قيда أو حدا جديدا على سلطة الإدارة التقديرية، إذ بعد أن انتهى إلى وجوب فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع، وصحة تكييفها القانوني، بحث في مدى أهمية وخطورة تلك الوقائع، وتقدير مدى التناسب بينها وبين الإجراء المتخذ على أساسها.

هذه الرقابة هي ما يقال لها رقابة التناسب أو رقابة الملائمة والتي تشكل والحال هكذا القيد الثالث للحد من سلطة الإدارة التقديرية.

ومع ذلك يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي لم يتبع سياسة موحدة تجاه تلك الحدود التي قيد بها من سلطة الإدارة التقديرية، فقد غاير بينها تبعا لأهمية المجالات التي تباشر فيها تلك السلطة، ومدى الحرية الواجب تركها للإدارة في هذه المجالات، إذ بينما جعل من الحد الأول (رقابة الوجود المادي للوقائع التي استندت إليها الإدارة في حالة عدم النص على مثل هذه الوقائع) مبدأ عاما يطبق في جميع الحالات، جعل من الحد الثاني (رقابة التكييف القانوني للوقائع السابقة) أصلا عاما ترد عليه استثناءات، وأخيرا يعتبر الحد الثالث (رقابة التناسب) استثناء من أصل عام يتمثل في عدم إجراء تلك الرقابة في مجال المنازعات الإدارية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة المصري والذي نشأ عام ١٩٤٦ تبنى منذ البداية ما انتهى إليه نظيره الفرنسي في هذا الشأن. ولهذا

عقد أخضع لرقابته - كمبدأ عام - الوجود المادي للوقائع التي يستند إليها القرار الصادر عن سلطة تقديرية، وكأصل ترد عليه استثناءات مدى صحة هذه الوقائع قانوناً، وأخيراً وعلى سبيل الاستثناء مدى التناسب بين أهمية وخطورة الرقائع وبين الإجراء المتخذ على أساسها.

وترتيباً على ذلك نتناول فيما يلي الثلاثة قيود التي أقرها القضاء الإداري الفرنسي وتبعه فيها نظيره المصري، للحد من سلطة الإدارة التقديرية، مخصصين لكل قيد منها فصلاً مستقلاً.

القيد الأول: رقابة ماديّات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها.

القيد الثاني: رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها.

القيد الثالث: رقابة تقدير أهمية وتناسب الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها.

الفصل الأول

رقابة ماديّات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها

الفرض هنا أن الوقائع محل الرقابة لا أساس لها في القانون، أي أنها ليست معتبرة كشرط يتطلبه القانون لاتخاذ قرار ما، وإنما فقط مجرد وقائع مادية تدرعت بها الإدارة من عندياتها، وادعتها سنداً لقراراتها وهو ما يمثل - كما ذكرنا - جوهر السلطة التقديرية للإدارة. ولهذا قلنا أن أعمال الرقابة القضائية على مثل هذه الوقائع إنما يعد بمثابة القيد التقليدي الأول للحد من تلك السلطة. إذ بعد أن كان يرفض مجلس الدولة - حتى بداية العقد الأول من القرن الحالي - إجراء أية رقابة على الأسباب أو الوقائع التي تدرعت بها الإدارة كسند لقراراتها، حيث كان يكتفى بالقول أن هذه الأسباب أو الوقائع لا يمكن مناقشتها أمامه بالطريق القضائي^(١): مالبث أن باشر رقابته على هذه الأسباب أو تلك الوقائع، واضعاً بذلك حداً لمطلق حرية الإدارة في التصرف. الأمر الذي حداً بالبعض إلى القول بأنه "إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر الإطلاق بالنسبة لسلطات الإدارة، فإن القرن العشرين هو عصر تقييدها"^(٢).

"Le xixe siècle avait été... le siècle des "actes discrétionnaires", le xxe siècle peut bien, être considéré comme celui de l'affirmation de l'emprise du juge sur les

(1) "l'appréciation des motifs sur lesquels est fondé le décret attaqué n'est pas susceptible d'être soumise au conseil d'Etat par la voie contentieuse".

C.E, 17nov. 1911, Rec. P.1 048; C.E, 16 nov.1901; Mougres, s., 1901-3-57; C.E., 3 janv.1902; Graziette, S., 1903-3-113, note Hauriou.

(2) Pacteau (B.), le juge de l'excès de pouvoir, op. cit, P.31.

actes de l'administration".

وقد بدأ هذا التحول - كما سنرى - عام ١٩٠٧ على أثر الحكم الصادر في قضية monod وتأكد ذلك بصدور حكم Dessay عام ١٩١٠، وحكم Ponsonnailles عام ١٩١٥، وكذلك حكم Camino عام ١٩١٦^(١).

وبمجرد أن أصبح اتجاه مجلس الدولة في هذا الخصوص متواترا، أثير التساؤل حول أساس تلك الرقابة؟ أي حول أساس رقابة القاضي الإداري لأسباب ووقائع لم يشترطها المشرع أو القانون للعمل الإداري؟

وقد أجهد الفقه الفرنسي ذاته للبحث عن إجابة لهذا التساؤل، إجابة تعطى للاتجاه القضائي الجديد آنذاك دعما وسندا من القانون، تعطى له الأسس والضوابط التي تكفل له الحماية والاستمرار.

وقد كان طبيعيا أن يستفيد القضاء الإداري، وكذلك فقه القانون العام في مصر من هذا التطور الذي شهدته الرقابة على الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، وهو ما نلمس انعكاساته في أحكام هذا القضاء وكتابات ذلك الفقه.

ولبيان ما أجملناه نتناول فيما يلي الموضوعين التاليين، مخصصين لكل موضوع منهما مبحثا مستقلا.

- ظهور الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها.
- أساس الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها.

(١) سوف نتناول هذه الأحكام تفصيلاً فيما بعد.

المبحث الأول

ظهور الرقابة على ماديّات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها في فرنسا ومصر

إذا كانت الرقابة على ماديّات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها قد ظهرت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي بعد نشأته بخمسة وثلاثين عاما تقريبا أي مع بداية القرن الحالي، فإن هذه الرقابة قد ظهرت في قضاء مجلس الدولة المصري منذ نشأته عام ١٩٤٦.

وعلى ذلك نتناول أولا ظهور تلك الرقابة في فرنسا ثم في مصر كمايلي.

المطلب الأول

ظهور الرقابة على ماديّات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها في فرنسا

لقد ظهرت الرقابة على ماديّات الوقائع في حالات السلطة التقديرية للإدارة - كما ذكرنا - عام ١٩٠٧، وذلك بمقتضى الحكم الصادر في قضية Monod بتاريخ ٢٨/٦/١٩٠٧، والتي تخلص وقائعها في أنه قد صدر قرار بإحالة أحد المحافظين ويدعى Monod إلى التقاعد. وقد استند هذا القرار إلى واقعة تقديم المحافظ المذكور طلبا بذلك، في الوقت الذي لم يتقدم فيه بطلب كهذا على الإطلاق. ولهذا فقد طالب السيد Monod بإلغاء هذا القرار لاستناده إلى مجرد واقعة مدعاة من جانب الإدارة لا أساس لوجودها في الواقع، وبذلك فهو يتضمن فصلا إداريا ينطوي على جزء تأديبي. وقد كان على مجلس الدولة - طبقا لقضائه المستقر في هذا الخصوص - أن يرفض التصدي لواقعة تقديم الطلب التي ذكرت سببا

للقرار، إلا أنه لم يسلك هذا السبيل وتصدى بالفعل لهذه الواقعة وانتهى إلى صحتها^(١).

إن ما يهمنا من هذا الحكم ليس فيما انتهى إليه المجلس من قرار، وإنما فيما أقدم عليه من بحث للواقعة التي استند إليها قرار الإدارة المتخذ على أساس من سلطتها التقديرية، مخالفاً بذلك - كما ذكرنا - قضاءه المستقر في هذا الشأن. ولهذا فهو يعد في الواقع بمثابة نقطة الانطلاق لما طرأ على قضاء مجلس الدولة من تطورات لاحقة، إذ لم يعد يقضي - منذ تاريخ هذا الحكم وكسابق عهده - بعدم قبول الدعاوى الموجهة ضمن القرارات الإدارية المستندة إلى خطأ في الوقائع التي تتذرع بها الإدارة كأساس لتلك القرارات، وإنما أخذ يبسط رقابته على هذه الوقائع - رغم تسليمه بسلطة الإدارة التقديرية في هذا الصدد - ويلغى القرارات التي تستند إليها كلما ثبت له عدم صحتها، أو تبين له وجه الخطأ فيها.

ففي قضية مشابهة لقضية السيد Monod السابقة اتخذ مجلس الدولة ذات الاتجاه حيث انتهى إلى القول "أنه يبين من أوراق الملف أن الطاعن إذ لم يعرب عن رغبته في إحالته على التقاعد... فإن القرار محل الدعاوى والذي قرر أن تلك الإحالة إنما كانت على أساس من طلبه، يكون قراراً مستنداً إلى واقعة غير صحيحة مادياً. ومن ثم فإن وزير الداخلية يكون بذلك

(١) حقيقة أن المجلس رفض إلغاء القرار المطعون فيه ولكن ذلك ليس على أساس عدم رقابته لوقائع القرارات الصادرة في حالات السلطة التقديرية كما كان مذهبه في الماضي وإنما على أساس أن المدعي قد توافرت فيه شروط الإحالة على التقاعد، وأن الإدارة عمدت إلى اتباع هذا المسلك رافة منها بالموظف حتى لا يبدو الفصل في صورة عقوبة تأديبية. فذكر واقعة تقديم طلب الاستقالة غير الصحيحة مادياً ليس من شأنها إذن وكما تقول مجلس الدولة، أن تعيب القرار طالما أنه لا يخفي جزاء تأديبياً وأنه يمكن حمله على الصحة بالنسبة إلى سن المدعى ومدة خدمته.

Rec., p. 616, Bonnard, la pouvoir discretionnaire, R.D.P, 1923, P. 373.

قد أعطى قراره سببا قانونيا منعدا^(١) "une cause juridique" "inexistante".

وهكذا يمكننا القول أن مجلس الدولة الفرنسي سجل بدءا من عام ١٩٠٧، تحولاً رئيسياً في منهجه الرقابي وذلك ببسط رقابته على الوقائع التي لا يشترطها القانون لتدخل الإدارة، أي على الوقائع التي تتبناها الإدارة بمحض إرادتها واختيارها، وبمطلق حريتها في التقدير كأساس لقراراتها، واستقر في هذا الصدد على وجوب إلغاء القرار الإداري وبصرف النظر عن موضوعه - إذا ثبت أن الإدارة قد استندت في تبريره إلى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية، يستوى في ذلك أن تكون الإدارة سيئة النية، أي كانت عالمة بانعدام هذه الوقائع، ففي الحالتين يلغي القرار لاستناده إلى وقائع غير صحيحة^(٢).

ومن الحثثات الهامة التي تذكر في هذا الصدد تلك التي تضمنها حكم مجلس الدولة في قضية Camino الصادر عام ١٩١٦، ذلك الحكم الذي يعتبره معظم رجال الفقه بمثابة الفاصل الحقيقي بين منهج مجلس الدولة في رفض بحث أو رقابة أية وقائع لم يشترطها القانون لتدخل الإدارة، وبين منهجه في بسط تلك الرقابة على مثل هذه الوقائع. تقول هذه الحثثية: "أنه إذا كان مجلس الدولة لا يستطيع تقدير ملائمة الإجراءات التي تعرض عليه بطريق دعوى مجاوزة السلطة، فإنه يملك التحقق من ماديات الوقائع التي بررت هذه الإجراءات"^(٣).

(1) C.E, 20 janv. 1922, Trepont, Rec, p.65, R.D.P., 1922, p.82, concl Rivet, S. 1925.3.51.

(٢) الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ٤٦.

(٣) وقد ألغى مجلس الدولة القرار الصادر بفصل اسيد Camino، عمدة إحدى القرى بعد أن ثبت له أن الاتهام الموجه للمذكور والمتمثل في تنكره للاحترام الواجب بجنازة، ليس صحيحاً ولا أساس له من الواقع.

وفي المجال التأديبي، وهو مجال غنى بمثل تلك الأحكام والتي يؤكد فيها مجلس الدولة سلطته في الرقابة على صحة ماديات الوقائع، نذكر الحكم الصادر في قضية le Général de Noué والذي بين فيه المجلس، أنه على الرغم من الحرية التي يتمتع بها وزير الحرب في تقييم وتقدير كل ما من شأنه المساس بمصلحة المرفق، إلا أنه ممنوع عليه أن ينسب إلى أحد الضباط سلوكا معيناً دون أن يكون مستنداً في ذلك إلى وقائع مادية صحيحة. ولهذا فقد ألغى القرار الصادر من هذا الوزير بإحالة الجنرال المذكور إلى الإستيداع بحجة ارتكابه لبعض الأخطاء التأديبية، بعد أن تبين له أن هذه الأخطاء لم تصدر عن الطاعن بل ولم تكن صحيحة مادياً *matériellement inexacts* ^(١).

حقيقة أن مجلس الدولة الفرنسي كان يستثنى من هذا المنهج القرارات المتعلقة بإجراءات الضبط الإداري المتخذة تطبيقاً لنصوص القوانين الاستثنائية، أو قوانين الاستعجال والضرورة ^(٢) *Lois d'urgence ou d'excepcion*، إلا أنه سرعان ما تخلى عن هذا الاستثناء، نتيجة ما وجه إلى مسلكه هذا من نقد ^(٣) وأخضع بالتالي تلك القرارات لرقابته للتحقق من

C.E, 14 Janv. 1916, Camino, Rec. P. 15, S. 1924.3.10, concl, Comeille, R.D.P., 1917, P. 463, note Jéze.

(1) C.E., 5 juill 1918, le general de Noué, Rec., P. 660.

(٢) كان المجلس يكتفي في هذه الحالة باشتراط أن تكون الإدارة قد استندت في إصدارها إلى وقائع تكفي - مع افتراض صحتها - لتبرير هذه الإجراءات، دون أن يقوم بالتحقق من الوجود الفعلي لهذه الوقائع؛ وبعبارة أخرى كان المجلس يكتفي بأن تكون الوقائع المدعاة تدرج في طائفة الوقائع التي تصلح سنداً لتبرير القرار، دون أن يتطرق إلى بحث مدى قيام هذه الوقائع فعلاً.

الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٤٧.

(٣) وقد تمثل هذا النقد في القول أنه إذا كان صحيحاً أن هذه القوانين تدرج في إطار الظروف الاستثنائية وما تقتضيه من اتساع سلطات الإدارة لتمكينها من مواجهة الأخطار الطارئة، إلا أنه مع التسليم بهذا فإن التحقق من الوجود المادي للوقائع التي تذرعت بها

مسلكه هذا من نقد^(١)، وأخضع بالتالي تلك القرارات لرقابته للتحقق من الوجود المادي للوقائع المدعاة كأساس لها، وكان ذلك بمناسبة حكمه في قضية Grange الصادر عام ١٩٥٩ حيث أخذ فيها برأى مفوض الحكومة Chardeau، الذي طالبه في تقريره بالعدول عن قضائه السابق، وذلك بمناسبة الطعن في قرار صادر عن السلطات الفرنسية بتحديد إقامة أحد المحامين استنادا إلى نصوص المرسوم الصادر بقانون في ١٩ مارس ١٩٥٦.

وقد استندت الإدارة في قرارها إلى انتماء ذلك المحامي إلى تنظيم سرى هدفه الإخلال بالأمن ومساعدة الثوار في الجزائر، وهي أسباب كانت تصلح طبقا لمسلك المجلس السابق في تأسيس القرار، غير أن المجلس أخذ في هذه المنازعة بالرأي الذي اقترحه المفوض في تقريره، وقرر فرض رقابته للتحقق من الوجود المادي لهذه الوقائع، وإذ ثبت للمجلس عدم صحتها، حكم بإلغاء قرار الإدارة الصادر بتحديد إقامة السيد Grange^(٢).

وهكذا أمكن القول بدءا من هذا الحكم، إن قاعدة ضرورة استناد القرار الإداري إلى وقائع صحيحة ماديا قد أصبحت في فرنسا قاعدة مطلقة لا ترد عليها أية استثناءات، مما يعني أن الإدارة من جانبها لا يمكنها أن تستند في

الإدارة، هو القدر الأدنى من الرقابة الذي يجب على المجلس مباشرته. ذلك أن التحقق من قيام هذه الوقائع كما يقول Castagné: "هو ضرورة لا تتطلبها أصول الرقابة القانونية وحدها، وإنما تحتمها أيضا اعتبارات المنطق".

l'existence des faits sur lesquels se fondé une mesure de police est, bien plus qu'une exigence de légalité, c'est une exigence logique inélucible".

(1)CASTAGNE (J.), Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police administrative, th., Paris, 1964, P. 155 etss.

وانظر أيضا الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ٤٨.

(2)C.E., 30 Jan. 1959, Rec. P. 85.

قراراتها إلى وقائع مادية غير صحيحة، وأن المجلس من جانبه كذلك عليه أن يتحقق دائماً من وجود وصحة هذه الوقائع^(١).

المطلب الثاني

ظهور الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها في مصر

إذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على مبدأ رقابة وجود وصحة الوقائع المادية التي تدعيها الإدارة لقراراتها، أو تذرع بها كسند لهذه القرارات، ذلك المبدأ الذي يجسد - كما ذكرنا - أول قيد تقليدي للحد من الحرية المطلقة التي كانت تتمتع بها الإدارة في هذا الخصوص، فإن مجلس الدولة المصري لم يتخلف عن هذا الاتجاه، بل وقد اعتنقه بمجرد نشأته - كما ذكرنا - عام ١٩٤٦. حيث فرض رقابته منذ ذلك التاريخ على صحة الوجود المادي للوقائع التذرع بها الإدارة، مسترشداً في ذلك بالمبادئ والأسس التي استقر عليها نظيره الفرنسي في هذا الشأن.

فقد قررت محكمة القضاء الإداري بداءة ، أنه إذا كانت الإدارة تستقل بوزن مناسبات قرارها وبتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره ، دون أن يكون للقضاء التعقيب عليها في هذا الشأن، إلا أن مناط ذلك أن تكون قد استندت في قرارها إلى وقائع صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار^(٢).

وتطبيقاً لذلك؛ فقد قضت تلك المحكمة "بأن القرار الصادر بتوقيع جزاء

(1) Odent, contentieux administratif, 1965, 1966, Fasc. IV, P. 1253; Vedel, droit administratif, op. cit., P. 527.

الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ٤٩؛ الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ١٤٠ وما بعدها.

(٢) الحكم الصادر في ٧ يناير ١٩٤٨، ق ٣٨، س ١، مجموعة السنة الثانية، ص ٢٢٢.

كأى قرار إدارى آخر، يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة بتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، ولمحكمة القضاء الإداري أن تراقب صحة هذه الوقائع....^(١). كما قضت كذلك بأنه "إذا كان القرار المطعون فيه قد استند بلا جدال إلى ما تضمنته مذكرة وزارة الداخلية المعروضة على المجلس الأعلى للبوليس من أسباب رأت أنها من الجسامة، بحيث يتأذى الصالح العام من بقاء الضابط في وظيفته، فإن هذه الأسباب لا بد أن تكون صحيحة منتجة لهذا القرار، وللقضاء بما له من حق في الرقابة على سلامة القرار الإداري، أن يتحرى ذلك. فإن ظهر أن هذه الأسباب غير صحيحة، ولو توهمت الإدارة صحتها بحسن نية، فقد القرار سنده القانوني الذي يقوم عليه..^(٢)".

ومن أبرز مجالات السلطة التقديرية التي أعمل فيها مجلس الدولة المصرى رقابته على صحة الوقائع التي تذرعت بها الإدارة، مجال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، باعتبار أنه مجال متروك للحرية المطلقة لتقدير الإدارة. تتخذ فيه ما تشاء من قرارات دون أن تكون ملزمة بذكر الأسباب أو الوقائع التي استندت إليها، فقد قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر عام ١٩٥٢ بإلغاء المرسوم الصادر من مجلس الوزراء بفصل وكيل وزارة التموين مستندة في ذلك إلى "أنه ليس المقصود من تخويل الحكومة سلطة فصل كبار الموظفين المعينين بمرسوم، بدون توسط المحكمة التأديبية العليا، أن تستغل هذه الرخصة بدون قيد أو شرط، فتفصل من تشاء وكيف تشاء - حسبما تريد وتهوى - وأن تتحلل من هذه الضمانات المقررة للموظفين"^(٣).

(١) الحكم الصادر في ٢٩ يناير ١٩٥٦، ق ٤٠٧، س ٦، مجموعة السنة العاشرة، ص ١٧٤.

(٢) الحكم الصادر في ٥ يناير ١٩٥٤، ق ١١٦٠، س ٧، مجموعة السنة الثانية، ص ٣٩٧.

(٣) الحكم الصادر في ١٩ مارس ١٩٥٢، ق ١٧٦، س ٤، مجموعة السنة السادسة، ص ٦٨٣.

ولم يختلف مسلك المحكمة الإدارية العليا عن ذات مسلك محكمة القضاء الإداري في هذا الصدد، فقد بسطت رقابتها على وجود وصحة الوقائع التي تاع بها الإدارة كأساس لقراراتها، متبينة في أحكامها المبادئ المستقرة في هذا الشأن وإن كانت قد أخرجت من نطاق تلك الرقابة إجراءات الضبط الإداري الخاصة بإقامة الأجانب ، حيث امتنعت - على عكس مذهب محكمة القضاء الإداري - من رقابة الوجود المادي للوقائع التي استندت إليها الإدارة في قراراتها الصادرة بإبعاد الأجانب عن مصر، وقد عللت المحكمة هذا المسلك بقولها "أن الترخيص أو عدم الترخيص للأجنبي بالإقامة أو مد أو علم على إقامته بعد ذلك هو على مقتضى المادة رقم (٩) من المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢، من المسائل التي تتركز الإدارة في تقديرها بسلطة مطلقة، في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام وليست سلطتها هذه مقيدة بقيود أو آثار قانونية معينة فرضها القانون مقدماً ، ومرد ذلك أن الدولة بحكم ما لها من سيادة إقليمية تتمتع بسلطة عامة وكاملة في تقدير مناسبات إقامة الأجنبي في أراضيها ، ولا تلتزم قانوناً لا بالسماح له بالدخول فيها ولا بمد إقامته بها، إلا إذا كانت تشريعاتها ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الأوضاع والشروط التي تقررها، فإن لم يوجد ، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعذار أو الذرائع التي يتعلل بها بل حتى ولم يكن به سبب يدل على خطورته على الأمن والآداب، إذ أن إقامته العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة متروكة تقديرها لسلطتها المطلقة استناداً إلى سيادتها على إقليمها وحققها في اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها ومصالح رعاياها حسبما يتراءى لها أنه محقق للمصلحة العامة بأوسع معانيها"^(١).

(١) المحكمة الإدارية العليا في ٧ أبريل ١٩٥٦، الطعن رقم ٧٥٣، مجموعة السنة الأولى، س ١، ص ٦٥٧. ومن الملاحظ أن القانون (القرار بقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠) قد نص على عدم جواز إبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة إلا بشروط معينة! أن يكون في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو

وعلى أية حال وباستثناء مسلك المحكمة الإدارية العليا في خصوص القرارات المتعلقة بالأجانب (الترخيص أو عدم الترخيص لهم بالإقامة أو إبعادهم)، يمكننا القول أن القضاء الإداري المصري قد انتهج ذات مسلك نظيره الفرنسي في ضرورة التحقق من وجود وصحة الوقائع التي تنذر بها الإدارة، وتتخذها دون سند من القانون أسباباً لقراراتها، بحيث أصبح هذا الاتجاه يشكل مبدأ عاماً ومستقراً يحد به القضاء الإداري - كما ذكرنا - من سلطة الإدارة التقديرية.

ولكن لنا أن نتساءل هنا عن أساس الرقابة التي يباشرها القضاء الإداري سواء في فرنسا أم في مصر على وقائع وأسباب لم يشترطها القانون كأسس تلتزم بها الإدارة عندما ترغب في اتخاذ قرارات معينة بما لها من سلطة تقديرية؟

هذا ما نبيه في المبحث التالي.

المصلحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالية على الدولة، ويلاحظ على هذه الشروط أنها من العموم والاتساع بحيث تترك للإدارة في العمل سلطة تقديرية واسعة في اختيار سبب إبعاد الأجنبي حتى من ذوى الإقامة الخاصة، وعلاوة على ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا لم تبسط رقابتها على وجود سبب الإبعاد الذي تستند إليه الإدارة، حتى من حيث الوجود المادي للوقائع، وأية ذلك أنها تقر مسلك الإدارة في تأسيس قراراتها على تحريات جهات الأمن، دون أن تقوم المحكمة بالتحقق من صحة هذه الوقائع وتصرح المحكمة في هذا الصدد بأن أمر تلك الأسباب متروك لمحض تقدير جهة الإدارة المختصة ولجنة الأبعاد، تترخص فيه كليهماً على مقتضى ما تطمئن إليه من قرائن ودلائل وأمارات في مقدمتها ما ورد بتقرير إدارة مكافحة المخدرات وإدارة المباحث العامة، فالمحكمة تترك تقدير الأسباب للإدارة مادامت هي قد اطمأنت إلى ما تجمع لديها من تحريات وما قام حول الأجنبي من شبهات. حكمها في ٢٨ مارس ١٩٦٤، س٩، مجموعة السنة التاسعة، ص ٨٨٨.

حول هذا الموضوع أنظر: الدكتور/ محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٨٠، ص ١٢٩؛ الدكتور/ محمد عصفور، مذاهب المحكمة الإدارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع، القاهرة، ١٩٥٧، ص ١٢٦؛ الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص ٤١٠؛ الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ١٥٢؛ الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ١٤٧ وما بعدها.

المبحث الثانى

أساس الرقابة على ماديّات الوقائع التى تدعيها الإدارة لقراراتها فى فرنسا ومصر

إن مصدر صعوبة البحث عن أساس قانوني لرقابة القضاء للوقائع التى تدعيها الإدارة لقراراتها، أن هذه الوقائع ليست شرطا استلزم المشرع ضرورة تحقيقه لجواز تدخل الإدارة. إذ لو كان الأمر غير ذلك، بأن كان تلك الوقائع شرطا استلزم المشرع ضرورة تحقيقه عند اتخاذ القرار وهو ما يندرج فى إطار السلطة المقيدة للإدارة، لما أثار أساس تلك الرقابة أدنى صعوبة، ذلك أن تخلف تلك الوقائع إنما يعنى تخلف الشرط الذى استلزمه القانون لتدخل الإدارة مما يجعل القرار معيبا بعبء مخالفة القانون، فالرقابة القضائية فى هذه الحالة إذن إجراء تحتمه رقابة مشروعية القرار.

أما حينما يسكت المشرع أو القانون عن تحديد الوقائع المبررة لإصدار القرار، أي حينما لا يجعل من الوقائع شرطا لمشروعية القرار، فإن السؤال الذى يثار بطبيعة الحال هو ما أساس إخضاع تلك الوقائع للرقابة القضائية؟

وهذا ما نبين الإجابة عليه تباعا فى كل من فرنسا ومصر كما يلي.

المطلب الأول

أساس الرقابة على ماديّات الوقائع التى تدعيها الإدارة لقراراتها فى فرنسا

إن أول من أجاب على التساؤل السابق هو ذاته صاحب فكرة إخضاع الوقائع التى تتدخل بها الإدارة ، كأساس لقراراتها، للرقابة القضائية، ألا وهو مجلس الدولة الفرنسى، فقد أحس ذلك المجلس منذ إقدامه على مباشرة تلك الرقابة بضرورة وضع أساس يبرر فضائه ويعزز اتجاهه فى هذا

الخصوص. وقد وجد هذا الأساس في فكرة "السبب القانوني Cause Juridique" معتبرا أن الوقائع المدعاة من قبل الإدارة والتي يستند إليها القرار هي بمثابة سبب قانوني له، فإذا لم تكن تلك الوقائع موجودة أصلا، أو كانت موجودة ولكنها لغير صحيحة، كان القرار مستندا إلى سبب غير صحيح، ومن ثم كان واجب الإلغاء.

وهذا ما أفصح عنه المجلس منذ طلائع أحكامه الصادرة في هذا الشأن، فقد أنكر على الحكومة - كما رأينا بمناسبة قضية Trepont - أن تؤسس قرارها، بإحالة المذكور إلى التقاعد على سبب غير موجود فعلا وحقيقة، ولهذا فقد الغى ذلك القرار لاستناده - كما يقول الحكم - إلى سبب قانوني غير موجود.

"Sur une cause Juridique inexistante"

هذا وقد أعمل المجلس هذه الفكرة في مجالات عديدة أخرى: ففي مجال التأديب مثلا تطلب أن يكون جزاء وقف العمد ومساعدتهم، وكذلك جزاء عزلهم من وظائفهم، مستندا إلى خطأ (وهو هنا السبب القانوني للجزاء)^(١). بل وفي مجال الضبط الإداري تطلب المجلس في حكم Olivier الصادر عام ١٩٠٩ أن يكون السبب على قدر من الأهمية أو من طبيعة تحقق التوازن بين الإجراءات البوليسية المتخذة على أساسه، وبين ضرورة احترام حقوق الأفراد وحررياتهم، الأمر الذي أدى إلى وضع قاعدة عامة في هذا الخصوص من مقتضاها: أن كل إجراء من إجراءات البوليس يجب - لكي يكون مشروعها - أن يكون مبررا بوجود تهديد كاف للإخلال بالنظام العام^(٢).

(1) C.E, 28 Juin 1912 Boisselet, Rec., P. 740.

(2) C.E, 19 Janv. 1909, Olivier, Rec., P. 180. D. 1910.3.123, concl. Chardenet.

"toute mesure de police doit, pour être régulière, être motivée par l'existence d'une menace suffisante de trouble à l'ordre public"

هذا مع ملاحظة أن مجلس الدولة الفرنسي ليس من طبيعته أن يأتي بتبريرات للأحكام التي يصدرها، ولا أن يضمن هذه الأحكام مبادي ونظريات عامة حتى يطلق لذاته العنان في تطوير قضائه وتغيير اتجاهاته بما يتلاءم وما قد يطرأ على ساحة العمل الإداري من متغيرات ومتطلبات^(١)، وإذا كان قد خرج على هذه السياسة القضائية في الحالة التي نحن بصدددها، فإنه في الواقع خروج استثنائي محض لجأ إليه تحت ضغط الحاجة إلى تبرير تحول رئيسي في حياته القضائية. لذلك وبمجرد أن استقر القضاء الجديد، وتصدى الفقه لصياغة النظريات المبررة له، عاد مجلس الدولة إلى سابق عهده من إيجاز في صياغة أحكامه، والبعد عن تضمينها أية نظريات أو مبادئ عامة. ولذا فقد تخطى عن الإشارة إلى فكرة السبب القانوني وذلك على الرغم من استمراره في إلغاء القرار الإداري لعييب في الوقائع.

أما عن الفقه فإنه وإن اتفق مع ما انتهى إليه مجلس الدولة من ضرورة إلغاء القرارات الإدارية التي لا تستند إلى وقائع صحيحة، حتى ولو كانت تلك الوقائع مما تتذرع به الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية، إلا أنه لم يسلك

(١) لقد ذهب البعض من الفقه إلى القول أن مجلس الدولة الفرنسي قد التزم في ذلك "جانب الحكمة والحذر، وكان دائماً يأبى أن يصوغ أحكامه بطريقة قد تحد من حريته في المستقبل. لذلك نجد أحكام المجلس تتميز بالإيجاز وعدم وضع مبادئ عامة. ويحرص المجلس دائماً على أن يحتفظ بحريته كاملة في المستقبل، حتى أن أحكامه تبدو عادة وكأنها تضع حلولاً عرضية، لظروف خاصة أو وقتية، وبذلك تمكن المجلس من تطوير قضائه باستمرار حتى يكون متجاوباً دائماً مع ظروف الإدارة ومستلزماتها".
أستاذنا الدكتور/ ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، المجلد الأول، سنة ١٩٦٨، ص ٧١.

مسلكا واحدا في تفسير أو تبرير هذا الاتجاه القضائي الجديد.

. فمن الفقهاء من أسند هذا الاتجاه القضائي إلى فكرة الانحراف بالسلطة، وعميدهم في ذلك الفقيه Hauriou الذي ذكر أن مجلس الدولة لا يراقب فقط مدى احترام الإدارة لقواعد القانون وإنما أيضا مدى احترامها للآداب أو الأخلاق الإدارية la moralité administrative التي تجسدها قواعد تنشأ من خلال التطبيق العملي اليومي داخل المرافق الإدارية أو المصالح العامة، يطلق عليها قواعد سلوك Règles de conduite ؛ تلك القواعد التي يجب على رجل الإدارة أن يلتزم بها في تصرفاته، كما يلتزم تماما بالقواعد القانونية، وإلا كان متجاوزا لحدود سلطته أو منحرفا بها وكان قراره بالتالي جديرا بالإلغاء^(١).

ويؤيد Vedel العميد هوريو في هذا الاتجاه، وإن كان يرى أن على القاضي الإداري وهو يتمتع بسلطات كبيرة تصل إلى حد إنشاء قواعد قانونية جديدة يستطيع تحت شعار روح القانون أو المبادئ القانونية العامة أن يدخل في نطاق المشروعية بعض التوجيهات الأخلاقية، أو بعض أدبيات مهنة الإدارة^(٢).

"Un minimum de conscience et de diligence professionnelle"

لتكون بمثابة عناصر ملزمة لرجل الإدارة، يجب عليه احترامها والالتزام بها كأسس للعمل الإداري، وإلا عد مخالفا لمبدأ المشروعية الإدارية. تلك المشروعية التي لا تعنى فقط لدى vedel، خضوع الإدارة للقانون بمعناه

(1) Sa note sous C.E., 27 mars 1925, mariani, S. 1927.3.57; Arrighi: "Hauriou, commentateur des arrêts du conseil d'Etat" Livre jubilaie du C.E, PP. 314 etss.; Pacteau (B.) op.cit. p.36,

(2) Sa thèse de doctorat en 1934 "Essai sur la notion de cause en droit administratif", p.285 etss.

الضيق، وإنما خضوعها كذلك للقانون في أوسع معانيه، ذلك لأن نطاق المشروعية لا يقتصر على القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية وحدها، وإنما يشمل كذلك على القواعد القانونية التي يضعها القضاء والتي تخضع لها الإدارة بنفس مقدار خضوعها للقواعد الأولى. فالقاضي الإداري عنده إذن مجرد حارس للمشروعية وإنما هو أيضا مصدر من مصادرها^(١).

- في حين ذهب جانب آخر من الفقه، من أجل تبرير الرقابة على الوقائع التي تتذرع بها الإدارة كأساس لقراراتها، إلى إدراج هذه الرقابة في إطار الرقابة على مخالفة القانون، مستندا في ذلك إلى أن القرار الإداري لكي يكون مشروعاً، يجب أن يكون مستندا إلى سبب معين، أو وقائع معينة، إذ لا يتصور أن يكون هناك قرار بدون سبب أو وقائع أدت إلى إصداره، ولهذا فإن مجرد تخلف هذا السبب أو تلك الوقائع أو عدم صحتها يجعل القرار المتخذ في هذه الحالة قراراً غير مشروع. فهذا هو Bonnard أحد الرواد الأوائل لهذا المذهب، بل وصاحب نظرية إعلان الأسباب والتي من مقتضاها أن قيام السبب هو أحد عناصر القرار الإداري وشرط من شروط مشروعيته.

برى بونار أن الرقابة على وجود وصحة الوقائع أو البواعث التي يستند إليها القرار الإداري، في غير الحالات التي يحدد فيها القانون هذه الوقائع أو تلك البواعث، أي الحالات التي يكون فيها للإدارة سلطة تقديرية بالنسبة للوقائع أو البواعث المشار إليها - تجد تبريرها أو أساسها في أن السلطة القانونية أو اللائحية التي تمكن رجل الإدارة من اتخاذ عمل أو قرار ما، لا يمكن مباشرتها إلا إذا توافرت شروط معينة، ومن هذه الشروط ضرورة قيام

(1) Vedel (G.) et Delvolvé (p.) droit administratif, P.U.F. Paris, 1982, P. 445.

سبب للعمل أو القرار المتخذ ؛ فمن المنطقي - يقول بونار - أنه لا يمكن أن نتصور صدور عمل أو قرار دون سبب أو باعث عليه وإلا أعتبر هذا العمل أو ذلك القرار مجرد نزوة^(١).

"logiquement on ne peut pas concevoir qu'une decision soit prise sans motif,ce serait un pur caprice"

وعلى هذا الأساس - يضيف أنصار الاتجاه الذي نحن بصدده - يمكن اعتبار وجود الباعث أو السبب بمثابة أحد الشروط اللازمة لمشروعية ممارسة السلطة، ويصبح القرار المؤسس على بواعث أو أسباب غير موجودة بالتالي قرارا غير مشروع على أن تؤخذ المشروعية هنا بمعناها الواسع، بحيث يشمل كل مخالفة ليس فقط للقواعد التشريعية، وإنما أيضا لكل قاعدة عرفية. ذلك أن قاعدة ضرورة قيام سبب أو باعث للقرار والتي تملئها اعتبارات المنطق هي قاعدة عرفية^(٢).

- وثمة اتجاه ثالث في هذا الخصوص يبرر مسلك القضاء الإداري إزاء الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، بأنه مما يندرج في إطار عيب عدم الاختصاص. ويتزعم هذا الاتجاه الفقيه Réglade حيث يذكر أن القانون حينما يخول رجل الإدارة اختصاصا بإجراء تصرف ما، فإن هذا القانون يتضمن في ذات الوقت أن هذا الاختصاص لا يجب أن يباشر إلا إذا وجدت فعلا وحقيقة وقائع أو أسباب مبررة لهذا التصرف بحيث لا

(1) "Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir ", R.D.P, 1923, P.388.

(2) "Car ce principe de la nécessité d'une existence de motifs qui procède de considérations rationnelles est une règle d'ordre coutumier" Réglade (M.),Du prétendu contrôle juridictionnel de l'opportunité en matière de recours pour excès de pouvoir", R.D.P. 1925, P.428.

ينعقد الاختصاص، وبالتالي يكون التصرف باطلا إذا لم توجد هذه الوقائع أو تلك الأسباب حتى وإن كان المشرع قد ترك لرجل الإدارة في هذا الخصوص قدرا من الحرية لاختيار الوقائع أو الأسباب التي يؤسس عليها هذا التصرف.

فوجود الوقائع أو الأسباب عند اتخاذ قرار ما يعد إذن بمثابة شرط تطلبه المشرع ضمنا لكي ينعقد الاختصاص بداءة لرجل الإدارة باتخاذ هذا القرار. ومن ثم فإنها أي الوقائع والأسباب لم تعد والحال هكذا فقط من مسائل الواقع وإنما أيضا من مسائل القانون.

يترتب على ذلك - يضيف الفقيه ريجلاد - أن مجلس الدولة حينما يباشر رقابته على الوقائع أو الأسباب، فإن هذه الرقابة لا تكون إلا من قبيل الرقابة على المشروعية، فالقاضي الإداري يهدف من وراء تلك الرقابة البحث عما إذا كان رجل الإدارة مختصا باتخاذ القرار الإداري المطعون فيه من عدمه. فإذا ثبت له أن تلك الوقائع أو الأسباب غير موجودة أو غير صحيحة وحكم بالتالي بإلغاء القرار ، فإن هذا الإلغاء لا يكون لعدم وجود أو عدم صحة تلك الوقائع والأسباب، وإنما باعتبار أن ذلك يعد دليلا على عدم اختصاص رجل الإدارة^(١).

واضح من هذا العرض الموجز لمختلف الآراء التي قيلت لتبرير رقابة مجلس الدولة على الوقائع التي تتدفع بها الإدارة كأساس للقرارات الصادرة عنها بمقتضى سلطتها التقديرية، أن تلك الآراء تنطلق من نقطة واحدة وهي

(1) En recherchant donc si les motifs existent le conseil d'Etatrecherchera si l'agent était compétent pour faire l'acte et c'est pour incompetence que l'acte est annulé s'il n'ya pas de motifs." op. cit. P.427.

أن هذه الرقابة تندرج في إطار الرقابة على المشروعية، على أساس من اعتقادهم بأن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون، وفي جميع الأحوال إلا رقابة مشروعية وذلك للأسباب السابق ذكرها.

من هنا يمكن القول أن محاولة كل منهم في أن يجد تبريرا للقضاء الجديد، ظلت محصورة أو رهن هذا الاعتقاد ، وفاتهم أنهم هم الذين اعتبروا أن الرقابة على مثل تلك الوقائع - وذلك بطبيعة الحال قبل أن يباشر القضاء رقابته عليها - من قبيل الرقابة على الملاءمة، ومن ثم فهي ممنوعة على مجلس الدولة وإلا أعتبر رئيسا إداريا أعلى. ولكن ها هو مجلس الدولة قد أعمل رقابته على الوقائع التي تتدرب بها الإدارة بوصفها سببا لقراراتها، فماذا قال الفقه؟ أتى لنا بالتبريرات السابقة والتي تحصر هذه الرقابة - كما رأينا - في نطاق الرقابة على المشروعية!

حقيقة أن القاضي الإداري لا يتعرض في هذه الحالات لفحص ملاءمة القرار، غير أن مرجع ذلك ليس لأن القاضي لا يراقب الملاءمة، ولكن لأن مسألة الملاءمة لا تثور أصلا لا بالنسبة للقاضي ولا بالنسبة للإدارة. الواقعة إما أن تكون موجودة وإما ألا تكون موجودة. فالإدارة تزعم أنها استندت في قرارها إلى واقعة ما، ثم يأتي دور القاضي في التحقق من صحة هذا الزعم، أي بالتحقق من وجود أو عدم وجود الواقعة. وعلى ذلك فإن الإدارة لم يكن لها أي تقديرات خاصة أعملتها بالنسبة لهذه الواقعة، ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للقاضي . فكلاهما أي الإدارة والقاضي يقف على نفس المستوى إزاء الواقعة بحيث يمكن القول أنه في رقابته يحل تحققه الخاص من وجود الواقعة محل تحقق رجل الإدارة⁽¹⁾.

(1) Rousseau (D.), le contrôle de l'opportunité de l'action administrative, thèse poitier, 1979, p.397, wei-teng-lin, le pouvoir

ولكن يلاحظ مع ذلك أن الوقائع التي تتذرع بها الإدارة كأساس لقراراتها، لا تكون دائما على هذا النحو من البساطة، أي مجردة من أية أوصاف، بل غالبا ما تكون مقرونة بوصف أو أكثر من الأوصاف التي تخلعها عليها الإدارة، بحيث يمكن القول أن وجود الواقعة يكون مقترنا دائما بالتكييف القانوني لها. ومن ثم فإن الرقابة على الوجود المادي لها يتناول أيضا وفي ذات الوقت الوصف القانوني لها. فلكي يقرر القاضي أن اضطرابا معينا يشكل خطرا على النظام العام ، فإن عليه في نفس الوقت الذي يبحث فيه قيام الوقائع من الناحية المادية، أن يقدر قيمتها وصفتها القانونية^(١). أي أن البحث في الوجود المادي للواقعة يتناول أيضا البحث في التقديرات الشخصية لرجل الإدارة إزاء تلك الواقعة ، وهو ما يعني أن القاضي يراقب دون شك ملاءمة العمل الإداري ، أو كما يقول Letourneur أن الرقابة على الوجود المادي للوقائع تسمح للقاضي بالرقابة على تقدير الإدارة وتفسيرها للوقائع التي استندت إليها في قرارها، ومن ثم تسمح له بإحلال تقديره الشخصي sa proper appréciation وتفسيره الخاص sa propre interpretation محل تقدير وتفسير رجل الإدارة لهذه الوقائع، أي أن الرقابة هنا هي رقابة على الملاءمة^(٢).

ومع ذلك نجد أن الفقه يقدم من جديد تبريرات لهذا القضاء، تجعله لا يخرج عن دائرة المشروعية، إذ يقول - كما سنرى فيما بعد - أنه لئن كان القاضي الإداري يحل في هذه الحالة تقديره الخاص محل تقدير رجل الإدارة

discrétionnaire de l'administration et le contrôle juridictionnel en droit français, thèse Lyon, 1944, p. 62.

(١) الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص ٣٣٩.

(2) L'appréciation des nouveaux éléments subjectifs dans le recours pour excès de pouvoir, E.D.C.E., 1953, p.70.

فإنه لا يفعل ذلك إلا في ضوء تفسيره لإرادة المشرع وقصده، ومن ثم فهو يظل دائماً في إطار رقابته على المشروعية.^(١)

وهكذا كلما تقدم مجلس الدولة خطوة تلو الخطوة إلى الأمام في سبيل الحد من سلطة الإدارة التقديرية، نجد أن الفقه يسارع من جانبه ويجتهد بتقديم التبريرات والأسانيد لتلك الخطوات دون أن يستطيع - كما يذهب البعض بحق - حصرها أو تأصيلها على أسس ثابتة. ودليل ذلك أنه ما أن يتوصل ذلك الفقه إلى ما يبدو في نظره نهاية المطاف بالنسبة لتأصيله النظري والقانوني لاتجاهات القضاء السائدة في وقت من الأوقات حتى يفاجأ بالقضاء وقد إستل نفسه من ذلك الإطار النظري إلى مواقف جديدة واتجاهات جديدة لم يكن يتوقعها الفقه أو لم تخطر له على بال، فلا يجد مفراً من أن يتابع هذا القضاء الجديد ويظهر له القبول ثم يقعد لتبريره وتأصيله.^(٢)

وعلى أية حال لا يسعنا أمام الحلول القضائية التي يقدمها مجلس الدولة الفرنسي، في إطار رقابته على أعمال الإدارة، إلا أن نقول أن هذا المجلس - حامي الحقوق والحريات - إنما يحاول دائماً الحد من سلطات الإدارة التقديرية بما يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة وحماية هذه الحقوق وتلك الحريات. ومن ثم فإن رقابته على الوجود المادي للوقائع - حتى وإن كانت تلك الوقائع مجردة الأوصاف أو أنها بسيطة وليست مركبة - إنما يعد في نظرنا خطوة هامة بدأ بها مجلس الدولة ليحقق سياسته القضائية الرامية إلى وضع القيود على سلطات الإدارة لكي لا تتحول هذه السلطات إلى نوع

(١) الدكتور/ مصطفى حسن، السلطة التقديرية، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٧.

(٢) الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص ٣١٥؛ الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ١٣٨، هامش رقم (١).

من الجور أو العسف.

وهنا لنا أن نتساءل عن موقف كل من القضاء والفقهاء المصريين إزاء تلك المسألة وهو ما نبينه فيما يلي.

المطلب الثاني

أساس الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها في مصر

لقد بينا فيما سبق أن القضاء الإداري المصري قد انتهج ما انتهى إليه القضاء الإداري الفرنسي في خصوص الرقابة على الحالات التي تنتزع فيها الإدارة بوقائع معينة، وهي الحالات التي يسكت فيها القانون من تحديد تلك الوقائع، ولذا فهو مستقر على إلغاء القرارات المستندة إلى مثل هذه الوقائع كلما تبين له عدم صحتها أو تبين له وجه الخطأ فيها. وقد سلك قضاؤنا المصري هذا المسلك، تماماً كما هو الحال في فرنسا، على الرغم من عدم وجود نص قانوني يسمح له بإجراء تلك الرقابة. فعلى أي أساس إذن باشر مجلس الدولة المصري هذه الرقابة؟

لقد اجابت محكمة القضاء الإداري على هذا التساؤل باللجوء إلى فكرة السبب القانوني، ومؤداها أن الإدارة يجب عليها، إذا أرادت أن تتخذ قراراً، أن تلتزم دائماً بضرورة الاستناد إلى سبب يحمل قرارها، أو كما تقول: "أنه من المفروض في كل قرار إداري حتى ولو صدر خلواً من ذكر أسبابه، أن يكون مستنداً في الواقع إلى دواع قامت لدى الإدارة حين أصدرته، وإلا كان القرار باطلاً لفقدانه ركناً أساسياً هو سبب وجوده ومبرر إصداره"^(١).

إن فكرة السبب القانوني هذه هي ذات الفكرة التي لجأ إليها القضاء

(١) الحكم الصادر بتاريخ ١٩/٢/١٩٥٢، ق ١٧٦، س ٤، المجموعة، ص ٦٨٣.

الإداري الفرنسي في بداية عهده كما رأينا. ولكن يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد تولى عنها نهائيا فيما بعد، تاركا أمر بيان أساس الرقابة القضائية في الحالات التي نحن بصددنا للفقهاء، وهذا ما يتلاءم - كما ذكرنا - مع سياسته القضائية في الإيجاز وعدم الدخول في متاهات النظريات والمبادئ العامة.

أما قضاؤنا المصري فعلى العكس من ذلك، حيث لم يبق على فكرة السبب في أحكامه فقط، بل وعمل أيضا على تأصيلها ووضع الضوابط اللازمة لها، الدرجة أنه صاغ حول فكرة السبب نظرية عامة مبينا فيها تعريف هذا السبب وبيان الشروط الواجب توافرها فيه بوصفه ركنا من أركان القرار الإداري، كما بين حدود رقابه في هذا الصدد. ومن الأحكام التي تتضمن كافة تلك العناصر، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ٢٩ أبريل عام ١٩٥٣ حيث تقول فيه: أن القرار الإداري "ينبغي أن يكون له سبب، بأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو الإدارة إلى التدخل، وإلا فقد علة وجوده ومبرر إصغاره، وفقد بالتالي الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه.. ويجب أن يكون هذا السبب حقيقيا لا وهميا ولا صوريا، وصحيا مستخلصا استخلاصا سائغا من أصول ثابتة تتجه، وقانونيا تتحقق فيه الشرائط والصفات الواجب توافرها فيه قانونا، والقرار فيما تقدم جمعية يخضع لرقابة المحكمة"^(١).

وقد رددت المحكمة الإدارية العليا من إنشائها بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ ذات المبادئ السابقة والتي استقرت عليها محكمة القضاء الإداري. ففي حكم لها بتاريخ ٨ ديسمبر سنة ١٩٥٦ تقول: "إن القرار الإداري سواء

(١) ق ١٢٠٦، س ٦، مجموعة السنة السابعة، ص ١٠٢٧.

كان لازماً تسببيه كإجراء شكلي، أو لم يكن هذه التسبب لازماً، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً، أي في الواقع والقانون، وذلك كركن من ركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً، ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل، بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار، ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار^(١).

وهكذا يمكن القول أن القضاء الإداري المصري ممثلاً في كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، اتجه لى يبرر رقابته على القرارات الصادرة من الإدارة بمقتضى ما تتمتع به من سلطة تقديرية، إلى افتراض أن لهذه القرارات سبب دفع رجل الإدارة إلى التدخل، وأن هذا السبب يجب أن يكون حقيقياً وصحيحاً، وإلا كانت تلك القرارات باطلة جديرة بالإلغاء لفقدائها أحد أركانها وهو هنا ركن السبب.

ولما كان المشرع المصري على عكس المشرع الفرنسي^(٢)، قد حدد القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ الصادر بإنشاء مجلس الدولة (م ٤)، وفي القوانين اللاحقة عليه وآخرها القانون الحالي رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ (م ٨)، أوجه الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية، حيث نص على أنه يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن هو عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها وتأييلها، أو إساءة استعمال السلطة."

(١) ق ١٣٧٨، س ٢، مجموعة السنة الثانية، ص ١٦١.

(٢) لم يحدد المشرع الفرنسي أوجه الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، الأمر الذي أفاد هذا المجلس بأن جعله يكتفي بإلغاء القرار المطعون عليه عند عدم صحة الوقائع التي يستند إليها دون أن يعني في ذلك ببيان وجه الإلغاء.

لهذا فقد ثار التساؤل حول وجه الطعن الذي يمكن أن يستند إليه إلغاء القرارات الإدارية المعيبة في أسبابها، هل هو عدم الاختصاص ؟ أم مخالفة الشكل؟ أم مخالفة القانون؟ أم أخيرا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها؟

لم يكن مسلك محكمة القضاء الإداري في بداية الأمر واضحا في هذا الخصوص، إذ ترددت في أحكامها بين الاستناد إلى عيب مخالفة القانون في بعض الأحيان^(١)، وإلى عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها في أحيان أخرى^(٢)، وذلك إلى أن استقر بها المطاف في نهاية الأمر بإلحاق العيوب التي تصيب ماديات وقائع القرارات الإدارية بوجه الطعن بالإلغاء لمخالفة القانون^(٣).

وهذا ما أقرته وأكدته المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها وحتى اليوم لدرجة يمكن معها القول أن هذا المسلك أصبح يمثل قضاء مستقرا في هذا الخصوص^(٤).

(١) الحكم الصادر في ٣ مايو سنة ١٩٦٠، ق ٩٥٤، س ١٣، مجموعة السنة الرابعة عشرة، ص ٢٩٢، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمس سنوات من أول أكتوبر ١٩٦١ إلى آخر سبتمبر ١٩٦٦، ص ٢٥٠.

(٢) الحكم الصادر في ٢٢ يناير ١٩٥٧، ق ٦١٥، ص ٨، مجموعة السنة الحادية عشرة، ص ١٥٥.

(٣) حول الأحكام العديدة الصادرة في هذا الخصوص. انظر الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، رسالته السابقة، ص ١٢٠، هامش رقم (١).

(٤) تقول المحكمة الإدارية العليا في أحكامها، أن القرار التأديبي كأى قرار آخر يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقع جزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية يسوغ تدخلها... ومن حيث أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها مادي أو قانونا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادي لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون.

وإذا كان هذا هو ما استقر عليه قضاء الإلغاء في مصر، وما انتهى إليه معظم رجال الفقه المصري للقانون العام، سواء فيما يتعلق بأساس الرقابة على أسباب القرار الإداري أم فيما يتعلق بالتكييف القانوني للعيب الذي يصيب هذا الأساس، فلنا أن نتساءل عما إذا كان قد أصاب بذلك الحقيقة أو وجه الصواب من عدمه؟

أولاً: فيما يتعلق بأساس الرقابة على أسباب القرار الإداري:

إذا كان مجلس الدولة قد أكد في أحكامه المتواترة - كما رأينا - على أنه يجب أن يكون لكل قرار إداري سبب، وأن هذا السبب قد يكون واقعياً وقد يكون قانونياً، أو كما تقول المحكمة الإدارية العليا: "إن القرار الإداري... يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفاً قانونياً ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه"؛ إلا أنه حينما أعمل رقابته على هذا السبب لم يفرق بين هاتين الحالتين، إذ اعتبر أن الخطأ سواء كان في الواقع أم في القانون، لا يكون سوى خطأ قانونياً مؤداه تخلف الأساس القانوني للقرار. ومن أمثلة ذلك ما ذكرته محكمة القضاء الإداري من أنه إذا ظهر "أن الوقائع التي استند إليها القرار غير صحيحة (خطأ في الواقع) أو جاءت منطوية على مخالفة للقانون (خطأ في القانون).. كان القرار معيباً لفساد الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه...".

- إن مسلك مجلس الدولة على هذا النحو معيب لسببين:

١ - أن فكرة فساد أو تخلف الأساس القانوني للقرار، لا علاقة لها البتة بأسباب القرار الواقعية، إذ ترتبط هذه الفكرة فقط بأسبابه القانونية

باعتبارها واحدة من أشكال العيوب القانونية التي يمكن أن تصيب تلك الأسباب^(١).

وفي هذا الصدد يقول Drago إن فساد أو تخلف الأساس القانوني للقرار *efaut de bases légale* يعني "أن السبب القانوني *motif de droit* الذي قام عليه القرار المطعون فيه لا يمكن أن يوجد، أو لم يوجد بعد، أو لم يعد موجودا ، أو أنه غير قانوني^(٢).

٢ - أن مجلس الدولة لم يعمل النتائج المنطقية المترتبة على هذا المسلك والتي تتمثل في ضرورة فرض رقابة كاملة على كافة الأسباب التي ترتكز عليها الإدارة في قراراتها، سواء في ذلك الأسباب القانونية والتي تعد أساسا لحالات السلطة المقيدة، أم الأسباب الواقعية والتي تتجسد فيها حالات السلطة التقديرية ، وإنما فرق في رقبته بين هذين النوعين من الأسباب سواء فيما يتعلق بنطاق هذه الرقابة أم في مداها ، حيث تقول المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد: "أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ليست على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية، وإنما تتنوع بحسب المجال الذي تتصرف فيه، ومدى ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف ، وهي تضيق حقيقة في مجال السلطة التقديرية... حيث تتمثل في التحقق من أن التصرف محل الطعن يستند إلى سبب موجود ماديا وصحيح قانونا وأنه صدر مستهدفا الصالح العام"^(٣). بل وحتى في مجال السلطة التقديرية، فإن

(١) أن العيوب التي يمكن أن تصيب الأسباب القانونية للقرار الإداري هي أن يتخذ هذا القرار خارج مجال تطبيق القانون *en dehors du champs d'application de la loi* ، أو أن يتخلف الأساس القانوني له *défaut de base légale* ، أو أن يكون هناك خطأ في القانون *erreur de droit*.

(2) Le défaut de base légale dans le recours pour excès de pouvoir E.D.C.E., 1960, P. 27.

(٣) الحكم الصادر في ٢٥ مايو ١٩٦٨ ، ث ٣٧٤ ، ص ١٣ ، مجموعة السنة الثالثة عشرة ، ص ٩٨٢ .

رقابة المجلس ليست في الواقع سوى رقابة متدرجة ومتفاوتة كما تختلف من حالة إلى أخرى، ذلك أن المجلس وإن كان يراقب دائما - كما ذكرنا - الوجود المادي للأسباب الواقعية، وأنه غالبا ما يراقب تكييفها القانوني، إلا أنه نادرا ما يتجاوز ذلك إلى تقدير قيمة هذه الأسباب ومدى خطورتها.

ثانيا: أما فيما يتعلق بالتكييف القانوني للعيب واعتباره في أغلب الأحوال عيبا يدخل ضمن مفهوم عيب مخالفة القانون:

فإنه يمكن القول أن مثل هذا التكييف وإن كان مقبولا بالنسبة للعيوب التي تصيب الأسباب القانونية في حالات السلطة المقيدة للإدارة، إلا أنه لا يكون على العكس من ذلك، مقبولا بالنسبة للعيوب التي تصيب الأسباب الواقعية أو الوقائع المادية للقرار الإداري، إذ الفرض هنا أننا أمام سلطة تقديرية، تتمتع الإدارة بمقتضاها بحرية اختيار الوقائع أو الأسباب التي تقيم عليها قراراتها. فإذا لم تكن هذه الوقائع أو تلك الأسباب المدعاة أو التي تذرعت بها الإدارة موجودة أصلا أو كانت غير صحيحة في ذاتها، فإنه لا يمكن - والحال هكذا - القول بأن الإدارة قد خالفت بذلك قانونا ما، أو أن العيب الذي اصاب هذه الوقائع أو تلك الأسباب يندرج في عيب مخالفة القانون. إذ لو كان الأمر كذلك لتساءلنا على الفور أي قانون هذا الذي خالفته الإدارة، والفرض أنها أتت بتلك الوقائع من عندياتها وبمحض إرادتها بناء على ما تتمتع به من سلطة تقديرية كما ذكرنا.

وإذا كان أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوى ينتهي إلى مثل هذا الرأي حيث يذكر أن عيب السبب يلحق بوجه الطعن بالإلغاء لمخالفة القانون فقط في حالة ما إذا قيد القانون سلطة الإدارة وألغى كل سلطة تقديرية لها وذلك بتحديد الوقائع التي يجب أن تبني عليها قرارها، أما في حالة السلطة التقديرية وهي الحالة التي لا يلزم فيها القانون الإدارة بوقائع أو أسباب

معينة، تبنى عليها قرارها، فإن العيب الذي يصيب هذه الوقائع أو تلك الأسباب لا يلحق بهذا الوجه، إلا أن سيده أضاف قائلاً: أنه في هذه الحالة الأخيرة وهي حالة السلطة التقديرية للإدارة، فإن عيب السبب يلحق بوجه الطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة^(١)، وهو ذات الرأي الذي انتهت إليه الأستاذة الدكتورة سعاد الشرقاوي حينما قالت: أنه إذا ترك المشرع للإدارة سلطة اختيار السبب فلا تتيسر رقابة هذا السبب إلا عن طريق فكرة الباعث وإساءة استعمال السلطة^(٢).

إن تكيف العيب الذي يصيب الوقائع في حالات السلطة التقديرية بأنه وجه من أوجه الانحراف بالسلطة لا يستقيم في الواقع مع اعتبار السبب ركناً مستقلاً في القرار الإداري، وهو ما يقربه أنصار الرأي السابق أنفسهم. ذلك أن الانحراف بالسلطة إنما هو عيب يصيب ركن الغاية من القرار، وركن الغاية هذا لا يختلط بركن السبب بل يتميز ومنفصل عنه. ونتيجة لذلك فإن العيب الذي يصيب أيًا منهما يجب أيضاً أن تكون له استقلالية عن العيب الذي يصيب الركن الآخر. ولهذا لا يصح القول أن السبب والغرض، وهما ركنان مستقلان ومتميزان - كما ذكرنا - إنما يصيبها عيب واحد هو عيب الانحراف.

إضافة إلى ذلك فإن صعوبة إثبات عيب الانحراف بالسلطة، جعل مجلس الدولة ينظر إليه على أنه عيب احتياطي لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا تعذر إلغاء القرار على أساس عيب آخر. ومن ثم فإن القول بإلحاق عيب السبب في حالة السلطة التقديرية بوجه الطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة لا

(١) النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة السادسة، ١٩٩١، مرجع سبق ذكره، ص ٧٨ وما بعدها.

(٢) الانحراف في استعمال السلطة وعيب السبب، تعليق على بعض من أحكام المحكمة الإدارية العليا، مجلة العلوم الإدارية، السنة الحادي عشر، العدد الثالث، ديسمبر ١٩٦٩، ص ١٤٥.

يتفق وتلك السياسة القضائية، وذلك لما يؤدي إليه مثل هذا القول من استغراق هذا الوجه الأخير من أوجه الطعن - وهو وجه استثنائي ذكرنا - لمعظم حالات العيوب التي يمكن أن تصيب أسباب القرار، مع أن العكس هو الصحيح، أو يجب أن يكون هو الصحيح. الأمر الذي دفع أستاذنا الدكتور/ محمد حسنين عبد العال إلى القول بحق "أن التحليل السليم يؤدي، لا إلى إلحاق عيب السبب بوجه الطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة، وإنما على العكس من ذلك إلى ابتلاع عيب السبب لمعظم حالات عيب الانحراف.."^(١).

إننا نرى أن تخطيط واضطراب كثير من رجال الفقه، سواء فيما يتعلق بأساس الرقابة على الوقائع التي تتدفع بها الإدارة في حالات السلطة التقديرية أم فيما يتعلق بتكييف تلك الرقابة على النحو السابق، لا يرجع - كما يعتقد هذا الفقه - إلى خطأ في النص القانوني الخاص بإنشاء مجلس الدولة وما تلاه من نصوص، والتي حددت أوجه الطعن بالإلغاء بأربعة عيوب ليس من بينها عيب السبب، ذلك أن عدم النص على وجه مستقل للطعن بالإلغاء لعيب في السبب، خاصة في الفرض الذي نحن بصدده والمتعلق بحالات السلطة التقديرية للإدارة، إنما هو الذي يتفق والمنطق القانوني السليم، إذ المجلس لا يراقب هنا مدى التزام الإدارة بوقائع قانونية معينة (في حال انعدام تلك الوقائع أو عدم صحتها) حتى يقال أنها أي الإدارة قد خالفت القانون الذي حدد لها الوقائع المذكورة وقيدها بضرورة مراعاتها... وإنما يراقب فقط ملاءمة تلك الوقائع.

فالرقابة هنا إذن رقابة ملاءمة، وهي رقابة لا تتطلب لإعمالها ضرورة أن يكون منصوص عليها في صلب القانون. وهذا ما يرفضه

(١) رسالته السابق الإشارة إليها، ص ١٢٨.

الجانب الفقهي الذي نحن بصدده، إذ افترض هذا الجانب مبدئياً أن الرقابة القضائية لا يمكن أن تكون إلا رقابة على المشروعية ، ثم اتجه بعد ذلك صوب البحث عن تبرير أو تفسير لرقابة المجلس في كل حالة يخرج فيها عن إطار المشروعية إلى نطاق الملاءمة وذلك مما يحفظ للرقابة القضائية على أعمال الإدارة حدودها كرقابة مشروعية^(١)، ولهذا يرى ضرورة إلحاق العيب الذي يصيب الوقائع التي تدعيها الإدارة في حالة السلطة التقديرية بواحد من العيوب التي جعلها القانون سبباً للطعن بالإلغاء.

إن مثل هذا القانون كان من الممكن قبوله لو أن القاضي الإداري يقف برقبته عند حد التحقق من صحة أو وجود الوقائع التي تتذرع بها الإدارة، وإنما يلاحظ أنه يتجاوز ذلك بكثير، إذ يندر أن توجد الوقائع المدعاة - كما ذكرنا من قبل - مجردة عن مدى أهميتها أو تبريرها للقرار المتخذ على أساسها. ولهذا فإن رقابة القاضي الإداري تتناول في ذات الوقت كل من وجود هذه الوقائع وكذلك مدى تبريرها لهذا القرار. ومعنى ذلك أن القاضي يراقب ملاءمة القرار الإداري، تلك الملاءمة التي تكمن في وجود الواقعة أو الوقائع التي يتكون منها السبب، ووجودها بالدرجة التي تبرر هذا القرار، بحيث يؤدي في النهاية إلى تحقيق النتيجة التي يسعى إليها رجل الإدارة.

إن رقابة القاضي الإداري للوقائع التي تدعيها الإدارة كأساس لقراراتها إنما تشكل في رأينا - وكما ذكرنا من قبل - مرحلة هامة ، وخطوة أساسية في السياسة القضائية التي تهدف نحو الحد من سلطة الإدارة التقديرية، بما يحقق التوازن المنشود بين صالح الإدارة وبين ضرورة حماية حقوق الأفراد وحياتهم.

(١) الدكتور/ ثروت عبد العال، رسالته السابقة، ص ٥٨.

ولكن كيف يباشر القاضي الإداري رقابته على الوقائع المذكورة، والفرض أن الإدارة ليست ملزمة قانونا باختيار تلك الوقائع؟ حيث تترخص في هذا الخصوص بما تراه ملائما ومبررا للقرار المزمع اتخاذه، والفرض كذلك أنها ليست ملزمة بالإفصاح عن الوقائع أو الأسباب في صلب قراراتها؟

تجدر الإشارة بداءة إلى أن هناك فرقا بين أن يكون للقرار سبب يبرره وهذا أمر حتمي وإلا كان القرار فاقدا لركن من أركان انعقاده، ومن ثم كان منعدهما^(١)، وبين تسبیب القرار كإجراء شكلي وهو ما قد يستلزمه القانون صراحة، أو لم يستلزمه كما هو الشأن في الحالة التي نحن بصدد^(٢)، فإذا ما طرحنا جانبا مسألة السبب كركن في القرار الإداري وهو ما تناولناه بشكل تفصيلي فيما سبق، وكذلك مسألة الالتزام بالتسبیب، حيث تدخل في إطار السلطة المقيدة للإدارة وهي ما تخرج عن نطاق دراستنا، واتجهنا صوب القرارات التي لم يلزم المشرع فيها الإدارة بتسبیب قراراتها، أو بالإفصاح عن الوقائع التي استندت إليها في خصوصها، وذلك للوقوف على كيفية رقابة القاضي لتلك الوقائع، لوجدنا أن هناك مبدأ فقهي وقضائيا مستقرا

(١) يصف الأستاذ فالين الذين يتخذون قرارات دون استنادهم إلى سبب معين بأنهم مجانيين، أو بأنهم يتصرفون طبقا لأهوائهم ونزواتهم.

Que "ce ne sont que les Fous qui se décident sans motif, ou tout au moins les personnes libres d'agir à leur fantaisie, ou selon leur caprices".

"legale admissibilité aux emplois public", chr. Sous C.E. (Ass.), 28 mai 1954, Barel, R.D.P., 1954, P. 509.

(٢) وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا: "تجب التفرقة بين وجوب تسبیب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا وحقا كركن من أركان انعقاده، فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبیب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها وعندئذ يتعين عليها تسبیب قرارها وإلا كان معيبا بعيب شكلي. أما إذا لم يوجب القانون أكان لازما تسبیبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبیب لازما، يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا".

في هذا الشأن سواء في فرنسا أم في مصر، مؤداه أن القرار الإداري إذا لم يشتمل على ذكر أسبابه فإنه يفترض فيه أنه صدر وفقا للقانون، وأنه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة^(١).

فهناك إذن قرينة على صحة القرار الإداري الذي لم يشتمل أو يتضمن الوقائع التي بني عليها، إلا أن هذه القرينة ليست قرينة قاطعة وإنما هي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها. ومن ثم فإن كل قرار إداري لم تذكر أسبابه أو وقائعه يبقى صحيحا إلى أن يثبت المدعى عكس ذلك، بأن هذه الأسباب أو تلك الوقائع غير مشروعة ولا تمت للصالح العام بأية صلة^(٢). فإذا اعتبر المجلس والذي يملك سلطة كاملة في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعى، أن هذا الدليل كافيا على الأقل لرحضة قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات غير المسببة، انتقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة التي يتعين عليها والحال هكذا اثبات مشروعية قراراتها، بأن تقدم الدليل على وجود وصحة الأسباب أو الوقائع التي تذرعت بها في خصوص تلك القرارات، وهذا يتضح من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ ١٦ يونيو ١٩٥٣ والذي تقول فيه : "من المبادئ المقررة أن القرار الإداري إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب التي استند إليها، يفترض فيه أنه صدر وفقا للقانون وأنه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري لم تذكر أسبابه، تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن الأسباب التي بني عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة، ولا

(١) حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ١٦/٦/١٩٥٣، ق ٥٢٥، س ٦، مجموعة السنة السابعة، ص ١٥٨٢؛ وحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في ١٧/٣/١٩٥٦، ق ٣١، س ٢، مجموعة السنة الثانية، ص ٥٥٥.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، بتاريخ ٨/٣/١٩٥٣، ق ١٥٥، س ٥، مجموعة السنة السابعة، ص ٦٣٢.

تمت بصلة إلى المصلحة العامة. وللمحكمة كامل السلطان في تقدير الدليل الذي يقدمه المدعى في هذا الصدد، ولها إذا رأت وجها لذلك أن تطلب بيان المبررات التي بني عليها القرار المطعون فيه، وهذا عن طريق اعتبار الدليل الذي قدمه المدعى كافيا على الأقل لزحزحة قرينة المشروعية التي يتمتع بها القرار الإداري، فينتقل عبء الإثبات عن عاتق المدعى إلى عاتق الحكومة^(١).

وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بل وقدمت التبرير اللازم له حيث تقول: "لأنه وإن يكن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال، بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعات، مما يتعذر معه على الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا. ولذا فإن من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا أو نفيا متى طلب منها ذلك..^(٢)".

ومن الأحكام الهامة التي ارسى هذه المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، حكم Barel والذي نقل القاضي بموجبه عبء الإثبات إلى عاتق الإدارة وذلك بعد أن تقدم الطاعن بدليل يزحزح عنه هذا العبء. إذ بعد أن أبعد السيد باريل وزملاء له من كشوف الالتحاق بمدرسة الإدارة الوطنية، طعن على قرار الإدارة بأنه بني على وقائع غير صحيحة تتعلق بميوله السياسية. وقد اعتبر المجلس هذا الطعن جديا بما فيه الكفاية لزحزحة عبء

(١) الحكم الصادر في ١٦ يونية ١٩٥٣، ق ٥٢٥، س ٦، مجموعة السنة السابعة، ص ١٥٨٢.

(٢) الحكم الصادر في ١١ نوفمبر ١٩٦٧، ق ١٠٨، ص ١٢، مجموعة السنة الثالثة عشرة، ص ٤٥.

الإثبات عنه ونقله إلى الإدارة، إلا أن الإدارة احتجت بأن قرارها هذا إنما اتخذته بموجب ما تتمتع به من سلطة تقديرية، ومن ثم فهي ليست ملزمة قانوناً بتسببيه أو بالإفصاح عن الوقائع التي استندت إليها في خصوصه. وقد رد المجلس على هذا الادعاء قائلاً « ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الطاعنين يكونون محقين في ادعاءاتهم بأن القرارات المطعون فيها تستند إلى سبب مشوب بعيب الخطأ في تطبيق القانون وبالتالي يكونون محقين بطلب إلغائها بسبب تجاوز السلطة... »^(١).

هذا وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن الإدارة إذا لم تكن ملزمة بذكر أسباب قراراتها، إلا أنها إذا ذكرت تلك الأسباب، فإن القاضي الإداري له كامل السلطة في التصدي لحكم صحة الوجود المادي لهذه الأسباب. وهذا ما انتهت إليه محكمة القضاء الإداري حيث تقول في هذا الصدد: "جرى قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت الإدارة غير ملزمة بتبيان أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون ذلك عليها، إلا أنه إذا ما ذكرت أسباباً ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر أسباب فيها تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الإداري لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعية..."^(٢).

(1) C.E., 28 mai 1954, Barel, Rec. P. 38, R.D.P., 1954, P. 509, note Waline.

(٢) الحكم الصادر في ١٥/٦/١٩٤٨، ١٥٨، س٢، مجموعة السنة الثانية، ص ٨٠٥.

الفصل الثاني

رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها

بعد أن أرسى القضاء الإداري دعائم القيد الأول للحد من سلطة الإدارة التقديرية والمتمثل - كما ذكرنا - في رقابة الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها والتأكد من صحتها، بدأ يتجه صوب إشادة قيد آخر يضيق به الخناق على الإدارة في مجالات السلطة التقديرية. هذا القيد يكمن في مراجعة الإدارة لما تخلعه من تكييف أو وصف قانوني على الوقائع التي تتذرع بها، للتأكد مما إذا كان هذا التكييف أو ذلك الوصف متفقاً مع ما قصد إليه الشارع، أم أنه يجانب ذلك القصد، ومن ثم يصبح غير صالح كسبب أو كأساس لحمل القرار الإداري ، الأمر الذي يفرض على رجل الإدارة التزاماً بأن يتحقق قبل أن يتخذ قراراً ما ، وهو بصدد مباشرة سلطته التقديرية، من أن الوقائع التي يتذرع بها في هذا الشأن تتفق والوصف الذي عناه المشرع لها وإلا كانت غير صالحة لأن تكون أساساً لهذا القرار أو دافعاً مشروعاً لاتخاذها.

وهكذا يتضح لنا أن رقابة القاضي الإداري للتكييف القانوني للوقائع التي تتذرع بها الإدارة، أي في حالة السلطة التقديرية يمثل والحال هكذا قيدها حقيقياً على تلك السلطة، يضاف إلى قيد الرقابة على صحة وجود تلك الوقائع مادياً، حقيقة أن القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر قد وقف بالنسبة لبعض القرارات عند حد رقابة صحة وجود الوقائع مادياً فقط دون أن يتجاوز ذلك إلى رقابة التكييف أو الوصف القانوني لتلك الوقائع، تاركاً ذلك لحرية تقدير الإدارة، إلا أن هذا الاتجاه وإن كان قد ساد في ظل المرحلة التقليدية التي نحن بصدها، غير أن مجلس الدولة الفرنسي قد عدل

عنه في المرحلة الحالية وذلك باستحداث رقابة كل من الخطأ البين والموازنة بين المنافع والأضرار كما سنرى في الباب الثاني من هذه الدراسة.

وتفصيلاً لما أجملناه نتناول الموضوعات التالية:

- مدلول التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها وموقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر منه.
- استثناءات قاعدة رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها.

المبحث الأول

مدلول التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها وموقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر عنه

المطلب الأول

مدلول التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها

لكي مدلول التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، يجب أن نشير بداءة إلى أن المشرع حينما يمنح رجل الإدارة سلطات معينة فإنه لا يحدد له في كثير من الأحيان الوقائع التي يجب أن يستند إليها لمباشرة تلك السلطات بشكل واضح ودقيق، وإنما غالبا ما يكتفى بمجرد الإشارة إليها بشكل عام ومطلق، بل وقد لا يشير إليها مطلقا مكتفيا بتحديد الهدف أو الغاية التي يجب أن يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها من وراء مباشرة السلطات القانونية الممنوحة له. من هنا كان على هذا الأخير أن يتحقق وهو يباشر هذه السلطات، من أن الوقائع التي يستند إليها، هي تلك التي قصدها المشرع للقيام بتلك السلطات. فالرئيس الإداري وقد منح سلطة تأديب موظفيه مثلا، فإنه يجب عليه عند مباشرة هذه السلطة أن يتحقق من أن الأفعال التي اقترفها الموظف إنما هي تلك التي اعتبرها المشرع من قبيل الخطأ التأديبي، ومن ثم أساسا لتوقيع الجزاء التأديبي. وكذلك الحال حينما يمنح المشرع رجل الإدارة سلطات معينة بقصد تحقيق هدف معين، كالمحافظة مثلا على النظام العام، فإنه يجب عليه وهو يباشر هذه السلطات أن يستند إلى وقائع أو أسباب مبررة للإجراء الذي يتخذه من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو هنا المحافظة على النظام العام. وهكذا الأمر بالنسبة لكافة السلطات الممنوحة لرجل الإدارة والتي لم يحدد له المشرع في

خصوصها وقائع معينة أو كان تحديده لتلك الوقائع غير متسم بالدقة والشمول.

ولهذا فإنه لا يكفي لرجل الإدارة كي يباشر السلطات الممنوحة له، أن يتحقق من مجرد الوجود المادي للوقائع التي يستند إليها، وإنما يجب إضافة إلى ذلك أن يتحقق من أن هذه الوقائع موجودة بالوصف الذي عناه المشرع لها، أو الوصف الذي أشارت إليه النصوص القانونية، وهو ما يقال له التكييف القانوني للوقائع.

حقيقة أن النصوص القانونية تتسم - كما هو معروف - بالعمومية والتجريد، فهي لا تخص في الواقع حالات أو مراكز فردية معينة، إلا أنها تجمع مع ذلك بين طياتها الخصائص المميزة أو الرئيسية لكافة هذه الحالات أو تلك المراكز، لتصبح بذلك صالحة للتطبيق عليها جميعا. ولهذا فقد قيل إن عملية التكييف القانوني تعنى "إعطاء الواقعة الثابتة لدى رجل الإدارة، إسما أو عنوانا يحدد موضعها داخل نطاق قاعدة القانون التي يراد تطبيقها، أو يدخلها ضمن الطائفة القانونية من المراكز أو الحالات المشار إليها في قاعدة القانون"^(١) أو أنها تعنى إدراج حالة واقعية داخل إطار فكرة قانونية^(٢).

"...Faire rentrer une situation de Fait dans le cadre d'une notion juridique"

ولكن كيف يباشر رجل الإدارة عملية التكييف؟ هل يجريها بشكل آلي بحيث يقتصر عمله على مجرد المطابقة بين الوقائع التي يدعيها

(1) L'opération de qualification consiste à donner au Fait brut, constaté par l'agent, l'étiquette qui dine sa place dans le domaine du droit qui l'insère dans la catégorie juridique vise par la loi".

(2) Venezai (J.C.), Pouvoir discrétionnaire, L.G.D.K., Paros, 1959, P. 25.

لقراراته والنصوص القانونية المتعلقة بها؟ أم أنها تتطلب منه بذل المزيد من الجهد العقلي والتفكير الخلاق؟.

يصعب في الواقع من الأمر القول بأن رجل الإدارة وهو يباشر عملية التكييف القانوني، يقتصر على مجرد المطابقة المادية للوقائع بالنصوص القانونية، خاصة في الحالات التي تتضمن - كما يقول فينيزيا - أفكارا يصعب التوصل إلى تعريفها أو تحديدها عن طريق التحليل المنطقي وحده وإنما تتطلب لذلك إجراء فحص شامل لكافة ظروف تلك الحالات^(١)، كما هو الشأن في حالات السلطة التقديرية، تلك الحالات التي تتسم بعدم وجود أية شروط واقعية يفرض المشرع على جهة الإدارة ضرورة مراعاتها أو التقيد بها، بل على العكس من ذلك تكون للإدارة في خصوصها حرية كاملة إذ لها أن تؤسس قرارها على ما تشاء من وقائع، والقيد الوحيد الذي يرد على سلطتها في هذه الحالة هو أن تكون هذه الوقائع (بفرض صحتها) من طبيعة تسمح بتبرير القرار المطعون فيه^(٢).

لذلك فقد قيل بحق أن عملية التكييف القانوني تقتضي من القائم بها جهدا مزدوجا في خصوص عنصرَي القانون والواقع:

- ففيما يتعلق بعنصر القانون: فإنه ينبغي على من يقوم بالتكييف أن يسعى للتوصل إلى استخلاص قاعدة تطبيقية من نص القانون العام والمجرد يمكن تطبيقها على الحالة محل البحث، ويتم ذلك عن طريق تخصيص أو تجسيد Concrétisation هذا النص القانوني، أي إعطائه معنى أكثر تحديدا وأقل عمومية مما هو عليه.

(1) op. cit., P. 30.

(2) M.R. Baviile, concl. Sous C.E., 24 janv. 1975, société Rome Paris films, Rec., P. 57, R.D.P. 1975, P. 286.

وانظر كذلك الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ١٧٢.

- أما بالنسبة لعنصر الواقع: فإن على رجل الإدارة أن يقوم، وذلك على العكس من عمله في استخلاص القاعدة التطبيقية من النص القانوني، بتجريد Abstraction الواقعة المادية التي يستند إليها في قراره، عن طريق إسقاط كافة العناصر عديمة الجدوى بالنسبة لقاعدة القانون، مع إبراز الصفات التي تميزها من وجهة النظر القانونية، بحيث يعمل بذلك على رفعها من فرديتها إلى مستوى قريب من عمومية نص القانون.

وهكذا فإنه عن "طريق تخصيص القاعدة القانونية وتجريد الواقعة المادية يمكن التوصل إلى قيام التطابق بينهما"^(١).

يمكن القول إذن وباختصار شديد إن عملية التكييف القانوني الصحيحة تتم بتخصيص قاعدة القانون التي تحكم الحالة الواقعية الفردية، وفي ذات الوقت بتجريد هذه الحالة الواقعية من فرديتها والوصول بها إلى مستوى عمومية القاعدة القانونية، أي تتم بإمرار قاعدة القانون من العمومية إلى التخصيص، والحالة الواقعية من الفردية أو التخصيص إلى العمومية وذلك بما يحقق التطابق أو التوافق بينهما.

إن عملية التكييف القانوني على هذا النحو لم تعد قاصرة - كما كان الحال في الماضي - على رجل الإدارة وحده، يجريها بمقتضى ما يتمتع به من سلطة تقديرية ودون أدنى رقابة قضائية، حيث كان ينظر إليها على أنها عملية تفسير للواقع، وإنما أصبح القاضي الإداري أيضا يخضع تلك

(١) الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٥٣؛ الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، رسالته السابقة، ص ٣٥٦؛ الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ١٦٤. وانظر كذلك:

VEDEL, Essai sur la notion du cause en droit administratif, Français, op. cit., P. 19 etss.

العملية لرقابته للتحقق من سلامة الوصف القانوني الذي أنزلته الإدارة على الوقائع التي تدعيها لقراراتها، أو بمعنى آخر للتأكد من حقيقة مسلك رجل الإدارة في هذا الخصوص، وبما يدعيه من تبرير للوقائع التي يستند إليها فيما يتخذه من قرارات.

فمتى وكيف أخضع القاضي الإداري عملية التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة - في حالة السلطة التقديرية - لرقابته ؟.
هذا ما نبينه فيما يلي:

المطلب الثاني

موقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر من التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها

بعد أن استقر القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر على إرساء دعائم الرقابة على الوقائع أو الأسباب التي تدعيها الإدارة لقراراتها، سواء من حيث وجود تلك الوقائع، أم من حيث صحتها، بدأ يزحف بتلك الرقابة، مدفوعا بواجب الحرص على تحقيق أكبر قدر من الضمان والفاعلية للأفراد، حماية لحقوقهم وحرياتهم، بدأ يزحف نحو رقابة التكييف القانوني لما تباشره الإدارة من سلوكيات أو تصرفات بمقتضى ما تتمتع به من سلطة تقديرية أو رقابة الوصف الذي تخلعه الإدارة على الوقائع التي تدعيها أساسا لهذه السلوكيات أو تلك التصرفات، ليتحقق - كما ذكرنا - من مدى مطابقتها للقانون، أو لما قصده المشرع من وراء منحها هذه السلطة التقديرية. وهو بذلك يكون قد وضع قيودا يحد به من تلك السلطة، ويمنع الإدارة بالتالي من الاحتماء وراءها لتحقيق أغراض وأهداف غير مشروعة، أو غير تلك التي

قصدها المشرع، حتى ولو كانت في ذاتها مشروعة أو صحيحة، الأمر الذي يجنب الأفراد مساوئ الانحراف بالسلطة أو التعسف في استخدامها^(١).

وكان أول حكم يقرر فيه مجلس الدولة الفرنسي ذلك القيد هو الحكم الذي صدر في قضية Gomel الشهيرة والذي تشير إليه تقريبا كافة مؤلفات القضاء الإداري سواء في فرنسا أم في مصر. ولهذا سنكتفي هنا بعرض موجز لمعطياته وبما يخدم فقط أغراض البحث الذي نحن بصدد.

فقد تقدم المواطن Gomel إلى محافظ باريس يطلب منه ترخيصا بالبناء في موقع يطل على ميدان Beauveau ، إلا أن المحافظ رفض منحه هذا الترخيص، بحجة أن البناء المزمع إقامته من شأنه تشويه المنظر الأثرى للميدان المذكور، مستندا في ذلك لنص المادة رقم (١١٨) من القانون الصادر في ١٣ بوليه ١٩١١ والذي يعطى للمحافظ الحق في رفض التصريح بالبناء في الحالات التي يؤدي فيها البناء إلى تشويه جمال أحد المواقع أو المناظر الأثرية. وعلى أثر ذلك رفع المواطن المذكور دعوى أمام مجلس الدولة يطلب فيها إلغاء قرار المحافظ لتجاوز السلطة.

(١) وهذا النوع من الرقابة قد وجد مكانه في كافة الأنظمة القانونية تقريبا، فهو في النظام الإنجليزي بعد امتدادا لفكرة الحقائق القضائية، وهي نفسها فكرة الرقابة على مشروعية الأسباب في النظام الفرنسي والمصري. ولعل أشهر القضايا التي أبرزت فكرة الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في القضاء الإنجليزي قضية "هوايت وكلين" ضد وزير الصحة سنة ١٩٣٩، والمهم في هذا الحكم أن رقابة القضاء قد امتدت إلى تكييف الوقائع التي تعطى للسلطة الإدارية أهلية اتخاذ واعتماد القرار، وهذا ما عبر عنه الحكم من أن مسألة ما إذا كانت الأرض موضوع النزاع تكون أو لا تكون جزءا من بستان هي مسألة سابقة على ممارسة الإدارة بذلك - أي التكييف - يخضع لرقابة هذه المحكمة. المستشار الدكتور/ محمود سلامة جبر، الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء، دراسة مقارنة في النظامين الفرنسي والمصري، مجلة إدارة قضايا الدولة، العدد الرابع، السنة الثامنة والعشرون، أكتوبر - ديسمبر، ١٩٨٤، ص ١١٨، ص ١١٩.

وقد انتهز المجلس هذه الفرصة لكي يدفع برقابته على الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها خطوة إلى الأمام، ولهذا لم يكتف كالعادة من التحقق من وجود وصحة تلك الوقائع وإنما بحث في أمرين آخرين هامين:

أولاً: عما إذا كان الموقع المزمع إقامة البناء عليه يصح أن يوصف بأنه موقع أثرى أو جمالي.

ثانياً: إذا صح وصف الموقع بأنه أثرى ، فهل سيسبب البناء المزمع تشييده تشويهاً أو ضرراً بالمنظر الأثرى أو الجمالي.

وبعد أن تحقق المجلس من أن الميدان المذكور لا يعتبر بمثابة موقع أثرى، أو بمعنى آخر بعد أن تحقق من أن الوقائع التي تستند إليها الإدارة غير صحيحة من حيث تكييفها القانوني ، قضى بأن رفض الإدارة التصريح بالبناء للطاعن يعتبر تطبيقاً خاطئاً للمادة رقم (١١٨) من القانون المشار إليه آنفاً^(١).

ومنذ صدور حكم Gomel المشار إليه، ومجلس الدولة الفرنسي لم يتوان لحظة عن رقابة التكييف أو الوصف القانوني الذي تسبغه الإدارة على الوقائع التي تدعيها لقراراتها. بل وقد عمم المجلس هذا القضاء في معظم مجالات العمل الإداري:

- ففي مجال التأديب مثلاً أقر مجلس الدولة لنفسه بحق رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة وتستند إليها فيما توقعه من

(1) "cons. que la place Beauveau ne saurait être regardée son ensemble comme formant une perspective monumentale, qu'ainsi, en refusant par la décision attaquée au requérant l'autorisation de construire, le préfet de la seine a fait une fausse application de l'art. 118 de la loi du 13 juill. 1911"

C.E., 4 Avr. 1914, Gomel, Rec., 488, S. 1917-3-25, note Hauriou.

جزاء تأديبية. بمعنى أن المجلس يبحث فيما إذا كانت هذه الوقائع تبرر قانونا الجزاءات الموقعة من عدمه^(١).

- وفي مجال القرارات الخاصة بالتطهير، يراقب المجلس كذلك التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للموظف والتي من أجلها وقع عليه جزاء التطهير، فقد قضى في إحدى الدعاوى بأن علاقة الموظف المستمرة مع ابن عمه الذي شغل مناصب وزارية في حكومة فيشي ليست لها صفة المخالفة مادام لم يثبت أن هذه العلاقة كانت لها طبيعة سياسية^(٢).

- وفي مجال حل المجالس البلدية، ورغم أن القانون يمنح لرئيس الجمهورية سلطة حل المجلس البلدي بناء على عرض وزير الداخلية، دون أن يحدد القانون الأسباب التي تبرر مثل هذا الحل، مما يعني أن أية وقائع ستكون من حيث المبدأ صالحة لتسبب هذا القرار، إلا أن مجلس الدولة قرر أن قرار الحل على هذا النحو لن يكون مشروعاً إلا إذا استند إلى وقائع مبررة، ولهذا فقد أعطى لنفسه الحق في رقابة تكييف مثل هذه الوقائع للوقوف على مدى تبريرها لقرارات حل المجالس البلدية، فقد قضى مثلاً بأن الخلافات بين العمدة وأغلبية أعضاء المجلس البلدي والتي بلغت في حدتها درجة تهدد الإدارة المحلية للإقليم، تعد واقعة مبررة لمرسوم الحل. أما إذا

(1) C.E, 14 janv, 1916, Camino, Ree. P 15 Précité,
كما أنه حكم في قضية أخرى، بأن واقعة إلقاء كلمة رثاء من قبل أحد القضاة، في جنازة شخص كان محبوساً لاتهامه في جريمة الاعتداء على السيادة الفرنسية (دون أن تكون هناك مناسبة خاصة تدعوه إلى ذلك العمل) بأن هذه الواقعة تعتبر خطأ تأديبياً، خرجت بالقاضي عن التحفظ الذي يجب أن يراعيه شاغلوا الوظائف القضائية.

C.E, 5 Fev. 1954, Addad Abdel Kader, R.D.P., 1954 P.564.
وأنظر أحكام أخرى عديدة من هذا القبيل في رسالة الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، السابق الإشارة إليها، ص ٣٦١، هامش رقم (٢).

(2) C.E, 23 juin 1954, Deat, R.D.P., 1954, P.1110.

كانت هذه الخلافات ناشئة عن عدم تنفيذ العمدة لقرارات المجلس، فإن هذا السبب يبزر فصل العمدة لا حل المجلس البلدي^(١).

- وفي مجال وسائل النشر من صحف ومجلات، وحيث تجيز نصوص القانون الصادر في ١٦ يوليو ١٩٤٩ لوزير الداخلية أن يمنع بيع هذه الجرائد والمجلات والإعلان عنها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة وذلك في حالة ثبوت إباحية هذه الجرائد والمجلات، فإن المجلس يقوم في كل حالة يمارس فيها الوزير هذه السلطة ببحث مدى توافر صفة الإباحية Caratère licencieux في هذه الجرائد^(٢).

وإذا كان هذا هو مسلك مجلس الدولة الفرنسي تجاه مسألة التكييف القانوني للوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتها الصادرة بناء على ما تتمتع به من سلطة تقديرية، فإن هذا المسلك يعد كذلك هو ذات المسلك الذي انتهجه مجلس الدولة المصري في هذا الشأن، حيث فرض رقابته منذ إنشائه عام ١٩٤٦ على التكييف القانوني للوقائع الثابتة لدى الإدارة والتي تستند إليها في قراراتها. وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا "... فإذا كانت الوقائع مع فرض ثبوتها لا تؤدي إلى هذا الوصف أو أن تكييفها على هذا النحو يعتبر تكييفاً غير سليم من الناحية القانونية، فإن السبب الصحيح لا يعتبر قائماً"^(٣).

(1) Jeze, motifs Justifiant la dissolution d'un conseil municipal, note R.D.P, 1939, P.341.

(٢) ومن تطبيقات هذا القضاء حكم Thibault في سنة ١٩٥٦، فقد حظر وزير الداخلية عرض وبيع إحدى المجلات بناء على النص المذكور في المتن. وقد قام المجلس بالتحقق من مدى انطباق وصف الإباحية على المواد التي تنشرها هذه المجلة، وخاصة في معالجتها لمسائل العلاقات الجنسية، وانتهى إلى إقرار مسلك الإدارة وذلك "بسبب إباحية المجلة في وصف العلاقات الجنسية الشاذة".

C.E.S Dec. 1956, thibault, D. 1957, P. 20 concl. Mosset..

وانظر كذلك الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، رسالته السابقة، ص ٦١ وما بعدها.
(٣) الحكم الصادر بتاريخ ١٩٧٦/٢/١، ق ٨٦٣، س ١٤، مجموعة السنة الحادية والعشرون، ص ٤٣.

وكما هو الحال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، فإن رقابة القضاء المصري لتكييف الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها لم تقتصر على مجال معين، وإنما تناولت معظم مجالات النشاط الإداري، ففي مجال التأديب مثلاً، يراقب القاضي الإداري المصري صحة تكييف الوقائع الثابت حدوثها من الموظف وما إذا كانت تعد مخالفة تأديبية تصلح للمؤاخذة من عدمه. فقد قضى بأن "قيام موظف بإحدى المحاكم بالغناء في فرقة من فرق العوالم لقاء أجر والذي اعتبرته الإدارة بمثابة سلوك يجسد جريمة تأديبية تستوجب فصله عن العمل، ليس فيه شبهة المساس بكرامة الوظيفة التي يشغلها ولا يحط من قدرها، وخلص إلى إلغاء قرار الفصل"^(١). كما باشر القضاء أيضاً رقابة التكييف في مجال الترخيص ببناء الكنائس، وفي مجال الترقيات، ومجال الإجراءات المتخذة من قبل السلطة القائمة على الأحكام العرفية... إلى غير ذلك من المجالات.

ولكن لنا أن نتساءل عن الكيفية التي يباشر بها القاضي الإداري رقابته على التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، إذ الفرض هنا أننا أمام حالات تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية، أي حالات تتمتع فيها الإدارة بحرية في تقدير الوقائع التي تستند إليها في قراراتها؟

ولمزيد من الإيضاح نذكر الحالات التي نص عليها القانون الفرنسي الصادر في ١٦ نوفمبر عام ١٩٤٠ والخاصة بالتصرفات العقارية، حيث أخضع هذا القانون جميع تلك التصرفات والتي تتم بين الأحياء، سواء تعلقت بحق الملكية أم بحق الانتفاع، أم بقسمتها، لتصريح من مدير المنطقة التي يقع فيها المال محل التصرف. فمدير المنطقة إذن يملك -

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ ٢٥ يولية ١٩٨٣، ق ٨٧٧، س ٢٨، مجموعة السنة الثامنة والعشرون، ص ٨٧٣.

والحال هكذا - سلطة تقديرية واسعة في منح أو رفض التصريح الخاص بالتصرفات العقارية ، وبناء على ذلك فقد رفضت الإدارة التصريح ببيع أراضي زراعية إلى أحد الأفراد بحجة أنه غير مزارع، كما رفضت بيع بيت صغير لأحد الأفراد بحجة أنه ليس من سكان الإقليم الذي يقع فيه البيت، وعندما طعن في هذه القرارات أمام مجلس الدولة قضى بإلغائها على أساس أن الوقائع التي تذرعت بها الإدارة لرفض الترخيص - وإن كانت موجودة وصحيحة ماديا - إلا أنها غير مبررة. أو بمعنى آخر هذه الوقائع الموجودة والصحيحة ماديا قد أصابها خطأ في التكييف^(١).

فعلى أي أساس إذن بني مجلس الدولة قضاءه بعدم صحة التكييف السابق؟ أو على أي أساس قرر أن كون المشتري من غير المزارعين في الحالة الأولى، أو من غير سكان الإقليم في الحالة الثانية، لا يعد واقعة مبررة لرفض التصريح بشراء أرض زراعية أو بيت صغير؟

سبق أن ذكرنا أن المشرع حينما يمنح رجل الإدارة سلطة ما، فإنما يمنحه إياها لتحقيق هدف أو غاية معينة، لتحقيق هذه الغاية إذن هو مناط منح السلطة. ومن ثم يجب على رجل الإدارة ألا يستخدم سلطته، أو بمعنى آخر ألا يستند بمقتضى هذه السلطة إلا إلى وقائع مادية من شأنها تحقيق الهدف أو الغاية التي قصدها المشرع. وعلى ذلك كلما أمكن الوقوف على هذا الهدف أو تلك الغاية، كلما أمكن تحديد الوقائع المبررة للتصرف، ومن ثم الحكم على ما استند إليه رجل الإدارة من وقائع تذرع بها لإصدار قراره.

وهذا هو ما انتهجه مجلس الدولة الفرنسي في خصوص المنازعات العقارية السابق الإشارة إليها، إذ استطاع بعد أن حدد الغرض الذي قصد

(1) C.E, 28 Juill. 1944 ,Rec. P. 219, concl. Léonard.

المشرع تحقيقه من إخضاع التصرف في الحقوق العقارية لترخيص من المدير (ذلك أن الواجب يحتم على القاضي الإداري دائماً أن يبحث عن الهدف أو الغرض الذي من أجله منح رجل الإدارة سلطة ما، حتى ولو أغفل المشرع بيان هذا الهدف أو ذلك الغرض) وهو منع المضاربة والاحتكار فيما يخص هذه الأموال، استطاع أن يحدد الوقائع المبررة لرفض الترخيص بالبيع سواء بالنسبة للأراضي الزراعية أو بالنسبة للبيت في المنازعتين السابقتين، إذ ينبغي أن تكون حالة من حالات المضاربة أو الاحتكار، وإلا كانت القرارات الصادرة على أساسها غير صحيحة، ومن ثم جديرة بالإلغاء. وهو ما انتهى إليه بالفعل كما ذكرنا، إذ لم ير في كون المشتري للأراضي الزراعية من غير المزارعين، أو كون المشتري للبيت من غير القاطنين في الإقليم، حالة تتحقق معها صفة المضاربة أو الاحتكار المبرر لرفض الترخيص بالبيع أو انتقال الملكية^(١).

وفي مصر فقد سلك القضاء الإداري ذات المسلك، إذ يلجأ عندما تعرض عليه إحدى المنازعات التي تتمتع الإدارة تجاهها بسلطة تقديرية، بالبحث عن الهدف الذي قصد إليه المشرع من منح الإدارة هذه السلطة. ومن هذا الهدف يستخلص الوقائع المبررة لمباشرة تلك السلطة. وذلك للوقوف على مدى صحة التكييف أو الوصف القانوني الذي أسبغته الإدارة على الوقائع التي تذرعت بها كأساس لقراراتها. ففيما يتعلق بقرارات فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، والتي تتمتع الإدارة في خصوصها بسلطة تقديرية واسعة، فإن القضاء الإداري لم يترك الإدارة حرة في اختيار ما تشاء

(1) Léonard, concl. précitées; Dubisson, la distinction entre la légitimité et l'opportunité dans la théorie du recours pour excès de Pouvoir, these, ,L.G.D.J., Paris, 1958, P.90.

من وقائع تؤسس عليها تلك القرارات، وإنما حدد بداءة الغرض أو الهدف الذي قصد إليه المشرع من منح الإدارة هذه السلطة ألا وهو حسن إدارة وسير المرافق العامة وذلك بإبعاد الموظفين غير الصالحين أو الذين يقفون عقبة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ومن ثم فإن الوقائع المبررة للفصل هنا تكمن في عدم صلاحية الموظف للاستمرار في خدمة المرفق الذي يعمل فيه. وعلى ذلك فكلما استند قرار الفصل الصادر من الإدارة على واقعة من هذا النوع كلما كان قرارا سليما، أما إذا استند إلى وقائع لا علاقة لها بصلاحية الموظف كان القرار باطلا.

ولهذا فقد حكم مجلس لدولة ببطلان قرار الفصل المؤسس على "قرب بلوغ الموظف سن التقاعد"^(١)، أو على أساس "اعتقاله"^(٢)، باعتبار أن مثل هذه الوقائع - حتى وإن كانت موجودة وصحيحة ماديا - لا شأن لها بصلاحية أو عدم صلاحية الموظف لمباشرة مهام وظيفته ومن ثم فإنها تكون غير مبررة، وذلك على عكس ما إذا كان قرار الفصل مؤسسا على الحالة الصحية للموظف، أو على عدم كفايته المهنية، إذ يعتبر في مثل هذه الحالات كما تقول محكمة القضاء الإداري، قرارا صحيحا لاستناده إلى وقائع مبررة"^(٣).

وهكذا يمكن القول ان تحديد الغرض هو نقطة البداية بالنسبة لعمل القاضي الإداري في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة

(١) محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر بتاريخ ١٣ فبراير ١٩٥٢، ق ٦٤٢، س ٤، ص ٤٥٥.

(٢) محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر بتاريخ ١٩ يولية ١٩٥٢، ث ٩٤٩، س ٥، ص ١٢٣٦.

(٣) محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر بتاريخ ٢٥ يولية ١٤٧، مجموعة عمر، ص ٤٢٧. ولمزيد من هذه الأحكام انظر رسالة الدكتور/ السيد محمد إبراهيم، السابق الإشارة إليها، ص ٣٤٢ وما بعدها.

كأساس لقراراتها. إذ كلما أمكن للقاضي - كما ذكرنا - أن يحدد هذا الغرض بدقة ، كلما أمكنه أن يحدد الوقائع التي تبرر إصدار القرار، ومن ثم الحكم على مدى صحة الوقائع المدعاة من قبل الإدارة.

ولكن يلاحظ من ناحية أخرى، أن الأغراض أو الأهداف التي قصد إليها المشرع من منح الإدارة سلطة تقديرية في خصوص مسائل معينة، لا تبدو دائماً بهذا الوضوح وذلك التحديد، إذ قد يصعب في كثير من الأحيان تحديدها بدقة، أو الوقوف على كنهها بشكل كاف، وذلك إما لأنها تتجسد في مجرد أفكار عامة تتسم بالمرونة أو سعة المدلول مثل فكرة المصلحة العامة - المنفعة العامة - النظام العام... الخ، وإما لأنها محاطة بكثير من الغموض والإبهام، مثل فكرة الموظف الأكثر كفاءة، أو فكرة حماية الإنتاج القومي، أو فكرة المحافظة على الميزان التجاري... وغير ذلك. الأمر الذي يترتب عليه بطبيعة الحال صعوبة الوقوف على الوقائع المبررة لها، أو صعوبة التحديد المسبق من قبل القاضي لمثل تلك الوقائع.

ولهذا يلاحظ أن مجلس الدولة يقتصر هنا على مجرد الوقوف على معرفة الغرض بشكل عام أو الجوانب المتعددة لهذا الغرض، دون أن يجهد نفسه في تحديد الوقائع المبررة، ثم يتجه بعد ذلك بالبحث فيما ادعته الإدارة ذاتها من وقائع أو أسباب، ليقف على ما إذا كانت هذه الوقائع أو الأسباب من طبيعة مبررة للقرار المتخذ ، أو بمعنى آخر من طبيعة تؤدي بهذا القرار إلى تحقيق أي جانب من جوانب الغرض الغير محدد بشكل دقيق أو بشكل كاف.

فالترخيص مثلاً بتصدير السلع والخامات إلى الخارج هو أمر تترخص فيه الإدارة بسلطة تقديرية. ولا شك أن هذه السلطة قد شرعت

لتحقيق عديد من الأغراض، منها حماية الإنتاج القومي ، والمحافظة على الميزان التجاري، ورعاية الاقتصاد القومي بصفة عامة. وإزاء مرونة هذه الأغراض وعدم دقتها، فإن القاضي لا يستطيع أن يحدد مقدما الأسباب التي تبرر عدم الترخيص بتصدير السلع إلى الخارج، ولذلك فإنه يقف عند السبب الذي تذكره الإدارة، فإذا كان مبررا ومن شأنه أن يؤدي بالقرار إلى تحقيق أي جانب من جوانب هذه الأغراض العديدة ، كان القرار مشروعاً وإلا بطل للانحراف"^(١).

وعلى ذلك فإنه إذا كانت الإدارة قد رفضت الترخيص بتصدير الحديد الخردة نظراً لحاجة المصانع الحربية والمصاهر المعدنية المحلية إلى هذه المادة الأولية التي لا يغني عنها أي معدن آخر، فإن هذا السبب يكون مبرراً لأنه يدفع القرار إلى تحقيق جانب من جوانب الغرض المشروع وهو حماية الإنتاج القومي"^(٢).

وهكذا يجهد القاضي الإداري ذاته دائماً للبحث عن مخرج للوصول إلى رقابة التكييف أو الوصف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقرارتها، وذلك أياً كان مدى الدقة والوضوح في تحديد الغرض أو الهدف الذي قصد المشرع تحقيقه من وراء منح الإدارة سلطة تقديرية في مباشرة كثير من المسائل الإدارية، باعتبار أن هذه الرقابة تشكل - كما ذكرنا - قيداً للحد من تلك السلطة ، ومن ثم وسيلة لمنع استغلالها فيما من شأنه الإضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم.

(١) الدكتور/ السيد محمد إبراهيم، الرقابة على الوقائع، مرجع سبق ذكره، ص ٣٥٣.

(٢) حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في ١٧/١١/١٩٥٤، ق ١٨، س ٧، مجموعة السنة التاسعة، ص ٣٣.

ومع ذلك يلاحظ أن هناك حالات يرفض القضاء الإداري في خصوصها إجراء تلك الرقابة، أي أنه يرفض بسط رقابته على التكليف الذي خلعه الإدارة على الوقائع التي استندت إليها في قراراتها المتعلقة بها، تاركا لها في هذا الشأن سلطة واسعة. فما هي تلك الحالات؟ وما هي المبررات أو الأسباب التي دفعت بالقضاء إلى انتهاج مثل هذا الموقف؟ هذا ما نبينه فيما يلي.

المبحث الثاني

استثناءات قاعدة رقابة التكييف القانوني للوقائع

التي تدعيها الإدارة لقراراتها

ذكرنا أن القضاء الإداري وقف برقابته في بعض الحالات عند مجرد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، دون أن يتجاوز ذلك إلى رقابة التكييف أو الوصف القانوني الذي خلعته على تلك الوقائع، الأمر الذي أثار حفيظة الفقه الإداري ودفعه نحو البحث عن أسباب هذا المسلك، وكذلك عن معيار لتمييز تلك الحالات، خاصة أن مجلس الدولة ذاته سواء في فرنسا أم في مصر لم يبين أو يذكر لا هذه الأسباب ولا ذلك المعيار، مكتفيا في هذا الصدد بالقول بأن التكييف القانوني في مثل هذه الحالات إنما يدخل في إطار التقدير الحر أو المطلق للإدارة، أو أن سلطة الإدارة في هذا الخصوص سلطة مطلقة من كل قيد، أو أن التقدير هنا من إطلاقات الإدارة بحيث لا يحد منه سوى قيد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها... الخ من تلك العبارات.

بل ومما زاد من صعوبة مهمة الفقه في هذا الشأن أن القاضي الإداري كان يباشر رقابته في التكييف على حالات أخرى مشابهة تماما لتلك التي يمتنع في خصوصها عن إجراء تلك الرقابة.

ولهذا يحسن بنا قبل أن نبين المحاولات الفقهية التي قيل بها في هذا الخصوص، أن نعرض بشكل موجز لبعض من الحالات التي امتنع فيها مجلس الدولة سواء في فرنسا أم في مصر عن رقابة التكييف أو الوصف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها

المطلب الأول

الحالات التي امتنع فيها القضاء الإداري عن إجراء رقابة التكييف القانوني للوقائع

يصعب في الواقع الإحاطة بكافة الحالات التي أخرجها مجلس الدولة الفرنسي والمصري من نطاق رقابة التكييف القانوني للوقائع، ليس فقط لتعددتها وكثرتها وإنما أيضا لانتمائها إلى مجالات متنوعة من العمل الإداري، ومع ذلك نستطيع القول إن معظم تلك الحالات تتدرج أساسا في إطار الضبط العام المتعلق بالأجانب، أو الضبط الخاص المتعلق بتراخيص حمل السلاح، والمحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة، كما تتدرج أيضا في إطار الوظيفة العامة وكذلك في إطار المسائل الفنية والعلمية... وهذا ما نبينه بإيجاز فيما يلي:

أولا: القرارات المتعلقة بالضبط الإداري:

وهنا نجد أكثر الحالات التي قرر فيها مجلس الدولة الفرنسي عدم رقابة تكييف الوقائع، تاركا للإدارة في هذا الخصوص قدرا واسعا من حرية التصرف. ومن التطبيقات الدالة على ذلك:

١ - في خصوص دخول الأجانب إلى البلاد أو إقامتهم فيها:

فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي فحص مدى صحة ووصف الإدارة للوقائع التي تدعيها لمنع دخول أجنبي إلى الأراضي الفرنسية^(١)، أو الطرد من البلاد^(٢)، مقررًا لذلك أن القرارات الصادرة من وزير الداخلية في هذا

(1) C.E., 21 nov. 1952, Marcon, Rec., P 524.

(2) C.E., 12 Juin, 1953, Dame de savitch- Ritchkgorsky, Rec., P. 281.

الصدد بنيت على وقائع تتعلق بالأمن العام وأن هذه الوقائع لا يجوز مناقشتها أمام مجلس الدولة^(١).

"..... le ministre de l'interieur s'est livré à une appréciation de fait qui n'est pas susceptible d'être discuté devant le conseil d'Etat"

وهو ذات الاتجاه الذي سلكه مجلس الدولة المصري، فقد قضت محكمة القضاء الإداري بأن "قرار الإبعاد متى صدر ممن يملكه وبالطريق الذي رسمه القانون مستندا إلى أسباب صحيحة ثابتة في الأوراق تؤدي إليه دون أن تشوبه شائبة من سوء استعمال السلطة يكون قد صدر صحيحا... أما ما يثيره المدعى من جدل حول الأسباب الموضوعية التي إرتكن إليها القرار المطعون فيه، فهو من الأمور التي تستقل جهة الإدارة بتقديرها دون معقب عليها..."^(٢) وتبرر المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه بقولها: إن الأصل في إقامة الأجنبي بإقليم الدولة، وفي حق الدولة في إبعاده، هو أن الدولة إذا ما سمحت للأجنبي بالدخول إلى إقليمها فإنه لا يترتب على ذلك نشوء حق دائم لهذا الأجنبي في الاستقرار بإقليمها... وإن كان من حق الأجنبي أن يتمتع خلال المدة المصرح له بها بالإقامة والتنقل... غير أن هذا الحق يرد عليه قيد أساسي مستمد من حق الدولة في البقاء والمحافظة على كيانها، وهذا الحق الأصيل كاف وحده لتحويل الدولة سلطة إبعاد كل أجنبي يهدد سلامتها وذلك على الرغم من عدم انقضاء مدة الإقامة المصرح بها"^(٣).

(1) C.E., 25 oct. 1952, Eckert, Rec., P. 467.

(٢) الحكم الصادر في ١٩٥٥/١١/١، ق ١٣، س ٨، مجموعة السنة العاشرة، ص ١٦.

(٣) الحكم الصادر في ١٩٥٦/٨/٤، ق ١٦٧٩، س ٢، مجموعة أبو شادي، مبدأ ١٤٨، ص ١٥٠.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد أعمل هذا القضاء في حالات تتعلق بالمواطنين الفرنسيين أنفسهم ، فقد امتنع مثلا عن رقابة تكييف الوقائع التي استندت إليها الإدارة في رفض الترخيص بالسفر إلى خارج البلاد وذلك بالامتناع عن منحهم جوازات السفر اللازمة لذلك؛ على أساس أن السلطة المختصة هي التي تقدر فيما إذا كان سفر الفرنسي إلى الخارج يضر بالأمن العام من عدمه^(١).

ولم يشذ مجلس الدولة المصري عن هذا الوضع حيث قرر أن الترخيص أو عدم الترخيص بالسفر للمواطن المصري خارج البلاد هو من أولى الأمور المتروكة لتقدير جهات الإدارة حسبما تراه متققا مع الصالح العام^(٢). ففي حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بتاريخ ١٩٩٤/٣/٢٦ تقول هذه المحكمة: بأن الدولة بما لها من سيادة على رعاياها فإن لها الحق في مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الأخلاقية وذلك حتي تتمكن من اتخاذ الإجراءات التي تحول دون انحرافهم أو الاساءة إلي سمعة بلادهم وأنه إذا كانت حرية التنقل داخل البلاد وخارجها أمراً مسلماً به... فينبغي التسليم بأن هذه الحرية تجد حدها الطبيعي في ألا تؤدي تلك الممارسة إلى الإساءة إلى سمعة المجتمع المصري بأسر وإلا تعين تقييدها بما يتفق وصالح البلاد. فإذا ما رأت السلطة المختصة أنه لا سبيل إلي تقويم سلوك الطاعة والحد من تصرفاتها المشينة خارج البلاد إلا بمنعها من السفر إلي الخارج وكان تقديرها في هذا

(1) C.E., 16 mars 1949, Boimond, Rec., P. 128.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا في ٢٨ مايو ١٩٨٨، ق ٩٩٤، س ٣١، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثالث، السنة الثالثة والثلاثون، يولية - سبتمبر ١٩٨٩، ص ٢٠٧.

الشأن قائماً علي أسباب مبررة فلا تثريب عليها إن هي أصدرت قراراً بمنعها من السفر إلى الخارج^(١).

٢ - في خصوص الجمعيات الأجنبية التي تباشر نشاطها على أرض الوطن:

فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي الدعوى المقامة من إحدى الشركات الأجنبية العاملة في فرنسا ضد قرار وزير الداخلية بجل هذه الشركة، على أساس أن الوزير هو المختص بتقدير ما إذا كان نشاط الشركة الطاعنة من طبيعة تهدد الأمن القومي من عدمه، وأن هذا التقدير لا يناقش أمام مجلس الدولة...^(٢) وذات المسلك اتبعه أيضاً في قضية مرفوعة ضد قرار صادر من وزير الداخلية بمنع مجلة أجنبية من الدخول إلى الأراضي الفرنسية وكذلك بمنعها من التوزيع أو التداول في هذه الأراضي، مكتفياً في مثل هذه الحالات بترديد العبارة التالية^(٣):

"qu'ily' avait là une "appréciation de fait qui n'est pas de pou- nature à être discutée devant le juge de l'excès de vir."

٣ - في خصوص حمل الأسلحة والاتجار فيها:

وهنا يلاحظ أن القضاء الإداري المصري زاحز بالأحكام المتعلقة بهذا النوع من المنازعات والتي يرفض في خصوصها رقابة تكييف الوقائع التي استندت إليها الإدارة لرفض الترخيص أو لسحبه أو لإلغائه ، مكتفياً

(١) حكم غير منشور، جريدة الأهرام بتاريخ ١٩٩٤/٣/٢٨، السنة ١١٨، العدد ٣٩١٩٣، الطبعة الثالثة، ص ١٠.

(2) C.E., 22 Avr. 1955, Franco-russe Rousk-Dom, Rec., P. 202.

(3) C.E., 17 dec. 1958, Olympia press, rec., P. 968, D. 1959,3, P. 175, concl, G. Braibant.

فقط برقابة الحد الأدنى، وهو صحة الوجود المادي للوقائع التي ادعتها الإدارة في هذه الحالات^(١)، وهو ذات الأسلوب الذي اتبعه أيضا فيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بالمحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة^(٢).

ثانيا: القرارات المتعلقة بالوظيفة العامة:

إذا كانت القاعدة أن القضاء الإداري سواء في فرنسا أم في مصر يراقب القرارات الصادرة في ميدا الوظيفة العامة، رقابة عادية *contrôle normal*، بمعنى أنه لا يقتصر على التحقق من الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة في خصوصها، وإنما يراقب أيضا التكييف أو الوصف القانوني الذي أسبغته عليها، إلا أنه استثنى من تلك القاعدة عددا من المسائل لا يتناول في رقابته لها سوى الوجود المادي للوقائع المستندة إليها . ومن تلك المسائل نذكر:

١ - الالتحاق بالوظيفة العامة :

لا يتم الالتحاق بالوظيفة العامة في فرنسا - كقاعدة - إلا عن طريق الاشتراك في إحدى المسابقات التي تعقد لهذا الغرض. وهنا يجب أن يتوافر في المتقدم لدخول تلك المسابقات كافة الشروط القانونية اللازمة لذلك ولكن ليس معنى توافر هذه الشروط أن يصبح لزاما على الإدارة إدراج المتقدم في كشوف المتسابقين، إذ تتمتع الإدارة في هذا الخصوص بسلطة تقدير ما إذا كانت الضمانات اللازمة لحسن مباشرة الوظيفة المطلوبة متوافرة فيه من عدمه. فإذا ما أثير نزاع أمام مجلس الدولة في خصوص هذا

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا، في ١٩٦٣/١١/٩، ق ٥٢٤، ص ٧، مجموعة أبو شادي، ص ٤٤٤؛ وكذلك الحكم الصادر في ١٩٥٨/١٢/١٣، ق ٨٧٢، س ٤، مجموعة أبو شادي، ص ١١٥٠.

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا، في ١٩٦٢/١١/٢٤، ق ١٦٩٥، س ٦، مجموعة أبو شادي، ص ٤٦٣.

التقدير، يقتصر دور القاضي على مجرد رقابة صحة الوجود المادي للوقائع، دون أن يتجاوز ذلك إلى رقابة تكييفها القانوني، أي أنه يتقيد فقط بحدود الرقابة الدنيا^(١).

وفي مصر فإنه يلاحظ أن التعيين في الوظائف العامة وإن كان أمراً متروكاً لجهة الإدارة باعتبارها المسؤولة عن حسن سير المرافق العامة، إلا أنها مقيدة في ذات الوقت بضرورة التحقق من توافر كافة الشروط المطلوبة قانوناً في المتقدم للتعين. فإن قصرت من هذه الزاوية كان قرارها غير شرعي. أما فيما عدا ذلك، فإنها حرة في اختيار الشخص الأكثر ملاءمة لشغل الوظيفة المعلن عنها، حتى ولو كان أقل كفاءة من الآخرين، أو كان ترتيبه في المسابقة التي أجريت لهذا الغرض تالياً لمن اختير للتعين. إذ تقول المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص "أن درجة الكفاية هي إحدى النواحي التي تقدرها الإدارة عند التعين، ولكنها لا تستغرق كل ما تتطلبه فيمن يصلح للوظيفة العامة من شروط وأوضاع. فالإلى جانب هذه النتيجة تستلزم الإدارة نواح أخرى كالحالة الاجتماعية والجنس وظروف البيئة وأحكام العرف... التي لا معقب عليها فيها مادام تقديرها بريئاً من الانحراف في استعمال السلطة"^(٢).

وهكذا يقتصر دور القاضي هنا على رقابة الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها. أما تكييف هذه الوقائع فإنه يعد كما تقول ذات المحكمة من الأمور الداخلة في سلطة الإدارة التقديرية^(٣).

(1) C.E., 28 mai 1954, Barel, Précité.

(٢) الحكم الصادر في ١٩٦٣/٣/٣١، ق ٢٥٣٦، س ٦، مجموعة أبو شادي، ص ٦٨٦.

(٣) الحكم السابق الإشارة إليه والصادر بتاريخ ١٩٦٣/٣/٣١.

وذاات المسلك اتبعه القضاء أيضا في خصوص تقدير صلاحية الموظف أثناء فترة الاختبار، إذ اعتبر أن هذا التقدير من اختصاص السلطة التي تملك حق التعيين دون معقب عليها من جانبه، ما دام أن قرارها يجيء خاليا من إساءة استعمال السلطة^(١). وكذلك الشأن فيما يتعلق بقرارات النقل المكاني حيث تقول المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أن "قرارات نقل الموظفين والمستخدمين أو ندبهم ليست من القرارات التي تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مادامت لا تحمل في طياتها قرارات أخرى مقنعة يختص بها القضاء الإداري"^(٢).

٢ - كفاءة الموظفين:

والتي تتم عن طريق الإدارة وذلك فيما يعرف في فرنسا بالترقيم العددي Notation أو التقييم المهني appreciation Professionnelle، وفي مصر بتقارير كفاية الموظفين. ويلاحظ هنا أن الإدارة تتمتع في كلا البلدين بحرية تامة، على أساس أن ذلك من المسائل المرتبطة بكيفية مباشرة الموظف للعمل المكلف به، أو بمدى إتقانه لهذا العمل الذي يخضع لإشرافها ورقابتها. ولهذا يمتنع القضاء الإداري عن رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لما تتخذه من قرارات في هذا الشأن، مكتفيا بإجراء ما يعرف بالرقابة الدنيا والتي تتجسد في مجرد البحث عن الوجود المادي للوقائع، وعن الخطأ في القانون وكذلك عن الانحراف بالسلطة^(٣).

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ١٩٦٧/٢/٤، ق ٦٣٦، ق ١٨٧، س ١٠، مجموعة السنة الثانية عشرة، ص ٥٨٥.

(٢) الحكم الصادر في ١٩٥٨/٣/١، ق ٦٢١، س ٣، مجموعة أبو شادي، ص ٢٣٥٦.

(٣) "le juge des faits se limité à un contrôle minimum de la notation qui consiste à rechercher l'exactitude matérielle de faits, l'erreur de droit et le détournement de pouvoir".

وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا أنه متى استوفى التقرير السنوى السرى أوضاعه الشكلية ومر بمراحله القانونية، انحسرت عنه رقابة القضاء الإداري، ولا سبيل إلى مناقشته، إلا إذا قام الدليل الإيجابي على إساءة استعمال السلطة^(١).

٣ - معادلة الوظائف العامة:

معتبراً أن مسألة معادلة الوظائف l'équivalence d'emplois من المسائل التي تتعلق بالتنظيم الداخلي للإدارة l'organisation interne de l'administration، فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي رقابة التكيف القانوني للوائح التي تدعيها الإدارة للقرارات التي تتخذها في هذا الشأن، مكتفياً في ذلك بإجراء رقابة الحد الأدنى السابق الإشارة إليها^(٢). وقد طبق المجلس ذات المبدأ القضائي في خصوص الوقائع الخاصة بقرارات تقسيم العمل، أو حينما تثار مسائل فنية كالمخاطر أو الإرهاق الاستثنائي الذي تسببه بعض الوظائف^(٣).

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة المصرى وإن كان قد تبنى - كقاعدة عامة - مسلك نظيره الفرنسي بالنسبة لتلك المسائل إلا أنه أخرج من بينها مسألة معادلة الوظائف حيث أخضع تلك المسألة لرقابة التكيف القانوني للوائح التي تدعيها الإدارة في هذا الخصوص . ومن تطبيقات هذا

C.E., 22 Fev. 1963, Maurel, Rec., P. 119; 31 janv. 1975, Volff, Rec., P. 70, R.D.P. 1975, P. 811, note de J. Robert.

(١) الحكم الصادر في ١٩٧١/٦/٢٧، ق ١١٦٠، س ١٣، مجلة قضايا الحكومة، السنة ١٦، العدد الرابع، ص ١١٢٧.

(2) C.E, 23 mars 1947, Boulland, Rec. P. 286, 28 janv.1976, S. Bessiere, A.J.D.A, 1976, P. 577.

(3) C.E, 21 avr. 1950, Delle Rambaud, Rec. P. 786, 3 Fev. 1954, peticard, Rec. p. 818.

القضاء، أن القرار الجمهوري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٥٨ قد اشترط لضم مدة الخدمة التي قضيت في غير الحكومة والأشخاص الإدارية العامة، أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل بالحكومة، وناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك. وقد فرض المجلس رقابته للتحقق من سلامة تقدير الإدارة لتمائل الوظائف واتحادها في طبيعة العمل^(١).

ثالثا: القرارات المتعلقة بمسائل فنية وعلمية:

اعتقادا من القاضي الإداري بأن اختصاصه كرجل قانون يجب أن ينحصر فقط في بحث ودراسة المسائل القانونية أو تلك التي تثير منازعات قانونية، هذا الاعتقاد جعله يمتنع في الواقع من التصدي لبحث ودراسة المجالات ذات الطبيعة العلمية أو الفنية والتي تطلب للوقوف على حقيقتها - من وجهة نظره - ضرورة الاستعانة برأى المتخصصين من أهل الخبرة أو العلم في تلك المجالات، ولهذا فقد فضل أن يترك أمر تقديرها أو تكييفها للإدارة ذاتها، صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، خاصة أن لديها من الإمكانيات الفنية والعلمية ما يجعلها أقدر منه في ذلك. ومن هنا فقد امتنع عن رقابة تكييف كثير من القرارات المتعلقة ببعض الأدوية أو المستحضرات الطبية سواء من حيث قيمتها العلاجية^(٢)، أو من حيث مدى

(١) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٥ مارس ١٩٦٧، ق ٨٩١، س ٨، مجموعة السنة الثانية عشرة، ص ٧٣٨. وقد أشار إليه الدكتور / محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ١٦٥. مع ملاحظة أن المحكمة تصدت في حكم آخر لبيان المقصود بالشرط الوارد في القرار الجمهوري المشار إليه في المتن قائلة " أن المقصود بالاتفاق هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا للعمل الحالي، وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد، أو أن يكون العمال متطابقين تطابقا تاما بحيث يتجاذبان في جميع الوجوه، ق ١٥١٦، جلسة ١٩٦٥/١٢/٥، س ١١، ص ١٠٥.

(2) C.E. 22 Fev. 1952, société des laboratoires conan, S. 1952.3.85.

خطورتها على الأفراد^(١). ومن هذا القبيل أيضا امتناع المجلس عن رقابة التكييف القانوني لرفض لجنة القراء بمسرح الكوميدي فرانسيز، عرض مسرحية أدبية ، إذ يقول في هذه القضية^(٢):

"il n'appartient pas plus à la juridiction administrative de statuer sur les mérites littéraires ou éducatif d'une pièce de théâtre..."

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمسلك مجلس الدولة الفرنسي تجاه المسائل السابقة، فإن مجلس الدولة المصري، وإن كان قد انتهج هذا المسلك أيضا حيث يمتنع عن إجراء رقابة التكييف القانوني في المسائل العلمية والفنية، إلا أنه لم يلتزم هذا النهج على إطلاقه ، إذا اختط لذاته في هذا الصدد مسلكا آخر حيث قرر استثناء عدد من القرارات الصادرة في مسائل علمية وفنية واخضعها لرقابة التكييف القانوني وهي القرارات التي تمس الحريات الشخصية مستعينا في ذلك برأي أهل الخبرة أو العلم في مجال تلك القرارات، ومن ذلك مثلا حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في ٢٧ يونيو ١٩٥٩ الذي تقول فيه: "أنه إذا كانت سلطة مركز مراقبة الأمراض العقلية في تقدير ما إذا كان الشخص مصاب بمرض عقلي أم لا، هي في الأصل سلطة تقديرية، باعتبارها من الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعي، بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها إلا عند إساءة استعمال السلطة، إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالحرية الشخصية، فمن ثم يجوز للقضاء الإداري اتخاذ ما يلزم للتحقق من قيام هذه الحالة المرضية أو عدم قيامها، وله في هذا الصدد أن يندب من يراهم من أهل الخبرة إذا قام لديه من الشواهد ما يبرر ذلك"^(٣).

(1) C.E., 27 avr. 1951, société toin, Rec., P. 236.

(2) C.E., 19 Janv. 1954, Rec. P. 118.

(٣) ق ٧٦٤، س ٥، مجموعة السنة الرابعة، ص ١٦٢٣.

هذه أمثلة على الحالات التي امتنع فيها القضاء الإداري سواء في فرنسا أم في مصر، عن إجراء رقابة على التكييف القانوني الذي تسبغه الإدارة على الوقائع التي تدعيها للقرارات التي تتخذها في خصوصها.

وكما هو واضح، فإن مجلس الدولة في كل من البلدين لم يبين الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا المسلك، ولم يبين كذلك معيارا لتلك الحالات الأمر الذي أثار - كما ذكرنا - حفيظة الفقه الإداري ودفعه نحو البحث عن هذه الأسباب وذلك المعيار، وهو ما نبينه فيما يلي.

المطلب الثاني

موقف الفقه من استثناءات قاعدة رقابة التكييف القانوني على الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها

أمام تعدد وتنوع الحالات التي امتنع فيها القضاء عن إجراء رقابة على التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، لدرجة استحالة معها حصر هذه الحالات في إطار محدد أو على نحو دقيق كما بينا، فقد وجدت محاولات فقهية متعددة، لرد تلك الحالات إلى مجموعات معينة بحيث تتضمن كل مجموعة عددًا متشابهًا منها. وكانت أولى هذه المحاولات تلك التي قدمها مفوض الحكومة Mosset في مذكرته حول قضية Thibault عام ١٩٥٦، حيث أدرج كافة ما سبق ذكره من حالات، والتي امتنع القضاء الإداري في خصوصها عن إجراء رقابة التكييف القانوني في مجموعتين^(١):

المجموعة الأولى: وتتضمن المنازعات المتعلقة بمسائل حساسة أو دقيقة، منها قرارات الضبط المتعلقة بالأجانب، أو المتعلقة بالمطبوعات الأجنبية، أو بالترخيص لسفر المواطنين خارج الدولة... الخ، حيث يرى

(1) D. 1957, Jurisprudence, P. 21 etss.

أنه من الأفضل أن يترك للإدارة في خصوصها قدراً واسعاً من حرية التقدير أو حرية التصرف.

المجموعة الثانية: وتتضمن المنازعات المتعلقة بمسائل فنية أو علمية حيث يصعب على القاضي الإداري - يقول Mosset - الالمام بها أو إبداء الرأي في خصوصها مثل تكييف الوقائع المتعلقة بالمواد السامة، أو المتعلقة بالقيمة العلاجية لدواء معين، أو بالقيمة العلمية لمصنف أدبي، أو بتعادل وتمائل الوظائف...الخ.

أما المحاولة الثانية فقد قال بها كل من Auby et Drago ، ومن مقتضاها تقسيم الحالات التي أخرجها القضاء الإداري من نطاق رقابة التكييف إلى أربع مجموعات: الأولى تتعلق ببعض قرارات الضبط، والثانية تتعلق بالمسائل ذات الطابع العلمي أو الفني، والثالثة خاصة بالقرارات المتعلقة باعتبارات معينة تقدرها السلطة الإدارية مثل منح المساعدات الاجتماعية، وأخيراً مجموعة المسائل المتعلقة بالوظيفة العامة^(١).

وفي الجانب المصري نجد أن هناك محاولة لرد كافة استثناءات الرقابة على تكييف الوقائع إلى معيار عام تتمثل في مدى خضوع تلك الوقائع لتقدير شخصي من جانب الإدارة. إذ كلما كان هذا الخضوع متحققاً، كلما امتنع القاضي عن إجراء تلك الرقابة^(٢)، أو كما يقول جانب آخر من الفقه أن هذا المعيار يتمثل في مدى اقتراب رقابة التكييف القانوني من رقابة الملاءمة لأن ركن السبب - بصفة عامة - يقترب من ركن الغاية أو

(1) op. cit., P. 398; Odent, cours de contentieux administratif, 1980-1987, Paris, P. 1266.

(٢) الدكتور/ محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة (الرقابة القضائية)، دراسة مقارنة، بيروت، ١٩٧٠ ص ١١٨٥.

الغرض و رقابته هي الحد الخارجي للسلطة التقديرية. فالقاضي وهو يرفض أن يستبدل نفسه بالإدارة، يقتصر على التحقق مما إذا كانت الغاية من القرار المطعون فيه مطابقة للتنظيم القائم، وما إذا كانت الأسباب المثارة مادية صحيحة. ففي هذه الحالات يحرص القاضي على منح الإدارة سلطة واسعة في التقدير، ومن ثم فإنه يمتنع عن رقابة تكييفها للوقائع^(١).

وأخيرا نجد أن أستاذنا الدكتور يحيى الجمل بعد أن يعترف بصعوبة وضع معيار أو شبه معيار للحالات التي أخرجها مجلس الدولة من رقابته على التكييف القانوني، يرى أن امتناع القاضي في مثل تلك الحالات إنما مرجعه

واحد من الاعتبارين العمليين التاليين^(٢):

١ - تقديره أن المصلحة العليا للدولة تقتضى أن يترك للإدارة سلطة تقدير واسعة.

٢ - تقديره أن الإدارة بما لديها من أجهزة فنية وعلمية أقدر منه على إجراء التكييف السليم للوقائع.

والاعتبار الأول - يضيف سيادته - ينصرف إلى قرارات الضبط، والاعتبار الثاني ينصرف إلى المسائل العلمية والفنية وما يجرى مجراها.

واضح من العرض السابق مدى التخبط والحيرة التي انتابت الفقه الإداري تجاه مسلك القضاء في الامتناع عن رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة في الحالات السابق بيانها، إذ لا يمكن في الواقع التسليم

(١) الدكتور/ محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية، مرجع سبق ذكره ص ١٨٩؛ الدكتور/ ثروت عبد العال، الرقابة القضائية على ملاءمة.....، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٨.
(٢) رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع، مجلة القانون والاقتصاد، سبتمبر وديسمبر ١٩٧١، العددان الثالث والرابع، السنة الحادية والأربعون، ص ٤٠٥.

بما قيل في هذا الشأن. فالبعض مما قيل قاصر ولا يشتمل على كافة الحالات التي أخرجها المجلس من نطاق رقابته المذكورة ، والبعض الآخر لا يستند إلى تأصيل علمي أو منطقي سليم، حيث يلاحظ مثلاً أنه في الوقت الذي يمتنع فيه القضاء الإداري عن مباشرة رقابة التكيف لبعض الحالات، فإنه يعمل هذه الرقابة على حالات أخرى من نفس نوع الحالات الأولى وذلك كما هو الحال بالنسبة لإجراءات الضبط الإداري الخاصة بتنظيم إقامة ونشاط الأجانب في فرنسا والتي يمتنع في خصوصها عن رقابة التكيف القانوني، في الوقت الذي يجري فيه تلك الرقابة بالنسبة لذات الإجراءات إذا ما تعلقت بالمواطنين الفرنسيين. إضافة إلى ذلك فإن كافة المحاولات الفقهية السابقة، تتسم بالعمومية والتجريد، الأمر الذي يصعب أن توصف معها بأنها معايير أو ضوابط دقيقة الاستثناءات الواردة على قاعدة رقابة التكيف القانوني للوقائع. بل إن القول بأن هذه الاستثناءات إنما تدخل في إطار الملاءمة، أو السلطة التقديرية للإدارة وليس في نطاق المشروعية أو السلطة المفيدة إنما هو قول غير مقبول ذلك أن القاضي الإداري يعمل الآن رقابته - كما سنرى - في مجال الملاءمة تماماً كما يعمل في مجال المشروعية وإن اختلفت الأساليب والأنماط التي يستخدمها في هذا المجال أو ذاك.

ومن جانبنا نرى أن الأمر أبسط مما يعتقده البعض، وأنه لا يحتاج في الواقع إلى فلسفة أو جهد في التفكير والبحث، ذلك أن القاضي الإداري لم يصل في رقابته إلى ما هو عليه الآن طفرة واحدة وإنما تدرج في ذلك تباعاً، بادئاً - كما رأينا - برقابة الوجود المادي للوقائع، ثم بعد أن أثبت وجوده في هذا المجال وأصبح بالتالي يقف على أرض صلبة، انتقل إلى مرحلة تالية وهي الرقابة على التكيف القانوني للوقائع، بادئاً - كما ذكرنا - بحالات السلطة المقيدة، ثم بعد فترة زمنية ليست ببعيدة، بدأ يراقب حالات

السلطة التقديرية، بادئاً أيضاً بتلك الحالات التي لا تثير حساسية معينة تجاه الإدارة، أي الحالات التي لا ترى الإدارة في رقابة القاضي على التكيف الذي تجريه في خصوصها أي مساس بحريتها في التقدير، أو أنه يستوى لديها أن يعمل القاضي الإداري هذه الرقابة أو يمتنع عن إعمالها؛ ثم بعد أن اطمأن القاضي الإداري إلى هذا الوضع وأصبح موقفه مقبولا في مجال الرقابة على التكيف، بدأ يزحف مرة أخرى على الحالات التي تركها من قبل وذلك بإجراء رقابة في خصوصها وهذا ما سنبينه فيما بعد.

لا يمكن إذن أن نفسر استثناءات قاعدة الرقابة على التكيف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة كأساس لقراراتها، إلا على أساس النظر إلى تلك الاستثناءات على أنها تشكل مرحلة في عمر المسيرة القضائية لمجلس الدولة. تلك المرحلة التي لم يكن لهذا المجلس خلالها من رأي سوى أن يسلم بها، أو بمعنى آخر، أن يترك الحالات التي تتضمنها دون رقابة وإلا تعرض - من وجهة نظرنا - لنقد وتجريح قد تكون ذات آثار سلبية أو نتائج خطيرة على تلك المسيرة القضائية، خاصة وأننا تعلم جميعا مدي حساسية العلاقة التي كانت قائمة في البداية، بل وإلى أن أعمل المجلس رقابة التكيف التي نحن بصدددها، بين مجلس الدولة والإدارة. لذلك وبمجرد أن تجاوز تلك المرحلة وبدأ يشق طريقه الذي اختطه لنفسه منذ البداية وحتى يستكمل مسيرته، وبمعنى أدق رسالته القضائية التي تعد حصنا منيعا لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فقد أجرى رقابته على كافة الاستثناءات التي كان يمتنع فيما مضى، عن إجراء رقابة التكيف في خصوصها، وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل في الباب الثاني من هذه الدراسة.

المبحث الثالث **طبيعة التكيف القانوني للوقائع التي تدعمها** **الإدارة لقراراتها**

إن رقابة مجلس الدولة للتكيف الذي أسبغته الإدارة على الوقائع التي استندت إليها الإدارة في قراراتها الصادرة بمقتضى سلطتها التقديرية لا تتم في الواقع بشكل آلي، وإنما تتطوى - كما ذكرنا من قبل - على قدر من الاجتهاد الشخصي للقاضي الإداري، إذ يقوم عند مباشرته لتلك الرقابة بمراجعة وفحص الظروف التي تمت فيها الوقائع، فإذا تبين له خطأ في الوصف الذي خلعتة الإدارة على هذه الوقائع، كان له أن يحل تقديره الشخصي محل تقدير الإدارة.

ولهذا فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن رقابة التكيف القانوني للوقائع إنما تبدو في حقيقة الأمر بمثابة انطباع تأصيلي يتولد من فحص الظروف الواقعية التي لا يمكن فصله عنها، الأمر الذي يقتضي من القاضي الإداري أعمال تقديره الشخصي بالنسبة لهذه الظروف. ومن ثم يمكن القول أن التكيف يختلط والحال هكذا، بتقدير الوقائع^(١).

"....la qualification se confond, avec l'appréciation des faits"

وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتساءل عن طبيعة هذه العملية؟ أو بمعنى أدق لنا أن نتساءل عما إذا كانت رقابة التكيف القانوني للوقائع تدخل في إطار رقابة المشروعية أم في إطار رقابة الملاءمة؟

(1) Venezia, op. cit., P.30.

لقد اختلف الفقه - كعادته - حول تلك المسألة: حيث ذهب جانب منه إلى إدخالها في الإطار الأول، بينما اعتبرها الجانب الآخر رقابة ملاءمة. فما هي حجج كل من هذين الفريقين؟ وما هو مدى صحة تلك الحجج؟

هذا ما نبينه فيما يلي:

المطلب الأول **رقابة التكيف في حالة السلطة التقديرية للإدارة** **رقابة مشروعية**

لقد قال بهذا الرأي جانب كبير من الفقه الفرنسي وشايهم في ذلك جانب من الفقه المصري، حيث يرى هذا الجانب الفقهي، أن الدور الطبيعي للقاضي الإداري هو التحقق من مدى مشروعية القرارات التي تتخذها الإدارة. ولهذا فإن رقابة التكيف القانوني للوقائع التي تستند إليها تلك القرارات، تعد امتدادا طبيعيا لهذه الرقابة، ومن ثم فهي تدخل في إطار رقابة المشروعية.

ولتبرير هذا النظر يقول Waline بفكرة الطوائف القانونية^(١) "les categories juridiques"، ومؤدي هذه الفكرة - كما يقول الفقيه الكبير - أن المشرع عادة ما يكتفي أمام استحالة إحاطته بكافة الوقائع التي يمكن أن تستند إليها قرارات الإدارة، يكتفي بتحديد السمات العامة أو المشتركة لكل مجموعة منها، بحيث تندرج الوقائع التي تحمل ذات السمات في إطار طائفة قانونية واحدة. ومعنى ذلك أن الطائفة القانونية الواحدة تتضمن كافة

(1) Etendue et limites du contrôle du juge administratif sur les actes de l'administration, E.D.C.E., 1956,P.27 etss.

الوقائع التي تجمع فيما بينها السمات التي اعتبرها المشرع أساسا لترتيب أن آثار معينة.

ومثال ذلك طائفة الأخطاء التأديبية حيث تتضمن كافة التصرفات التي اعتبرها المشرع أساسا لتوقيع الجزاءات التأديبية. الأمر الذي يعني أن طائفة الأخطاء التأديبية قد أوجدها المشرع بالنص على جزاءات معينة يجوز للإدارة توقيعها على الموظف عند ارتكابه لواحد أو أكثر من تلك التصرفات. وبالمثل فإن المشرع قد أوجد طائفة الأشغال العامة المستعجلة travaux publics urgents بنصه على ترتيب إجراءات معينة للاستيلاء، تلجأ إليها الإدارة عند قيام ظروف معينة... وهكذا.

وإذا كانت نصوص القانون هي التي تحدد - على هذا النحو - مختلف الطوائف القانونية، فإن على القاضي لكي يتمكن من تطبيق هذه النصوص، أن يقوم بداءة بتحديد الطائفة التي يرى أن الوقائع التي استندت إليها الإدارة في قراراتها تندرج في إطارها. وقيام القاضي بتحديد الطائفة إنما يعني أنه يقوم بتفسير النص القانوني الذي يتضمن هذه الطائفة. وهذا - أي تفسير النص القانوني - هو مما يدخل في إطار الدور العادي للقاضي. ومن ثم فإن الرقابة التي يباشرها في هذه الحالة، وهي رقابة تكييف الوقائع، إنما تنصب على مشروعية القرارات الإدارية لا على ملاءمتها.

ولهذا - يضيف فالين لإيضاح فكرته - فإن دور القاضي في مجال حماية المواقع الأثرية لا يمتد إلى مدى فعالية إجراءات الإدارة لحماية تلك المواقع، وإنما يقتصر فقط على البحث في تحديد مدى توافر الطابع الأثري في هذا الموقع أو ذاك، حتى يكون جديرا بالحماية القانونية. وإذا كان هذا البحث من جانب القاضي يقتضى بالضرورة قدرا من الاجتهاد الشخصي لتوضيح وتحديد معالم طائفة المواقع الأثرية التي أوجدها المشرع، إلا أن

ذلك مما يدخل في إطار الدور العادي له في تفسير القانون؛ ومن ثم فإن رقابته هنا ليست رقابة ملاءمة وإنما رقابة مشروعية.

ويتفق الأستاذان Auby et Drago مع الأستاذ فالين في هذا الرأي، حيث يقرران أن الرقابة على التكييف القانوني للوقائع تتدرج في إطار الرقابة على المشروعية، حتى وإن كان القاضي الإداري بحل في خصوصها تقديره الشخصي محل تقدير الإدارة، ذلك أنه لا يفعل ذلك إلا في ضوء تفسيره لإرادة المشرع. ويضيف الأستاذان أن هذا الرأي يتأكد في الواقع من العبارات التي يستخدمها القاضي ذاته عند تصديده لرقابة التكييف، حيث يستخدم عادة عبارة التكييف القانوني للوقائع "la qualification juridique des faits"، أو أن الواقعة من طبيعة تبرر القرار "le fait de nature à justifier légalement la décision".^(١)

هذا ويؤيد جانب من الفقه المصري ذلك الرأي فقد قيل مثلاً أن عملية التكييف القانوني للوقائع عملية قانونية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى... ولا يغير من هذا الوصف أن تتدخل في تلك العملية اعتبارات شخصية أو ظروف خاصة بالحالة محل البحث والتي مردها غموض النص التشريعي وعدم تحديده، حيث ينشط عندئذ دور القاضي في بيان مقاصد المشرع وتفسير الغامض من نصه^(٢). بل ويقرر البعض الآخر تأكيداً لذلك أن عملية تكييف الوقائع ستبقى مهما تدخلت فيها اعتبارات شخصية أو

(1) Traité de contentieux administratif, L.G.D.J., 1975, 2ème vol. p.396 etss.

(٢) دكتور/ محمود سلامة جبر، الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء، مرجع سبق ذكره، ص ١٥٣.

ظروف محيطية من قبيل التكييف القانوني، وذلك لوجود أساس تشريعي لها حتى وإن كان غامضا أو عاما^(١).

وهكذا ينتهي هذا الجانب الفقهي سواء في فرنسا أم في مصر إلى اعتبار رقابة التكييف القانوني للوقائع في حالة السلطة التقديرية من قبيل الرقابة على المشروعية ولا تدخل بالتالي في إطار رقابة الملاءمة.

المطلب الثاني

رقابة التكييف في حالة السلطة التقديرية رقابة ملاءمة

على النقيض من الاتجاه السابق، يرى جانب آخر من الفقه الفرنسي والمصري، أن الرقابة القضائية للتكييف الذي تجريه الإدارة على الوقائع التي تستند إليها في قراراتها تدخل في إطار الرقابة على الملاءمة، وليس في إطار الرقابة على المشروعية. ففي تعليقه على حكم Gomel السابق الإشارة إليه يقول الفقيه Hauriou، أن القاضي الإداري بإصداره هذا الحكم قد خرج عن مهمته الأصلية في الرقابة على المشروعية *contrôle de légalité*، وأصبح يباشر إلى جوارها رقابة على الملاءمة بحيث أنه لم يعد من الممكن القول، بدءا من تاريخ هذا الحكم، أن القاضي الإداري لا زال مجرد قاضٍ للمشروعية فقط^(٢)، وهذا ما يؤكد الفقيه Jéze حينما يقول أن الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري في مجال تكييف الوقائع هي رقابة على الملاءمة^(٣).

(١) دكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص ١٦٨.

(2) note sous C.E., 14-4-1914, Précité, S. 1917.3.25.

(3) Exman du fait par le conseil d'Etat au contentieux, R.D.P., 1923, P. 45.

تلك الرقابة التي تتم - كما يقول الأستاذ Kahn - في كل مرة يكون فيها ثمة إحلال من جانب القاضي لتقديره الشخصي محل تقدير جهة الإدارة، ففي قضاء المناظر الأثرية مثلاً لا يخفى ما تنطوى عليه عملية التكيف في هذه الحالة من تقديرات شخصية تقوم بها جهة الإدارة لتحديد ما إذا كان هذا المنظر يعد أو لا يعد من قبيل المناظر الأثرية، ثم يأتي دور القاضي بعد ذلك في الرقابة على صحة هذا التقدير ، وذلك بالتحقق من صحة أو عدم صحة الوصف الذي انتهت إليه جهة الإدارة وفقاً لتقديره الخاص ودون الرجوع إلى أية قاعدة قانونية، ولذلك فإن الذي يفصل في توافر هذه الصفة هو خبير فني وليس رجل قانوني ، ومع ذلك فقد أقام مجلس الدولة الفرنسي من نفسه خبيراً فنياً وأخضع المسألة لحكمه^(١).

ولذلك فقد ذهب الفقيه Dubisson إلى القول بأن القاضي في رقابته للتكييف - في حالات معينة - يقوم بإحلال تقديره الشخصي للوقائع محل تقدير الإدارة، وبهذا الوصف يتجاوز عمله إطار فحص المشروعية ويندرج تحت رقابة الملاءمة^(٢).

وهذا هو ما انتهى إليه أيضاً جانب من الفقه المصري ، حيث ذهب البعض إلى القول بأن رقابة القاضي الإداري للتكييف القانوني للوقائع رقابة على سلطة الإدارة التقديرية لا على حدودها، باعتبار أن التكييف القانوني للوقائع يعد مجالا للملاءمة المتروكة للإدارة ، تتصرف فيه بحرية دون إلزام؛

(1) concl. sous C.E, 12 janv. 1968, Dame perrot , A.J.D.A,1968, P.180.

وانظر كذلك الدكتور/ السيد محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص ٢٦ وما بعدها؛ الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ١٧٠ وما بعدها.

(2) "La distinction entre la légalité et l'opportunité dans la théorie du recours pour excès de pouvoir", these, Paris, 1958, P. 45 etss.

وانظر أيضاً الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ٥٦.

ومن ثم فإن رقابة القاضي الإداري لهذا المجال، والذي يعمل فيه تقديره الذاتي تخرجه عن حدوده الطبيعية في الرقابة على القرارات الإدارية، وتدخله في مجال الرقابة على الملاءمة . فرقابة التكيف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها تعتبر إذن رقابة على الملاءمة^(١).

المطلب الثالث

رأينا في طبيعة رقابة التكيف في حالة السيطرة التقديرية

إذا كان لنا أن ندلي بدلونا في هذا الخصوص، فإنه يجب أن نشير بداءة إلى أن النصوص القانونية إذا ما حددت بشكل جلي وواضح الشروط أو الوقائع التي يجب على الإدارة أن تلتزم بها كأسس لقراراتها ؛ ففي هذه الحالة لا يمكن القول بأن تكيف تلك الوقائع مما يدخل في إطار الملاءمة المتروكة للإدارة، وإنما يدخل في إطار المشروعية ، ومن ثم يصبح اختصاصها في هذا المجال اختصاصا مقيدا، وبالتالي فإن دور القاضي الإداري هنا لا يعدو أن يكون تطبيقا للنصوص القانونية التي سبق وأن التزمت بها الإدارة.

وترتibia على ذلك فإن الرقابة القضائية لا تكون - والحال هكذا - إلا رقابة مشروعية ولا تدخل بحال من الأحوال في مجال الرقابة على الملاءمة. وأعتقد أن أنصار الاتجاه الأول يحصرون آراءهم التي قالوا بها في المجال الذي نحن بصده، في هذه الدائرة، أو في هذا الإطار. ذلك أن هذه الآراء جميعها إنما تصدر - كما ذهب البعض بحق - عن فكرة واحدة مؤداها "أن هناك شروطا واقعية معينة يلزم المشرع جهة الإدارة بمراعاتها

(١) المستشار/ سمير صادق، قرارات وأحكام التأديب في ميزان الإدارية العليا، ١٩٨٥، ص ١٦.

دون أن يقوم بتحديد مضمون هذه الشروط، وعندئذ قد تقوم الإدارة بتحديد مضمونها على نحو قد لا يقرها القاضي عليه، غير أن ذلك لا يعد خروجاً من القاضي - طبقاً لتلك الآراء - عن حدود مهمته في الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة، لأنه إذا كان يحل تقديره الخاص محل تقدير جهة الإدارة، إلا أنه يفعل ذلك في ضوء تفسيره لمقاصد المشرع الذي ألزم الإدارة بمراعاة هذه الشروط^(١).

هذه الدائرة أو ذلك الإطار، وإن كانت لا تثير في الواقع أية صعوبات إلا أنها لا تمثل من ناحية أخرى كل جوانب العمل الإداري، إذ من المعروف أن هناك جانباً آخر لذلك العمل وهو الجانب التقديري، أي الذي تصدر فيه القرارات عن سلطة تقديرية للإدارة. هذا الجانب الأخير هو الذي يثير الصعوبات والمشاكل في الواقع العملي نظراً لما تتمتع به الإدارة من حرية تامة في اعتبارها أو عدم اعتبارها وقائع معينة أساساً لقرارتها، ولهذا تبدو في خصوصه أهمية وفعالية الرقابة القضائية على ما تجربة الإدارة من تكيف لتلك الوقائع حيث يستطيع القاضي عن طريق هذه الرقابة أن يمنع التعسف أو التحكم الذي تتسم به بعض تصرفات الإدارة تجاه حقوق الأفراد وحياتهم، ومع ذلك يلاحظ أن هذا الجانب التقديري في العمل الإداري قد أهمله تماماً - كما هو واضح - أنصار الاتجاه الأول، ولذا يصعب تعميم وجهة نظرهم التي قالوا بها في هذا الصدد بحيث تشمل هذا الجانب التقديري. ففكرة الطوائف القانونية مثلاً والتي قال بها فالين لا تصلح لاعتبار الرقابة على التكيف في حالات السلطة التقديرية رقابة مشروعية. إذ يلاحظ في جميع المنازعات التي تصدى فيها القاضي لرقابة التكيف، عدم وجود أي شروط واقعية ألزم المشرع جهة الإدارة بمراعاتها في

(١) دكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ١٦٩.

إصدار قرارها، بحيث يمكن القول بأن كل هذه الشروط تدخل في إطار طائفة من الطوائف القانونية التي أوجدها المشرع . فالوقائع في تنوعها وتعددتها لا يمكن حصرها وتصنيفها في إطار طوائف محددة، بحيث يجمع بين الوقائع التي تنتمي إلى طائفة معينة سمات مشتركة، فالوقائع التي يمكن أن ينطبق عليها وصف الخطأ التأديبي مثلا لا يمكن أن تخضع لحصر ولا يجمع بينها أي روابط أو سمات مشتركة ، والأمر كذلك بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تشكل تهديدا للنظام العام.

بل لنا أن نتساءل مع البعض من رجال الفقه، عن جدوى وقيمة فكرة الطوائف القانونية - إذا سلمنا جدلا بوجودها - فالقاضي في إدراجها للواقعة التي يقوم عليها القرار، في إطار طائفة من هذه الطوائف يقوم بنفس العمل الذي كان ينبغي عليه القيام به عند بحثه عن القاعدة القانونية التي تحكم هذه الواقعة؛ إذن فلماذا لا يقوم القاضي بإدراجها مباشرة في إطار هذه القاعدة دون اللجوء من الأصل إلى فكرة الطوائف القانونية^(١).

أما عن قول البعض الآخر من أنصار هذا الاتجاه بأن الرقابة على التكييف تعد رقابة مشروعية على أساس الوصف الذي يلحق بكلمة التكييف وهو "القانونية" حيث يقال عادة "التكييف القانوني للوقائع" أو "أن الواقعة من طبيعة تبرر القرار المطعون فيه قانونا"، فإن مثل هذا القول فيه خلط في الواقع بين عملية تقدير الوقائع في ذاتها وبين التعرف على النصوص التي تحكم تلك الوقائع. فعملية تقدير الوقائع والتي تقوم بها الإدارة بحرية تامة، وذلك بطبيعة الحال في مجال السلطة التقديرية وهي التي تهمنا في هذا الخصوص، حيث لا تلتزم الإدارة بوقائع معينة لقراراتها، هي التي تنصب

(١) المرجع السابق، ص ١٧٦.

عليها الرقابة القضائية، إذ يراجع القاضي الإداري التقدير الذي تجرّيه الإدارة لتلك الوقائع بفرض وجودها وصحتها ليتحقق بداءة من سلامة هذا التقدير، فإن لم يكن كذلك أحلّ تقديره الذاتي محله، وذلك لكي يتمكن بعد ذلك من التوصل إلى تحديد القاعدة القانونية التي تحكم الوقائع محل التقدير. فالقول مثلاً بأن هذا المنظر أثري أو ليس كذلك هو الذي يدخل في مجال التقدير، وهو أيضاً الذي يتفاوت فيه الرأي بين الإدارة والقضاء. فإذا ما انتهينا من هذه العملية سواء بإضفاء صفة الأثرية على المنظر أو بعدم إضفاءها، يبدأ البحث بعد ذلك عن النص القانوني الواجب التطبيق. ومن ثم يجب أن نفصل بين كلمة "التكييف" حيث يقصد بها التقدير أو الوصف الذي ينتهي إليه القضاء للوقائع المدعاة من جانب الإدارة، وكلمة "القانوني" والتي يقصد بها معرفة النص القانوني الواجب التطبيق على ذلك التقدير.

خلاصة القول إذن أن الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في مجال السلطة التقديرية، إنما هي رقابة ملائمة، وتعد في نظرنا مرحلة متطورة من مراحل الرقابة التقليدية للقضاء الإداري، حيث كان القصد منها الحد من هذه السلطة التقديرية، وذلك بوضع قيد جديد على تصرفات وسلوكيات الإدارة، يتمثل في ضرورة مراعاتها عند اختيار الوقائع التي تدعيها لقراراتها أن تكون هذه الوقائع إضافة إلى وجودها وصحتها من الناحية المادية أن تكون مبررة في ذاتها، أو مؤدية بالقرار المستند عليها إلى تحقيق الغرض الذي قصد المشرع تحقيقه من وراء اتخاذ مثل هذا القرار.

الفصل الثالث

رقابة تقدير أهمية وتناسب الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها

إيماناً من مجلس الدولة الفرنسي بأن سياسته القضائية الرامية إلى الحد من سلطة الإدارة التقديرية، لا يجب أن تعرف معنى التوقف أو التراجع لما تمثله هذه السياسة من ضمانات فعالة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فقد بدأ ولم يكن قد مضى وقت طويل على مباشرته رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، بدأ يراجع الإدارة في تقديرها لمدى أهمية وخطورة كل من هذه الوقائع والإجراء المتخذ على أساسها للوقوف على مدى التناسب أو التلاؤم بينهما.

ولكن كعادته عندما يتخذ خطوة إلى الأمام، فقد كان حذراً عند إعمال هذا الوجه الجديد من أوجه الرقابة، ولذا فقد اقتصر بادئ ذي بدء على مباشرته في ميدان وحيد من ميادين النشاط الإداري وهو ميدان الضبط الإداري، على أساس أن هذا الميدان يمثل أهمية بالغة في نظر الرأي العام الفرنسي، لما للحقوق والحريات العامة من قدسية في المجتمع الفرنسي. فهي من الأمور الجديرة بالاحترام في هذا المجتمع والتي يتعين عدم المساس بها إلا إذا وجدت ضرورة من ضرورات المحافظة على النظام العام.

ولهذا فقد قدر أن رقابته هنا ستجد استحساناً وقبولاً من جانب هذا الرأي العام، ومن ثم دعماً وتأييداً لسياسته المستقبلية. تلك السياسة التي وصلت - كما سنرى فيما بعد - إلى درجة من التقدم والتطور في مجال الحد من السلطة التقديرية للإدارة، حتى ليخيل إلينا أن هذه السلطة قد زالت أو في طريقها إلى الزوال، وهنا يتساءل Laubadère عما إذا كان المجلس

يستطيع أن يتجه نحو المزيد من التدخل أو من اتباع طرق جديدة للرقابة دون مخاطرة الوقوع في رقابة الملاءمة بمعناها الدقيق^(١)!

إن رقابة أهمية وخطورة الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها يمثل في الواقع خطوة جريئة من قبل مجلس الدولة، إذ عن طريق تلك الرقابة لا يصبح القاضي الإداري مجرد قاض يختص بالفصل في المنازعات الإدارية على أساس من قواعد القانون السائدة كما هو الشأن بالنسبة للقضاء العادي، وإنما يصبح إضافة إلى ذلك قاض للملاءمة، حيث يباشر مهمته في هذه الحالة لا بالنظر إلى قواعد القانون فحسب وإنما كذلك إلى الظروف والمعطيات التي أحاطت بالقرار المتخذ ومدى تقدير الإدارة لهذه الظروف وتلك المعطيات، الأمر الذي دفع البعض إلى تشبيهه بالرئيس الإداري الأعلى أو باعتباره كذلك^(٢).

ومع ذلك يحاول جانب من الفقه الإداري تحجيم دور القاضي الإداري في هذا الصدد وحصره فقط في إطار المشروعية مستثنين في ذلك إلى حجج وتبريرات لا تقوى في الواقع على الصمود أمام النقد والتفنيد كما سنرى.

(1) Le pouvoir discrétionnaire et le juge administratif, institut Français des sciences administratives cahier No, 16- Éd. cujas, colloque du 5mars. 1977, Paris, 1978, PP.49-50.

وانظر كذلك الدكتور / أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة في الأحكام الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي (١٩٧٠ - ١٩٨٠)، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر ١٩٨٣، ص ١٦ وما بعدها.

(2) Waline (M.) Etendue et limites du contrôle du juge administratif sur les actes de l'administration, E.D.C.E, 1956, p.29.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة المصري لم يتخلف عن نظيره الفرنسي في هذا المجال فقد اعتنق التطور الذي أصابه هذا الأخير وبدأ في إعماله منذ نشأته عام ١٩٤٦ وذلك خروجاً على القاعدة السائدة آنذاك في المجالات الأخرى والتي تتمثل في أن دور القاضي في دعوى الإلغاء يجب أن يقتصر على فحص مشروعية القرار الإداري دون ملاءمته، أو بمعنى آخر وكما تقول المحكمة الإدارية العليا: "إذا كان القضاء الإداري أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانوني، إلا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة منها والتصرف الذي تتخذه حيالها"^(١).

وتفصيلاً لما أجملناه نتناول على التوالي الموضوعات الآتية:

- الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري أمام مجلس الدولة الفرنسي.
- الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري أمام مجلس الدولة المصري.
- موقف الفقه الإداري من الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري.

(١) الحكم الصادر في ٢٥ فبراير سنة ١٩٦٧، ق ١٣٦٤، س ١٠، مجموعة السنة الثانية عشرة، ص ٦٧٩.

المبحث الأول

الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري

أمام مجلس الدولة الفرنسي

رغم أن الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري تعد استثناء من القاعدة العامة التي يلتزم بها القضاء في رقابته لكافة الأنشطة الإدارية، إلا أنه أورد مع ذلك على هذا الاستثناء استثناء آخر حيث امتنع عن مباشرة تلك الرقابة في خصوص بعض مجالات الضبط الإداري ذاته.

فما هي إذن المجالات التي باشر فيها تلك الرقابة؟ وما هي المجالات التي امتنع عن إعمالها في خصوصها؟ وما هي الأسباب التي دفعته إلى مثل هذه التفرقة؟

هذا ما نبيئه تباعا فيما يلي:

المطلب الأول

مجالات الضبط الإداري التي باشر مجلس الدولة

في خصوصها رقابة الملاءمة

تشكل قرارات الضبط الإداري الصادرة عن السلطات المحلية، وهي ما يقال لها إجراءات الضبط المحلية *mesure de police municipale* المجال الأساسي الذي باشر فيه مجلس الدولة الفرنسي رقابته لمدى التناسب بين أهمية وخطورة الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، والإجراءات التي تتخذها بناء على تلك الوقائع، أو بمعنى آخر رقابة التناسب بين إجراء الضبط المحلي وبين الخطر الذي أُنْخِذَ من أجله.

ولعل بداية هذا القضاء كانت في عام ١٩٠٧ حينما أصدر المجلس حكمه في قضية شركة الفيلها رموني الموسيقية بإلغاء قرار عمدة Fumay

برفض الترخيص لهذه الشركة بممارسة مهنتها بحجة المحافظة على النظام العام، حيث وجد المجلس أن الأسباب أو الوقائع التي استند إليها القرار المذكور ليست من شأنها الإخلال بهذا النظام^(١).

وفي عام ١٩٠٩ أصدر المجلس حكما مشابها للحكم السابق، بل وأشار فيه صراحة أن مهمة القاضي يجب أن تمتد في مجال نزاعات الضبط الإداري إلى بحث ما إذا كانت الإدارة قد اتخذت طبقا لظروف الدعوى، فرارا لا تبرره ضرورات المحافظة على النظام العام^(٢).

"si l'administration n'a pas, dans l'espece pris un arrêté ne se justifiant pas par la nécessité de maintenir l'ordre public"

وفي الواقع من الأمر يعد حكم Benjamin الشهير^(٣) نقطة الانطلاق الحقيقية لتلك الرقابة، أو بمعنى آخر نقطة التحول الفعلي في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن، إذ من تاريخ هذا الحكم يمكن القول أن مجلس الدولة قد استقر على أن من حقه بحث وتقدير مدى خطورة الأفعال أو الوقائع التي تهدد النظام العام، ومدى تناسب الإجراء الذي اتخذته الإدارة مع تلك الخطورة . فقد صدر هذا الحكم بمناسبة قرار أصدره عمدة مدينة evers، يمنع بمقتضاه اجتماعا عاما بسبب تخوفه من الاضطرابات التي قد يتسبب فيها هذا الاجتماع، وما قد يؤدي إليه ذلك من إخلال بالأمن والنظام في المدينة.

ومع اعتراف المجلس في الحكم المذكور بإمكانية حدوث مثل هذه الاضطرابات إلا أنه ألغى مع ذلك قرار العمدة حيث تبين له بعد فحص

(1) Rec. P. 221.

(2) C.E., 19 Feb. 1909, Abbé Olivier, Rec., P. 186.

(3) C.E., 19 mai 1933, Rec., P. 541, concl, Michel, S. 1934.3.1.

ظروف الدعوى وإجراء التحقيقات اللازمة، أن الاضطرابات المحتملة والتي تذرع بها العمدة لا تبلغ في خطورتها الدرجة التي يعجز معها بما لديه من سلطات البوليس، من المحافظة على النظام العام إذا ما سمح بعقد الاجتماع^(١).

وهكذا أرسى مجلس الدولة بهذا الحكم المبادئ الأساسية للرقابة على ملاءمة قرارات الضبط المحلية:

- فمن ناحية يجب أن يكون النظام العام مهددا بشكل فعلي أو حقيقي.

une mēnace réelle de désordre.

-ومن ناحية أخرى يجب أن تكون إجراءات الضبط المتخذة ضرورية ومتناسبة ليس فقط مع درجة التهديد الذي يتعرض له النظام العام أو التي تحدثها الاضطرابات، وإنما أيضا مع قيمة الحرية موضوع النزاع^(٢).

que toute restriction de police soit strictement nécessaire eproportionnnlle à la gravité du désordre ainsi qu'à la valeur de la liberté en cause".

وترتبيا على ذلك يراقب القاضي الإداري في منازعات الضبط المحلى مدى التلاؤم أو التناسب بين كل من^(٣):

(1) "Cons, qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité des troubles) alléguées par le maire de nevers ne presentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pas pu, sans interdire la conférence maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre"

(2) VEDEL (G.), Droit administratif, P.U.F, 100 éd., 1988 P.1087.

(3)"une décision de police prise dans une matière donnée dépend, d'une part de l'importance du trouble à éviter, en liaison avec la gravité du

- خطورة الوقائع المدعاة من قبل الإدارة على الأمن أو النظام العام.

- الإجراءات البوليسية المتخذة لمواجهة تلك الوقائع.

- الاعتداء الذي تحدثه هذه الإجراءات على الحريات العامة وما قد يترتب على ذلك من ضرر يصيب المواطنين.

فالرقابة هنا إذن هي ما يقال لها الرقابة القصوى على الوقائع *Contrôle maximum des faits*، إذ يجرى القاضي من خلالها - كما سنرى فيما بعد - تقييما شخصيا لمدى ضرورة وتناسب الإجراءات البوليسية بمراعاة ظروف الواقع^(١).

.... en procédant à l'évaluation subjective de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure prise, eu égard aux circonstances de fait ..."

وتطبيقا لهذه الرقابة، فقد أصدر مجلس الدولة مجموعة من الأحكام الهامة التي تتضمن حماية قضائية فعالة لحقوق الأفراد وحرياتهم تجاه إجراءات الضبط الإداري، مقيدا بذلك سلطة الإدارة التقديرية في هذا

préjudice matériel que cause effectivement cette décision aux individus qu'elle atteint, d'autre part, elle varie selon la valeur juridique de la liberté atteinte. En d'autre termes, une mesure de police restrictive d'une liberté publique doit être proportionnée à l'intensité de la menace sur l'ordre public ainsi qu'à la valeur de la liberté en cause"

Stavroula (K) thèse, précitée, P.94 et 95. .

(1) Cherigny (B.), le juge administratif, gardien de la moralité des administrateurs, thèse, politiers, 968, T. 11, P. 226.

المجال، إذ إضافة إلى الأحكام الخاصة بحرية الاجتماعات العامة والسابق الإشارة إليها^(١)، فقد صدرت أحكام أخرى تتعلق مثلاً:

- **بحرية العبادة** **liberté de culte**: فقد ألغى مجلس الدولة قرار المحافظ بمنع تنظيم صلاة دينية في الهواء الطلق في ميدان Palais de chaillot.. لأن الإخلال المتوقع بالأمن والنظام العام بسبب هذا الاجتماع الديني لم يبلغ درجة من الخطورة تعجز السلطات المحلية عن مواجهتها بوسائل البوليس المناسبة^(٢).

- **بحرية الصناعة والتجارة** : فقد قضى المجلس بإلغاء قرار العمدة الذي يحدد فيه عدد مرات عرض فيلم سينمائي في منطقة معينة، حيث رأى أن الخطورة التي يشكلها هذا العرض والتي تتمثل كما يدعي العمدة فيما يتسبب فيه من ازدحام وإفساد للتعليم، يمكن تداركها بإلغاء العرض نهائياً أو بصورة مطلقة، لا بتقييد مواعيد ذلك العرض. فالتقييد إذن - وكما يقول مجلس الدولة - إجراء جسيم يمس حرية الصناعة والتجارة ولا يبرره السبب المشار إليه في القرار^(٣).

- **بحرية النشر والصحافة** **liberté de press**: فقد قرر المجلس أنه إذا كان مفروضاً على السلطات المزودة بسلطات البوليس اتخاذ إجراءات يتطلبها حفظ النظام، فإنه يجب عليها أن توفق بين ممارسة هذه السلطات واحترام حريات النشر، وأنه حتى مع التسليم بادعاء الإدارة بأن

(1) C.E, Benjamin, préc; C.E., 23 jan. 1953, sieur Maud, Rec. P.23; C.E., 19 Juin 1953, Houphoust Boiguy, Rec., P.298

(2) C.E, 5 mars 1948, Jeunesse independante chrétienne féminine, Rec. P.121.

وانظر أيضاً الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ٨٠.

(3) C., E. 14 mai 1954, sieur de pischhof, Rec. p. 269, R.D.P., 1954, P. 1105.

عرض الجريدة وتوزيعها في الطرق العامة يمثل - بسبب طبيعة الجريدة وطبيعة المقالات التي بها - خطرا على النظام العام، فإنه لا يتضح من ملف الدعوى أن هذا الحظر كان من شأنه أن يبرر قانونا ذلك القرار المانع من العرض و التوزيع على كل المنطقة ودون تحديد لوقت سريانه^(١).

وإذا كان مجلس الدولة قد باشر رسالته القيمة هذه في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية، فإنه تأكيدا لتلك الرسالة فقد باشر أيضا رقابته على قرارات الضبط الإداري الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية، تلك الظروف التي تجد فيها هيئات الضبط الإداري عادة سندا لتوسيع وتشديد إجراءاتها على حساب الحريات العامة. فقد قضى مثلا بإلغاء قرار عمدة مدينة Nante بالاستيلاء على شقة سكنية لإحدى الأرامل لاتخاذها مأوى لمنكوبي الحرب العالمية الثانية، مؤسسا حكمه على أن مشكلة إيجاد مأوى لهؤلاء المنكوبين ليست سببا كافيا لنزع ملكية تلك الشقة، حيث يمكن تدبير هذا المأوى بوسيلة أخرى غير الاستيلاء^(٢).

فمجلس الدولة يتطلب إذن من الإدارة حينما تلجأ إلى استخدام سلطاتها في الظروف الاستثنائية، أن يكون هذا الاستخدام بالقدر اللازم والضروري لمواجهة متطلبات تلك الظروف. بمعنى أنه يتطلب منها أن تراعي أن يكون هناك تناسبا بين الإجراء الذي تتخذه والحالة التي تعمل من أجل حمايتها أو تداركها، وإلا كان قرارها معيبا وجديرا بالإلغاء.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن مجلس الدولة لم يعمل رقابة التناسب المشار إليها إلا في خصوص قرارات الضبط الإداري،

(1) C.E. 23-11-1951 (SEC), nouvelle d'imprimerie et d'édition et de publicité, R.D.P., 1952, P.821.

(2) C.E, 29-11-1944, Dame Goguet, Rec. P126.

سواء الصادر منها في ظل الظروف العادية، أو في ظل الظروف الاستثنائية، إلا أنه لم يعمم مع ذلك تلك الرقابة على كافة قرارات الضبط الإداري، حيث أخرج منها عددا من القرارات، تاركا للإدارة في خصوصها حرية واسعة في التقدير.

فما هي تلك القرارات؟ وما هي مبررات هذا المسلك من جانب القضاء الإداري؟

هذا ما نبينه فيما يلي.

المطلب الثاني

مجالات الضبط الإداري التي امتنع مجلس الدولة في خصوصها عن رقابة الملاءمة وأسباب ذلك

رغم ما تحققه الرقابة القضائية على مدى التناسب أو التلاؤم بين الوقائع التي تدعيها الإدارة وبين الإجراءات البوليسية التي تتخذها لمواجهة تلك الوقائع من ضمانات هامة وأساسية لحماية حقوق الأفراد وحياتهم، إلا أن القضاء الإداري امتنع عن إعمال تلك الرقابة فيما تتخذه الإدارة من إجراءات بوليسية عليا، أو من قرارات ذات سمة سياسية، وكذلك في حالات الضبط الخاص المتعلقة بمسائل فنية، وهي كما هو واضح ذات الحالات التي امتنع فيها عن رقابة الإدارة فيما تجريه من تكييف للوقائع التي تدعيها في خصوصها.

فما هي الأسباب التي دعت إلى مثل هذا السبيل؟

هذا ما سنبيه بعد عرض سريع وموجز لعدد من تلك الحالات.

أولاً: مجالات الضبط الإداري التي امتنع القاضي الإداري في خصوصها عن رقابة الملاءمة:

١ - إجراءات البوليس العليا: *mesures de la haut police*

وهي الإجراءات التي تتعلق بأشخاص أو أنشطة معينة، مثل إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب، وإجراءات الضبط الخاصة بالحدود، وكذلك الإجراءات الخاصة بالمطبوعات والجمعيات الأجنبية وغيرها. فقد كانت تلك الإجراءات وحتى نهاية القرن الماضي معتبرة من أعمال الحكومة *actes du gouvènement*، ومن ثم لم تكن خاضعة لأيّة رقابة قضائية. بل وحينما خضعت لهذه الرقابة مع بداية القرن الحالي، فإنها لم تخضع إلا لبحث ما إذا كانت معيبة بخطأ في القانون أو في الوجود المادي للوقائع؛ فالقاضي الإداري كان يقف برقابته في واقع الأمر عند حد التحقق مما إذا كانت الأسباب أو الوقائع التي تدعيها الإدارة كأساس لتلك الإجراءات ليست أجنبية عن مجال تطبيق القانون. كما أن عبء الإثبات كان يقع دائماً على عاتق المدعى^(١).

إضافة إلى أن القاضي الإداري لم يكن بإمكانه أن يصدر قراراً بوقف أو تأخير تنفيذ العديد من بينها. ففيما يتعلق بالقرار الصادر بإبعاد أجنبي عن البلاد مثلاً، نجد أن مجلس الدولة قد اعتبره من القرارات ذات التأثير الهام على النظام والأمن والسكينة العامة، ومن ثم فقد قضى بأنه يمتنع على المحاكم الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذه^(٢). ولم يتغير هذا الوضع إلا بصدور

(1) C.E, 21 oct. 1949, *persager*, s. 1950. III, P.72; C.E.14 Mars. 1951, *Missir*, Rec. P.16.

(2) C.E, 26 nov.1954, *Van Peborgh*, A.J.D.A., 1954, le commentaire de Braibant (G.), P.489; VIGOR (P.) Du contrôle juridictionnel de l'expulsion des étrangers, R.D.P., 1954, P. 292.

حكم جمعية حماية حي Notre Dame عام ١٩٧٦ والذي تأكد بصدور حكم كوناتا في ذات العام، حيث أصبح وقف تنفيذ إجراء إبعاد الأجانب، وكذلك اجراءات الاستعجال القصوى رهنا بتقييم القاضي الإداري للحالة المعروضة عليه^(١).

وهكذا ظل القاضي الإداري يتمتع حتى وقت قريب نسبيا، ليس فقط عن رقابة تقييم ما إذا كان وجود الأجنبي أو ما يباشره من أنشطة على الإقليم الفرنسي يشكل تهديدا للنظام العام، وإنما أيضا عن رقابة وتقييم كافة إجراءات البوليس العليا، معتبرا أن مثل هذا التقييم ليس من طبيعته أن يناقش أمام قاضي تجاوز السلطة^(٢).

"... une appréciation de fait qui n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir"

٢ - إجراءات الضبط الخاص ذات الطبيعة الفنية:

mesures de police spéciale à caractère technique

كما ذكرنا من قبل، حينما يواجه القاضي الإداري بقرارات صادرة عن متخصصين، تتطلب لتقييمها خبرات فنية أو علمية دقيقة، فإنه يتمتع عن إجراء الرقابة العادية contrôle normal وهى رقابة التكييف القانوني

(1) "qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, dans chacun des cas qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution... et d'utiliser la procédure d'urgence absolue".

C.E, 18 Juin 1976, Moussa Konaté, A.J.D.A., 1976, P.582,

(2) C.E, 4 Juin 1954, Joudoux et Riaux , Rec. P.346; C.E 17 dec.1985, Olympia press, Rec. P.968, D.1959, 111, P.175, Concd, Braibant; C.E, 20 mars 1970, Ghomari, Tables décennales (1965-1974) P.1133.

للقوائم، ولذا فإنه من باب أولى يمتنع عن رقابة التناسب أو التلاؤم بين هذه القوائم ومضمون القرارات الصادرة على أساسها، مكتفيا في هذا الصدد برأي الخبراء المتخصصين في مجالات تلك القرارات، ومنهج القاضي الإداري على هذا النحو وإن كان يعد اعترافا منه باستحالة مباشرته لمثل هذا التقييم، إلا أنه منهج يعبر في ذات الوقت عن مدى الأمانة والصدق اللذين يتسم بهما في عمله، فهو يقتصر في رقابته في مثل هذه الحالات على التحقق من وجود وصحة القوائم ماديا دون الخوض في رقابة التكييف القانوني لهذه القوائم، أو رقابة الملاءمة لعدم امتلاكه للوسائل التي تسعفه في خصوصها، ولذا فقد امتنع - كما رأينا من قبل - عن أن يحل تقييمه محل تقييم لجنة فنية في خصوص الأضرار الناجمة عن بعض الأدوية أو العقاقير الطبية على الصحة العامة^(١) أو على درجة خطورة بعض المواد الداخلة في صناعة أدوية معينة^(٢)...وهكذا.

ثانيا: أسباب امتناع القاضي الإداري عن رقابة الملاءمة في بعض مجالات الضبط الإداري:

من الواضح أن المجالات التي يمتنع فيها القاضي الإداري عن أعمال رقابته، سواء العادية أم القصوى ، تتسم بخصائص معينة، فهي تتعلق إما بأجانب وهنا يجب أن تعلق المصلحة العليا للوطن أو الدولة Raison d'Etat على مصلحة هؤلاء الأجانب، أيا كانت الاعتبارات التي تحيط بهذه المصلحة الأخيرة، مما يعني أنه يجب أن تمنح الإدارة في هذا

(1) C.E., 27 fev. 1948, Sté des laboratoires du Bac, Rec. P. 100.

(2) C.E., 27 avr. 1951, St toni, Rec. P. 236.

الخصوص سلطة تقديرية واسعة، خاصة أن القاضي الإداري يثق عادة، وكما يقول di Qual فيما تتخذه الإدارة من قرارات في هذا الشأن^(١).

فالامتناع هنا إذن لا يجد تفسيره في أية اعتبارات قانونية وإنما فقط في اعتبارات عملية والدليل على ذلك يبدو من قيام المجلس بمراقبة التكييف القانوني للوقائع في خصوص نفس القرارات محل البحث إذا تعلقت بمواطنين فرنسيين بدلا من الأجانب كالقرارات التي تصدرها الإدارة بمنع بيع أو الإعلان عن الجرائد والمطبوعات الفرنسية^(٢).

وكذلك الحال في مصر حيث أطلق مجلس الدولة حرية الإدارة في خصوص القرارات الصادرة بتنظيم إقامة ونشاط الأجانب في مصر، وكذلك القرارات الصادرة بإبعادهم، في حين أنه أخضع مثل هذه القرارات لرقابته التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حدودها القصوى، إذا ما تعلقت بمواطنين مصريين^(٣).

أما عن المجالات الأخرى التي يمتنع فيها القاضي عن أعمال رقابته المشار إليها فهي المجالات التي تتعلق بمسائل فنية، والسبب في ذلك أن القاضي الإداري يفضل أن يترك أمر تقييمها أو تقديرها للمختصين أو لأصحاب الخبرة الفنية، بدلا من أن يدعى معرفة بها وهو ليس كذلك كما أوضحنا. ومعنى ذلك أن امتناع القاضي الإداري في خصوص تلك المسائل ليس مرده ما تتمتع به الإدارة من سلطة تقديرية وإنما لأنه أحس من ذاته أنه لا يملك الوسائل التي تعينه على إجراء تلك الرقابة. فالامتناع إذن امتناع

(1) la competence lieé, these, Lille, L.G.D.J., 1964, P. 152.

(2) C.E., 5 dec. 1956 Thibault, D. 1957, concl. Mosset, P. 20.

(٣) الدكتور/ محمود عاطف البناء، حدود سلطات الضبط الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ١٢٧.

ذاتي لا امتناع مفروض عليه. امتناع تحتمه أيضا الاعتبارات العملية لا الاعتبارات القانونية.

ولهذا يقول دى كال في خصوص حالات الضبط الإداري التي يمتنع فيها القاضي الإداري عن أعمال رقابته العادية أو القصوى عامة، أن هذه الحالات تندرج في طائفتين: الأولى وهي التي لا يرغب القاضي في إجراء تلك الرقابة في خصوصها وإن كان يملك إجراءها وهي الحالات الخاصة بالأجانب. والطائفة الثانية تشمل الحالات التي يعترف في خصوصها بعدم قدرته على إجراء تلك الرقابة وهي المتعلقة بالمسائل الفنية^(١).

وهكذا يمكن القول أن الاعتبارات التي حالت دون امتداد رقابة مجلس الدولة للتكييف القانوني الذي تسبغه الإدارة على الوقائع التي تدعيها لقراراتها إنما هي اعتبارات عملية وليست قانونية. ومعنى ذلك أنه لا يوجد من الناحية النظرية ما يحول دون رقابة المجلس لجميع الحالات السابقة حتى ذات التقنية العلمية أو الفنية. إذ يستطيع مجلس الدولة مثلا أن يستعين في خصوصها بالخبراء والمختصين، كالرجوع إلى مجلس مراقبة الأمراض العقلية لبيان مدى إصابة الشخص بمرض عقلي من عدمه وذلك كما سنرى فيما بعد.

(1) Les hypothèses dans lesquelles le juge administratif ne se livre pas à contrôler de la qualification juridique des faits peuvent se ramener finalement à deux hypothèses : celles dans lesquelles il ne veut pas le son faire alors qu'il le pourrait, celles dans lesquelles il reconnaît incapacité à le faire.

L. di Qual, la compétence liée, op. cit., p.157.

وعلى أية حال فإن مجلس الدولة الفرنسي لم يقف مكتوف الأيدي تجاه كافة الطوائف التي امتنع في خصوصها عن إعمال رقابة التكييف القانوني بما فيها حالات الضبط الإداري السابق الإشارة إليها ، فقد ابتدع نظرية الخطأ البين ونظرية الموازنة كأسلوبين حديثين للحد من سلطة الإدارة التقديرية وهو ما سوف نبينه في الباب الثاني من هذه الدراسة.

المبحث الثانى

الرقابة على الملاءمة فى مجال الضبط الإدارى أمام مجلس الدولة المصرى

ذكرنا أن مجلس الدولة المصرى لم يتخلف عن نظيره الفرنسى فى إعمال رقابته على ملاءمة القرارات الصادرة فى مجالات الضبط الإدارى، خاصة تلك التى تتضمن تقييدا للحريات العامة، سواء فى ذلك قرارات الضبط الصادرة فى ظل الظروف العادية أم الصادرة فى ظل الظروف الاستثنائية، مع ملاحظة أن رقابة القضاء الإدارى فى مصر لقرارات الضبط الصادرة فى ظل هذه الظروف الأخيرة تكتسب أهمية بالغة ، نظرا لسيادة تلك الظروف الاستثنائية فى المجتمع المصرى، أكثر من سيادة الظروف العادية. أو بمعنى أدق نظرا لميل الحكومات المصرية المتعاقبة نحو تفضيل العمل بقانون الطوارئ، وإعلان الأحكام العرفية ، على العمل بالقوانين العادية، سواء أكانت هناك ظروف استثنائية أو حالات ضرورة بالفعل أم لم تكن هناك مثل هذه الظروف أو تلك الحالات. ففى خلال الفترة من عام ١٩٣٩ وحتى الآن (١٩٩٢) تلاحظ أن قانون الطوارئ قد طبق فى مصر لمدة خمسة وأربعين عاما من أصل ثلاثة وخمسين عاما ولا زال مطبقا!!.

من هنا تبدو مدى الأهمية والآمال التى تعلق على قضائنا الإدارى فى رقابته لقرارات الضبط الإدارى لمنع استغلال أو لمنع التستر وراء القوانين الاستثنائية لمباشرة التعسف والاستبداد تجاه حقوق الأفراد وحرياتهم.

ولهذا نبين فيما يلى كيف يراقب القضاء الإدارى المصرى قرارات الضبط الإدارى سواء فى الظروف العادية أم فى الظروف الاستثنائية وذلك فى مطلبين متاليين.

المطلب الأول

رقابة قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية

تتطلب الظروف العادية للمجتمع في واقع الأمر أن يتحقق التوازن أو التعادل بين الحرية ومقتضيات النظام العام ، بحيث لا يجوز في تلك الظروف أن يجور أحدهما على الآخر. فليس من شك في أن حماية الحرية والاشفاق من التضييق عليها لا ينبغي أن يبالغ فيها إلى الحد الذي يفضي إلى التضحية بالنظام العام ، كما لا ينبغي كذلك الإصاخة لمقتضيات النظام العام بحيث نسقط من الاعتبار ما ينبغي للحريات من حرمة ورعاية، وللكرامة الإنسانية من تقدير وعناية. وعلى هذا أرسيت الضمانات القضائية والقانونية التي تؤكد هذا التوازن المحكم بين الحرية والنظام^(١).

من هنا فإن القضاء الإداري في مصر - كما هو الحال في فرنسا - يتشدد تجاه ما تصدره الإدارة من قرارات تمس بها حقوق الأفراد وحياتهم، وذلك بإخضاع تلك القرارات لرقابة التناسب. تلك الرقابة التي تتيح للقضاء مراجعة الإدارة في تقديرها وتقييمها لأهمية وخطورة الوقائع التي تستند إليها، ومدى تناسب ذلك مع القرارات التي تصدرها استنادا إليها ولقد كان لمحكمة القضاء الإداري منذ إنشائها عام ١٩٤٦ فضل السبق في هذا المضمار وذلك بما أرسته من مبادئ تترجم ما ينطوي عليه ضمير القاضي من رغبة في حماية حقوق الأفراد وحياتهم وعدم التحيف بها إلا بقدر يتلاءم ويتناسب مع ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام . فقد أخضعت تلك المحكمة قرارات الضبط الإداري الماسة بهذه الحقوق وتلك الحريات لرقابة الملاءمة، للوقوف على مدى التناسب بين أهمية وخطورة الوقائع التي تدعيها الإدارة وبين

(١) الدكتور/ محمود سعد الدين الشريف، فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحريات مجلة مجلس الدولة، المكتب الفني، ١٩٦٩، ص ٤٥.

مضمون تلك القرارات، فهي تقول في أحد أحكامها: أن المناطق في مشروعية العمل الإداري هو أن يكون لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام، وأن يكون الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر. وللقضاء الإداري حق الرقابة على قيام هذا المسوغ أو عدم قيامه، فإذا ثبتت جدية الأسباب التي تبرر هذا التدخل كان القرار بمنجاة من أي طعن، أما إذا اتضح أن الأسباب لم تكن جدية ولم يكن فيها من الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات كان القرار باطلاً^(١).

ولهذا فقد قضت "بأن القرارات التي تصدرها وزارة الصحة للمحافظة على الصحة العامة ومنع نشوء الأمراض وانتشارها، تخضع بوصفها قرارات بوليسية لرقابة هذه المحكمة التي لها سلطة واسعة في تحرى أسبابها وملابساتها لكي تتأكد من موافقتها لظروف الحال وأنها لازمة وضرورية لصيانة الصحة العامة، وأنها وليدة ضرورة وقاية هذه الصحة في الظروف الخاصة التي تقرر من أجلها. وبمعنى آخر للمحكمة في هذه الحالة سلطة بحث ملاءمة هذه القرارات للظروف والملابسات التي أدت إليها"^(٢).

كما قضت في دعوى أخرى متعلقة بممارسة حرية التجارة بإلغاء قرار الإدارة بإغلاق أحد الأسواق على أثر حدوث نزاع بين قبيلتين، مستندة في ذلك إلى أنه "وقد مضى على الحادث الجنائي مدة طويلة دون أن يقع ما يخل بالأمن، فإن تعطيل الإدارة للسوق بعد ذلك بدعوى المحافظة على الأمن ليس هو الوسيلة الوحيدة لبلوغ هدفها، وليس من الضروري والحالة هذه تعطيل السوق الذي لا يدار إلا يوماً واحداً في الأسبوع ولا يترتب على قيام حادث بين قبيلتين إغلاق السوق، لا سيما بعد أن انقضى أكثر من سنة

(١) ق ٧/٣١٢١، جلسة ١٩٥٦/٣/٢٥، س ١٠، ص ٢٥٨.

(٢) ق ٦٥٧ س ٢، جلسة ١٩٤٩/٦/١٦، مجموعة السنة الثالثة، ص ١٠١٥.

ونصف منذ وقوع الحادث دون أن يتم التصالح بين المسلمين، وقد كان في مقدور الإدارة اتخاذ الاجراءات الكفيلة ، يمنع الحوادث دون الالتجاء إلى إغلاق السوق حتى إذا ما اضطرتها الظروف إلى اتخاذ هذا الإجراء الشديد، كان هذا بالقدر المناسب ولمدة قصيرة من الزمن^(١).

وفي مجال حرية العبادة فقد ألغت قرار الإدارة برفض الترخيص ببناء كنيسة، مقرر أن الأسباب التي استندت إليها الإدارة لتبرير هذا الرفض والتي تتمثل في قرب الموقع المقترح لبناء هذه الكنيسة من إحدى دور السينما مما يهدد بقيام احتكاك بين جمهورها وجمهور المصلين، كما قد يتضمن عرقلة للمرور، غير كافية لرفض مثل هذا الترخيص^(٢).

فالمحكمة إذن قامت برقابة مدى التناسب بين الإجراء الضبطي الذي اتخذته الإدارة وبين أهمية وخطورة الوقائع التي استندت إليها، وعندما اتضح لها عدم تحقق هذا التناسب لم تتردد في إلغاء القرار. وهو ما انتهجته في كافة القضايا أو النزاعات المتعلقة بمسائل الضبط الإداري التي يترتب عليها تقييد لواحد من الحريات العامة للأفراد.

هذا وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا منذ أول إنشائها عام ١٩٥٥ هذا الاتجاه، وباشرت بالتالي الرقابة على مدى الملاءمة أو مدى التناسب في قرارات الضبط المتعلقة بالحريات العامة، بل لقد رددت في بعض أحكامها ذات العبارات التي كانت تقول بها محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن مما يدل على تبنيها وإقرارها للمبادئ التي استقرت عليها هذه الأخيرة.

(١) ق ١٦٧/٥، جلسة ١٩٥٢/١/٢٢، س ٦، ص ٣٤٠.

(٢) ق ١٥٠/١، جلسة ١٩٤٨/٢/٢٤، مجموعة السنة الثانية، ص ٣٧٨.

والأمثلة على ذلك كثيرة نكتفى من بينها بالحكم الصادر في ٣٠ مايو ١٩٦٤ الذي ألغت بموجبه قرار الإدارة الصادر برفض الترخيص ببناء كنيسة مؤسسة هذا الإلغاء على أن الوقائع أو الأسباب التي ادعتها الإدارة لهذا الرفض والتي تتمثل في قرب الموقع المقترح إقامة الكنيسة فيه من أحد المساجد ومدرستين ابتدائيتين مما يجعل لجرس الكنيسة تأثيراً على إقامة الصلاة وعلى الدراسة بالمدرستين، الأمر الذي يخشى معه حدوث فتنة بين المسلمين والأقباط وبالتالي الإخلال بالنظام العام. هذه الوقائع وتلك الأسباب ليست من الأهمية أو الخطورة التي تبرر رفض الترخيص. فقد قالت المحكمة: أن ما ساقته الوزارة تبريراً للقرار المطعون فيه وهو خشية الفتنة لاحتمال حدوث احتكاك بين المسلمين والأقباط إنما هو قول غير سديد؛ "ذلك أنه ليس هناك أحياء خاصة بالأقباط وأخرى خاصة بالمسلمين، بل إنهم جميعاً يعيشون جنباً إلى جنب، وتوجد كنائس في أحياء غالبية سكانها من المسلمين كما وأن هذه الكنائس مقامة في وسط أكنة أهلة بالسكان، وبالقرب من المدارس والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، بل وبعضها مقام بجوار الجوامع، ومع ذلك فلم تقع الفتنة أو حصل من جراء هذا أي إخلال بالنظام والأمن"^(١).

المطلب الثاني

رقابة قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية

قد يطرأ على الدولة ظروف طارئة استثنائية متعددة الصور ومختلفة المصادر مثل نشوب حرب أو وقوع كوارث أو حدوث اضطرابات داخلية أو حدوث أزمات اقتصادية أو انتشار وباء أو حدوث فتنة وهي كلها ظروف

(١) الحكم الصادر بتاريخ ٣٠ مايو ١٩٦٤، ق ١٤١٦ س ٧، مجموعة السنة التاسعة، ص ١٠٧١.

تتصف - كما هو واضح - بالفجائية وعدم التوقع، ولذا غالبا ما يحدث خلافا في نظام الدولة واستقرارها وأمنها الداخلي أو الخارجي أو الاثنين معا، الأمر الذي يبرر اتساع سلطات الضبط الإداري في مثل تلك الظروف حتى تتمكن من مواجهتها والسير بالمجتمع إلى بر الأمان، ولكن أيا كانت درجة اتساع هذه السلطات وما قد يترتب على حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية من مخالفات قانونية، فإن الإدارة لا يمكن أن تعفى من الخضوع للرقابة القضائية في خصوص ما تتخذه من إجراءات ضبط تواجه بها هذه الحالة أو تلك الظروف، فهذا مبدأ مستقر في القضاء الإداري المصري - كما هو الحال في القضاء الإداري الفرنسي - منذ نشأته لأول مرة عام ١٩٤٦.

فقد أشارت محكمة القضاء الإداري إلى ذلك قائلة أن "قضاء هذه المحكمة جرى على أن مرسوم إعلان الأحكام العرفية المقابل لقرار إعلان حالة الطوارئ يعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية، أما التدابير الفردية التنظيمية التي تتخذها السلطات القائمة على تنفيذ النظام العرفي فهي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء"^(١).

وتطبيقا لذلك فقد قضت هذه المحكمة "أن إجراءات الاعتقال وتحديد الإقامة يجب ألا يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى التي يستعصى فيها اللجوء إلى الإجراءات العادية لما في ذلك من مساس بالحرية الشخصية، وأن يكون ذلك بالقدر الضروري اللازم للمحافظة على الأمن، فلا يتجاوز ذلك إلى غيره من الأغراض..."^(٢).

(١) ق ١٤٢٧ س ٣١، بتاريخ ١٣/١٢/١٩٧٧.

(٢) ق ٥٠٢٤ / ٨، بتاريخ ١٣/١/١٩٥٦، س ١٠، ص ١٢٨.

وقضت كذلك بأن خطورة الشخص على الأمن والنظام لكي يكون سببا جديا يبرر اتخاذ هذا الإجراء المقيد للحرية يجب أن يستمد من وقائع حقيقية منتجة في الدلالة عن هذا المعنى، وأن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها. وأن مجرد انتماء المدعى لو صح إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة على الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلا وشخصيا أمورا من شأنها أن تصفه حتما بهذا الوصف^(١).

وإذا كان هذا هو مسلك محكمة القضاء الإداري والذي يعتبر بحق مفخرة للقضاء في مصر وللمواطن المصرى على حد سواء، لما يتسم به من جدية وعمق بل ومن ثبات واستقرار في رقابة قرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية، بذات أسلوب أو منهج رقابتها لتلك القرارات في الظروف العادية، مما يؤكد مدى حرصها . كما ذكرنا . على أن تكون سندا لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، نقول إذا كان هذا هو مسلكها فلنا أن نتساءل حول المسلك الذي انتهجته المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد؟ وما إذا كان مطابقا لمسلك محكمة القضاء الإداري من عدمه؟

يمكن القول بصفة عامة أنه في ظل الظروف الاستثنائية تراقب المحكمة الإدارية العليا التلاؤم أو التناسب في قرارات الضبط المقيدة للحريات العامة، متبعة في هذا الخصوص ذات المسلك الذي رأيناه في

(١) ق ٦/١١٤٢، بتاريخ ١٩٥٢/٦/٣٠، س٦، ص ١٣٩٠.

ولمزيد من هذه الأحكام انظر الدكتور/ محمود سلامة جبر، المرجع السابق، ص ٤٧٨ وما بعدها؛ الدكتور/ عصام عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ٤٢٥ وما بعدها.

أحكام محكمة القضاء الإداري، ومن ذلك مثلاً أنها تقول في أحد أحكامها، وهي تردد هنا ذات عبارات محكمة القضاء الإداري: أنه إذا كان "القانون يخول الحاكم العسكري في ظل الأحكام العرفية سلطة تقديرية واسعة، يواجه بها ما تقتضيه الحالات الاستثنائية التي تعرض له من اتخاذ تدابير سريعة حاسمة، إلا أنه ينبغي ألا تتجاوز سلطته التقديرية الحدود الدستورية المرسومة، وألا تخل بالتزاماته القانونية وألا تتوغل بوجه خاص على الحريات العامة بدون تخل بالتزاماته القانونية وألا تتوغل بوجه خاص على الحريات العامة بدون مبرر قانوني وإلا شاب تصرفاته عدم المشروعية"^(١).

بل لقد أعملت هذه الرقابة في الحالات التي يتطلب فيها الأمر خيارات واختصاصات فنية معينة لتقدير الملاءمة، من ذلك مثلاً القرارات الخاصة بحجز المصابين بأمراض عقلية، فقد قضت في هذا المجال بأنه "لئن كانت سلطة مجلس مراقبة الأمراض العقلية على النحو المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية في تقرير ما إذا كان الشخص مصاباً بمرض عقلي أو لا هي في الأصل سلطة تقديرية باعتبارها من الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعي، بحيث ما كان يجوز التعقيب عليها إلا عند إساءة استعمال السلطة إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالحرية الشخصية فإنه يجوز للقضاء الإداري من حيث المبدأ اتخاذ ما يلزم للتحقق من ذلك إذا قدم إليه طلب الإلغاء"^(٢).

(١) الحكم الصادر بتاريخ ١٣/٤/١٩٥٧، س٢، ق٩٣، ص ٨٨٦.

(٢) القضية رقم ٥/٤٦٧ ق بتاريخ ٢٧/٦/١٩٥٩، مجموعة أبو شادي، مبدأ ١٧١٨، ص ١٧٨٤.

ومع ذلك يلاحظ أن مسلك المحكمة الإدارية العليا لا يتسم في هذا الصدد بالثبات والاستقرار، إذ كثيرا ما تتساهل تجاه سلطات الضبط الإداري، تاركة لها حرية أكبر في تقدير الأمور أو في وزن المناسبات التي تتخذها أساسا لما تصدره من قرارات مقيدة للحرية (أثناء العمل بقانون الطوارئ أو في ظل الأحكام العرفية). فقد قضت مثلا بأن: "السلطة القائمة على إجراءات الأحكام العرفية هي التي تستجمع العناصر والأدلة بوصفها الجهاز المسئول المختص وهي التي تقدر مدى خطورتها على الأمن والنظام العام..."^(١).

ولذلك لم تتشدد بالنسبة لأوامر الضبط والاعتقال، في التحقق من مدى خطورة الشخص على الأمن والنظام العام تاركة مثل هذا الأمر لتقدم المحاكم العسكرية، حيث اكتفت في هذا الصدد بالقول بأن "مجرد انتهاء شخص إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي يفيد خطورته على الأمن العام"^(٢). ومعنى ذلك أنها لم تتطلب لذلك ضرورة أن تنسب إلى هذا الشخص وقائع محددة يثبت ارتكابه لها، وذلك على عكس محكمة القضاء الإداري التي قررت - كما بينا من قبل - عدم الاعتداد بقرار القبض أو الاعتقال طالما أن الشخص - حتى ولو كان منتميا إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة - لم يثبت أنه قد ارتكب فعلا وشخصيا أمورا من شأنها أن تصفه بصفة الخطورة على الأمن العام.

بل وفي الدعوى رقم ٢٢٠ بتاريخ ١١ فبراير ١٩٧٨، نفت المحكمة الإدارية العليا أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في الترخيص أو عدم

(١) الحكم الصادر بتاريخ ١٩٦٣/٣/٢٣، قضية رقم ١٧٢٠ س ٦ق، مجموعة السنة الثامنة، ص ٨٧٢.

(٢) الحكم الصادر في ١٣ أبريل ١٩٥٧، ق ١٥١٧، س ٢، مجموعة السنة الثانية، ص ٨٨٦.

الترخيص بالسفر إلى خارج البلاد. وأن ذلك من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام ، ويجوز لجهة الإدارة رفض الترخيص بالسفر إذا قام لديها سبب من الأسباب المبررة لذلك^(١). كما قضت أيضاً بأن سوء السمعة حالة تلحق بالشخص وتحيط به ولا تطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة وإنما يكفي في ذلك قيام دلائل جدية وقرائن مادية وهي في حد ذاتها سببا يكفي لحمل القرار المطعون فيه على محمل

(١) مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، س ٢٣ سنة ١٩٧٨، رقم ٧٣، ص ٤٣.

ويلاحظ على هذا الحكم أنه يضع مبدأ عاماً يعطى للإدارة السلطة التقديرية المطلقة بلا قيد أو شرط في موضوع الترخيص أو عدم الترخيص للمواطنين بالسفر إلى الخارج، وبذلك يحرم القضاء الإداري نفسه من حق مراقبة قرارات الإدارة التي تصدر في هذا المجال، مع احتمال أن تكون مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة، وذلك إذا لم تكن قائمة على مصلحة عامة معينة، بل على عوامل شخصية أو أسباب سياسية وكثيراً ما لجأت الحكومات إلى استخدام سلاح المنع من السفر ضد خصومها السياسيين لمجرد الكيد لهم. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (فقرة ٢) تعطي كل إنسان الحق في الخروج من أي دولة بما في ذلك دولته، وفي العودة إلى وطنه في أي وقت يشاء. كما أن المادة الثانية والخمسين من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في ٢٨ سبتمبر ١٩٧١ تعطي المواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج على أن يكون تنظيم هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد بقانون. وتحظر المادة الحادية والخمسون إبعاد أي مواطن أو منعه من العودة إليه، وبذلك يكون الحكم السابق مخالفاً للدستور المصري وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن منع المواطنين من السفر إلى الخارج لا يجب أن يخضع للسلطة التقديرية للإدارة العامة، بل يجب أن يكون "اختصاصاً مقيداً" يخضع لنصوص قانونية صريحة ومحددة تنظمه وتضع شروطه وإجراءاته كما قرر الدستور. ولا يتقرر المنع من السفر إلا طبقاً لذلك القانون، وبموجب حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بناء على أسباب جنائية تحتم ذلك المنع.

أما منع المواطنين من العودة إلى وطنهم في أي وقت يشاءون فيجب حظره نهائياً، نظراً لتعارضه مع حق كل إنسان في أن يكون له وطن يلجأ إليه في أي وقت. ولا ننسى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (مادة ١٤) وكذلك جميع الدساتير المتحضرة تعطي للأجانب حق اللجوء السياسي إلى الدول الأخرى، فيجب أن يكون للمواطن من باب أولى - حق اللجوء إلى وطنه.

الدكتور أحمد حافظ نجم، السلطة التقديرية للإدارة ودعاوى الانحراف بالسلطة، الجزء الثاني، عام ١٩٨٣، مرجع سبق ذكره، ص ٢٥ وما بعدها.

الصحة، وأن قرار سحب جواز سفر المطعون ضدها وإدراج اسمها بقوائم الممنوعين برىء من إساءة استعمال السلطة.

وهكذا يتضح لنا مدى التقهقر أو التراجع الذي طرأ على موقف محكمتها العليا تجاه سلطة الإدارة التقديرية في مجال الضبط الإداري، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، مع أن هذا المجال هو الذي يتطلب من تلك المحكمة ضرورة التشدد واتخاذ المواقف الصارمة تجاه الإدارة ، ذلك أنه إذا قام القضاء الإداري عن حماية حقوق الأفراد وحياتهم فما هي الفائدة التي ترجي بعد ذلك ؟ فهل هناك ما هو أهم وأعظم من حرية الإنسان في الوجود؟

ومن ناحية أخرى، ألا ترى المحكمة الإدارية العليا أن حكوماتنا قد أصيبت -كما ذكرنا من قبل - بداء تطبيق قانون الطوارئ حتى أصبح هو القاعدة وأن القانون العادي أصبح استثناء! ولذا فلا أقل من أن يجد الأفراد تجاه هذا الوضع المؤسف ملجأً وحصناً يصون حقوقهم ويضمن لهم حرياتهم، وليس هناك ملجأً وحصن أفضل من قضاء عادل ومنصف يراجع الإدارة فيما تدعيه من أسباب أو وقائع معينة، ويزن مدى أهميتها ومدى تناسبها مع الإجراءات الاستثنائية المتخذة حيالهم.

لكل ذلك نتمنى أن تستجيب المحكمة العليا للنداءات المتكررة من جانب رجال الفقه^(١)، ونحن من بينهم، أن تباشر دورها في مجال الضبط

(١) الدكتور/ أحمد حافظ نجم ، المرجع السابق، ص ٣٣؛ الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ١٧٨؛ الدكتور/ سامي جمال الدين، والذي يرى أنه "من الغريب أن المحكمة العليا قد أقرت مشروعية قيام نظام حالة الطوارئ أو على الأقل استمراره في ظل الظروف العادية، ونسيت أو تناست طبيعة ذلك النظام الاستثنائي المؤقت، ومن الغريب كذلك أن تعمل المحكمة بأحكامها هذه على تعطيل القضاء على أداء وظائفه الخطيرة والحيوية والتي لا غنى عنها للأفراد وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية وذلك

الإداري بما يحقق الآمال المعقودة عليها والطموحات التي نرجوها منها، وذلك بأن تكون حصنا منيعا وقلعة شامخة - كما تعودنا دائما - لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم تجاه عسف الإدارة وتسلطها خاصة في ظل الظروف لاستثنائية.

دفاعا عن سلطة الطوارئ". لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٨٢، ص ٣٧٥.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه قد صدرت في الآونة الأخيرة بعض الأحكام التي تفيد أن المحكمة الإدارية العليا تتجه نحو تلبية النداء الفقهي وتحقيق رجاء الملايين في أن تظل دائما حصنا من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات، أملا ألا تكون هذه الأحكام مجرد أحكام فردية صدرت في ظل ظروف وأوضاع معينة أو لاعتبارات خاصة. ومن هذه الأحكام مجرد أحكام فردية صدرت في ظل ظروف وأوضاع معينة أو لاعتبارات خاصة. ومن هذه الأحكام نذكر: ما قضت به بشأن منع إحدى الجامعات بعض الطالبات من ارتداء النقاب حيث أبدت قضاء محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الجامعة بحظر ارتداء النقاب على الطالبات مقرر أن هذا الحظر ينطوي على مساس بالحرية الشخصية وتقييد للحرية العقيدية لا يمكن إباحته تحت ستار التحوط من دخول عناصر دخيلة للجامعة وتوقيا للانتحال، فهذه الضرورة تقدر بقدرها ويلزم مواجهتها بالقدر اللازم لسد الذرائع مثل تكليف المنقبة بالكشف عن وجهها عند اللزوم أو رصد مختص ولو من بنات جنسها للتحقق منها حيث لا مبرر لها للامتناع، وأن الحظر المطلق أو المنع الكلي ينطوي على مساس بالحرية الشخصية.

حكمها في الطعن رقمي ١٣١٥، ١٩٠٤ لسنة ٣٤ق، بجلسة ١٩٨٩/٧/١، غير منشور. وفي مجال حرية الرأي والتعبير قضت في حكمها الصادر في قضية فيلم "درب الهوى" بجلسة ١٩٩١/١/١٦ أن الدستور قد كفل حرية الرأي والتعبير، وحرية التعبير الفني هي إحدى الحريات التي كفلها الدستور وأنه لا جدال في أن حدود القانون هي السياج الذي يجب أن تمارس في إطاره حرية الرأي أيا كانت وسيلة التعبير عنه للغير ويشمل ذلك التعبير بالصوت والصورة في صورة فيلم سينمائي وأن المشرع قيد حرية الإبداع لافني بحدود بينها على سبيل الحصر هي حماية الآداب العامة والمحافظة على امن والنظام العام ومصالح الدولة العليا. ومن ثم فإن تقدير الإدارة لقيام المقتضى المبرر لمنع عرض العمل السينمائي أو سحب الترخيص بعرض ينبغي أن يقوم على عناصر تنتج وتبرره، يقوم عليها ويستند إليها غايتها الصالح العام الأعلى للمجتمع والدولة في إطار الشرعية وسيادة القانون". طعن رقم ٣٢/١٠٠٧ق، بجلسة ١٩٩١/١/٢٦، غير منشور؛ وانظر أيضا الدكتور/ محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين، مرجع سبق ذكره، ص ٤٩٠ وما بعدها.

المبحث الثالث

موقف الفقه من الرقابة على الملاءمة في

مجال الضبط الإداري

يقصد بالملاءمة في مجال الضبط الإداري - كما بينا - مدى التناسب بين الإجراء الذي قيدت به الإدارة إحدى الحريات التي يتمتع بها المواطنون، وبين الوقائع أو الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا الإجراء، وهذا يتطلب في الواقع من السلطة الإدارية المختصة أن تقوم بعملية تقييم وتقدير جيد ودقيق لأهمية وخطورة هذه الوقائع أو الأسباب، حتى يتسنى لها اختيار الإجراء الملائم أو المناسب لها.

إن عملية التقييم أو التقدير على هذا النحو تشكل في واقع الأمر جوهر السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة في هذا المجال والتي تقتضي والحال هكذا، أن تكون لها حرية كاملة في إجراءاتها على ضوء الظروف والاعتبارات التي تحيط بالموقف الذي تتعامل معه على أرض الواقع. ولكن يجب أن يلاحظ أنه أيا كان مدى هذه الحرية، فإن الإدارة ليست طليقة في هذا الخصوص من كل قيد، حيث ينبغي عليها وهي بصدد اتخاذ إجراءات الضبط الإداري، أن توائم بين أمرين جد مختلفين أو متعارضين هما: المحافظة على الأمن والنظام العام في المجتمع من ناحية وعلى حماية حقوق الأفراد وحياتهم من ناحية أخرى، فلا تضحي بواحد من هذين الأمرين على حساب الآخر إلا بالقدر الذي يتطلبه الموقف أو الواقع الذي تواجهه، ولهذا يقول فالين: إن على الإدارة في هذا الصدد التزام بأن تضع نفسها في أفضل الظروف والأحوال، وأن تجري تقييمها لهذا الموقف أو ذلك الواقع بروح موضوعية، وبعيدا عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها

العناصر اللازمة لإجرائه^(١)، وهي تفعل ذلك بطبيعة الحال تحت رقابة القضاء.

فالقضاء الإداري سواء في فرنسا أم في معسر، واستثناء من القاعدة التي كان ينتهجها بعدم بسط رقابته في مجال الملامة أو التناسب الذي تجريه الإدارة، قد باشر هذه الرقابة في خصوص قرارات الضبط الإداري. ولهذا فقد ثار التساؤل عن أساس تلك الرقابة.

وهنا نجد اختلافا بينا بين الفقه، حيث ذهب جالب منهم إلى اعتبار الرقابة على التناسب في مجال الضبط الإداري، حتى وإن كانت تتم في مجال الملاءمة، رقابة مشروعية على أساس أن دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء يقتصر فقط على مجرد فحص المشروعية دون الملاءمة، لذلك فهم يقلون بتفسيرات تتلاءم ووجهة نظرهم هذه. في حين أن جانبا آخر من الفقه يرى أنه لا تعارض على الإطلاق بين ما تجريه الإدارة، وهي بصدد مباشرة سلطاتها التقديرية، من ملاءمة في مجال الضبط الإداري وبين أن تخضع هذه الملاءمة للرقابة القضائية. فقاضي الإلغاء لم يعد كما كان في الماضي فقط قاضي مشروعية وإنما أصبح أيضا قاضي ملاءمة. فأى من هذين الفريقين أولى بالاتباع. هذا ما نبينه تباعا فيما يلي:

(1) "L'obligation de se mettre dans les meilleures conditions pour faire avec un esprit objectif et en connaissance de cause cette obligation" le pouvoir discrétionnaire de l'administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel, R.D.P, 1930, P.208.

وأنظر كذلك الدكتور/ سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية، موجه سبق ذكره، ص ٧٨.

المطلب الأول **المشروعية أساس رقابة الملاءمة في مجال** **الضبط الإداري**

رغم اعتراف أنصار هذا الاتجاه^(١) بأن القاضي الإداري يراقب مدى ملاءمة الإجراء الذي اتخذته الإدارة في مجالات الضبط الإداري مع أهمية وخطورة الوقائع التي استندت إليها، وهو ما يجسد جوهر السلطة التقديرية للإدارة، إلا أنهم يرون مع ذلك أن هذه الرقابة لا تخرج عن كونها رقابة مشروعية، مستندين في ذلك إلى أن التناسب أو الملاءمة تعد شرطاً أو عنصراً من عناصر مشروعية قرارات الضبط الإداري، باعتبار أن هذه القرارات تمس موضوع الحريات العامة وهو موضوع يشكل مسألة قانونية تكمن - كما يقول فالين - فيما تواجهه الإدارة - وهي بصدد اتخاذ إجراء من إجراءات الضبط التي تمس إحدى الحريات العامة - من تنازع بين القوانين، إذ يرى الفقيه الكبير أنه في جميع الحالات التي تتصرف فيها الإدارة بمقتضى سلطات الضبط الإداري المخولة لها من أجل المحافظة على النظام العام ، إنما تجد نفسها أمام تنازع حقيقي بين القوانين المسؤولة هي عن تطبيقها حيث تفرض عليها هذه القوانين واجبين، يبدو أن كليهما يتعارض مع الآخر. فهناك من ناحية أولى واجب الإدارة في الحفاظ على

(1) Waline, le pouvoir discrétionnaire de l'adm. et sa limitation, op. cit., p. 222; étendue et limites du contrôle du juge adm. sur les actes de l'adm., E.D.C.E., 1956, P.30 etss.; venezia (j.c.), le pouvoir discrétionnaire, L.G.D.J. 1958, P. 95 etss., Di Qual (L.) la compétence liée, L.G.D.J., 1964, P.185 etss.

الدكتور/ محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٨٠، ص ٧٢؛ الدكتور/ محمد فريد سليمان، الرقابة على التناسب في القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٤١٠ وما بعدها؛ الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص ١٦٥ وما بعدها.

النظام العام الذي يفرضه عليها قانون الضبط الإداري، وهناك من ناحية أخرى، واجب الإدارة في احترام الحريات العامة المفروض عليها بمقتضى القانون المنظم لتلك الحريات، وهنا يصبح من المحتم على جهة الإدارة أن تضحي ببعض هذه القوانين في سبيل تطبيق البعض الآخر^(١). ومعنى ذلك أن قرارات الضبط الإداري لا تكون صحيحة ومشروعة إلا إذا كانت ضرورية ومتلائمة مع الحالات أو المواقف الواقعية المتخذة على أساسها. ولكي يتحقق القاضي الإداري من تلك المشروعية، عليه أن يفحص هذه الضرورة أو تلك الملاءمة، وهو بذلك يباشر اختصاصه الطبيعي كقاضي مشروعية، وذلك على عكس ما إذا كانت الملاءمة لا تشكل عنصرا من عناصر مشروعية القرار الإداري، إذ يجب عليه في هذه الحالة أن يمتنع عن رقابة تلك الملاءمة ، وإلا يصبح متجاوزا حدود اختصاصه.

ويجمل الأستاذ فالين محتوى أو مضمون هذا الاتجاه حينما يقول: أنه في كافة الحالات التي تكون فيها إحدى الحريات العامة محلا للتقييد بمقتضى إجراء ضبطي، فإن هذا الإجراء لا يكون مشروعاً إلا إذا كان ضرورياً، ومن ثم ملائماً، والسلطات القضائية حامية الحريات العامة لها أن تتحقق - وفقاً لمبدأ المشروعية - من قيام هذه الضرورة وتلك الملاءمة وهو ما يؤدي في النهاية إلى خضوع هذه الإجراءات لرقابة قضائية كاملة تنصب على مشروعيتها وملاءمتها^(٢).

وإذا كان العميد فيدل يؤيد فالين فيما ذهب إليه حينما يقول: إن إجراءات الضبط الإداري، خاصة تلك التي تمس الحريات العامة لا تكون

(1) Waline, Le pouvoir discrétionnaire... sa limitation, op. cit., P. 222.
وانظر أيضا الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ٤٢٢ وما بعدها.

(2) op. cit., P. 223.

مشروعة إلا إذا كانت ضرورية أو نافعة، ومن ثم ملائمة، وأن القاض الإداري عندما يتحقق من قيام هذه الضرورة أو تلك المنفعة، فإنه يجعل من نفسه قاضيا للملاءمة وذلك دون أن يخرج - بطبيعة الحال - عند حدود اختصاصه في الرقابة على المشروعية، لأن الملاءمة تصبح في هذه الحالة عنصرا من عناصر المشروعية، نقول إذا كان فيدل يتفق مع فالين في هذا الصدد ، إلا أنه يختلف عنه فيما يعترف به للقضاء من سلطة إنشاء قواعد قانونية مستقلة عن إرادة المشرع، يدرج بمقتضاها بعض عناصر الملاءمة ضمن شروط مشروعية القرار. الأمر الذي يوسع من نطاق الاختصاص المقيد وبالتالي من نطاق المشروعية، ويضيق في ذات الوقت من نطاق السلطة التقديرية وبالتالي من نطاق الملاءمة.

ويترتب على ذلك نتيجة من مقتضاها أنه في حالة ما إذا كان هناك قانون قائم أو موجود، فإن الرقابة على عناصر الملاءمة تكون منعقدة، أما في حالة ما إذا كان هذا القانون في مرحلة الإنشاء، أي أثناء تكوينه، فإن القاضي الإداري يستطيع رقابة تلك العناصر وذلك بما يقرره من قواعد قانونية جديدة يوسع بها من نطاق المشروعية^(١).

ويتفق لوبادير مع فيدل، إذ يقول أن الرقابة القضائية على التناسب أو الملاءمة إنما تجد أساسها في القواعد القانونية التي يضعها القاضي الإداري باعتباره مصدرا من مصادر المشروعية، ويقيد بها بالتالي الاختصاص التقديري للإدارة بحيث يمكن القول . يضيف الفقيه الكبير - أنه

(1) Essai sur la notion de cause en droit administratif Français, thèse, toulouse, sirey, 1934, P.214.

إلى جوار السلطة المقيدة بواسطة المشرع توجد سلطة مقيدة بواسطة القضاء وهي التي تكمن فيها أساس رقابته لعناصر الملاءمة^(١).

وفي الفقه المصري يلاحظ أن هناك جانبا هاما من هذا الفقه يذهب في تفسيره لرقابة التناسب أو الملاءمة في مجال الضبط الإداري ذات المذهب السابق. ويأتي في مقدمة هذا الفقه أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي الذي يرى أن القضاء الإداري ما يزال في هذا الخصوص قضاء مشروعية لا ملاءمة، لأن ملاءمة القرار الإداري في مثل هذه الحالات هي شرط من شروط صحته. ولهذا قالوا - يضيف الفقيه - بأن سلطات البوليس هي سلطات مقيدة باستمرار^(٢) le pouvoir de police n'est jamais un pouvoir discrétionnaire. كما يرى أستاذنا الدكتور/ محمود عاطف البنا أن الأساس الذي يستند إليه القاضي في رقابة الملاءمة أو التناسب في مجل الضبط الإداري يكمن في أن التناسب أصبح من عناصر مشروعية القرار، موضحا بأن ذلك يوافق الأصل في رقابة القاضي الإداري، فهو يراقب الشرعية ولا يراقب الملاءمة ولكن الملاءمة تصبح في قرارات الضبط الإداري عنصرا من عناصر المشروعية^(٣).

كما نجد أن أستاذنا الدكتور/ محمد حسنين عبد العال يتبنى رأي كل من فيدل ولوبادير فيما ذهبا إليه عند تفسيرهما لرقابة مجلس الدولة على ملاءمة قرارات الضبط المحلي، حيث يقول سيادته: أنه إذا كان صحيحا أن دور القاضي في دعوى الإلغاء يجب أن يقتصر على فحص الشرعية،

(1) De laubadère, traité de droit administratif, paris, L.G.D.J. 10ème éd. 1988, P.255 etss., Eisenmann, le droit administratif et le principe de légalité, E.D.C.E., 1957 P.25 etss.

(٢) النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٩٠.

(٣) حدود سلطات الضبط الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٧١.

بحيث لا يجوز له أن يلغي قرارا مشروعاً لمجرد عدم ملاءمته، إلا أنه يجب ألا نغفل أن السلطات الواسعة التي يملكها القاضي الإداري، والتي تصل إلى حد إنشاء وتقرير قواعد قانونية جديدة، تمكنه أن يدخل بعض عناصر الملاءمة ضمن شروط مشروعية القرار^(١).

وهكذا يخبص أنصار هذا الإنجاء إلى أن رقابة القاضي الإداري سواء في فرنسا أم في مصر، للملاءمة في مجال الضبط الإداري، إنما يكمن في أن هذه الملاءمة تعد شرطاً من شروط مشروعية قرارات الضبط الإداري. ولذا يصبح واجباً على القاضي - باعتباره قاضياً للمشروعية - رقابة هذا الشرط للتأكد من سلامة تقدير الإدارة له.

فالمبدأ الأساسي لديهم إذن أن القاضي الإداري لا يراقب سوى مشروعية القرارات الإدارية دون ملاءمتها، وإذا اضطرت لرقابة هذه الملاءمة، فذلك فقط حينما تعتبر شرطاً من شروط تلك المشروعية، أما الملاءمة في ذاتها كظاهرة مستقلة ومنفردة، فإنها لا تخضع بحال من الأحوال لرقابة القضاء.

إذا كان هذا هو ما انتهى إليه أنصار هذا الاتجاه، فلنا أن نتساءل عن الأساس الذي استندوا إليه في اعتبار التناسب أو الملاءمة في قرارات الضبط الإداري شرطاً من شروط مشروعية تلك القرارات؟! حقيقة أن المشرع قد ينص في مجال تقييد الحريات العامة على أن الإجراءات الضبطية يجب أن يكون لازماً وضرورياً، ولكن هل وضع المشرع ذاته معياراً يحدد به متى يكون أو لا يكون الإجراء لازماً أو ضرورياً؟! أم أنه ترك ذلك لمحض تقدير الإدارة تجريه وفقاً لظروف وملابسات كل حالة على حدة؟! وهب أن الرقابة

(١) فكرة السبب في القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٧٦، ص ٧٧.

هنا رقابة مشروعية - كما يرى أنصار هذا الاتجاه - فلماذا لم يلتزم مجلس الدولة (سواء في فرنسا أم في مصر) بمباشرتها على كافة حالات الضبط الإداري التي تنطوي على مساس بالحريات العامة؟! ذلك أننا قد رأينا من قبل أن هناك حالات عديدة مستثناة من تلك الرقابة، حيث يكتفى القضاء الإداري في خصوصها برقابة الحد الأدنى *contrôle minimum* مثل إجراءات الضبط العليا أو تلك التي تنطوي على مسائل علمية أو فنية.

أما فيما يتعلق بالقول بأن القاضي الإداري بما ينشئه من قواعد قانونية يقيد بها سلطة الإدارة التقديرية، يكون قد أوجد أساسا قانونيا للرقابة على التناسب في مجال الضبط الإداري، الأمر الذي يضيف على تلك الرقابة سمة المشروعية، فإنه قول لا يقوى أيضا على الصمود أمام التمحيص والتفنيد.

ولكن بداءة تجدر الإشارة إلى أن اعتراضنا على هذا القول لا ينصب على دور القاضي الإداري في خلق وإنشاء قواعد قانونية ، فهذا أمر مسلم به وسبق لنا بيانه^(١). إن اعتراضنا ينصب في الواقع على ما يدعيه أنصار هذا الاتجاه من أن رقابة القاضي الإداري للملاءمة في مجال الضبط الإداري لا تجد أساسها إلا فيما يضعه هذا القاضي من قواعد قانونية أو كما يطلق عليها البعض قواعد قضائية.

ذلك أن التساؤل المطروح يدور حول معرفة هذا الأساس قبل أن يقوم القاضي بتلك الرقابة، أي قبل أن يقوم بخلق أو إنشاء مثل هذه القواعد، إذ من البديهي أو من الأمور المسلم بها أن خلق أو إنشاء قواعد قانونية إنما يأتي في مرحلة تالية للرقابة القضائية، أو بمعنى أدق يأتي من

(1) HARDY (J.), le statut doctrinal de la jurisprudence en droit administratif français, R.D.P. 1990, P.453.

خلال النظر في النزاع المطروح على القاضي، أي لحظة الفصل في هذا النزاع، ولهذا يقال بأن القاعدة القضائية هي قاعدة ظرفية circonstentielle تولد لحظة الفصل في النزاع الذي صدرت من أجله^(١). ومن ثم لا يمكن التسليم بأن هذه القواعد توجد في مرحلة سابقة على الرقابة، الأمر الذي يعني بدوره تخلف الشرط الأساس لاعتبار الرقابة هنا رقابة مشروعية والمتمثل في وجود قاعدة قانونية سابقة، يستند إليها القاضي في رقابته.

إضافة إلى ذلك هل يتسنى لنا أن نقول أن الرقابة على ملاءمة قرارات الضبط الإداري تندرج في إطار الرقابة على المشروعية، لأن القاضي الإداري قد قام بتحويل هذه الملاءمة بعد أن باشر رقابته عليها إلى عنصر من عناصر المشروعية، أو كما يقول laubadère إلى حالة جديدة من حالات الاختصاص المقيد، وذلك بما أنشأه، أو خلقه في خصوصها من قواعد قانونية؟!

إن التساؤل المطروح والذي نعيد تكراره في أكثر من مناسبة، هو عن طبيعة الرقابة التي يباشرها القضاء الإداري على اختصاص تقديري للإدارة، كما هو الحال في مجالات الضبط الإداري، ويظل كذلك أي يظل اختصاصا تقديريا، إلى أن يعرض النزاع الذي يدور حوله على القضاء، فإذا ما باشر القضاء رقابته هنا، هلي نكون أمام رقابة مشروعية أم أمام رقابة ملاءمة؟ وذلك بصرف النظر - بطبيعة الحال - عن النتيجة التي ينتهي إليها القضاء حول هذا النزاع سواء بوضع قواعد قانونية في خصوصه أم بعدم

(1) Rivero, sur la retroactivité de la règle jurisprudentielle, A.J.D.A., 1968, P. 15 etss.

وانظر أيضا أستاذنا الدكتور/ ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٤، ص ١٠١.

وضع مثل هذه القواعد، أو بمعنى آخر، سواء بتحويل الاختصاص المذكور إلى اختصاص مفيد أم بتركه كما هو اختصاص تقديرى؟

لهذه الأسباب مجتمعة فإننا لا نقر هذا الاتجاه فيما انتهى إليه من بيان للأساس الذي يستند إليه القاضي الإداري في رقابته للملاءمة أو التناسب في قرارات الضبط الإداري. ومن ثم تكييفه لتلك الرقابة بأنها رقابة مشروعية، خاصة أن الأساس الصحيح للرقابة القضائية على ملاءمة قرارات الضبط الإداري يكمن كما سنرى في اعتبار تلك الرقابة مرحلة من مراحل التطور التي يرغب مجلس الدولة في تحقيقها على مستوى المنازعات الإدارية وذلك بما يتلاءم مع ما يطرأ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية من متغيرات بل ربما يتلاءم مع الدور المتنامي لسياسته القضائية في المجتمع. ذلك الدور الذي يأمل المواطنون في أن يحقق لهم العدالة والحماية في علاقاتهم مع السلطة الإدارية.

فالساسة القضائية la politique juridictionnelle لمجلس الدولة إذن هي التي تشكل الأساس السليم لرقابة الملاءمة أو التناسب في مجالات الضبط الإداري وهو ما نبينه فيما يلي.

المطلب الثاني

السياسة القضائية لمجلس الدولة أساس رقابة الملاءمة في مجال الضبط الإداري

سبق أن بينا العلاقات التاريخية بين كل من الإدارة ومجلس الدولة الفرنسي، ورأينا كيف أن هذه العلاقات قد أملت على القضاء الإداري ضرورة أن يسلك في مواجهة السلطات الإدارية مسلكاً يتسم بالتساهل والتسامح في رقابته على أعمالها التقديرية، وذلك بما يحفظ عليه وجوده

وبقاءه اللذين كانا معرضين لشبهة الإلغاء فيما لو سلك مسلكا آخر. فالإدارة لم تكن لترغب على الإطلاق - نتيجة ما كانت تتمتع به من سيادة ونفوذ آنذاك- أن ترى سلطاتها واختصاصاتها التقديرية قد قيدت من جانب مجلس الدولة الوليد، لتصبح بين غمضة عين وانتباهتها مجردة من كل حرية فيما تباشره من هذه السلطات أو تلك الاختصاصات.

لقد أدرك مجلس الدولة هذه الحقيقة، الأمر الذي دفعه نحو انتهاج سياسة قضائية حكيمة وحذرة في ذات الوقت، سياسة تتمثل في التدرج الواعي اليقظ للرقابة التي يباشرها منذ نشأته على أعمال الإدارة التقديرية . هذه الأعمال التي كان نطاقها متسعا للغاية في ظل ما كان يعرف بأعمال الإدارة البحتة والتي ما كان ليجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه ، وذلك إلى أن بدأ المجلس أولى خطواته نحو الحد من هذا النطاق عندما قبل الطعن على تلك الأعمال بعيبي عدم الاختصاص والشكل . ثم جاءت الخطوة التالية في هذا الاتجاه عندما ظهر في قضاء المجلس عيب الانحراف بالسلطة كقيد على النطاق التقديرى لأعمال الإدارة ، ذلك القيد الذي اختفت معه فكرة الأعمال التقديرية لتحل محلها فكرة السلطة التقديرية كما بينا من قبل.

وهكذا استمر المجلس متدرجا في رقابته حيث باشر بعد ذلك رقابة الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة ثم بمدى تبرير تلك الوقائع لما تتخذه من إجراءات وهي ما يقال لها رقابة التكييف القانوني للوقائع وذلك في حالات دون أخرى ، ثم أراد في مرحلة لاحقة أن يجس نبض الإدارة فيما لو باشر رقابة الملاءمة أو التناسب التي نحن بصددتها على بعض من أعمالها. لذلك فقد اقتصر على أعمال هذه الرقابة في مجال محدود للغاية وهو مجال الضبط الإداري، وذلك على التفصيل السابق بيانه.

هذا ولم يتوقف مجلس الدولة سواء في فرنسا أم في مصر عند هذا الحد بل استمر في اتباع سياسته القضائية تلك ، ذلك أن أية مطالعة بسيطة لأحكام المجلسين تشير - كما سنرى تفصيلا في الباب الثاني من هذه الدراسة- إلى ظهور قيود جديدة في هذا المجال منها على سبيل المثال نظرية الغلو في القضاء الإداري المصري - نظرية الخطأ البين في التقدير ونظرية الموازنة بين التكاليف والمزايا في القضاء الإداري الفرنسي.

إن هذا التدرج القضائي وما يصاحبه من ظهور قيود جديدة على سلطة الإدارة التقديرية دفع جانب من الفقه إلى التساؤل عما إذا كان من شأن استمرار هذه الرقابة القضائية في التطبيق واتجاه نطاقها نحو الاتساع على حساب النطاق التقديرى الذي تمارسه الإدارة أن يؤدي إلى اختفاء فكرة السلطة التقديرية بل وزوالها كلية من مجال النشاط الإداري ، أو بمعنى آخر. ألا يؤدي هذا التطور إلى أن يأتي يوم نتحدث فيه عن سلطة الإدارة التقديرية، كما نتحدث الآن عن أعمالها التقديرية ومن قبلها أعمالها البحتة خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن فكرة السلطة التقديرية ذاتها ، هي فكرة حديثة نسبيا لا تزيد في عمرها إلا قليلا عن خمسة وسبعين عاما^(١).

لقد سبق أن ذكرنا أن مثل هذه التطورات القضائية وإن كانت تشكل ثورة في مجال القضاء الإداري إلا أنها ثورة لا للقضاء على السلطة التقديرية أو من أجل تجريد الإدارة من حق مباشرتها أو تقييد مجالات أعمالها ، وإنما فقط ثورة لضبط وإحكام التوازن الذي من أجله منحت تلك السلطة للإدارة، التوازن بين تمكين الإدارة من مباشرة مرافقها بما يحقق صالح المجتمع ويصون النظام العام فيه، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم^(٢).

(١) الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ٦٨٦.

(٢) فالإدارة كانت ولا تزال وستظل دائما - كما ذهب البعض بحق - متمتعة بجانب من حرية التقدير في نشاطها بصرف النظر عن اتساع هذا الجانب حيناً وضيقه حيناً آخر،

ومع ذلك لا يسعنا أمام هذا التطور القضائي الهام إلا أن نسلم بأن السياسة القضائية الحكيمة لمجلس الدولة هي وراء رقابته للتكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، ومن قبلها رقابته للوجود المادي للوقائع كما بينا، الأمر الذي يؤكد ما سبق أن قلناه بأن القاضي الإداري لم يعد فقط قاضيا للمشروعية وإنما أصبح أيضا قاضيا للملاءمة.

وهنا لنا أن نتساءل عما إذا كان هناك تعارض بين أن يكون للإدارة مكنة إجراء تناسب أو تلاؤم في قراراتها وبين أن يباشر القضاء رقابته على هذه المكنة؟ أو بمعنى آخر هي هناك تعارض بين الملاءمة الإدارية والرقابة القضائية؟

لقد أجاب جانب من الفقه على هذا التساؤل بالإيجاب بل ويرى هذا الجانب أن التعارض ليس فقط بين الرقابة القضائية وبين الملاءمة أو التناسب الذي تجريه الإدارة في مجالات الضبط الإداري، وإنما بين هذه الرقابة والسلطة التقديرية بشكل عام^(١). مستندين في ذلك إلى ما سبق ذكره من تبريرات عديدة، يهمننا من بينها على وجه الخصوص تلك التي تدور حول عجز القاضي الإداري عن إجراء تلك الرقابة وذلك إما لبعده عن

وذلك لأن حرية التقدير ظاهرة تلازم النشاط الإنساني في جميع مستوياته وأشكاله... ولهذا لا ينبغي أن يفهم من الاعتراف للقضاء بدور إنشائي في وضع قواعد القانون الإداري، أحكام الخناق على النشاط الإداري، بحيث ينتهي الأمر إلى أن يكون نشاطها بكل وقائعه، صادرا بالمطابقة التامة مع القواعد القانونية دون أن يكون لها أي قدر من حرية التصرف أو حرية تقدير ملاءمة هذا النشاط.

الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، المرجع السابق، ص ١٨٤.

(1) Di Qual, la compétence liée, op. cit. p. 393, waline, le pouvoir discrétionnaire et sa limitation, op. cit., P.229.

وانظر أيضا: الدكتور/ سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص ٧٨؛ الدكتور/ طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة العربية، ١٩٧٦، ص ٨٧ وما بعدها.

مكان حدوث الوقائع التي استندت إليها الإدارة في قراراتها، وإما لطول الفترة بين حدوث تلك الوقائع وبين الفصل في النزاع الذي ثار بشأنها، وإما أخيراً لضعف خبرته في مجال المشكلات التي تعرض على الإدارة أو بوسائل مجابهتها.

وإذا كانت هذه هي الاعتبارات التي يقول بها الفقه لتبرير استبعاد الرقابة القضائية في المجال الذي تباشر فيه الإدارة اختصاصاتها بما لها من سلطة تقديرية، فلنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الاعتبارات قاصرة على القاضي الإداري، أم أن كلا من القاضي المدني والقاضي الجنائي يواجه أيضاً تلك الاعتبارات عندما يباشر رقابته على النزاع المعروض عليه؟! بل ومما يقلل من شأن الاعتبارات المذكورة في مجال القضاء الإداري، أن هذا القضاء ليس كمثيله المدني أو الجنائي، حيث تربطه بجهة الإدارة صلات خاصة، تجعله قريب منها، وثيق الصلة بها، يعمل معها ويتفاعل مع مشاكلها، ويتبادل وإياها الرأي والنصيحة. فهو - كما يقول أستاذنا السنهوري: "الحليف الطبيعي للإدارة وصديقها الأمين، يسمع لها ويشير عليها ويفتيها في النوازل وهو الذي يرسم بقضائه الحدود فيما تعمل وفيما تترك فينير لها السبيل، ويعبد أمامها الطريق"^(١).

إضافة إلى ذلك فإن القاضي الإداري ينفرد عن كل من القاضي المدني والقاضي الجنائي، بأنه لا يبحث عن حكم القانون السليم، أي لا يبحث في مشروعية أو عدم مشروعية العمل الإداري في المنازعة المطروحة أمامه، بقدر ما يبحث في خصوص هذا العمل عن نقطة التوازن التي تتحقق عندها كل من المصلحة العامة ومصالح الأفراد، الأمر الذي يملئ عليه عدم الاكتفاء فقط بالرجوع إلى نصوص القوانين التي تحكم النزاع،

(١) تقديمه للعدد الأول من مجلة مجلس الدلة، السنة الأولى، يناير ١٩٥٠، ص ٣٠ وما بعدها.

وانما كذلك إلى الظروف والملابسات التي تحيط بهذا النزاع سواء ما يتعلق منها باعتبارات الملاءمة الإدارية وضرورات الإدارة ومتطلباتها، أو ما يتعلق منها بحقوق الأفراد وحرّياتهم . وهو ما يبرر اعتباره في حقيقة الأمر، جهة قضائية مستقلة أكثر من كونه جهة قضائية متخصصة أو نوعية، إذ لو اكتفى بالبحث عن حكم القانون كما يفعل كل من القاضي المدني أو الجنائي أو قاضي الأحوال الشخصية...، لكان من الأفضل أن نكتفى، والحال هكذا بمجرد تخصيص دوائر، بل وحتى محاكم تختص بالفصل في المنازعات الإدارية في ظل نظام قضائي موحد ، كما هو الشأن بالنسبة للدوائر العمالية أو التجارية أو غيرها^(١).

هذه الخصائص أو تلك السمات والتي تحيط بالقضاء الإداري كفيلة في الواقع بالتغلب على الاعتبارات أو الصعوبات التي يقول بها الفقه لتبرير اعتراضهم على رقابة هذا القضاء لما تباشره الإدارة من اختصاصات تقديرية، خاصة ما تعلق منها بالملاءمة أو التناسب وهو الموضوع الذي يهمننا في هذا المقام.

فرقابة القاضي الإداري لمدى تناسب أو ملاءمة قرارات الضبط الإداري إذن لا تتعارض البتة مع ما يجب أن تتمتع به الإدارة من استقلال أو حرية في هذا الشأن، ومن ثم فهي لا تمثل إفتئاتا عليها من جانب القاضي مما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات كما يقول بذلك جانب آخر من الفقه^(٢) ، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه الرقابة لا تعنى على

(١) الدكتور/ السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق والبحوث القانونية والاقتصادية، السنة الخامسة عشرة، ١٩٧٠، العدد الثاني، ص ١١.

(2) Hauriou, précis de droit administratif, paris, 1927, p.375 etss.; Bonnard, précis de droit administratif, paris 4ème éd.,1943 p.95 etss.; La ferrière, traité de la juridiction administrative, 2ème éd, Paris 1896, P. 7 etss.

الإطلاق أن يحل القاضي الإداري نفسه محل رجل الإدارة ، أو أن يعتدى على اختصاصه في هذا الشأن، ذلك أن ما يتوصل إليه رجل الإدارة هذا من تقدير لهذه الملاءمة أو ذلك التناسب هو الذي يشكل في واقع الأمر الإطار أو النطاق الذي تدور فيه رقابة القاضي . تلك الرقابة التي قد تنتهي إما بالإبقاء على القرار المتضمن لهذا التقدير وإما بإلغائه دون تعديل، أي دون أن يصل الأمر إلى حد إصدار القاضي لقرار جديد بدلا من القرار الملغى، أو إلى حد التعديل في مضمون هذا القرار مع الإبقاء عليه . إذ هنا فقط يمكن القول بوجود إفتئات أو اعتداء من جانب القاضي على استقلال وحرية السلطات الإدارية وهو مالم يحدث مطلقا مما يؤكد احترام القاضي الإداري لوظيفته القضائية^(١).

صفوة القول إذن أن رقابة القاضي الإداري للتناسب أو الملاءمة في مجالات الضبط الإداري، إنما هي رقابة ملاءمة وليست رقابة مشروعية، وأن أساسها يكمن - كما ذكرنا - في السياسة القضائية لمجلس الدولة، أو في الاعتبار التاريخية التي ارتبط بها تطور رقابته على أعمال الإدارة للحد من سلطاتها التقديرية، وذلك بما يضمن حماية فعالة لحقوق الأفراد وحياتهم، ودون الانتقاص في ذات الوقت من فعاليته وكفاءة العمل الإداري وما يهدف إليه من تحقيق الصالح العام.

وأُنظر أيضا الدكتور/ السيد محمد إبراهيم، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات تأديبية، مجلة العلوم الإدارية، العدد اثناني، السنة الخامسة، ١٩٦٣، ص ٢٧٥ وما بعدها؛ الدكتور/ سعد عصفور والدكتور/ محسن خليل، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٦٨، ص ٧٨ وما بعدها.

(1) "... on constate que le juge de l'excès de pouvoir à l'intention de rétablir la déontologie administrative et d'éviter les sanctions, formelles, il ne substitue nullement sa décision à l'acte en cause respectant ainsi sa fonction juridictionnelle. stavroula (K.) op. cit. P. 318.

ولهذا يلاحظ أن القضاء الإداري يزحف بتلك الرقابة إلى الأمام، كلما وجد الفرصة سانحة أو مواتية لذلك وهو ما تظهره الاتجاهات الحديثة في قضائه والتي نتناولها في الباب الثاني.

الباب الثاني

**الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة
الفرنسي للحد من سلط الإدارة التقديرية
وموقف مجلس الدولة المصري منها**

الباب الثاني

الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

للحد من سلطة الإدارة التقديرية

وموقف مجلس الدولة المصري منها

بينما فيما سبق كيف تطور مجلس الدولة الفرنسي في رقابته للأعمال الصادرة عن الإدارة بمقتضى ما تتمتع به من سلطة تقديرية، وكيف سلك في هذا الخصوص سياسة قضائية رائعة اتسمت بالتدرج الهادئ والثابت من ناحية، وبعدم إثارة حفيظة الإدارة أو بعدم إثارة مشاعر العداء لديها من ناحية أخرى.

فقد اتجه بداءة - كما رأينا - إلى إنكار كل دور رقابي له في مجال تلك الأعمال، ثم ما لبث أن غير من سياسته هذه ، ولكن بحذر شديد، حيث بدأ برقابة الغلط في القانون، ثم الغلط في الوقائع، ثم مد هذه الرقابة - كقاعدة عامة - إلى التكييف القانوني للوقائع ، وأخيراً انتهى المجلس ببسط رقابته ولكن استثناء من القاعدة العامة في قضائه، على تقدير الإدارة لخطورة وأهمية الوقائع التي تدعيها ومدى تناسب الإجراء الذي اتخذته مع هذه الخطورة أو تلك الأهمية، لدرجة أنه وصل به الأمر في بعض الحالات إلى أن يحل تقديره أو تقييمه هو للوقائع بدلا من تقدير وتقييم رجل الإدارة.

حقيقة أن الاتجاهات المتطورة التي أصابها المجلس في هذا الصدد لم تستغرق وقتاً طويلاً حيث بدأت - كما ذكرنا - في نهاية القرن الماضي واستقرت قبل منتصف القرن الحالي، إلا أنه أصبح ينظر إليها مع ذلك على أنها لا تمثل سوى مجموعة من المبادئ أو القواعد القضائية الثابتة أو الدارجة في العمل القضائي للحد من سلطة الإدارة التقديرية، أو بمعنى آخر أصبح ينظر إليها على أنها لا تعدو أن تكون مجرد اتجاهات

تقليديه ليس فقط في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وإنما أيضا في قضاء نظيره المصري للحد من تلك السلطة.

لذلك وأمام إحساس مجلس الدولة الفرنسي بعدم كفاية هذه الاتجاهات أو عدم كفاية ما تنطوي عليه من أساليب وأنماط رقابية لا تشتمل عليه من نقاط ضعف أو من ثغرات تسمح للإدارة في بعض الأحيان من أن تباشر سلطاتها التقديرية بشكل تحكيمي أو تعسفي، خاصه في المجالات الحديثة الدولة المعاصرة؛ أمام ذلك ولمواجهة هذا الوضع، فقد خطا هذا المجلس في الآونة الأخيرة، وعلى وجه التحديد ابتداء من عام ١٩٦١ خطوات هامة وجاده في هذا المجال، خطوات لم يكن الفقه الإداري متوقعا إياها أو مبادرا بمحتواها خطوات تشكل في حقيقتها ثوره في مجال القضاء الإداري على سلطة الإدارة التقديرية - ثورة لا للقضاء على هذه السلطة، أو لتجريد الإدارة من حق مباشرتها أو تقييد مجالات أعمالها، وإنما فقط ثورة لضبط وإحكام التوازن الذي من أجله منحت هذه السلطة للإدارة التوازن بين تمكين هذه الأخيرة من إدارة مرافقها بما يحقق صالح المجتمع ويصون النظام العام فيه، وبين حماية وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم.

وتمثلت أولى تلك الخطوات فيما يعرف برقابة الخطأ البين في التقدير، وهي الرقابة التي أصبحت تمثل نظرية أو مبدأ عاما في فقه وقضاء القانون العام، حيث أصبح القاضي الإداري يلجأ إليها في كافة مجالات ذلك القانون لتأكيد دوره الفعال في إحكام وتحقيق التوازن المشار إليه، إضافة الى ذلك فقد خطا مجلس الدولة في هذا الاتجاه خطوة أخرى ، وذلك بانتهاجه أسلوب الموازنة بين المنافع والأضرار في الرقابة، لكي يحكم قبضته على كيفية مباشرة الإدارة لسلطاتها التقديرية ومنعها بالتالي من كل تسلط أو تحكم محتمل في هذا الشأن.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة المصري وإن كان قد ابتدع نضاء الغلو في مجالات التأديب الإداري، إلا أنه لم يجعل من هذا القضاء نظرية أو مبدأ عاماً يطبق في مختلف مجالات النشاط الإداري، كما هو الحال بالنسبة لنظرية الخطأ البين في القضاء الإداري الفرنسي . إضافة إلى أنه لم يأخذ أو يتبنى حتى الآن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، حيث يبدو من أحكامه التي أصدرها في المجالات التي تطبق فيها هذه النظرية، خاصه ذلك المجال الذي ظهرت فيه لأول مرة وهو مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، أنه لا زال على عهده القديم وفيماً للمبادئ المستقرة في هذا الشأن. وإن كنا نتمنى بل ونأمل أن يسير مجلسنا الفتى على ذات درب مجلس الدولة الفرنسي في خطواته التقدمية الحديثة في مجال الرقابة على سلطة الإدارة التقديرية لما يمثله هذا الدرب من سبيل أمثل لضمان وحماية حقوق الأفراد وحياتهم دون إعاقة الإدارة في ذات الوقت عن مباشرة مرافقها بما يحقق الصالح العام.

وتبيننا لهذا الإجمال تتناول فما يلي الموضوعين التاليين،
مخصصين لكل موضوع منهما فصلاً مستقلاً:

- نظرية رقابة الخطة البين.

- نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

الفصل الأول

نظرية رقابة الخطأ البين^(١)

(١) ذهب بعض من الفقه الى تسمية هذه النظرية باسم "الغلط البين". دكتور/ يحيى الجمل، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع، مجلة القانون والاقتصاد، حقوق القاهرة، العددان الثالث والرابع، السنة الحادية والأربعون، ١٩٧٢، ص ٤٣٩؛ دكتور/ محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف وتقدير الوقائع في دعوى الإلغاء، دكتوراه، حقوق عين شمس، ١٩٩٢. ومن جانبنا نفضل مصطلح "الخطأ البين" حتى لا يختلط الأمر مع نظرية "الغلط في القانون المدني" خاصة أن لكل من النظريتين أحكاما تتميز بها عن الأخرى سواء من حيث المضمون أم من حيث مجالات التطبيق أم من حيث أطراف العلاقة.... الخ. بل وحتى نجعل القانون الإداري ذاتية واستقلالا في مواجهة ذلك القانون الأخير.

حول نظرية الخطأ البين في التقدير أنظر:

أولا: في الفقه الفرنسي:

Bourgeois (JP) l'erreur manifeste d'appréciation, L'Espace Juridique université de Lille, 1988; Lagasse (D.), L'erreur manifeste d'appréciation en droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 1986; Rousseau (D.) Le contrôle de l'opportunité de l'action administrative par le Juge administratif, thèse, 2 vol., Poitiers, 1979; Galabert et Gentot, le contrôle de l'erreur manifeste par le Juge de l'excès de pouvoir, chron. générale de la Juris. adm. A.J.D.A., 1962, p.552; Henry (J.P) une nouvelle fonction pour l'erreur manifeste, AID.A., 1979.p.17; Kornprobst (B.) l'erreur manifeste, D. chr., 1965 p.121 Labetoulle et Cabanes, Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-erreur manifeste d'appréciation, chr. De Jur. A.J.D.A. 1971, p.33.; Letourneur (M.) L'erreur manifeste d'appréciation dans la Juris. du C.E., in mélanges GANSCHOF van der MEERSCH, M11, p.563; MOUSSA(H), aspects de l'erreur manifeste d'appréciation et des pouvoirs discrétionnaire et lié, prétend droit de l'administration à l'erreur non manifeste et présomption quasi-irréfragable de légalité chr. de Jur., le "quotidien Juridique", 1987N 45,46 et 47., Rouvière (J.), Reflexion sur l'erreur manifeste, E.D.C.E, 1988, p.65, Vincent (J.Y) l'erreur manifeste d'appréciation, Rev. adm., 1971, p.407.

ثانيا في الفقه العربي:

دكتور/ يحيى الجمل، المرجع السابق، دكتور/ محمود سلامة جبر، المرجع السابق؛ دكتور/ محمد فريد سيد سليمان الزهيري، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، دكتوراه، جامعة المنصورة، ١٩٨٩؛ دكتور/ ثروت عبد العال أحمد، الرقابة القضائية على

تعد نظرية رقابة الخطأ البين من المستجدات التي استحدثتها مجلس الدولة الفرنسي في رقابته للمنازعات الإدارية، استحدثتها بهدوء لدرجة يمكن أن يقال معها أنه فاجأ بها ليس فقط فقه القانون الإداري، وإنما أيضا مفوضى الحكومة الذين يعملون معه في ذات الساحة القضائية، حتى أن جانبا من الفقه ذهب إلى حد القول بأن هذه النظرية قد دخلت مجال القضاء الإداري سرا^(١).

حقيقة أن هذه النظرية قد وجدت بشكل أو بآخر في بلدان أخرى مثل سويسرا - إنجلترا - بلجيكا ، بل إن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية L.O.I.T قد عرفت هذا النوع من أنواع الرقابة^(٢) إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يكتسب مع ذلك في خصوص تلك النظرية فضل السبق في حسن صياغتها وفي تعميم مجالات أعمالها ، بل لقد جعل منها نظرية عامه في نطاق القانون الإداري لا تقل في أهميتها - كما ذهب البعض بحق - عن أهمية نظرية السلطة التقديرية ذاتها^(٣).

ملاءمة القرارات الإدارية، دكتوراه، جامعة أسبوط، ١٩٩٢؛ دكتور/ محمد ميرغني خيرى، التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، دكتوراه، جامعة عين شمس، ١٩٧٢؛ دكتور/ حلمى الدقوقي، رقابة القضاء على المشروعات الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دكتوراه، جامعة القاهرة، ١٩٨٩.

(1) L'entré de L'erreur manifeste dans le contentieux administratif Fut discrète" Kornprobst (B.),op. cit. P.127.

(2) Chauvin, le contrôle de la légalité des actes administratifs en droit suisse, thèse, paris, 1970, p. 48 etss.; Letourneur (M.) une Juris prudence administrative originale : la Jur . du Tribunal de l'o.i,t; in melange P.COUZINET, univ. des sci. soc. de toulouse, 1974. P. 449; Dreyfus (F.) les limitations du pouvoir discrétionnaire par l'application du principe de proportionnalité á propos de trois Jugements du tribunal adm. de l'O.I.T,R.D.P., 1974, P. 691 Moussa (H.),op. cit, No 46, P.12

(٣) بل لعل جهود مجلس الدولة الفرنسي في مجال إبراز معالم هذه النظرية وصلت إلى الحد الذي جعل منها نظرية عامة غير مقصورة على مجال القانون الإداري وحده، وإنما امتدت أيضا إلى قضاء المجلس الدستورية فيما يمارسه من رقابة على دستورية القوانين.

فالقاضي الإداري أصبح بفضل هذه النظرية يراقب الإدارة في تقييمها للوقائع التي تدعيها كأساس لقراراتها وذلك في حالات لم تكن تخضع في خصوصها من قبل لمثل تلك الرقابة ، ليتأكد من أنها لم ترتكب عند اجراء هذا التقييم خطأ يوصف عادة أنه خطأ بين أو ظاهر، والذي لا يؤخذ في الاعتبار - والحال هكذا - إلا بدءاً من درجة معينة D'UN CERTIAN SEUIL يستشعر معها القاضي أن هناك خلافاً قد أصاب ذلك التقييم، جعله تقييماً غير معقول أو مخالف للصواب.

وهكذا تبدو أهمية ذلك التكنيك الحديث في الحد من سلطة الإدارة التقديرية أو بمعنى أدق في تضيق المدى الكلاسيكي للفارق بين مجال الرقابة القضائية ومجال هذه السلطة. بل لقد برزت تلك الأهمية على أثر

Cons. Contit., 8 -23 aout, 1985, decoupage territorial de la nouvellecalédonie, Rev. adm., 1986, chr. Villiers, P. 325.

وإن كان قد وجه إلى المجلس الدستوري بمناسبة تطبيقه لنظرية الخطأ البين فقد تمثل في أنه لا يتمتع، كما هو الحال بالنسبة للإدارة بسلطة تقديرية وإنما بسلطة سيادية، كما أنه يبدو من الصعب أن بسند إلى البرلمان الذي يمثل هيئة منتخبة ويتكون من جمع من الأعضاء، خطأ ظاهر أو جسيم ويتم اكتشافه من جانب عدد محدود من القضاة، هم أعضاء المجلس الدستوري.

Habib (L.), La notion d'erreur manifeste dans la Jurisprudence du cons. Cons. R.D.P. 1986, P. 702; Savy, La constitution de Juges, D. 1983, Chr. Xix., P. 109.

كما أن محكمة النقض الفرنسية اتجهت مؤخراً نحو تطبيق النظرية التي نحن بصدددها، وذلك في مجال رقابتها على تقدير قاضي الموضوع للوقائع التي يستند إليها صاحب العمل فيما يصدره من قرارات فصل العمال وتسريحهم من الخدمة، وهو تقدير - كما هو معروف - يستقل به قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، غير أن هذه الأخيرة اتجهت إلى بسط رقابتها على هذا التقدير وإلغاء الحكم الذي يصدره قاضي الموضوع متى كان تقديره مشوباً بخطأ بين.

Cour du cass., 21 dec., 1985, Le feuvre, D. 1986, P. 120. Note Boré (J).

دكتور/ ثروت عبد العال أحمد، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٤، ص ٣٣٥.

تزايد مجالات العمل الإداري التي تتمتع الإدارة في خصوصها - بحكم طبيعة تلك المجالات - بسلطة تقديرية واسعة ، مثل مجالات التوجيه أو التدخل الاقتصادي - المجالات المالية - المجالات المهنية - المجالات الفنية...الخ. إذ أصبح من الضروري - والحال هكذا - إيجاد وسيلة تكبح جماح مخاطر التوسع الحديث لتلك السلطة.

فكانت نظرية رقابة الخطأ البين كمرحلة حاسمة في تاريخ منازعات أسباب العمل الإداري، مرحلة خطا بها مجلس الدولة الفرنسي - كما ذكرنا - خطوة جديدة الى الأمام، تضاف إلى خطواته السابقة في هذا المجال والتي بدأها منذ بداية القرن الحالي، وذلك من منطلق حرصه على تحقيق أكبر قدر من الضمان والفعالية لحقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية ، ولحقوق الإدارة وحريتها في تقدير وتقييم ملاءمة أعمالها من ناحية أخرى.

إن نقطة التوازن Point d'équilibre بين هذه الناحية وتلك تعد في حقيقة الأمر وكما قال الأستاذ Waline ، المشكلة الأساسية في القانون الإداري، بل والمشكلة الأساسية التي واجهها القضاء الإداري خلال مراحل تطوره المختلفة، باعتبار أنها نقطة لا تتسم بالثبات والجمود، وإنما بالتغير والحركة تبعا لتغير وحركة أحداث الحياة بصفة عامة؛ الأمر الذي يتطلب دوما من هذا القضاء، البحث والتجديد والتطوير في نظرياته بما يتلاءم مع تلك الأحداث.

من هنا يمكن القول إن نظرية رقابة الخطأ البين تعد واحدة من نتائج هذا البحث والتجديد و التطوير. فكيف إذن ظهرت هذه النظرية؟ وما هو مضمونها ؟ بل ما هو نطاق تطبيقها في مجال العمل الإداري ؟ وأخيرا ما هو موقف مجلس الدولة المصري من تلك النظرية؟

هذا ما نبينه من خلال تناولنا للمسائل التالية:

- مراحل ظهور رقابة الخطأ البين ومعيار هذه الرقابة وموقعها بين مستويات الرقابة القضائية.
- نطاق تطبيق رقابة الخطأ البين.
- موقف مجلس الدولة المصري من رقابة الخطأ البين.

المبحث الأول

مراحل ظهور رقابة الخطأ البين ومعيار هذه الرقابة وموقعها بين مستويات الرقابة القضائية

لم يكن ظهور نظرية رقابة الخطأ البين في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، نتيجة أبحاث رجال الفقه الإداري، أو نتيجة مطالبة من جانب مفوضى الحكومة، إنما ظهرت في واقع الأمر - وكما ذكرنا - كعمل قضائي خالص.

ومع ذلك يلاحظ أن مجلس الدولة لم يهتم ببيان مضمون هذه النظرية، أو بوضع معيار منضبط لها ، مكتفيا في هذه الشأن بإقرار الفكرة في قضائه دون الدخول في شرح وبيان كافة العناصر التي تحيط بها ، وهو ما يتفق في الواقع ومسلكه العام في هذا الصدد كما بينا ، كما أن الفقه الإداري من جانبه لم يعط لهذه العناصر ما تستحق من دراسة وبحث يتناسبان وأهمية هذا البناء القضائي الحديث، وإن كانت هناك إشارات قليلة وردت في بعض المؤلفات أو التعليقات الفقهية تلقى بعضا من الضوء عليها.

لذلك ولمزيد من الإيضاح نتناول فيما يلي الموضوعات التالية مخصصين لكل موضوع منها مطلبا مستقلا.

- مراحل ظهور رقابة الخطأ البين.
- معيار الخطأ البين.
- موقع رقابة الخطأ البين بين مستويات الرقابة القضائية.

المطلب الأول

مراحل ظهور رقابة الخطأ البين

بداءة تجدر الإشارة إلى أن نظرية الخطأ البين قد ظهرت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ عام ١٩٥٣ ولكن بصورة ضمنية حيث أعملها ذلك المجلس في أحكامه دون أن يشير إليها صراحة، أو أن يطلق على الخطأ الذي باشر عليه رقابته من خلالها مصطلحا معينا، وذلك على عكس ما حدث ابتداء من عام ١٩٦١، حينما أصدر حكما بتاريخ ١٥ فبراير من هذا العام نقل به تلك النظرية من الضمنية أو التلميح إلى الإعلان أو التصريح إذ استخدم في هذا الحكم ولأول مرة مصطلحا يدل عليها دون منازع حيث يقول -كما سنرى - أن تقييم الإدارة لتعادل الوظائف لا يناقش أمام قاضي تجاوز السلطة إلا في حالة الغياب أو التخلف البين للتعادل^(١).

Souf dans le cas d'absence manifeste d'équivalence.

حقيقة أن مجلس الدولة لم يذكر أو يشر صراحة في هذا الحكم الأخير إلى فكرة الخطأ البين أو الواضح ، إلا أن استخدامه لمصطلح قريب منه أو مشابه له إلى حدما، يعني من ناحية، أن اتجاهه نحو رقابة التقييم التقديري للإدارة في بعض المجالات التي لم تكن خاضعة لمثل تلك الرقابة قد بدأ يتغير ويتخذ مسلكا مغايرا لمسلكه السابق في هذا الشأن ، كما يعني من ناحيه أخرى أنه كان يمهد للإعلان عن نظريته الجديدة في الرقابة، وقد تأكد ذلك من خلال حكم آخر له صدر في ذات عام ١٩٦١، أشار فيه

(1) C.E., 15 Fev. 1961, Lagrange, Rec., P. 121; A.J.D. 1961, chr. Galabert et Gentot, P. 201.

صراحة إلى فكرة الخطأ البين التقدير كوسيلة فاعلة لرقابة التقدير الإداري للإدارة.

إن هذا الأسلوب يتفق في الواقع وسياسة مجلس الدولة الفرنسي التي تتسم - كما ذكرنا - بالتدرج والتطور الهادئ ، والبعد بالتالي عن التحول المفاجئ في التعامل مع الإدارة ، خاصة فيما يتعلق بما تباشره من اختصاصات أو سلطات تقديرية.

ومنذ صدور هذا الحكم الأخير ولم يكف مجلس الدولة الفرنسي عن أن يعلن في أحكامه المتعددة عن هذا التكنيك الحديث لا في مجال تعادل الأراضي الزراعية أو الوظائف العامة فقط وإنما أيضا في مجالات أخرى عديدة كما سنرى، لدرجة أصبح الخطأ البين معها وجها مألوفاً من أوجه رقابة الإلغاء.

وهكذا يمكننا أن نبرز ملامح ظهور وتطور نظرية رقابة الخطأ البين في قضاء مجلس الدولة الفرنسي من خلال دراستنا لأربع مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: من عام ١٩٥٣ حتى عام ١٩٦٠: لا يمكن الجزم خلال هذه المرحلة بأن نظرية رقابة الخطأ البين في تقدير الإدارة لملاءمة قراراتها، قد ظهرت على الساحة القضائية بشكل واضح أو محدد المعالم، أو بصورة تدعو إلى القول بأن مجلس الدولة قد اعتنقها كفيد يحد به من السلطة التقديرية للإدارة ، وإنما ظهرت في واقع الأمر كاتجاه أو كسلوك يرمي مجلس الدولة من ورائه التخفيف من حدة تراجعها عن رقابة التكيف القانوني في المجالات التي تنور بصدها فكرة المقارنة أو المعادلة، كتلك المتعلقة - كما بينا من قبل - بالأراضي الزراعية أو الوظائف العامة، فقد

وجد مجلس الدولة نفسه إزاء تلك المجالات - وكما يقول الأستاذ Pacteau (B.)، في حاجة لإجراء رقابة يوازن بها بين امتناعه عن مباشرة رقابة التكييف هذه، وبين عدم وقوفه مكتوف الأيدي تجاه ما تجربته الإدارة من تقدير في خصوصها ، الأمر لذي يخشى معه أن تتحول هذه الأخيرة إلى حكم أكثر من كونها إدارة"^(١).

لذلك فقد توصل إلى صيغة وسطى une formule intermédiaire، تمكنه من ذلك، وتتضح هذه الصيغة من حكمة Denizet الصادر في ١٣ نوفمبر ١٩٥٣ حيث يقول فيه: أنه ينتج بوضوح manifestement من قواعد تنظيم الوزارة الفرنسية لما وراء البحار، أنه ليس هناك وظيفة تعادل وظيفة إداري مستعمرات^(٢)، وقد كرر المجلس لفظه "وضوح" أيضا في حكم آخر مشابه للحكم السابق أصدره في عام ١٩٥٨^(٣).

وهكذا ظهر لأول مرة في القضاء الإداري الفرنسي مصطلح الوضوح manifestement، أو بمعنى أدق، ظهر هذا المصطلح لأول مره في مجال كانت تتمتع فيه الإدارة بسلطة تقديرية^(٤). حقيقة أن ذلك لا يعني تبني مجلس الدولة للنظرية التي نحن بصددھا، أو على الأقل تبنيھ لها بالصورة التي هي عليها الآن. خاصة أن الأحكام التي صدرت خلال تلك الفترة

(1) "Le Juge de l'excès de pouvoir et les motifs de l'acte administratif thèse, Paris, 1977, p. 238.

(2) S'il résultait manifestement des règles d'organisation du Ministère de La France d'outre-Mer, qu'aucun emploi équivalent ne pouvait être trouvé à celui d' administrateur des colonies".

(3) C.E, 19 Fevr., 1958, dame Poirier et autres, Rec., P. 111

(٤) ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الخطأ الظاهر أو الصارخ "Flagrante" كان قد استعمل من قبل، ولكن في مجال الرقابة على المشروعات، وذلك كما في حالة الرقابة على قرارات لجان التعويض عن أضرار الحرب.

Vincent, l'erreur manifeste, op. cit., P. 408.

وأشارت إلى كلمة الوضوح لم تتجاوز الثلاثة أحكام، بل ولم تكن هذه النظرية أساسا لإلغاء القرار المطعون عليه في أي منها ، إضافة إلى ذلك - وكما يقول الأستاذ باكتو - أن صياغة تلك الأحكام لم تكن دقيقة أو جلية في هذا الخصوص^(١).

ومع ذلك يمكن القول أنه غالبا ما يكون الظهور فكرة جديدة في القضاء لإداري - أي ظهور فكرة لم تكن قد وجدت من قبل في هذا القضاء - غالبا ما يكون له دلالة خاصة أو معينة. هذه الدلالة قد تكون الرغبة في التغيير أو التطوير، أو الرغبة في لفت الانتباه إلى مسلك مستقبلي جديد يرغب القضاء الإداري في تبنيه أو إرسائه؛ ولهذا يلاحظ أن المجلس كي يؤكد أن فكرة الوضوح لم تتردد في أحكامه بصورة عفوية أو دون أية فعالية، فقد بدأ يباشرها في مجال آخر غير مجال الوظيفة العامة وهو مجال الأراضي الزراعية، وكان ذلك بمناسبة دعوى تدور وقائعها حول مبادلة أراضي زراعية بأخرى بمناسبة تجميع وتوزيع الأراضي الزراعية في منطقة معينة. فقد حدث أن استولت الإدارة والممثلة في لجنة شبه قضائية، على قطعة أرض مملوكة للسيد Gesbert وذلك في مقابل إعطائه قطعة أخرى، رأى أنها تقل جودة وكفاءة إنتاجية عن أرضه ، مدلاً على ذلك بما كان من فارق في النقاط بين القطعتين، إذ بينما كانت القطعة الأولى والمملوكة له تساوي ٤٥٧٠٨ نقطة، كانت القطعة الثانية محل المبادلة تساوي ٤٢١٠٨ نقطة، أي أن الفارق بينهما كان يساوي ٣٦٠٠ نقطة، مع أن الفارق المسموح به قانونا في هذا الخصوص يجب ألا يتجاوز ٨٧٩ نقطة تقريبا أي ما يعادل ١٪.

(1) op. cit., P. 239.

ولهذا فقد طعن في قرار الاستيلاء أمام المحكمة الإدارية المختصة ،
والتي قضت بإلغاء هذا القرار لعدم التعادل بين القطعتين المشار إليهما، أو
كما تقول المحكمة^(١):

"Un écart qui présente une importance telle que la règle
de l'équivalence ... ne peut être regardée comme respectée".

وعندما طعن وزير الزراعة على هذا الحكم أمام مجلس الدول، أيد
هذا المجلس الحكم الصادر من المحكمة الإدارية وذلك بعد أن قام بحث
مدى التعادل بين القطعتين محل المنازعة، وذلك خلافاً لمسلكه السابق في
الامتناع عن رقابة تقدير الإدارة لوجود أو عدم وجود مثل هذا التعادل.

هذا ويلاحظ أن مجلس الدولة لم يشر في هذا الحكم الى مصطلح
الوضوح manifestement السابق الإشارة إليه، وإن كان قد استخدم
مصطلحا آخر يدل عليه ؛ إذ بعد أن قام بالبحث في موضوع النزاع، انتهى
الى القول بأن:

L'écart ainsi constaté présente une importance telle
que la règle de l' équivalence posée par la loi ne peut
être regardée comme respectée "

حاصل القول إذن أن المرحلة الأولى لظهور نظرية الخطأ البين لم
تكن في حقيقة الأمر أكثر من لبنة أولى وضعها مجلس الدولة لتكون أساساً
لبناء قضائي يهدف من إقامته إلى الحد من سلطه الإدارة التقديرية.

(1) C.E., 2 mare1960, Secrétaire d'Etat à l'agriculture C. Gesbert, Rec.,
P. 62.

المرحلة الثانية: من بداية عام ١٩٦١ حتى نهاية عام ١٩٦٢:

في خلال تلك الفترة يمكن القول دون تردد أن نظرية الخطأ البين، بدأت في الوضوح والثبات، بل وبدأت تتردد على ألسنة الفقهاء وكذلك مفوضى الحكومة. اذ بعد أن بدأ عام ١٩٦١ بشهر ونصف فقط وبالتحديد في ١٥ فبراير من هذا العام، أصدر مجلس الدولة - في نطاق الوظيفة العامة أيضا وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعادل الوظائف - حكما تجاوز به مجرد التلميح بهذه النظرية إلى حد الإعلان أو التصريح بها^(١)، حيث أشار فيه إلى مضمونها صراحة ؛ ولهذا يعد تاريخ هذا الحكم البداية الحقيقية لظهور تلك النظرية إذ على الرغم من إقرار هذا القضاء من أن الإدارة تملك بمقتضى أحكام القانون الصادر في ٣ سبتمبر ١٩٤٧، إعادة تنظيم الجهاز الإداري وذلك بأن تلغى ما ترى إلغائه من وظائف، أو بتقدير أي الوظائف الشاغرة تعادل تلك الملغاة باعتبار أنها الأقدر على إجراء ذلك بما لها من خبرة ودراية في هذا الشأن، رغم ذلك فإن المجلس قد انتهى في الحكم المشار إليه إلى القول، بأن الإدارة وإن كانت حرة في تقدير قيام التعادل بين الوظائف أو عدم قيامه، إلا أن هذا التقدير لا يجب أن يكون مبنيًا على عدم تعادل بين أو واضح:

"Sauf dans le cas d' absence manifeste d' équivalence "

وهكذا وجد مضمون نظرية رقابة الخطأ البين في القضاء الإداري الفرنسي بشكل لا يقبل الجدل أو النقاش، نقول وجد مضمون النظرية، ولا نقول وجد اسم النظرية، حيث لم يشر هذا الحكم إلى مصطلح الخطأ البين، كما لم تشر التعليقات الصادرة على أساسه إلى هذا المصطلح. إلا أن ذلك

(1) C.E., Lagrange, Rec., P. 121.

لا يقلل في الواقع من أهمية الحكم السابق في إخراج تلك النظرية إلى حيز الوجود، كأسلوب جديد للحد من سلطه الإدارة التقديرية؛ إذ العبرة كما نعلم لا بشكل الشيء أو اسمه وإنما بجوهره ومضمونه.

هذا ولم يمض أكثر من أربعة أشهر على صدور حكم Lagrange السابق، إلا وصدر حكم آخر يفصح فيه مجلس الدولة، لا عن مضمون النظرية فحسب وإنما أيضا عن اسمها. وكان هذا الحكم بمناسبه نزاع حول مبادلة الأراضي الزراعية التي تتم وفقا لعمليات التجميع الزراعي remembrement rural السابق الإشارة إليها^(١). فقد رفعت الأنسة Achart دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة تطلب فيها إلغاء قرار اللجنة المشرفة على عملية التجميع لاعتقادها بأن هذه اللجنة لم تقدر قطعة الأرض التي كانت تملكها تقديرا صحيحا؛ حيث أعطتها قطعة أرض أخرى تقل كثيرا في قيمتها عن القطعة المملوكة لها؛ إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى، وعلى أثر ذلك تقدمت المدعية إلى مجلس الدولة بطعن في الحكم المذكور ولكن المجلس رفض هذا الطعن مؤيدا حكم المحكمة الإدارية، لا لأنه لا يختص برقابة تقدير الإدارة لمعادلة الأراضي الزراعية - كما كان يفعل في الماضي - وإنما لأنه وجد أن تقدير الإدارة لم يشبه خطأ بين، أو كما يقول المجلس:

"... que cette appreciation portée sur la vocation cultureale des sols et qui n'est pas entachée d'erreur manifeste n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'accès de pouvoir..".

(1) C.E., 13 Juill, 1961, Delle Achart, Rec. P. 476, A.J.D.A., 1982, P. 552.

وكما هو واضح فإن مجلس الدولة استعمل في الحكم السابق ولأول مرة مصطلح "الخطأ البين" *erreur manifeste* ليعبر به عن مضمون النظرية التي نحن بصدددها. ومن ثم يمكن القول إن هذا الحكم بعد تتويجا وتجسيدا صريحا لتلك النظرية سواء من حيث الشكل أو المصطلح أم من حيث الجوهر والمضمون. وقد تأكد ذلك بصدور حكم آخر استعمل فيه مجلس الدولة أيضا مصطلح الخطأ البين^(١)، ذلك المصطلح الذي أصبح بعد ذلك مصطلحا تقليديا للتعبير عن واحد من السياسات القضائية لرقابة السلطة التقديرية أو لرقابة الملاءمة في مجال القرارات الإدارية.

المرحلة الثالثة: من عام ١٩٦٢ حتى عام ١٩٧٢: يمكن أن توصف هذه المرحلة بمرحلة اتساع وتعدد مجالات تطبيق نظرية الخطأ البين، إذ بعد أن كانت تطبق فقط في مجال معادلة الوظائف العامة ومبادلة الأراضي الزراعية وهما ما يمكن أن يقال لهما المجالين التقليديين لتلك النظرية، أصبحت تطبق بدأ من عام ١٩٦٣ في مجالات أخرى عديده، خاصة المجالات الحديثة للإدارة والتي يغلب عليها الطابع الفني أو التقني المعقد والتي تحتم، بحكم طبيعتها أن يكون للإدارة في خصوصها - كما ذكرنا من قبل - قدر من الحرية في التقدير.

(1) C.E. mai 1962, commune de Montfermeil /c. sieur Foittier, Rec p. 304.

وتخلص وقائع هذه القضية في أن المجلس البلدي لمدينة Montfermeil أصدر قرارا بإلغاء إحدى الوظائف الخاصة به مع تسريح شاغلها وهو السيد Foittier فطعن هذا الأخير على القرار السابق أمام المحكمة الإدارية لفرساي على أساس وجود وظيفة أخرى بالبلدية تعادل وظيفته الملغاة، وتتوافر فيه شروط شغلها، ومع ذلك رفضت البلدية نقله إليها، وحكمت هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وقد تأيد هذا الحكم من مجلس الدولة الذي أعلن بطلان تسريح السيد Foittier من الخدمة لوجود وظيفة أخرى معادله لوظيفته بشكل بين:

"..... Manifestement equivalaient a f' emploi supprimée du sieur Forittier...".

بل وحتى في المجالين التقليديين المشار إليهما، فقد تطور تطبيق النظرية في خصوصهما خلال تلك المرحلة: ففي مجال الوظيفة العامة مثلاً، لم يعد إعمال نظرية رقابة الخطأ البين قاصراً فقط على موضوع التعادل بين الوظائف، وإنما شمل أيضاً موضوع التعادل بين الكادرات المتشابهة أو المجموعات الوظيفية، بحيث أصبح تقدير الإدارة لمثل هذا التعادل أو التشابه باطلاً إذا شابه - كما يقول مجلس الدولة - خطأً بين^(١). كما امتد كذلك ليشمل موضوع الترقيات . فقد رفع السيد Maurel دعوى أمام مجلس الدولة يطلب فيها إلغاء قرار الإدارة الضمني بعدم ترقيته، إلا أن المجلس رفض طعنه على أساس أن تقدير الإدارة في هذه الحالة لم يشبه خطأً بين، وهو ما يعني أن سلطة الإدارة التقديرية في إجراء الترقية من عدمه لم تعد خارج مجال الرقابة القضائية إذا شاب تصرفها خطأً بين في التقدير^(٢). وأخيراً فقد شمل تطبيق النظرية كافة سياسات الوظيفة العامة مثل النذب^(٣) Détachement الاستيداع^(٤) Le mise en disponibilité - الوقف عن العمل^(٥) La suspension - الكفاءة المهنية^(٦) L'aptitude professionnelle....الخ.

أما في المجال التقليدي الآخر وهو مجال مبادلة الأراضي الزراعية فقد شهد تطبيق النظرية التي نحن بصدددها أيضاً تطوراً خلال تلك المرحلة،

(1) C.E., 17 mai. 1961, Delle Cavaignac, Rec. P. 319.

(2) C.E., 22 fev. 1963, Rec. P. 119.

(3) C.E. 24 mai 1968, Dame Paoli, Tables décennales, p.792; 2 dec 1987, Tanesie, T. P.788

(4) C.E. 25 mars 1987, Mme Josseline ELL, Rec.p.105, A.J.D.A.1987, P.605

(5) C.E. 17 nov. 1986, Edwige, Rec. P.350.

(6) C.E.16 dec .1988, M. Bleton, C./saravin ,A.J.D.A.,1989 P. 102, chr. Azibert et Boisdeffre, R.F.D.A., 1989, P. 522 concl. Ch. Vigouroux.

حيث لم يعد ذلك التطبيق مقتصرًا على مجرد التعادل الكمي أو الحسابي بين قطع الأراضي محل التبادل، وإنما امتد ليشمل كذلك التعادل الكيفي أو النوعي، مثل مدى جودة الأراضي الزراعية، مدى قربها أو بعدها عن المساكن، وغير ذلك من العناصر التي قد تؤثر في قيمة الأرض^(١).

هذا عن التطور الذي أصابته النظرية في المجالين التقليديين خلال المرحلة التي نحن بصدددها. أما عن التطور الذي أصابته في المجالات الأخرى، فإنه يبدو من ناحية في اتجاه القضاء الإداري لرقابة الخطأ البين في المسائل العلمية أو الفنية . تلك المسائل التي سبق له أن أخرجها - كما رأينا - من إطار رقابته للتكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة كأساس لقرارتها. وكان أول حكم يؤكد هذا الاتجاه، ذلك الحكم الذي صدر في السادس من نوفمبر عام ١٩٦٣ في قضية Société Iranex والتي تخلص وقائعها في أن الشركة لمذكورة والمختصة بإنتاج المواد الغذائية والمثلجات، كانت تستعمل مادة الصمغ العربي "La gomme arabique" في صناعة الجيلاتين لما له من تأثير في تقوية قوامه والتقليل بالتالي من سرعة ذوبانه، غير أن وزير الصحة أصدر قراراً يحظر استخدام هذا الصمغ في تلك الصناعة، فتقدمت هذه الشركة إلى مجلس الدولة بطعن على قرار الوزير، إلا أن المجلس انتهى إلى رفض الطعن ليس على أساس سياسته السابقة في الامتناع عن رقابة التكييف القانوني بالنسبة للمواد العلمية أو الفنية، وإنما على أساس أن تقدير الإدارة في هذا الشأن لم يكن مشوباً بخطأ بين^(٢).

هذا وقد استخدم مجلس الدولة ذات الحل أيضاً في مسائل علمية وفنية أخرى عديدة منها مثلاً تقدير المستوى العلمي والمهني للأطباء

(١) دكتور/ يحيى الجمل، المرجع السابق، ص ٤٣٢.

(2) C.E, 6 nov.1963 , Société Iranex, Rec P.523, A.J.D.A.,1964, P.187.

الراغبين في إدراج أسمائهم على قائمة الجدارة الطبية Notoriété médicale، حيث انتهى إلى القول بأن هذا التقدير لا يخضع للرقابة القضائية إلا إذا شابه خطأ بين^(١) entachées d'erreur manifeste؛ وكذلك تقدير الوزير المختص للسماح بإنتاج عقاقير طبية^(٢)؛ أو بمنع تداول دواء معين؛ فقد حكم في الدعوى التي رفعها الاتحاد الوطني لنقابات الصيادلة لإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بمنع تداول دواء معين، بأن تقدير الوزير في هذا الشأن لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا إذا كان مشوباً...أو بخطأ بين^(٣).

ونفس المسلك أيضاً فيما يتعلق بتقدير الإدارة بإجراء مسابقة لشغل إحدى الوظائف من عدمه؛ فقد حدث أن رفض مفتش الصحة في مدينة NANTES إجراء مسابقة لشغل وظيفة خالية في إحدى المستشفيات ؛

(١) هذا وتجدر الإشارة إلى أن القيد على قائمة الجدارة الطبية يتم بعد موافقة لجان مختصة بذلك وفقاً لمعايير وضوابط علمية مثل ممارسة المهنة فترة زمنية معينة، أو الحصول على لقب من جامعة، أو سلطة علمية أو من مستشفى. ويتمتع من يقيد على هذه القوائم بميزات خاصة تتمثل أساساً في الحصول على أجور إضافية زيادة عن الأجور العادية. وقد كان مسلك مجلس الدولة في خصوص المنازعات التي تنور حول هذا الموضوع هو عدم إخضاعها لرقابته إذ تعد من المسائل العلمية أو الفنية التي تدخل في الاختصاص التقديري للإدارة، إلا أنه عدل عن ، هذا المسلك – كما رأينا في المتن- وأصبح يخضعها لرقابته بفضل نظرية الخطأ البين، فقد حدث أن تقدم أحد الأطباء إلى اللجنة الفنية المختصة بطلب إدراج اسمه في القائمة المشار إليها عاليه، غير أن اللجنة رفضت هذا الطلب بحجة أنه غير حاصل على المؤهلات العلمية والفنية المطلوبة لذلك. وعندما طعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة، انتهى بعد بحث ودراسة كافة المؤهلات التي سبق للطاعن أن حصل عليها، إلى أن تقدير اللجنة في هذا الصدد كان مشوباً بخطأ بين.

C.E, 24 avr. 1964 ,Villard , Rec. P.243.; C.E,5mai 1966, ministre de la santé publique, Rec., P.1070; C.E,16 dec .1988, Bleton, A.J.D.A., 1988, P.144 chr Aziber et Boideffre.

(2) C.E (S.), 28 avr. 1967, Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Rec, P.180, A.J.D.A., 1967-2- 401,concl. Galmot.

(3) C.E, 20 mai,1988, société laboratoires de thérapie moderne, A.J.D.A., 1988, P.403, chr. Azibert et Boideffre, P.451

فقامت النقابة الفرعية لهذه المدينة بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي قضت بإلغائه. غير أن وزير الصحة طعن في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الذي انتهى إلى إلغائه قائلًا إن الإدارة وإن كانت لها سلطة تقدير إجراء أو عدم إجراء مسابقة لشغل وظيفة عامه ، إلا أن هذا التقدير يجب ألا يكون مشوباً بخطأ بين^(١).

كما يبدو التطور الذي أصابته نظرية رقابة الخطأ البين من ناحيه أخرى في أعمال تلك النظرية في المجال الاقتصادي وهو من المجالات الحديثة للإدارة والتي تتمتع في خصوصها بسلطة تقديرية واسعة. فقد طبقت مثلاً في خصوص تقدير الإدارة لاشتراطات البناء أو تصريحات الهدم^(٢)، أو الترخيص بالبناء. ومن ذلك ما قضى به مجلس الدولة في الطعن الذي أقامته إحدى شركات المقاولات ضد قرار وزير الإسكان بسحب الترخيص الصادر لها من الإدارة المحلية ببناء ثلاث عمارات على شاطئ البحر الأبيض بالقرب من مدينة نيس . فقضى بإلغاء ذلك القرار نظراً لما ينطوى عليه من خطأ بين في تكييف صفة الأماكن المجاورة^(٣).

"une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère des lieux avoisinants"

كما طبقت أيضاً في مجال الضرائب، فقد بحث مجلس الدولة في عام ١٩٦٨ ما إذا كان الوزير قد ارتكب خطأ بيناً من عدمه في تقديره لمدى كفاية الفوائد الاقتصادية للمشروع المقدم من إحدى الشركات لمنحها مزايا ضريبية معينة^(٤).

(1) C.E, 17 mars 1965, Hôpitaux de NANTES, Rec., P.177.

(2) C.E, 15 mars 1963 Rec.,P,167 ;C.E,17 dec.1965, Rec.,P.695.

(3) C.E., 29 mars. 1968, Société du lotissant de la lague de pempelonne, Rec. P. 210.

(4) C.E., (S), 26 Janv, 968, société Maison Gensetal, Rec. P. 62.

وأخيراً فإن التطور الذي إصابته نظرية رقابة الخطأ البين خلال تلك المرحلة، يبدو - إضافة إلى ما سبق - في تطبيق أحكامها على إجراءات الضبط الإداري التي تتمتع الإدارة في خصوصها بسلطة تقديرية واسعة، بل والتي كان يرفض مجلس الدولة أن تباشر في شأنها كما رأينا، أية رقابة على التكييف القانوني الذي تخلعه الإدارة على الوقائع التي تدعيها أساساً لتلك الإجراءات، فقد أصدر مجلس الدولة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٦٨ حكماً يبين فيه بما لا يدع مجالاً للشك أن إجراءات الضبط الإداري ليست بمنجاة من الرقابة القضائية؛ إذ يقول في هذا الحكم أن تقدير الإدارة لهذه الإجراءات أو لتكييفها القانوني لا يعتبر سليماً إلا إذا كان غير مشوب بخطأ بين^(١).

وهكذا يمكن القول إن نظرية رقابة الخطأ البين، والتي تعد خلال تلك المرحلة علامة مميزة في القضاء الإداري الفرنسي، أصبحت تطبق في مجالات العمل الإداري سواء التقليدي منه أم الحديث؛ تطبق كوسيلة ردع لاحتimalات التعسف عند مباشرة السلطة التقديرية في تلك المجالات، أو كما يقول M. Baudauin مفوض الحكومة تطبق كوسيلة تهديد دائم للإدارة "une constante menace, La crainte révérentielle de l'adm" من شأنه أن يخفف أو يلطف من رهبتها وهيبتها في الحالات التي تملك فيها وسائل تمكنها من الإفراط أو التجاوز في استخدام سلطتها التقديرية^(٢)، أو من شأنه أن يفرض عليها كما يقول Braibant التزاماً بضرورة احترام قدر أوفى من المنطق أو الرشاد والصواب فيما تباشره من أعمال^(٣).

(1) C.E., 20 nov. 1968, des armées et sieur Anger, Rec. P. 580.

(2) Concl. Sous, C.E., (S) 6 nov. 1970, Guyé, précité.

(3) Concl. Sous, C.E. 13 nov. 1970, A.J.D.A., 1971.1.33.

"La technique jurisprudentielle de l'erreur manifeste est le moyen d'imposer aux autorités administratives le respect d'un minimum de logique et de bon sens "

المرحلة الرابعة: من عام ١٩٧٣ حتى الآن: إذا كانت نظرية رقابة الخطأ البين قد شهدت خلال المرحلة السابقة نمواً وازدهاراً في القضاء الإداري الفرنسي على ما بينا، إلا أنها كانت مع ذلك قاصرة من ناحيتين:

الناحية الأولى: عدم تطبيقها في مجالات معينة، ذلك أنه رغم إعمال مضمون تلك النظرية في معظم مجالات العمل الإداري، إلا أن القضاء امتنع عن مباشرتها في خصوص إجراءات الضبط العليا سواء في ذلك الإجراءات الخاصة بالأجانب أم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين أنفسهم.

- ف فيما يتعلق بإجراءات الضبط العليا الخاصة بالأجانب، فقد امتنع المجلس عن تطبيق النظرية التي نحن بصدددها على المنازعات التي تدور حول دخول هؤلاء الأجانب إلى فرنسا، أو إقامتهم فيها أو إبعادهم عنها، أو التي تدور حول ما يباشرونه من أنشطة مختلفة على الإقليم الفرنسي، وكذلك على المنازعات الخاصة بتداول المطبوعات الأجنبية في فرنسا^(١). إضافة إلى ذلك فقد رفض القضاء الإداري إمكانية وقف أو تأجيل تنفيذ قرار الإبعاد للأجنبي La possibilité d'ordonner la sursis à l'exécution 'une telle decision لدرجة أن مجلس الدولة أعلن - كما ذكرنا من قبل - أن على المحاكم الإدارية الامتناع عن اتخاذ مثل هذا الإجراء على أساس أن قرار الإبعاد يعتبر من القرارات التي تهم النظام العام بمدلولاته الثلاثة: الأمن والصحة والسكينة، ومن ثم يجب أن ينفذ فوراً^(٢).

(1) Conch de G. Tixier sur l'arrêt du 24 oct. 1953, Eckert; S.1953,111. P.52.

(2) C.E, 25 nov 1954, van Peborgh, AJDA, 1954, P.489.

- أما فيما يتعلق بإجراءات الضبط العليا الخاصة بالمواطنين الفرنسيين ومثالها عدم إصدار جوازات السفر، فقد رأينا أن مجلس الدولة قد وقف برقابته في خصوص تلك الإجراءات - لاعتبارات سياسية أو كما يقال لدواعي المصلحة العليا - Raison d Etat - عند حد التحقق فقط من الوجود المادي للوقائع؛ بل وقد جعل عبء الإثبات في هذه الحالة على المدعى وحده^(١).

وهكذا بقيت تلك الإجراءات في شقيها خارج مجال الرقابة العادية Conrole normal أو القصوى maximum، التي يباشرها القضاء الإداري في مجالات النشاط الإداري المختلفة. بل وبقيت كذلك خارج مجال أعمال نظرية رقابة الخطأ البين التي نحن نصدها، الأمر الذي كان محل نقد شديد من جانب رجال الفقه الفرنسي الذين رأوا أن الرقابة القضائية بحالتها

حيث يقول المجلس في هذا الحكم:

"...que l'expulsion d'un étranger était du nombre des décisions intéressant l'ordre, la sécurité et la Tranquillité publique, à propos desquelles les tribunaux administratifs ne peuvent prescrire de sursis à execution...".

وانظر أيضا:

P. VIGOR De contrôle Juridictionnel de l'expulsion des étrangers, Rev. pol. Et parl. 1956, P. 292.

ولم يتغير هذا الوضع إلا بصدور حكم مجلس الدولة في ١٣ فبراير ١٩٧٦ والذي أكد فيه أن على قاضي تجاوز السلطة بحث كل حالة على حدة ليرى ما إذا كان هناك مقتضى لتأجيل التنفيذ من عدمه.

"...il appartient au Juge adm. d'apprécier dans chacun des cas, qui lui sont soumis, s'il y a lieu d'ordonner le sursis à execution...".

وقد تأكد هذا الحكم بصدور عدة أحكام أخرى منها:

C.E., 18 Juin 1976, M. Konaté, A.J.D.A., 1976, P. 582; C.E., 25 mai 1988, Ministre de l'intérieur C./ habibi kaheroudi et autre, R.F.D.A., 1989, P. 26 concl. Ch. Vigouroux.

(1) C.E., 21 oct. 1949, Persager, S. 1950.111, P. 72; C.E. 14 mars 1951, Missir, Rec. P. 161.

تلك لا تؤدي في حقيقة، الأمر والواقع إلى حماية فعالة للحقوق والحريات الأساسية لطائفه اجتماعية معينة من الأفراد، مما يتنافى مع اعتبار فرنسا دولة قانونية أو دولة الحريات^(١).

وللتوفيق بين اعتبارات دواعي المصلحة العليا للوطن وبين هذه الاعتبارات الإنسانية التي يقول بها رجال الفقه، اتجه القضاء الإداري الفرنسي، كخطوة جديدة الملحد من سلطه الإدارة التقديرية، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن الأجانب غالباً ما يفتقدون الرعاية والاهتمام *une catégorie sociale particulièrement défavorisée*، اتجه نحو إعمال نظرية رقابة الخطأ البين في المجالات التي نحن بصدددها، وكان ذلك في ٢ نوفمبر ١٩٧٣ حينما أصدر حكماً هاماً وأساسياً في هذا الخصوص أعلن فيه أن تقدير الإدارة للوقائع التي تدعيها لمنع إحدى المجالات الأجنبية من التوزيع والبيع في فرنسا لا تناقش أمام القضاء الإداري إلا إذا كانت مشوبة بخطأ بين^(٢). ثم أصدر بعد ذلك أحكاماً أخرى تناولت كافة إجراءات الضبط العليا والسابق ذكرها، حيث انتهى إلى وضع قاعده مفادها أنه لكي تعتبر تلك الإجراءات مشروعة وسليمة، يجب أن يكون تقدير الوقائع التي استندت إليها غير مشوبة بخطأ بين وهذا ما سوف نتناوله بشكل أكثر تفصيلاً فيما بعد.

(1) S. Ktistaki, l'évolution du contrôle Juridictionnel des motifs de l'acte administratif, these, Paris, 1991, P. 113 etss.

(2) C.E., 2 nov. 1973, Maspero, J.C.P., 1974, 11, 17642.

حيث يقول في هذا الحكم:

"... que des lors qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste, l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'intérieur du danger que la revue présentait pour l'ordre public ne peut pas être discutée devant la Juridiction administrative".

الناحية الثانية: والتي تؤكد قصور نظرية رقابة الخطأ البين في المراحل السابقة، حيث لم تكن تباشر أثناء تلك المراحل خارج إطار الحالات التي امتنع القضاء الإداري في خصوصها عن رقابة التكيف القانوني للوقائع.

بمعنى أن القضاء الإداري كان يقتصر في تطبيق هذه النظرية فقط على الحالات التي كان يمتنع في خصوصها - لسبب أو لآخر كما أوضحنا من قبل - عن إجراء رقابة التكيف القانوني. ولهذا فقد استبعد مجلس الدولة من مجال تطبيق نظرية الخطأ البين ، الحالات التي لم يكن يراقب في خصوصها أهمية وخطورة الوقائع ومدى تناسب ذلك مع الإجراء المتخذ من قبل الإدارة وهو ما يقال له رقابة التناسب . فقد امتنع مثلاً عن إعمالها في المجال التأديبي، خاصة فيما يتعلق بمدى ملاءمة الجزاء للذنب الذي اقترفه صاحب الشأن^(١)، وكذلك في مجال تقارير كفاية الموظفين^(٢) (مدى تلاؤم التقدير العددي Notation مع التقييم العام appreciation générale وهكذا.

أما في المرحلة التي نحن بصدددها فقد تغير موقف مجلس الدولة إزاء تلك المسائل، حيث باشر في خصوصها رقابة الخطأ البين.

- ففيما يتعلق مثلاً بالتأديب فإننا نكتفي هنا بالحكم الذي يعد نقطة تحول في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن والذي صدر في قضية Lebon عام ١٩٧٨ والتي تخلص وقائعها في أن مدرساً بأكاديمية تولوز، اتهم بارتكابه أفعالا مخلة بالحياء مع تلميذاته في الفصل، ولذا فقد

(1) C.E, 22 nov 1967, demoiselle chevreau, Dr. ouvr., 1968 ,P,113, concil, kahn ,D., 1969. J.51, Note Mqurgeon.

(2) C.E, 22 Fev, 1963 ,Maurel, Rec.,P.119.

صدر قرار بإحالته إلى المعاش ، وعندما طعن السيد Lebon في هذا القرار على أساس جسامه الجزاء الموقع عليه بالنسبة للأفعال التي أتاها رفض مجلس الدولة هذا الطعن قائلاً: إنه لا يتضح من الأوراق أن هذا الجزاء يقوم على غلط بين في التقدير^(١).

- أما فيما يتعلق بتقارير كفاية الموظفين فقد أصدر مجلس الدولة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٧٩ حكماً أخضع فيه تلك التقارير للرقابة القصوى من خلال فكرة الخطأ البين للوقوف على مدى التناسب بين التقدير الرقمي للطاعن وبين التقييم العام له، وتخلص وقائع هذا الحكم في أن السيد Leca ويعمل مديراً مساعداً بوزارة الاقتصاد والمالية ، طلب من الوزير مراجعة التقدير الرقمي الذي منح له لاعتقاده بأنه يقل عن كفايته الوظيفية الحقيقية، وإزاء عدم رد الوزير على طلبه، فقد طعن في القرار الضمني بالرفض أمام المحكمة الإدارية مارسيليا التي رفضت دعواه على أساس أن قرار تقدير كفايته غير مشوب بخطأ بين ، طعن المذكور في الحكم أمام مجلس الدولة والذي رفض بدوره هذا الطعن قائلاً إن الدرجة الرقمية التي حصل عليها السيد Leca ومقدارها ١٧,٢٥ تتناسب مع التقييم العام له، ومن ثم فإن تقدير كفايته على هذا النحو لم يصدر مشوباً بخطأ بين^(٢).

حاصل القول إذن أن المرحلة الرابعة والتي نحن بصددتها تعد المرحلة التي اكتمل بها تطبيق نظرية رقابة الخطأ البين ، لدرجة يمكن معها القول إن هذه النظرية أصبحت نظرية عامة، تتناول كافة مجالات العمل أو النشاط الإداري، ليس فحسب لرقابة التكيف الذي تخلعه الإدارة على الوقائع

(1) C.E., 9 Juin 1978, Sieu lobon, Rec. P. 245, A.J.D.A., 1978, P. 575, concl. Genevois.

(2) C.E., 26oct. 1979, Rec. P. 379.

التي تدعيها لقراراتها، أو لمدى تقديرها للإجراءات التي تتخذها، وإنما أيضا لرقابة مدى التناسب بين هذه الوقائع وتلك الإجراءات.

ومع ذلك ورغم ما تمثله تلك النظرية من نقلة جريئة للقضاء الإداري الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية، إلا أن هناك تساؤلا هاما في هذا الصدد يتعلق بمدى الخطأ الذي ترتكبه الإدارة في التقدير حتى يعتبر خطأ بينا أو بمعنى آخر ما هو المقصود بالخطأ البين؟ أو ما هو المضمون الحقيقي لذلك الخطأ؟

وهذا ما نبينه فيما يلي.

المطلب الثاني

معيار الخطأ البين

من العرض السابق لمراحل تطور نظرية رقابة الخطأ البين، يمكن القول الي هذه النظرية تجسد رغبة حقيقية لدى مجلس الدولة لمنع أو لجزر كل تعسف وتجاوز ينتج عن مباشرة الإدارة لسلطانها التقديرية؛ إذ لم يعد القاضي الإداري يكتفي عند رقابته للوقائع أو لأسباب القرار الإداري بمجرد إجراء الرقابة الثلاثية المعروفة والتي يقال لها "الرقابة الدنيا" Contrôle minimum، وهي كما ذكرنا من قبل: رقابة الوجود المادي للوقائع - الخطأ في القانون - تجاوز السلطة أو الانحراف بها؛ وإنما اضاف إلى ذلك رقابة الخطأ البين، تلك الرقابة التي تتطلب من الإدارة - حيث تكون حرة في تقدير أو تقييم الوقائع - أن يكون هذا التقدير أو التقييم معقولا أو منطقياً. أو بمعنى آخر ألا يكون مشوباً بخطأ واضح جلى أو كما يطلق عليه خطأ بين erreur manifeste، كما باشر أيضا هذه الرقابة، وهي رقابة الخطأ البين

عند إجرائه للرقابة العادية وهى رقابة التكييف القانوني للوقائع، وكذلك في خصوص رقابة الملاءمة وذلك كما بينا آنفا.

ومع ذلك يلاحظ أن مثل هذا القول وإن كان من السهولة بمكان ترديده نظرياً، إلا أن وضعه موضع التطبيق العملي ليس بهذه السهولة، إذ متى يعتبر مثلاً التقدير أو التقييم الذي تجريه الإدارة للوقائع التي تدعيها معقولاً أو منطقياً؟ أو متى لا يعتبر هذا التقدير أو التقييم مشوباً بخطأ واضح وجلي؟ ما هى الدرجة التي يجب أن يكون عليها الخطأ حتى يوصف بأنه خطأ بين؟ ما هو المعيار المعتمد في هذا الشأن؟

واضح إذن مدى الصعوبة التي ينطوى عليها الواقع العملي لفكرة الخطأ البين. بل ومما يزيد من تلك الصعوبة أن القضاء اداري ذاته، صاحب تلك الفكرة قد اتخذ إزاء تحديد عناصرها أو بيان ضوابطها موقفاً سلبياً، إذ من المعروف - وكما أوضحنا من قبل - أن مجلس الدولة الفرنسي يميل بطبعه إلى الإيجاز والبعد عن المناقشات الفقهية والنظرية، كما يحرص عادة على ألا يضع تعريفات في أحكامه ، قد تكون سبباً في تعويق قضائه في المستقبل.

ولهذا فقد اكتفى عند تبنيه لنظرية الخطأ البين بترديد بعض عبارات أصبحت شبه مستقرة مفادها أن تقدير الإدارة في هذا الشأن أو ذلك لا يكون خاضعاً للرقابة القاضي الإداري إلا إذا قام على وقائع مادية غير موجودة أو شابه غلط في القانون أو انحراف في السلطة أو بني على خطأ بين . وذلك دون أي محاولة مباشرة للإلقاء مزيد من الضوء والتحديد على ماهية فكرة الخطأ البين^(١) مع أن القيمة العملية لهذه الفكرة الأخيرة لا تتحقق في الواقع

(١) الدكتور/ يحيى الجمل، المرجع السابق، ص ٤٤٠.

إلا

بتحديد مضمونها، ووضع معيار منضبط لإعمالها، يتيح للمتقاضين من ناحية سهولة اللجوء إليها لدحض أو ادعاءات أو افتراءات الإدارة تجاههم، ما يضئ للقاضي الإداري من ناحية أخرى الطريق عند مباشرته لهذه الفكرة.

هذا ويمكن التمييز في هذا الصدد بين معيارين يترددان على السنة رجال الفقه الإداري ومفوضى الحكومة^(١)، هما المعيار اللغوي أو الوصفي والمعيار الموضوعي، وهو ما نتناوله تباعاً فيما يلي ذلك قبل أن نبين وجهة نظرنا في هذا الخصوص.

(١) غير أن المشرع قد يقرر من جانبه أيضاً بعض المعايير والقواعد مثل معيار "التعادل" بين القطع في قضايا ضم الأراضي الزراعية الوارد بالمادة (١٩) من قانون ٩ مارس سنة ١٩٤١ والواردة أيضاً في المادة (٢١) من قانون الزراعة والتي تستوجب التعادل في القيمة الإنتاجية الحقيقية، وقاعدة "التعادل" بين الوظائف في مجال الوظيفة العامة كالواردة في المادة (٨٤) من قانون ٢٨ أبريل ١٩٥٤. ومعيار الإضرار بالصحة العامة استناداً إلى المادة السابعة من قانون ٢٩ مارس ١٩٤٩ والذي يقوم به وزير الزراعة، ومعيار الاعتداء على المواقع والمناظر الأثرية طبقاً للمادة الأولى من مرسوم ٣١ ديسمبر ١٩٥٨ يحث يختص المدير بتقدير هذا الاعتداء. ومعيار "الاستعجال" في إطار نزاع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليه في قانون ٣١ مارس ١٩٣١. ومعيار "حاجة السكان" التي تبرر فيتحة صيدلية بطريق المخالفة، والذي يفدره وزير الصحة استناداً إلى المادة ٥١٧٠ من قانون الصحة العامة، ومعيار الاعتداء على طابع وصفة الأماكن المجاورة الوارد في المادة ٢ من مرسوم ٣٠ نوفمبر ١٩٦١. ومعيار الضرر الذي يلحقه محرر أجنبي بالأمن والنظام العام الذي يفدره وزير الداخلية استناداً إلى قانون ١٩ مارس ١٩٣٩. هذه المعايير التي يقرها المشرع لاشك أنها تفتح الباب لسلطة تقديرية بلا معقب. وقد قرر مجلس الدولة في الواقع أنه يوجد هنا تقدير بلا معقب للوقائع، ومن ثم لا يمكن مناقشته أمامه.

Rials (S.) le Juge administratif Français et techniques du standard, these, Paris, 1980, P. 193.

وانظر كذلك الدكتور/ محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، دكتوراه، حقوق عين شمس، ١٩٩٢، ص ٩٢١ ومابعدها.

أولاً: المعيار اللغوي للخطأ البين

يبدو في واقع الأمر أن كلمة "بين Manifeste" التي يوصف بها الخطأ البين في التقدير والذي يراقبه القاضي الإداري، إنما توحى بأن هذا الخطأ قد وصل إلى درجة من الوضوح تكفي لإقناع القاضي بوجود مثل هذا الخطأ أو تكفي لإزالة أي شك لديه حول هذا الخطأ^(١).

D' une erreur que le juge puisse censurer sans hesitation.

ودرجه الوضوح هذه تتجسد - كما يقول الفقه الفرنسي^(٢) - في كون الخطأ بديهياً Evidente أو جسيماً grossiere ، أو صارخاً Flagrante ، أو خطيراً Grave ، أو جلياً Eclatante أو فاحشاً Lourde...الخ. فإذا تحقق في خطأ ما واحد من تلك الأوصاف، أصبح "بيناً Manifeste"، ومن ثم يكون القرار الإداري المشتبه عليه جدير بالإلغاء. وهذا ما انتهجه مجلس الدولة في معظم أحكامه المتعلقة بهذا الوجه من أوجه الإلغاء فقد اعتبر مثلاً - كما رأينا - أن التباعد الصارخ أو الهام l'importante d'écart بين مظهر أو هيئة وقائع القرار الإداري وبين ما أسبغته الإدارة على تلك الوقائع من تقدير أو تقييم، سواء في مجال مبادلة الأراضي الزراعية أم في مجال تعادل الوظائف ، يعد بمشابهة خطأ بين أو بديهي؛ بل وحتى في المجالات الفنية ، وهي من أكثر المجالات التي باشر القضاء في خصوصها ذلك التكنيك الحديث ، فقد اعتبر مجلس الدولة أن الخطأ البديهي أو البين هو الخطأ الذي يدرك، أو يمكن التعرف عليه من قبل غير المتخصص في تلك

(1) Pacteau (B), op. cit., P. 248.

(2) Auby et drago, op. cit., P. 394, Kahn, le pouvoir discrétionnaire et le Juge administratif in "le pouvoir discrétionnaire" colloque du 5 mars 1977, P. 15; J. Baudouin, concl. sou, C.E., 6 nov. 1970, Gbyé, R.D.P. 1971, P. 527.

المجالات، أو كما يقول مفوض الحكومة Braibant يمكن التعرف عليه حتى من قبل جاهل Par un profane^(١).

ولهذا يعرف الأستاذ أوبى ودراجو الخطأ البين بأنه "الخطأ الواضح أو الجسيم بل والخطير الذي يكون مرئياً حتى بالنسبة لغير المتخصصين من رجال القانون"^(٢)؛ أو كما يقول الأستاذ VEDEL: هو الخطأ الذي يقفز أمامنا بحيث يمكن ملاحظته بمجرد النظر إليه، ومن أول وهلة دون ثمة حاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة والتخصص في اكتشاف^(٣).

ومع ذلك يلاحظ أن مثل هذا القول إنما يشير فقط إلى المعنى اللغوي أو الاصطلاحي لصفة "بين" أو "ظاهر Manifeste" التي يوصف بها الخطأ الذي ترتكبه الإدارة في تقدير أو تقييم الوقائع التي تستند إليها في قراراتها، وهو معنى يفيد باختصار شديد أن القاضي الإداري ليس في حاجة من أجل التعرف على هذا الخطأ لأن يجري بحثاً متعمقاً أو لأن يجري تحقيقاً حول تلك الوقائع، إذ يمكنه الوقوف عليه، أو تلمسه من مجرد النظر إلى وقائع الدعوى أو من مجرد عرض تلك الوقائع عليه.

فالقاضي مثلاً ليس في حاجة لأن يجري تحليلاً أو بحثاً متعمقاً لكي يثبت أن أحد قدماء الأطباء Ancien intern بمستشفيات باريس، والذي شغل من قبل وظيفة رئيس إكلينيك بكلية الطب في العاصمة لسنوات عديدة، تتوفر فيه الكفاءة المهنية أو المستوى العلمي الذي يؤهله لأن يسجل على قائمة الجدارة الطبية La notoriété médicale . ولهذا فقد اعتبر أن

(1) Concl. sous C.E., (S) 13 nov. 1970, Lambert A.J.D.A., 1971 chr, de jurispr., de MM Labetoulle et Cabanes, p.33

(2) op. cit., P. 394.

(3) Vedel et p. delvolvé, Droit administratif F, P.U.F, Paris, 1982, P.800.

تقدير الإدارة لهذه الكفاءة أو ذلك المستوى بشكل سلبي، يعني أن هناك خطأ بينا في هذا التقدير^(١). فالكفاءة المهنية لهذا الطبيب أو مستواه العلمي أمر مؤكد أمام القاضي من مجرد النظر إلى ملف الدعوى، ولذا فقد تبين له على الفور أن هناك خطأ بينا في تقدير الإدارة لهذه الكفاءة، أما إذا تسرب إليه الشك أو التردد حول وقائع الدعوى، فإن الخطأ البين ينتفى على الفور وتصبح الإدارة بالتالي محقه في قرارها المستند إلى هذه الوقائع، وهذا هو ما دعا مفوض الحكومة M. Galabert إلى التخلي عن اقتراح له بإلغاء قرار وزير الصحة بمنع بيع دواء معين للجمهور على أساس الخطأ البين في تقدير الأخطار الناجمة عن هذا الدواء، إذ اعتبر أن الحجة التي قال بها المدعون في هذا الخصوص، وإن كانت حجة قوية حيث تتمثل في أن الدواء رغم استعماله من قبل الجمهور، فإنه لم يتسبب حتى الآن في حدوث أية إصابة أو خطر، إلا أنها لا تتسم مع ذلك بالبدهة أو الجلاء ، ولا تزيل من ثم كل شك أو تردد حول أخطار الدواء محل الدعوى . من هنا فقد ركز في تقريره على نغمه الشك أو نغمة التشكيك هذه Sur le ton du bitatif وانتهى إلى القول- الذي تبعه فيه مجلس الدولة - أن الإدارة لم ترتكب خطأ بينا في تقديرها للخطر الذي ينطوى عليه الدواء محل المنازعة^(٢).

فمع الشك إذن ينتفى كل خطأ بين، ومع اليقين يتحقق هذا الخطأ^(٣)، ولهذا نجد الأستاذ Kahn يعرف الخطأ البين بأنه الخطأ الذي لا يثير في

(1) C.E , 7 Juin 1967 ,Rougemont ,Rec ,p.240 ,A.J.D.A., 1968 ,P.48 note peiser, D.1968, p.201,Note Dupeyroux et Garagnon.; C.E, 28 mai 1971,langlais. Rec., P.416.

(2) C.E,(S),28 avr .1967 ,F.N.S.P.F., Rec.P.180 ,A.J.D.A. ,1967 P,401, Bulletin de L'ordre des pharmaciens, 1967, P. 347.

(٣) هذا ويذهب الأستاذ Peisey إلى القول بأن العبرة بكون الخطأ مؤكداً، ومن ثم بينا، هي بلحظة المداولة لا بلحظة اتخاذ الإدارة للقرار المشوب بالخطأ البين.

نفس القاضي أدنى شك في وجوده. فإذا تطرق إليه الشك افتقد صفته كخطأ بين، حيث يفسر الشك لصالح الإدارة^(١).

ثانياً : المعيار الموضوعي للخطأ البين

إن المعنى اللغوي أو الاصطلاحي للخطأ البين على النحو السابق لم يكن في الواقع محل إجماع من جانب رجال القانون، فقد ذهب مفوض الحكومة Baudouin مثلاً إلى القول بأن معيار الخطأ البين لا يكمن في مدى خطورة أو وضوح هذا الخطأ، بل ولا في كونه حدثاً بارزاً، وإنما يكمن أساساً في إطار درجة عدم الانضباط أو الكفاية بالنسبة لعناصر التقييم التي كانت تحت نظر الإدارة عند إجرائها لهذا التقييم^(٢). مما يعني لديه أن معيار الخطأ البين يجب أن يكون معياراً موضوعياً لا معياراً لغوياً أو اصطلاحياً؛ وهذا ما يؤكد جانب آخر من الفقه الفرنسي حيث يميز البعض بين الخطأ البين والخطأ غير البين على أساس مدى قدرة الشخص العادي من التعرف عليه؛ فالخطأ الأول يمكن التعرف عليه كما يقول Goyard من قبل شخص عادي في ثقافته وفي تفكيره، في حين أن الخطأ الثاني لا يمكن التعرف عليه إلا من قبل المتخصصين أو من خلال الاستعانة بأهل الخبرة والمعرفة^(٣).

l'erreur est donc manifeste du moment qu' elle est sure, incontestable qu'elle apparait clairement au Juge au moment où il délibère, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été apparente au moment où la décision a été prise "

Note sous C.E., Rougemont, A.J.D.A.,1968, P.49

(1) Article précité, P. 15.

(2) Concl. sur C.E., 6 nov 1970 ,Sieur guye , R.D.P., 1971, P.517.

(3) "Les idées des charles Eisenmann Sur le conterôle des motifs" mélanges Eisenmann, 1975, P. 339.

وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور يحيى الجمل: "والذي يبدو لنا من استقراء أحكام المجلس في هذا الشأن أنه يريد أن يضع للخطأ البين معيارا موضوعيا بحيث لا يعتمد تقدير وجود الخطأ البين على حسن نية الإدارة وسوتها من ناحية، وبحيث لا يكون أمره متروكا لمحض تقدير القاضي من ناحية أخرى، وإنما يقوم الخطأ البين حيث يقوم على عناصر موضوعية تكشف عن الخلل في التقدير"^(١).

هذا ويذهب البعض إلى القول بأن كل المحاولات التي تعتمد على المعنى اللغوي، كأساس لها في تعريف الخطأ البين، لا تتفق والمعنى الحقيقي الذي ينصرف إليه قضاء مجلس الدولة عند استخدامه لهذه النظرية، حيث أضفى هذا القضاء طابعا موضوعيا على تلك النظرية، وآية ذلك أن هناك حالات باشر المجلس فيها رقابته على تقدير الإدارة من خلال نظرية الخطأ البين، ودون أن يكون فيها هذا الخطأ بينا ومن أمثلة ذلك حكمة في قضية université de Paris x Nantere et syndicat générale de l'éducation national.

حيث ألغي بمقتضى هذا الحكم وعلى أساس الخطأ البين قراراتين صادريين من وزير الدولة للجامعات بنقل بعض أعضاء هيئة التدريس من جامعة نانثير إلى جامعة باريس وذلك على الرغم من عدم وضوح هذا الخطأ في تقدير الادارة لاحتياجات كل من الجامعتين المذكورتين^(٢). مما يعني أن التلازم بين وصف ظاهر أو واضح أو بين وصف الجسامة والخطأ البين في التقدير ليس ضروريا في جميع الأحوال، ذلك أن ما يراقبه

(١) المقال السابق، ص ٤٤٤.

(2) C.E., 30 mars 1979, Rec. P, 145, A.J.D.A. 1979 P. 40 Note. Achille Mestre

لمجلس تحت اسم الخطأ البين هو في حقيقة الأمر التقدير الموضوعي المشوب بالخطأ. ولهذا فهو لا يعتمد لاكتشاف هذا الخطأ على مجرد الوقوف على سمة الوضوح أو الجلاء أو الجسامة. وإنما يلجأ في الغالب إلى إجراء دراسة وفحص لكافة عناصر الموضوع المطروح أمامه^(١)، بل وأحياناً يلجأ إلى إجراء تحقيق على الطبيعة في حضور الأطراف أو زيارة المواقع محل النزاع كما هو الشأن في القرارات المتعلقة بترخيص البناء واختيار المواقع وحمايتها^(٢).

فالدور الذي يلعبه المجلس في رقابته على الخطأ البين هو في الواقع دور تقريرى *un role cognitif* يقتصر على مجرد التأكد من صحة أو خطأ التقدير الذي سبق للإدارة أن أجرته بالنسبة لملاءمة نشاطها، وهو ما يتفق ودوره في الرقابة - عموماً - على أعمال الإدارة^(٣).

خلاصة القول بالنسبة لهذا الجانب الفقهي إذن أن معيار الخطأ البين إنما هو معيار موضوعي . مع ملاحظة أن الموضوعية في المعيار

(1) Concl. Baudouin sur C.E.12 avr.1968,société Beauregard et cie ,A.J.D.A., 1968, P. 418.

إذ يقول في هذا التقدير:

Le critère de l'erreur manifeste doit, en cette matière, être recherchée non pas dans l'étendu ou dans la gravité ou encore dans le caractère flagrant de la confusion qui est à l' origine de la décision erronée prise par l'administration, mais uniquement dans le degré d'inexactitude ou insuffisance des éléments d'appréciation au vu desquels l'autorité administrative a été appelée à se prononcer.

(2) Letourneur (M.), le conseil d'Etat et les tribunaux administratifs, 1970, P. 273.

(3) O. Sachs ,le contrôle de l'utilité publique des servitudes administratives, Economica, 1984, P.129.

انظر أيضاً الدكتور/ ثروت عبد العال أحمد، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٦٨.

على هذا النحو- يضيف أنصار هذا الرأي - لا تعنى الثبات والتحديد للمعيار ذاته وإنما تعنى موضوعية التقدير والكيفية التي يراد بها الاستدلال على الخطأ البين، وبيان أن هذا الاستدلال والبحث لا يخضع لتقدير ذاتي للقاضي وإنما عمادة تقدير موضوعي يستخلص من ملف الدعوى وأوراقها^(١).

ثالثاً: رأينا في معيار الخطأ البين

مما سبق يتضح أن هناك جانباً من رجال القانون يرى أن معيار الخطأ البين إنما هو معيار لغوي أو اصطلاحى، وجانب آخر يرى على العكس من ذلك أن هذا المعيار ليس في حقيقته سوى معيار موضوعي . ومن جانبنا نرى أنه يصعب في الواقع أن نضع معياراً جامداً في هذا الخصوص ، بحيث يجب على القاضي الالتزام به في كافة المنازعات التي تعرض عليه ويكون مبناهاً خطأ بين. فما قد يعتبر خطأ بين في خصوص نزاع ما، قد لا يعتبر كذلك في نزاع آخر، بل وما قد يعتبر خطأ بين في وقت معين ، قد لا يعتبر كذلك في وقت آخر... وهكذا.

حقيقة أن هذا الخطأ يجب أن يكون على درجة معينة من الجسامه، لكي لا تحاسب الادارة على أي خطأ ترتكبه حتى ولو كان يسيراً أو كان من الأخطاء الشائعة أو البسيطة في المجال الإداري والتي كثيراً ما يتغاضي القاضي الإداري ذاته عنها، وحقيقة أيضاً أن هذا الخطأ يجب أن يكون بيناً أي واضحاً وظاهراً، بحيث يتسنى للقاضي الوقوف عليه أو معرفة كنهه، ومن ثم التأكد من وجوده دون عناء، ولكن من ناحية أخرى لا يجب أن نبالغ ونغالي في حقيقة صفة البيان أو الوضوح التي يجب أن يكون عليها

(١) الدكتور/ محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين، مرجع سبق ذكره، ص ١٢١، ١٢٢،

الخطأ في التقدير لدرجة يقال معها إن الشخص العادي يستطيع بيانه أو اكتشافه، فمثل هذه الأخطاء يندر - كما قيل بحق - أن يقع فيها رجل الإدارة حيث يفترض فيه أنه الأخطاء يندر - كما قيل بحق - أن يقع فيها محل الإدارة حيث يفترض فيه أنه على قدر من التخصص والخبرة في الشؤون الإدارية بما يجنبه الوقوع في مثل هذه الأخطاء. بل ويتساءل الاستاذ Delvoivé في هذا الصدد: كيف يمكن للقاضي وهو غير متخصص في الشؤون الإدارية أن يدرك الخطأ البين بينما لا يدركه رجل الإدارة والفرض أنه متخصص في هذا المجال؟

وترتباً على ذلك فإننا لا نقر المعيار اللغوي أو الاصطلاحي للخطأ البين على إطلاقه، خاصة أن هذا المعيار غالباً ما يؤدي إلى تضارب أو تعارض في وجهات النظر حول ما إذا كان الخطأ في التقدير يعتبر خطأ بيناً من عدمه، ولا أدل على ذلك مما حدث في الواقع العملي، إذ بينما اعتبرت بعض محاكم الدرجة الأولى أن الخطأ الذي أصاب تقدير الإدارة هو خطأ بين، فإن مجلس الدولة لم ير في هذا الخطأ صفة البداة أو الوضوح ومن ثم لم يعتبره خطأ بيناً^(١)، بل وفي إطار مجلس الدولة ذاته يحدث مثل هذا التعارض أو التضارب إذا كثيراً ما يذهب مجلس الدولة في نزاع ما، عكس ما اقترحه عليه مفوض الحكومة من أن الخطأ المثار في هذا النزاع من الأخطاء البينة أو غير البينة. وهذا ما يؤكد مفوض الحكومة Braibant حينما اعترف بأن هناك حالات رغم وضوحها، إلا أن وجهات النظر تختلف في خصوص ما إذا كانت تثير شكوكاً من عدمه، أو ما إذا كانت تتطوّل على خطأ بين أم لا^(٢).

(1) C.E., 26 nov. 1975, Vandevolve, J.C.P., 1976.2.18.382, note Guyon.

(2) Concl. Sous C.E. (S.) 16 nov. 1970, Lambert, A.J.D.A., 1971.2.33.

"Parfois, des esprits également éclairés se partageront sur le point de savoir si une question est douteuse ou si une erreur est manifeste"

ومع ذلك فإن بلوغ الخطأ درجة معينة، أو كما يقال عادة تجاوز الخطأ لدرجة المعقولية أو الدرجة التي لا يغتفر عندها ، تساعد القاضي على سرعة اكتشافه أو التعرف عليه، وهنا يأتي دور المعيار الموضوعي، حيث لا يعقل أن يكون موقف القاضي إزاء اكتشاف الخطأ البين دور سلبي، إذ كيف يتسنى له التعرف على أن هناك خطأ في تقدير الإدارة دون أن يباشر من جانبه أدنى تحقيق أو بحث ودراسة لملف الدعوى المنظورة أمامه، مع أن عناصر هذا الخطأ تكمن أساساً في هذا الملف أو بين الأوراق التي يحتوى عليها.

فالمعيار اللغوي أو الاصطلاحي والمعيار الموضوعي للخطأ البين يكمل إذن كل منهما الآخر، بحيث لا يمكن الاعتماد على واحد من بينهما فقط لاكتشاف أو للتعرف على هذا الخطأ. فالوضوح وتجاوز المعقولية في الخطأ (وهو المعيار اللغوي أو الاصطلاحي) يساعد القاضي عند فحصه لملف الدعوى أو للظروف التي أحاطت بتقدير الإدارة للوقائع (وهو المعيار الموضوعي) من سرعة اكتشاف هذا الخطأ أو التعرف عليه.

من هنا يمكن تعريف الخطأ البين في التقدير بأنه الخطأ الذي يرى فيه القاضي (من خلال بحثه لملف الدعوى ولمختلف الظروف التي جرى فيها هذا التقدير) تجاوزاً لحدود المعقولية ووضوحاً لدرجة البداهة.

المطلب الثالث

موقع رقابة الخطأ البين بين مستويات الرقابة القضائية

واضح من العرض السابق أن الخطأ البين يكمن دائماً في التقدير أو التكييف الذي تجريه الإدارة للوقائع التي تدعيها كأساس لقراراتها وذلك بمقتضى مالها من سلطة تقديرية، أما في حالات الاختصاص المقيد، فلا محل لوجود أو إثارة هذا الخطأ؛ لأن المشرع بنصه على الوقائع التي تلتزم الإدارة بها عند إصدارها القرار المستند إلى هذه الوقائع إنما يكون قد حدد لها في ذات الوقت أهمية تلك الوقائع، مما يعنى أنه لم يترك لها أية حرية في تقدير مدى ملاءمتها بالنسبة لهذا القرار^(١). ومعنى ذلك أن رقابة الخطأ البين تنصب على ملاءمة القرار الإداري وليست على مشروعيته، خاصة أنها تهدف - كما يقول Kahn مفوض الحكومة - إلى تصحيح كل ما تنطوى عليه نظرية السلطة التقديرية من إمكانية للتجاوز أو التعسف^(٢).

ولهذا فإن القاضي الإداري يقوم من خلال هذه النظرية بإحلال تقديره الشخصي محل تقدير رجل الإدارة، وذلك في حالة ما إذا كان هذا التقدير الأخير بطبيعة الحال مشوباً بخطأ بين. وهذا ما يؤكده مفوض الحكومة Braibant. حينما خاطب مجلس الدولة قائلاً: ليس هناك أدنى شك في أن القاضي لا يستطيع أن يحل تقديره محل تقدير رجل الإدارة في الحالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية، ومع ذلك فقد توسعت في

(١) دكتور/ السيد محمد إبراهيم، الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء، دكتوراه، حقوق الإسكندرية، ١٩٦٢، ص ٣٣ وما بعدها؛ دكتور/ ثروت عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص ٣٦٥.

(2) "Corriger ce que la théorie du pouvoir discrétionnaire peut avoir d'excessif et d'arbitraire" Concl,sous C.E., 12 Janv. 1968, Ministre de l'Economie et des finances C/., Dame perrot, A.J.D.A.1968.179.

نطاق الرقابة التي يمارسها المجلس منذ اثني عشرة سنة من خلال نظرية الخطأ البين في التقدير حتى شملت هذه السلطة^(١).

وهنا لنا أن نتساءل عن موقع رقابة الخطأ البين بين مستويات الرقابة التي يباشرها قاضي تجاوز السلطة؟

فمن المعروف أن هناك ثلاثة مستويات لتلك الرقابة سبق لنا بيانها وهي كالتالي:

أولاً: رقابة دنيا *Centrôle minimum*: وتتناول الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها من حيث وجودها المادي أو عدم مخالفتها للقانون، وكذلك من حيث عدم انطوائها على تعسف أو سوء استعمال من جانب الإدارة.

ثانياً: رقابة عادية *Centrôle Normal*: وتتناول التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها.

ثالثاً: رقابة قصوى *Contrôle maximum*، وتتناول أهمية وخطورة الوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتها، ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها.

لقد ذهب معظم رجال الفقه الفرنسي والمصري الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث والدراسة إلى اعتبار رقابة الخطأ البين عنصراً من عناصر المستوى الأول في الرقابة أي عنصراً من عناصر الرقابة الدنيا. فالفقيه الفرنسي Kornprobst يقول مثلاً: إن رقابة الخطأ البين قاصرة فقط على المنازعات التي لا تباشر في خصوصها سوى الرقابة الدنيا^(٢).

(1) Concl. Sur. C.E., 13 nov. 1970 Lambert, A.J.D.A., 1971, P. 34.

(2) op. cit., P. 123.

"il S'agit... de contentieux où ne S'exerçait qu' un contrôle minimum ..."

بل ونجد أن الأستاذ Pecteau قد وضع عنوانا للباب الثاني في رسالته السابق ذكرها يؤيد هذا المعنى إذ يقول في هذا العنوان: ظهور رقابة دنيا جديدة : الخطأ البين^(١).

L'apparition d' un nouveau contrôle "Minimum" Sur l'appréciation adm. Des faits (l'erreur manifeste).

ومن الفقه المصري نذكر الدكتور يحيى الجمل حيث يقول: "إن أحكام مجلس الدولة الفرنسي عممت تطبيق هذه الفكرة واعتبرتها أحد عناصر الحد الأدنى للرقابة^(٢)."

وقد استند هذا الفقه على ما يبدو فيما يقول إلى أحكام مجلس الدولة الصادرة في هذا الخصوص والتي أضافت عنصر الخطأ البين إلى عناصر تلك الرقابة الدنيا، إذ بعد أن كانت تشير هذه الأحكام إلى أن تقييم الإدارة أو تقديرها للوقائع لا يناقش أو يراقب من قبل مجلس الدولة طالما أنه لم يستند إلى وقائع مادية غير صحيحة أو إلى خطأ في القانون أو لم يكن مشوبا بإساءة استخدام السلطة ، أضافت العنصر الذي نحن بصدد. قائلة أو الم يكن مشوبا بخطأ بين، ومثال ذلك:

"que l'appréciation des commission... n'est pas Susceptible d' être discutée devant le Juge de l'excès de pouvoir , des lors qu' il..... ne repose ni sur une erreur de

(1) op. cit., PP. 233.

(٢) المقال السابق، ص ٤١٩.

droit, ni sur des faits matériels inexacts et n'est d'autre part, entachée d'aucun détournement de pouvoir ou d'aucune erreur manifeste "

فعلى أساس تلك الصياغة في الأحكام اعتبر أنصار الرأي الذي نحن بصدد أن الخطأ البين يقع في ذات مستوى الأخطاء الأخرى والتي تشكل أساس الرقابة الدنيا ومن ثم فهو يدخل كما يقولون في إطار هذه الرقابة الأخيرة.

ومن جانبنا نرى أنه لتحديد الموقع الذي يشغله الخطأ البين من مستويات الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري، فإنه يجب البحث أولاً من المجال الحقيقي الذي يعمل فيه هذا الوجه من أوجه إلغاء القرار الإداري، أو من الهدف الذي من أجله أستخدمت في مجال المنازعات الإدارية. إذ لا يكفي لتحديد هذا الموقع الاكتفاء بأمور شكلية أو ظاهرية كمجرد إدراجه في أحكام مجلس الدولة مع بقية عناصر الرقابة الدنيا، خاصة أن الخطأ البين لا يرتبط بتلك العناصر، فهو لا يتعلق مثلاً بالوجود المادي للوقائع أو عدم وجودها ذلك أن أحكام المجلس تجري على الجمع بين التعبيرين مما يدل على المغايرة بينهما، أو على أن المجلس يراقب الأمرين واحداً بعد الآخر. وكذلك الأمر بالنسبة للخطأ في القانون، حيث ينطوي هذا الأخير على معنى مغاير لذلك الذي استهدفه القضاء من إدخال فكرة الخطأ البين في منازعات أسباب العمل الإداري^(١).

(١) فالغلط في القانون يتحقق عندما تفسر الإدارة القانون تفسيراً خاطئاً، فتطبق النص القانوني المطروح أمامها باعتبار أنها مختصة في حين أنها غير مختصة أبداً، أو لا تطبق هذا النص على أساس أنها غير مختصة وهي في الحقيقة كذلك. في حين أن الخطأ البين إنما يتعلق بتقدير الإدارة للوقائع المادية للقرار.

وأخيرا فإنه لا تلازم بين الخطأ البين والانحراف بالسلطة، إذ قد يوجد هذا الخطأ والادارة حسنة النية^(١).

وكما ذكرنا من قبل لم يلجأ القاضي الإداري إلى فكرة الخطأ البين إلا للتغلب على الصعوبات التي تواجهه لبسط رقابة التكيف القانوني على مسائل أو حالات تتسم بالدقة والتقنية، أو تتطلب خبرة عملية معينة لارتباطها بالواقع العملي أكثر من ارتباطها بالواقع النظري، ومن ثم فقد اعتبرت رقابة الخطأ البين آنذاك وسيلة ناجعة لسد الثغرات أو النقائص التي تعتور تلك الرقابة. ولهذا فقد ظهرت بواكير تطبيقها - كما رأينا - في المجالات التي كانت مستثناة من رقابة التكيف القانوني للوقائع مثل معادلة مبادلة الوظائف، أو مبادلة الأراضي الزراعية أو المجالات العلمية والفنية... الخ.

لذا يمكن القول إن هذه الرقابة هي في حقيقتها ومعناها أقرب إلى الرقابة العادية *Contrôle normal* والخاصة بالتكيف القانوني للوقائع، أكثر من قربها للرقابة الدنيا لتلك الوقائع.

ومع ذلك يلاحظ أن جانبا من الفقه قد شكك في مدى أهمية رقابة الخطأ البين في مجال وصف أو تكيف وقائع العمل الإداري على هذا النحو، إذ يرون أن هذه الرقابة قد تكون عاملا من عوامل فرملة أو إعاقة تطور الرقابة القضائية في مجال المنازعات الإدارية على أساس أنها لا تتناول إلا التفاوت الصارخ أو البديهي في تكيف الوقائع . ولهذا فقد تساءل

(١) فقرار إعلان المنفعة العامة بالنسبة لموقع معين لنزع ملكيته، قد يشوبه عيب في تقدير قيمة الوقائع التي أدت إلى إعلان المنفعة العامة، ومع ذلك قد يكون غرض القرار صحيحا حيث أن الإدارة لم تستهدف غرضا ذاتيا.
دكتور/ سليمان الطماوي، نظرية الانحراف....، مرجع سبق ذكره، ص ٣٨ وما بعدها.

هذا الجانب الفقهي متخوفا عما إذا كان استخدام هذا الأسلوب الجديد يعد سببا يمنع القاضي من أن يجعل رقابة التكييف القانوني للوقائع رقابة كاملة في المجالات التي يطبق فيها هذا الأسلوب؟ أو عما إذا كان هذا الاستخدام يشكل تراجعاً أو ارتداداً لسلطات القاضي الإداري في مجال رقابة الأسباب؟^(١).

إن الواقع العملي للرقابة القضائية كفيل في حقيقة الأمر من الإجابة على تلك التساؤلات، فقد أثبت هذا الواقع، وكما سنرى عند دراستنا للتطبيقات القضائية، أن رقابة الخطأ البين والذي بدأ إعمالها كعامل مساعد أو معاون للقاضي من أجل بسط رقابته على المسائل التي يتضمن تكييفها تقديرات فنية أو علمية كما ذكرنا، أصبحت هذه الرقابة لا تباشر فقط على مثل هذه المسائل، أو على ما تتضمنه من تكييف قانوني للوقائع ، وإنما امتد مجال إعمالها إلى تقدير الإدارة للوقائع في ذاته، وهي الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري في حالة ما إذا لم يكن هناك نص قانوني يحكم المسألة موضوع النزاع أو في حالة ما إذا كان هذا النص متسماً بالغموض وعدم التحديد، حيث تتمتع الإدارة في خصوص هذه المسألة بسلطة تقديرية. لهذا يقال للرقابة هنا رقابة الملاءمة. ومن ثم فقد أطلق البعض على رقابة القاضي

(1) "....que l'utilisation de l'erreur manifeste ne stoppe l'évolution du contrôle juridictionnel et ne l' empêche d'aller jusqu'à un contrôle complet de qualification juridique des faits dans les domaines que ce contrôle constitue une régression du pouvoir concernés, du juge dans le contrôle des motifs"

B. Kornprobst, op. cit., P. 124, J.Y. Vincent, l'erreur manifeste d'appréciation, Rev. adm., op. cit., P. 413; Note Mazibert et de M. Boisdeffre sur C. E. lo dec, 1968, M. Crépin loredon; et C. E. 13 Janv. 1968, M. Daniel legrand, A. J.D.A., 1987, P. 97 etss.

للخطأ البين في هذه الحالة اسم "رقابة الخطأ البين في التقييم" ^(١) Contôle de l'erreur manifeste d'appréciation. بل لقد امتد مجال أعمال نظرية الخطأ البين إلى مدى تناسب مضمون أو محل القرار الإداري مع الوقائع التي يستند إليها هذا القرار وهو ما يقال له رقابة النسبة أو التناسب Controle de proportionnalité وذلك على التفصيل السابق بيانه.

ثلاثة مواقع إذن لرقابة الخطأ البين في مجال المنازعات الادارية:
الخطأ البين في تكييف الوقائع - الخطأ البين في تقييم وتقدير هذه الوقائع -
الخطأ البين في مدى ملاءمة القرار لظروف الوقائع.

ولمزيد من الإيضاح نتناول في المبحث التالي نطاق تطبيق رقابة
الخطأ البين في الواقع العملي.

(1) S. Ktistaki, op. cit., P. 4 etss.

المبحث الثاني

نطاق تطبيق رقابة الخطأ البين

لم يكن نطاق تطبيق نظرية رقابة الخطأ البين عند العمل بها عام ١٩٦٠ يتضمن سوى حالات محدودة من نزاعات العمل الإداري، إذ كان مقتصرًا في هذه الأثناء - وكما بينا - على بعض من الحالات التي كان يمتنع القضاء عن أعمال رقابة التكييف القانوني في خصوصها مثل معادلة الوظائف - مبادلة الأراضي الزراعية - تقدير حالة منتج دوائي معين... الخ. أما الآن وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على تبني تلك النظرية، فإن مراجعة بسيطة للأحكام التي صدرت عن مجلس الدولة في شأنها، يكشف على الفور مدى الانتساع الذي طرأ على هذا النطاق، إذ أصبح متضمنًا في واقع الأمر، كافة نزاعات العمل الإداري التي لم تكن محلًا لأية رقابة قضائية من قبل، سواء في ذلك تلك التي تثور في المجالات التقليدية لهذا العمل، أم النزاعات التي تثور في المجالات الحديثة له، بل وسواء أكانت هذه النزاعات أو تلك تتعلق بمسألة التكييف القانوني للوقائع، أم بمسألة التناسب بين الإجراء المتخذ من قبل الإدارة وبين مدى أهمية وخطورة الوقائع المرتكزة عليها، وهو ما يقال له الرقابة القصوى *Contrôle maximum*.

وتفصيلًا لهذا الإجمال نبين فيما يلي الموضوعين التاليين:

- المجالات التقليدية لنزاعات العمل الإداري ورقابة الخطأ البين.
- المجالات الحديثة لنزاعات العمل الإداري ورقابة الخطأ البين.

المطلب الأول

المجالات التقليدية لنزاعات العمل الإداري

ورقابة الخطأ البين

يعتبر مجال كل من الوظيفة العامة والضبط الإداري من المجالات التقليدية لنزاعات العمل الإداري، بل ويعتبران في حقيقة الأمر عصب تلك المجالات، ذلك أن القاضي الإداري باشر فيها ولأول مرة، رقابته على مدى صحة وقائع العمل الإداري لدرجة يمكن معها القول أنهما يجسدان مهد تلك الرقابة، و هذا أمر بديهي إذ يبدو في هذين المجالين التعارض أو التناقض على الأقل من حيث الظاهر بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

فالإدارة من جانبها تسعى دوماً إلى اعلاء كل ما شأنه تحقيق مصلحة المرافق العامة وحماية النظام العام ولو كان ذلك على حساب حقوق الأفراد وحررياتهم. وهؤلاء الآخر يسعون من جانبهم كذلك إلى الحصول على أكبر قدر من الامتيازات أو إلى تحقيق المزيد من الحقوق والحریات ولو كان ذلك على حساب مصلحة المرافق العامة أو النظام العام، الأمر الذي من شأنه إثارة الكثير من النزاعات أو القضايا التي تتطلب حلاً أو حسماً من جانب القضاء.

فمجال الوظيفة العامة ومجال الضبط الإداري يشكلان إذن التربة التي تمت وتطورت فيها الرقابة القضائية حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن. ولهذا يعد أمراً طبيعياً بل ومنطقياً أن تظهر في إطارهما أولى تطبيقات نظرية رقابة الخطأ البين.

وعلى ذلك نتناول فيما يلي الموضوعين التاليين:

- منازعات الوظيفة العامة ورقابة الخطأ البين.

- منازعات إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب ورقابة الخطأ البين.

الفرع الأول

مناعات الوظيفة العامة ورقابة الخطأ البين

إذا كانت نظرية رقابة الخطأ البين قد ظهرت لأول مرة - كما بينا - في مجال الوظيفة العامة، إلا أنها لم تكن مع ذلك تتناول كافة المنازعات التي تثور في هذا المجال، إذ بقي تأديب الموظفين خارج نطاق تطبيقها حتى عهد قريب نسبياً، حيث كان يفضل مجلس الدولة - قبل أن يعدل عن مسلكه هذا - أن تظل الإدارة متمتعة في خصوصه بسلطة تقديرية واسعة لأسباب سنبينها فيما بعد.

ولهذا نرى قبل أن نتناول مسألة تأديب الموظفين ورقابة الخطأ البين لما يحيط بتلك المسألة من اعتبارات خاصة، أن تلقى في عجلة نظرة إجمالية على كيفية تطبيق هذه الرقابة في منازعات الوظيفة العامة الأخرى كي نتبين كيف تدرج مجلس الدولة في إعمالها في خصوص تلك المنازعات.

وعن ذلك نتناول المسألتين التاليتين:

- لمحة عن منازعات الوظيفة العامة ورقابة الخطأ البين.

- منازعات تأديب الموظفين ورقابة الخطأ البين.

المسألة الأولى: لمحة عن منازعات الوظيفة العامة ورقابة الخطأ البين:

ذكرنا من قبل أن مسألة معادلة الوظائف العامة ليست فقط من أولى المسائل التي حسمت عن طريق نظرية رقابة الخطأ البين، وإنما أيضاً من أولى المسائل التي طبقت فيها تلك النظرية بصفة عامة. من هنا كان القول

بأن مجال الوظيفة العامة يمثل المجال الأساسي لظهور وتطور النظرية التي نحن بصددتها، خاصة أن القاضي الإداري كان حريصاً منذ البداية على أن تكون تصرفات الإدارة التقديرية في هذا المجال تصرفات منطقية ومعقولة Raisonnable. لذلك فقد عمل على إعمال رقابته للخطأ البين في كافة المنازعات التي تثور في مختلف سياسات الموظف الوظيفية وذلك بدءاً من الالتحاق بالوظيفة العامة وحتى انتهاء خدماته به.

وفيما يلي نبين بعضاً من تلك السياسات :

١ - الالتحاق بالوظيفة العامة:

يمكن القول أن مجلس الدلة، بعد أن كان يرفض مناقشة مدى صحة تقدير الإدارة لشروط القبول في المسابقات التي تعقد لشغل إحدى الوظائف العامة^(١)، باشر رقابة الخطأ البين في تكييف هذا التقدير، خاصة ما تعلق من هذه الشروط بالكفاءة المطلوبة في المرشح لكي يسجل على قائمة المقبولين لدخول المسابقة^(٢)، كما باشر هذه الرقابة أيضاً في خصوص تقييم الإدارة لكفاءة المرشح لشغل الوظيفة العامة بعد النجاح في المسابقة . فقد قضى مثلاً بشرعية قرار المحافظ بعدم تعيين من كان ترتيبه الثاني في

(1) C.E., 6 avr. 1973, Jacques, Rec., P. 288.

(2) C.E., 19 Juin 1981, Regnault de la Mothe Tables, P. 777, Concl. Massot.

كما أعمل المجلس رقابة الخطأ البين كذلك في المنازعات المتعلقة بتحديد الإدارة لشروط شغل الوظائف. ففي حكمه الصادر في قضية Sieur Boyert الأستاذ بكلية طب باريس والذي نازع في شروط التعيين في وظيفة مفتش عام للخدمات الصحية لمدينة باريس والتي ترتب عليها أن عينت في هذه الوظيفة السيدة corre-hurst بدلا منه، رفض المجلس طلبات المدعي مقرا أن تكييف الإدارة وتقديرها لتوافر شروط شغل هذه السيدة للوظيفة المذكورة لم يكن مشوبا بخطأ بين.

C.E. 10 Fev. 1978, boyer, Rec. P. 68; C.E. 16 de. 1988, MD Pavillon, A.J.D.A., 1989, P. 143.

امتحان المسابقة التي عقدت لشغل إحدى الوظائف العامة، قائلاً أنه لم يثبت أن تقدير الادارة لعدم كفاية نتائج امتحانات الطاعن الأول والتي تبين عدم صلاحيته لشغل الوظيفة المطلوبة يقوم على أساس من الوقائع المادية غير الصحيحة، وأنه مشوب بخطأ بين^(١).

هذا ويلاحظ أن رقابة القاضي الإداري في هذه الحالة لم تكن تتناول سوى تقييم الادارة لنتائج الامتحانات التي أجراها المرشح لشغل إحدى الوظائف العامة دون أن تمتد لتشمل الظروف الخارجية التي أحاطت بهذا التقدير أو التقييم والتي كان لها أثرها أيضاً على القرار المطعون فيه، فقد اقتصر - كما ذكرنا - على رقابة نتائج الامتحانات واستخلص منها عدم الصلاحية لشغل هذه الوظيفة، إلا أنه سرعان ما خطا في هذا الصدد خطوة أخرى إلى الأمام وذلك عندما قبل أن يجرى رقابة كاملة على تقدير الإدارة في هذا الشأن، حيث لم يكتف برقابة تقييم الادارة لنتائج الامتحانات التي أجراها صاحب الشأن، وإنما فحص أيضاً كافة الظروف التي أحاطت بقرار الادارة برفض التعيين بما فيها تلك النتائج . فهو يقول في الحكم الصادر بتاريخ ٢٢ أكتوبر ١٩٨٢: أنه ينتج من ملف الدعوى ومن فحص كافة الظروف التي أحاطت بتلك الدعوى، عدم وجود دليل على عدم الكفاية المهنية لصاحب الشأن، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون مشوباً بخطأ بين في التقدير^(٢).

(1) qu'il n'est pas établi que l'appréciation sur l'insuffisance des résultats et l' inaptitude à remplir l'emploi visé... repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d' erreur manifeste C. E., 12 oct. 1979, Albino ., A. J, D, A. , 1980, P. 168,

(2) C.E., 22 oct. 1982, R.D.P. 1983, P. 1111.

حيث يقول في هذا الحكم:

فمجلس الدولة باشر هنا إذن رقابة قصوى طالما أنه قبل بحث التقدير الشخصي لكافة الظروف التي أحاطت بالقرار المتخذ. ولهذا يقال لتلك الرقابة: الرقابة القصوى للخطأ البين في التقييم المجرد للوقائع:

Le Contrôle maximum de l'erreur manifeste d'appréciation concrète des faits.

٢ - تقارير كفاية الموظفين:

يلاحظ أن مجلس الدولة قد اتبع في شأن المنازعات التي تثور بمناسبة هذه التقارير، ذات التدرج الذي رأيناه في رقابته لمنازعات الالتحاق بالوظيفة العامة، إذ بعد أن كان يرفض كل رقابة على تقدير الإدارة لكفاية الموظفين، خاصة ما تعلق منها بالكفاية الرقمية^(١) (Notation) قبل أن يراقب الخطأ البين في تكييف هذا التقدير؛ ومن صور هذا القبول أنه رفض الدعوى التي أقامها Sieur Bart الموظف بوزارة الشؤون الاجتماعية، طالبا فيها إلغاء القرار الصادر بتقدير كفايته عن عام ١٩٦٧، قائلاً لتبرير هذا الرفض إن التقدير المذكور لم يشبه خطأ بين^(٢)، ثم انتقل بعد ذلك الى تطبيق الصورة القصوى لرقابة الخطأ البين، وهي مدى التناسب أو التلاؤم بين الكفاية الرقمية Notation وبين التقييم العام للكفاءة المهنية L'appréciation générale d' aptitude professionnelle

"qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'absence de Tout élément permettant d' établir l' inaptitude professionnelle de M. Pierre que, dans les circonstances de l' espèce, la decision attaquée est entachée d' une erreur manifeste d'appréciation".

(1) C. E, 22 Juil . 1937, Ferrere , Rec. P. 713 ; C, E., 5 Janv. 1951, Barat, Rec. P. 750; C.E., 18 Juin 1948, lamflin, Rec., P. 275., C. E. 19 nov. 1971, Delle Brugiere, Rec. P. 692.

(2) C.E., 16 fev. 1973, Bart, Rec., P.147.

وكان ذلك بمناسبة الحكم السابق الإشارة إليه في قضية Leca بتاريخ ٢٦ أكتوبر ١٩٧٩.

حقيقة أن مجلس الدولة رفض طعن السيد Leca في القرار الضمني برفض مراجعة الدرجة الرقمية التي منحت له كما بينا، قائلًا إن هذه الدرجة ليست مشوبة بخطأ بين في التقدير، إلا أن صدور الحكم على هذا النحو يمثل في الواقع أهمية بالغة، إذ يعبر عن تخطي مجلس الدولة عن رفضه الدائم لرقابة التناسب بين الكفاية الرقمية والتقييم العام للكفاءة المهنية، أو بمعنى آخر يعبر عن تخليه كقاعدة عامة عن الرقابة المقيدة *Contrôle maximum* لصالح الرقابة القصوى *Contrôle restraint* في خصوص كفاية الموظفين.

وقد تأكد ذلك في أحكام أخرى عديدة منها الحكم الصادر عام ١٩٨١ والذي اعتبر فيه مجلس الدولة أن السلوك السلبي للموظف العام يؤثر على حسن إدارة المرفق الذي يعمل فيه ويبرر بالتالي حصوله على درجات أقل عند منحه تقرير الكفاية الرقمية^(١). فالقاضي هنا يراقب إذن خطأ البين في التقدير الذي أجرته الإدارة بالنظر إلى الوقائع التي استندت إليها في هذا التقدير وهو ما يقال له رقابة النسبية أو التناسب *Contrôle de proportionnalité*.

٣ - إحالة الموظفين إلى الاستിاداع أو فصلهم من الخدمة:

لم يتوان مجلس الدولة أيضا عن تطبيق نظرية الخطأ البين عند رقابته للقرارات الادارية الصادرة في مثل هذه الحالات، ففي حكمه الصادر

(٢) C.E, 25 mars 1981, Vial, Rec, P. 164, C.E, 13 mars 1997, (1) Bauhain, Rec. P. 95, D. 1987, P. 523, note stephone Doumbe Bille.

في قضية السيد Poix الضابط بالبحرية والذي يطلب إلغاء المرسوم الصادر بإحالة للاستيداع بالتطبيق لأحكام القانون الصادرة في ١٩ مايو ١٩٣٤، يقول مجلس الدولة: إن للإدارة بمناسبة تنظيم أو إعادة تنظيم الجهاز الإداري سلطة تقديرية في إحالة الضباط إلى الاستيداع، ومن ثم فهو لا يراقب أسباب هذه الإحالة إلا إذا كانت هناك وقائع مادية غير صحيحة أو كان هناك غلط في القانون أو انحراف بالسلطة أو خطأ بين في التقدير^(١).

وقد تأيدت رقابة المجلس على قرارات الإحالة إلى الاستيداع باستخدام نظرية الخطأ البين في أحكام أخرى عديدة منها الحكم الصادر في ١٧ يناير ١٩٧٣ والذي تخلص وقائعه في أن السيد Gazelles معاون السكرتير العام لمدينة Rennes أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية لهذه المدينة يطلب فيها إلغاء القرار الصادر من عمدة المدينة بإحالة إلى الاستيداع. فرفضت المحكمة طلبه ، فطعن في الحكم الصادر منها أمام مجلس الدولة الذي رفض بدوره الطعن على أساس أن قرار العزل مبرر بما ارتكبه السيد Gazelles من أخطاء وظيفية، وأنه لا يتضح من الأوراق أن هذا القرار يقوم على وقائع مادية غير صحيحة أو أنه مشوب بخطأ بين في التقدير^(٢).

وذات الاتجاه أيضا طبقة في القرارات الصادرة بفصل الموظفين. ففي حكمه الصادر عام ١٩٨٣ رفض مجلس الدولة إلغاء القرار الصادر من مدير المركز القومي للفن والثقافة لجورج بومبيدو، بفصل أحد الموظفين حيث ثبت له أن هذا القرار لم يكن مشوبا بخطأ بين في التقدير^(٣).

(1) C.E., 26 avr. 1967, Soeur Poix, Rec. P. 176.

(2) C.E., 17 Janv. 1973, Gazelles, Rec., P. 43.

(3) C.E., 30 sep. 1983, Barre, Rec., P. 394.

هذه لمحة سريعة عن بعض أحكام القضاء الإداري التي تؤكد مدى حرص مجلس الدولة الفرنسي على تطوير رقابته لأسباب المنازعات الإدارية وذلك من خلال إعماله نظرية الخطأ البين في شأن هذه المنازعات، خاصة تلك التي تثار بصدد مسائل تتمتع الإدارة في خصوصها بسلطة تقديرية، الأمر الذي يحد من هذه السلطة ويقيم في ذات الوقت ضماناً هامة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

هذا وقد سبق لنا الحديث عن رقابة الخطأ البين في خصوص بقية سياسات الأفراد الوظيفية مثل الترقيات - النقل - النذب - التطهير الإداري...الخ فنحيل عليه.

المسألة الثانية: منازعات تأديب الموظفين ورقابة الخطأ البين:

أولاً: الاتجاه التقليدي للقضاء الإداري في رقابة منازعات تأديب الموظفين:

تجدر الإشارة بأن من السمات المميزة للجريمة التأديبية أنها تقتصر الى تعريف قانوني محدد، اذ يكتفى المشرع عادة ببيان واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم، ثم ينص على أن كل موظف يخالف هذه الواجبات أو تلك المحظورات يجازي تأديباً، فالجريمة التأديبية إذن هي إخلال الموظف بواجبات وظيفته، سواء أكانت هذه الواجبات كانت إيجابية أم سلبية. ولهذا فإن المبدأ القاضى بأنه (لا جريمة إلا بنص) والمقرر فى قانون العقوبات أو القوانين الجنائية الأخرى لا وجود له فى المجال التأديبى، كما أن الجزاءات التأديبية وإن كان المشرع قد حددها على سبيل الحصر، إلا أنه ترك للإدارة حرية اختيار إحداها بما يتلاءم ويتناسب مع الخطأ أو الذنب الإداري^(١).

(1) C.E., 12 Janv. 1938 Coulangeon, Rec. P. 11; C.E., 29 oct. 1948, Maussac, Rec. P. 397; C.E., 11 Juill. 1952, Dame veuve monluc, Rec., P. 378.

فالإدارة اذن تتمتع في المجال التأديبي بسلطة تقديرية وذلك من ناحيتين:

الأولى: في نطاق التأثيم حيث لها أن تعتبر أو لا تعتبر أفعالا بذاتها جرائم تأديبية.

الثانية: في نطاق توقيع العقوبة الملائمة أو المناسبة ، إذ تملك حرية اختيار هذه العقوبة من بين العقوبات المحددة قانونا.

والقضاء الإداري من جانبه أقر بهذه السلطة التقديرية، مكتفيا في هذا الصدد بالتحقق من صحة الوجود المادي للوقائع وبأن هذه الوقائع مما يندرج في إطار الجرائم التأديبية، أو أنها تشكل ذنبا إداريا وهو ما يقال له رقابة الوجود المادي للوقائع، ورقابة التكييف القانوني لهذه الوقائع، ومن ثم فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي وحتى عام ١٩٧٨ رقابة تقدير الإدارة

فتقدير الجزاءات التأديبية أو مدى ملائمة هذه الجزاءات - يقول مجلس الدولة - في الأحكام السابقة ليس من طبيعته أن يكون موضع نقاش أمام القضاء.

L'appréciation des peins disciplinaire infliger n'est pas de nature à faire l'objet d'un débat par la voie contentieuse.

أو أن اختبار الجزاء التأديبي لا يناقش أمام القاضي.

Le choix de la sanction ne saurait être discuté devant le juge.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا محدودا جدا من الأحكام التي فرض مجلس الدولة الفرنسي رقابته فيها على التناسب، وهي الأحكام المتعلقة بمسائل التطهير الإداري. فعندما وقعت فرنسا تحت الاحتلال الألماني أصدرت حكومة فيشي قانونا في ١٩٤٠/٧/١٧ لتعيين العناصر الوطنية. وبعد تحرير فرنسا صدر قانون ١٩٤٤/٧/٢٧ لمعالجة آثار القانون الأول وذلك بتطهير الجهاز الإداري ممن تعاونوا مع سلطات الاحتلال.

وهنا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي لم يقتصر في خصوص المنازعات التي ثارت في هذا الشأن ببحث مدى صحة الوقائع المنسوبة للموظف أو بتكييفها القانوني وإنما تجاوز ذلك إلى بحث ما إذا كانت هذه الوقائع من الخطورة بحيث تبرر إجراء التطهير.

"...mais si par leur nature (les faits) et leur gravité, ils Justifient L'épuration..., C.E., 7 nov. 1951, Grund, Rec., P. 516.

لمدى ملاءمة أو تناسب الجزاء التأديبي الموقع على الموظف مع الأفعال أو الوقائع المنسوبة^(١)، وقد كان يعبر عن ذلك بصيغة شبه مستقرة يقول فيها:

"il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité de la sanction légalement prononcée par l'autorité competente"

وقد قيل في تبرير موقف مجلس الدولة هذا أن الرقابة على مدى ملاءمة الجزاء التأديبي للمخالفات المنسوبة إلى صاحب الشأن يتعارض مع ما يجب أن يكون للإدارة من سلطة في تقدير الظروف المشددة أو المخففة والتي تكون عادة مصاحبة للوقائع المشكلة لتلك المخالفات. فالإدارة بإمكانها في واقع الأمر أن تضع في حساباتها عند توقيع الجزاء التأديبي، عناصر غير قانونية يصعب على القاضي تقدير مدى أهميتها بحكم كونه بعيدا عن الظروف التي تحيط بالمرفق والتي تكون قد دفعت بالموظف إلى ارتكاب الفعل الآثم^(٢). فلما مثلا أن تضع في الاعتبار مصلحة المرفق التي قد تتطلب أن يكون الجزاء رادعا وزاجرا حتى يكون الموظف المخطئ عبرة لغيره من الزملاء، كما لها أن تضع في اعتبارها السلوك العام للموظف وكذلك الظروف الشخصية أو العائلية له، وهذه كلها كما هو واضح مسائل يصعب على القاضي الإداري - كما ذكرنا - الإلمام أو العلم بها أثناء نظره للنزاع المطروح أمامه، الأمر الذي قد يجعل جزاءه أو تقديره لهذا الجراء في أحيان كثيرة غير ملائم في حقيقة وواقع الحال الذي عليه الموظف صاحب الشأن.

(1) Auby, le contrôle juridictionnel du degré de gravité d'une sanction disciplinaire, note sous CE, 9 juin 1978 lebon, R.D.P., P.827.

(2) Pacteau (B.), le nouveau contrôle du juge adm. sur la sanction disciplinaire, note sous. C.E., 9 juin 1978, lebon No2 1979, p.30 etss

وإذا كانت هذه هي المبررات التي ارتكز عليها مجلس الدولة في رفضه لرقابة الملاءمة في المجال التأديبي، فإنها أيضا كانت على ما يبدو السبب وراء رفضه لرقابة الخطأ البين في هذا المجال. إذ بعد أن ظهرت تلك الرقابة في قضائه فترة زمنية طويلة نسبيا بقي مصرا على موقفه المبدئي في هذا الخصوص. إذ يقول في أحد أحكامه الصادرة عام ١٩٧٦^(١):

le degré de gravité de la sanction, compte tenu des faits reprochés, ne saurait être discuté par la voie contentieuse.

بقي على هذا الموقف رغم مطالبة مفوضي الحكومة له بضرورة العدول عنه، ومن ثم تطبيق نظرية رقابة الخطأ البين في مجال القرارات التأديبية؛ فقد اقترح السيد Kahn في مذكرته المقدمة للمجلس بخصوص قضية الآنسة chevreau والتي كانت تعمل مساعدة ممرضة في إحدى المراكز الطبية، بإلغاء الجزاء الموقع في حق هذه الآنسة على أساس الخطأ البين، قائلًا في هذه المذكرة: إن التفاوت بين الخطأ المقترف (عدم معاملة إحدى المرضى بلطف ورقة) والعقوبة الموقعة (العزل من الخدمة) يبدو أنه تفاوت غير مقبول أو غير ملائم.... وأثل الحل التقليدي بعدم رقابة هذا التفاوت يتسم بالقسوة ولم يعد مبررا في الواقع.

ثم يضيف قائلًا إنه إذا كان من غير العدل توقيع عقوبة الإنذار أو اللوم لفعل لا يبرر بطبيعته توقيع أي جزاء، فإنه يكون من غير العدل أيضا توقيع عقوبة العزل أو الطرد من الخدمة لمجرد ارتكاب الموظف لخطأ طفيف أو عرضي^(٢).

(1) C.E., 1 oct. 1976, M. Boutet, note B. Pacteau. D. 1977, P. 552.

(٢) يقول السيد Kahn بلغته في المذكرة المشار إليها:

ومن جانبه يدافع أيضا السيد Braibant مفوض الحكومة عن الاقتراح بضرورة تطبيق رقابة الخطأ البين في المجال التأديبي حيث يتساءل أمام مجلس الدولة ساخرا ومتهكما مما يستطيع أن يفعله موظف عوقب بالطرد من الخدمة لمجرد وصوله متأخرا بعض الوقت إلى موقع عمله؟! ماذا يفعل هذا الموظف امام امتناع القضاء الاداري عن التصدي لمثل هذا التفاوت الصارخ؟!^(١).

بل لقد كان موقف القضاء على هذا النحو محل امتعاض وشجب من جانب عدد من رجال الفقه الذين كانوا يرون فيه اساسا وسندا لاستبداد وتعسف السلطات التأديبية، خاصة في وقت تزايدت فيه الأعباء الادارية واصبحت تثقل كاهل الموظفين، ولهذا فهم كانوا يأملون دائما أن يعدل مجلس الدولة عن هذا الموقف في السنوات المقبلة^(٢).

لقد بقي مجلس الدولة رغم تلك المطالبات والنداءات وفيا لقضائه السابق المتمثل في الامتناع عن رقابة التناسب أو رقابة الخطأ البين في المجال التأديبي.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه قد حدث في هذه الأثناء تطور قضائي هام في هذا المجال وذلك على أثر ما أصاب رقابة تعدد أسباب

" il ya une telle disproportion entre la faute et le châtement que l'initiative du directeur apparait à ce point inopportune, pour ne pas dire inconvenante... la solution traditionnelle ne se justifie plus dans sa rigueur". Concl. Sur, C.E., Delle cheverau, 22 nov. 1967, D. 1969, D. 1969, 111, P. 51, note J. Murgeon.

(1) S. Ktistaki, Thase précitée, P. 80.

(2) J.Y. Vincent, l'erreur manifeste d'appréciation, op. cit., P. 417; Cf. Heumann, Dix ans de jurisprudence du C.E., 1967 à 1986 E.D.C.E., 1976, P. 25.

العمل الإداري من تحول أو تغير وهو ما نشير إليه بإيجاز شديد فيما يلي.

ثانياً: تعدد الأسباب ومنازعات تأديب الموظفين

يقصد بتعدد الأسباب أن العمل الإداري يستند عند إصداره لا إلى واقعة أو سبب واحد وإنما إلى وقائع أو أسباب عديدة. وقد تكون هذه الوقائع أو تلك الأسباب محددة قانوناً، وهنا لا تثور أدنى صعوبة أو مشكلة، حيث يجب على كل من الإدارة والقاضي الالتزام بضرورة تحققها جميعاً وإلا كان القرار باطلاً؛ بمعنى أن تخلف أو عدم صحة واحد أو أكثر منها يؤدي غالباً إلى إلغاء القرار المستند إليها. نقول غالباً لأن القاضي الإداري قد ينتهي - رغم ذلك- إلى الإبقاء على هذا القرار إذا ما اتضح له أنه كان سيصدر في جميع الأحوال؛ إذ يقوم القاضي في هذه الحالة بإحلال السبب الصحيح محل السبب الخاطئ الذي استندت إليه الإدارة^(١).

فإذا لم تكن وقائع القرار أو أسبابه محددة قانوناً، مما يعني أن الإدارة تتمتع في خصوصها بسلطة تقديرية واسعة، فإن الصعوبة أو المشكلة تكمن في معرفة مدى سلطة القاضي الإداري إزاء القرار المستند إلى هذه الوقائع أو تلك الأسباب، إذا اتضح له عدم صحة أحدها أو بعضها. هل يملك إلغاء مثل هذا القرار؟

لقد مرت الإجابة على هذا التساؤل بثلاث مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: وفيها اعتبر القاضي الإداري أن القرار التأديبي المستند إلى وقائع أو أسباب متعددة، وثبت له عدم صحة إحداها أو بعض منها، اعتبره رغم ذلك قراراً سليماً؛ على أساس أن الأسباب الصحيحة الأخرى والتي يمكن للإدارة بما لها من سلطة تقديرية الاستناد إليها، تكفي

(1) Pacteau, op. cit., P. 115 etss.

لحمل هذا القرار أو لتبريره. فإذا نسب إلى أحد الموظفين عدة وقائع أو مخالفات ثبت لمجلس الدولة تخلف أو عدم صحة بعضها، امتنع عليه - رغم ذلك - إلغاء القرار التأديبي المستند إليها جميعاً، باعتبار أن الوقائع أو المخالفات التي تثبت صحتها والتي يمكن للإدارة بما لها من سلطة تقديرية - كما ذكرنا - الاستناد إليها فقط، تكفي لحمل أو لتبرير هذا القرار.

وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بصحة القرار التأديبي الصادر بفصل موظف عن العمل والذي استندت الإدارة عند إصداره إلى سببين تبين للمجلس صحة الأول منهما فالمجلس لم يتعرض في الواقع للبحث في مدى صحة السبب الثاني معتبراً أن السبب الأول يكفي بمفرده لتبرير قرار الفصل^(١).

وهذا هو ما انتهجه مجلس الدولة المصري حيث تقول المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها: "ومن حيث أنه متى كان الأمر على النحو السالف إيضاحه، وقد تبين أن القرار التأديبي المطعون فيه قد بنى على سببين، فإنه وإن كان قد ثبت عدم صحة الثاني منهما.. إلا أن هذا القرار يظل على الرغم من ذلك محمولاً على سببه الأول.. ومن ثم يكون قد قام على سببه الصحيح المبرر له وصدر مطابقاً للقانون.. إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا قام القرار الإداري على أكثر من سبب واحد، فإن استبعاد أي سبب منه لا يبطل القرار ولا يجعله غير قائم على سببه طالما أن السبب الآخر يؤدي إلى النتيجة ذاتها"^(٢).

فتخلف أو عدم صحة بعض أسباب أو وقائع القرار التأديبي لم تكن

(1) C.E., 5 Juill 1939, Pujol, Rec., P. 450.

(٢) الحكم الصادر في ٢٤ مايو ١٩٦٩، س ١٠، ق ٢١، مجموعة السنة الرابعة عشر، العدد الثاني، ص ٧٢٣.

إذن ذات أثر على سلامة أو مشروعية هذا القرار، إذ كان القضاء يكتفي لاعتباره كذلك مجرد استناده إلى سبب أو أسباب أخرى صحيحة. ومع ذلك فإن هذا القضاء كان يصطدم بما كان سائداً في الفقه آنذاك^(١)، حيث كان ينظر إلى كافة وقائع أو أسباب القرار على أنها تشكل في مجموعه ركن السبب في القرار؛ ومن ثم يجب تحققها جميعاً، وإلا اختل هذا الركن وكان القرار بالتالي باطلاً.

وللتوفيق بين الفقه السائد على هذا النحو وبين القضاء السابق، ثم التمييز بين نوعين من الوقائع أو الأسباب^(٢):

الأولى: ويطلق عليها الأسباب الزائدة *Motifs Surabondants* ، وهي تلك التي لا أثر لها على سلامة القرار، ومن ثم فإن تخلفها أو عدم صحتها لا يؤدي إلى بطلان القرار.

(1) JEZE, motifs Justifiant la dissolution d'un conseil municipal, R.D.P., 1922, P.377; De Soto, Note, R.D.P., 1950, P448.

الدكتور/ السيد محمد إبراهيم سليمان، الرقابة على الوقائع في قضاء الإبعاد، مرجع سبق ذكره، ص ٣٩٦ وما بعدها.

(2) Waline, droit administratif, 9ème, éd., 1963 P437; VEDEL, droit administratif paris, 1967, P.429; Letourneur, apparition de nouveau éléments Subjectifs dans le recours pour excès de pouvoir, E.D.C.E., 1953. P.9.; Debbesch et Ricci, contentieux administratif, Paris, 1982, P 776; Gandolfi. les motifs de terminants dans le recours pour excès de pouvoir, J.C.P, 1964-1.1935.

وانظر أيضاً: دكتور/ محمد حسنين عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٨٤، ص ١٩١؛ دكتور/ ثروت عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص ٢٠٥ وما بعدها؛ دكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة، مرجع سبق ذكره، ص ٣٥١؛ دكتور/ محمد مصطفى حسن، السلطة التقديرية، مرجع سبق ذكره، ص ١٧٨ وما بعدها؛ دكتور/ سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٢ ص ١٦١ وما بعدها.

الثانية: وهي ما يقال لها الأسباب الدافعة *Motifs déterminants* وهي الأسباب التي تلعب دوراً رئيسياً في إصدار القرار أو التي تدفع الإدارة الى اتخاذ هذا القرار. ولهذا فإن تخلف إحداها أو ثبوت عدم صحته يؤدي الى تصدع ركن السبب، الأمر الذي يصبح معه القرار باطلاً.

والأصل - كما يذهب البعض بحق - أن جميع الأسباب التي تستند إليها الإدارة تعتبر أسباباً رئيسية بحيث يكفي عدم صحة بعضها لإبطال القرار. ولذا فإن الطابع الثانوي للسبب يجب أن يظهر بوضوح من عبارات القرار نفسه أو من الأوراق التي يضمها ملف الدعوى^(١).

وفي هذا الصدد نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يقرر في أحد أحكامه أنه "... إذا كان صحيحاً أن ثلاثة من الأسباب التي استند إليها محافظ مقاطعة Landes في قراره قد اتضح عدم وجودها مادياً ... فإنه يبين من التحقيق أن المحافظ كان سيصدر نفس القرار لو لم يستند إلا إلى السببين اللذين ثبت صحتها^(٢).

كما تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر أيضاً أنه إذا "ثبت أن من بين الوقائع التي قدم العمدة من أجلها إلى لجنة الشياخات، فقررت فصله، ما يمكن طرحه أو الغض عنه وعدم الاعتداد به، وإن في باقي ما نسب إليه من وقائع ما ينهض في جملته سبباً كافياً مبرراً للمؤاخذة التأديبية التي انتهت إليها قرار اللجنة المذكورة ... إذا ثبت ما تقدم ، فإن هذا القرار يكون صحيحاً في محله ويتعين على القضاء رفض الدعوى بطلب إلغائه"^(٣).

(١) دكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ٨٥.

(2) C.E., 19 avr. 1968, Mlle Letum, Rec., P. 251.

أشار إليه الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ٨٥، هامش رقم ٣.
(٣) الحكم الصادر في ١٥/٦/١٩٥٧، س ٣، ق ١١٥، مجموعة السنة الثانية، ص ١١٧٣.

ومع ذلك تجدر الإشارة الى أنه رغم ما قيل من معايير لتحديد ما يعتبر من الأسباب زائد وما لا يعتبر كذلك؛ أو ما يعتبر منها ثانوى وما يعتبر دافع أو أساسي، تلك المعايير التي تكمن إما في النظر إلى مدى تأثير الواقعة أو السبب على إرادة رجل الإدارة في اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار، وإما في النظر إلى مدى أهمية كل واقعة أو سبب على حدة دون نظر إلى بقية الوقائع أو الأسباب الأخرى، إذ يعتبر السبب في هذه الحالة رئيسي إذا اتضح أن القرار ما كان ليتخذ لو أن عدم صحة هذا السبب كانت معلومة بشكل مسبق، أما إذا كان القرار سوف يتخذ رغم عدم صحة السبب، فإن هذا السبب يعتبر والحال هكذا سبباً زائداً أو ثانوياً، نقول رغم ما قيل من معايير، فإن الأمر يتوقف في النهاية على تقدير القاضي الإداري لكافة وقائع أو أسباب القرار، ما يعني ضمناً مراجعته لتقدير الإدارة لهذه الوقائع أو تلك الأسباب، بل وإحلال تقديره الشخصي محل تقديرها في هذا الصدد، وهو ما يتلاءم مع مسلك القضاء الإداري الرامي إلى ضرورة الحد من سلطة الإدارة التقديرية^(١).

المرحلة الثانية: لقد بدأ القضاء الإداري في هذه المرحلة يعول على كافة الوقائع التي استندت إليها الإدارة في قرارها التأديبي بحيث أصبح الخطأ في واحدة منها من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على صحة تقدير الإدارة لكل الوقائع التي تذرعت بها، وأن هذا الشك يجب أن يفسر - كما هو الحال في المواد الجنائية - لمصلحة المدعى والتي تتمثل في إلغاء القرار المطعون فيه^(٢).

(١)

(٢) ومع ذلك يلاحظ أن القضاء الإداري العربي ميز بشكل واضح في هذا المجال بين قرارات التأديب وبين قرارات الفصل بغير الطريق التأديبي. فإذا كان يجهد نفسه لجعل تقديره للأسباب تقديراً دقيقاً ليتبين بمنتهى الحذر الأسباب الزائدة من الأسباب الدافعة

ومعنى ذلك أن مجرد تخلف أو عدم صحة سبب أو أكثر من الأسباب التي تتذرع بها الإدارة لاتخاذ قرار ما، أصبح يؤدي إلى إلغاء هذا القرار وذلك بصرف النظر عن مدى تبرير أو كفاية الأسباب الصحيحة الأخرى له.

وقد كانت بداية هذا التحول حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضية Canavaggia الصادر بتاريخ ١٤ يناير سنة ١٩٤٨م والذي تقرر بموجبه إلغاء قرار الإدارة بفصل المدمر Canavaggia من وظيفته، وذلك لعدم قيام هذا القرار على كامل سببه، أو لعدم قيامه على كافة الوقائع المدعاة من جانب الإدارة، فقد ثبت للمجلس في تلك الدعوى أن هناك واقعيتين أو سببين من الأسباب الثلاثة التي يستند إليها قرار الفصل غير صحيحة أو غير متحققة.

فمجلس الدولة الفرنسي بدأ إذن يفترض أن كافة الأسباب التي تتذرع بها الإدارة هي كأصل عام أسباب دافعة أو رئيسية مالم يقدّم الدليل على عكس ذلك.

هذا وقد انتهج مجلس الدولة المصري أيضاً هذا التحول، إذ تقول المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها أنه "ولئن كان للإدارة تقدير الجزاء

بالنسبة لقرارات التأديب، إلا أنه لم يبذل هذا الجهد فيما يتعلق بقرارات الفصل بغير الطريق التأديبي، تركاً للإدارة مجالاً واسعاً في حرية اختيار أسباب فصل من تراه غير صالح من موظفيها. وتقول المحكمة الإدارية العليا في ذلك "إن القرار الصادر بفصل الطاعن لم يكن في الواقع من الأمر جزاء تأديبياً وقع عليه، حتى يسوغ القول بوجوب قيامه على كامل سببه، بمعنى أنه إذا كان قائماً على عدة تهم لم يثبت بعضها أو إحداها فيتعين إلغاؤه. وإنما القرار المطعون فيه هو قرار فصل الطاعن بغير الطرق التأديبي، ومثل هذا القرار لا يستلزم لمشروعيته ثبوت كل الوقائع التي يستند إليها. وإنما يقع صحيحاً منتجاً لآثاره ويعتبر قائماً على السبب المبرر له قانوناً حتى ولو أنهار جانب من تلك الوقائع".

الحكم الصادر بتاريخ ١٩٦٤/١٢/٥، س٦، ق٤٥٦، مجموعة السنة العاشرة، س ١٢٣؛ وانظر أيضاً الدكتور/ عصام عبد الوهاب، المرجع السابق، ص ٣٥٢.

التأديبي في حدود النصاب القانوني، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع أخطاره، فإذا تبين أنه قدر على أساس تهمتين أو تهم عدة لم يرق في حق الموظف سوى بعضها دون البعض الآخر، فإن الجزاء والحالة هذه لا يقوم على كامل سببه ويتعين إذن الغاؤه لإعادة التقدير على أساس استبعاد ما لم يرق في حق الموظف وبما يتناسب صدقاً وعدلاً مع ما قام في حقه، حتى ولو كانت جميع الأفعال المنسوبة للموظف مرتبطة بعضها مع البعض الآخر ارتباطاً لا يقبل التجزئة. إذ ليس من شك في أنه تبين أن بعض هذه الأفعال لا تقوم في حق الموظف ؛ وكان ذلك ملحوظاً عند تقدير الجزاء، لكان للإدارة رأي آخر في هذا التقدير، فلا يجوز أن يكون الموظف ضحية خطأ في تطبيق القانون^(١).

وهكذا يمكن القول أن تخلف أو عدم صحة سبب أو أكثر من أسباب القرار التأديبي أصبح يعد كافياً لإلغاء هذا القرار حتى وإن كانت هناك أسباب صحيحة أخرى. ولهذا فقد توقف مجلس الدولة - سواء في فرنسا أو في مصر خلال تلك المرحلة - عن البحث فيما إذا كانت الوقائع التي ثبتت صحتها تبرر أو لا تبرر القرار المطعون عليه وذلك على عكس ما كان عليه الحال في قضائه السابق.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الحالية والتي بدأت منذ عام ١٩٦٨م على أثر صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيدة Perrot^(٢)،

(1) Waline, Sous, C.E., 2 oct. 1954. Rougier, R.D.P., 1955, P. 187.

(٢) الحكم الصادر في ١٩٥٧/١١/٩، س١، ق ٩٠٦، س٣، المجموعة، ص ٦٦.
تخلص وقائع هذه القضية في أن الطاعنة طلبت التصريح لها بمزاولة نشاطها التجاري في أحد الأسواق التجارية بمدينة جرونبل، غير أن جهة الإدارة رفضت إصدار هذا التصريح للطاعنة استناداً إلى ما تتمتع به من سلطة تقديرية في منح هذه التصاريحات أو رفضها، وقد أسست قرارها الصادر بالرفض على سببين: الأول ويتمثل في الاختلاف الواضح في البيانات التي تقدمت بها الطاعنة إلى مصلحة الضرائب وتلك التي تقدمت بها إدارة السوق،

حيث أصبح القاضي الإداري يبحث فيما إذا كانت الإدارة سوف تتخذ في الحالات التي يثبت فيها خطأ سبب أو أكثر من الأسباب التي يستند إليها القرار التأديبي، سوف تتخذ ذات القرار على أساس ما ثبتت صحته من أسباب أخرى^(١).

ومعنى ذلك أن القاضي الإداري أصبح يباشر في خلال تلك المرحلة دوراً إيجابياً أكبر وذلك بقيامه بفحص كافة الوقائع أو الأسباب التي استند إليها القرار التأديبي للوقوف من ناحيه، على الدوافع الحقيقية من وراء إصداره ومن ناحية أخرى على ما إذا كانت تلك الدوافع تكفي للإبقاء عليه أم لا تكفي لذلك، ومن ثم يقضى بالبطلان أو الإلغاء.

أما السبب لثاني فيتمثل في تأخر الطاعة الملحوظ في دفع ما هو مستحق عليها من ضرائب، فلما عرض الأمر على مجلس الدولة استطاعت الطاعة أن تثبت عدم صحة السبب الأول منها وذلك لقيامه على وقائع مادية غير صحيحة.

Des Faits matériellement inexacts.

ومن الجلي أن ثبوت عدم صحة هذا السبب كان كافياً لإلغاء القرار المطعون عليه وذلك وفقاً للاتجاه الذي استقر عليه المجل في المرحلة السابقة. ولهذا اقترح مفوض الحكومة على المجلس إلغاء هذا القرار إعمالاً لقضائه المستقر عليه في هذا الشأن. غير أن المجلس لم يأخذ بما اقترحه عليه مفوض الحكومة ولا بالصيغة التقليدية التي درج على استخدامها في حالة الإلغاء، وإنما ذهب إلى إلغاء القرار وذلك استناداً إلى أنه "لا يتضح من التحقيق أن جهة الإدارة كانت سوف تتخذ في مواجهة الطاعة نفس القرار فيما لو كانت غير مدفوعة بالسبب الآخر غير الصحيح".

"Le Juge administratif recherche désormais si l'administration, qui a pris sa décision en se Fondant Sur un ou plusieurs motifs viciés, "aurait pris la meme décision" Si elle n'avait retenu que le ou les motifs réguliers" stavroula Ktistak, op.c.t.p.80

حول حكم Perrot انظر :

Rec., P.39 A.J.D.A, 1968, P. 179. J.P. COLSON, L'office du Juge et La prevue dans le contentieux administratif, these, Paris, L.G.D.J., 1970, P. 9.

وانظر كذلك رسالة الدكتور/ ثروت عبد العال السابقة، ص ٢٣٣.

(1) Sauvignon (E.), La pluralité des motifs dans l'exercice d'un pouvoir de création devant le juge de l'excès de pouvoir, A.J.D.A., 1971, P. 200 etss.

فالإبقاء على القرار أو إلغائه أصبح يرجع والحال هكذا إلى إرادة القاضي الإداري ذاته، حيث يتساءل في ظل ذلك الاتجاه عما إذا كانت الإدارة سوف تتخذ أولاً تتخذ نفس القرار التأديبي أو ذات العقوبة التأديبية إذا ما نحينا جانب الأسباب الأخرى التي ثبت عدم صحتها، وهو في صدد إجابته على هذا التساؤل إنما يضع نفسه موضع رجل الإدارة وذلك من خلال الفحص أو التحقيق L'instruction الشامل لموضوع الطعن وظروفه والذي يشتمل على أسانيد الأطراف ودفوعهم، والظروف التي أحاطت بإصدار القرار ونصه وكذلك ملف الدعوى... وإجمالاً على كافة الظروف المعطيات التي أحاطت بالحالة المعروضة.

من العرض السابق لمراحل التطور القضائي لرقابة تعدد الأسباب خاصة في المجال التأديبي، يتبين لنا بوضوح أن هذا التطور إنما يترجم رغبة حقيقية لدى مجلس الدولة للحد من التعسف الإداري في هذا المجال. كما أن هذا التطور يجسد أيضاً نوعاً من الرقابة القريبة للغاية من تلك التي كان يأمل، بل ويطالب بها مفوضو الحكومة وكذلك الفقه في مجموعته، وهي رقابة الخطأ البين في مجال الجزاءات التأديبية^(١). تلك الرقابة التي ظهرت في هذه الأثناء أمام محكمة العمل الدولية كما بينا من قبل.

وهكذا نستطيع القول إن مثل هذه الأحداث أو التطورات القضائية كانت بمثابة المعطيات أو المقدمات التمهيديّة لكي يعلن القضاء الإداري بعدها عن اتجاهه الحديث في المجال التأديبي والمتمثل في تبني نظرية

(1) Moderne (E.), L'extension du contrôle Juridictionnel à la corrélation, Faute disciplinaire-mesure disciplinaire dans le droit de la Fonction public, Rev. adm., 1978, P.573, les notes de J.M, Auby, R.D.P, 1979, P 227.

رقابة الخطأ البين في هذا المجال^(١). ذلك أن من سمات هذا القضاء أنه يتحين - كما ذكرنا من قبل - الفرص أو المناسبات لكي يخطو في خصوص رقابته لنزاعات العمل الإداري، خاصة تلك التي تدخل في إطار سلطة الإدارة التقديرية، خطوات تهدف إلى الحد من هذه السلطة وهو ما نبينه في الفقرة التالية.

ثالثاً: الاتجاه الحديث للقضاء الإداري في رقابة منازعات تأديب الموظفين

يبدو هذا الاتجاه الحديث من تبني مجلس الدولة لنظرية رقابة الخطأ البين في المجال التأديبي، حيث أصبح بفضل هذه النظرية يراقب الخطأ البين في تقييم أو تقدير الإدارة للوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتها التأديبية ومدى تناسبها مع ما تتضمنه تلك القرارات من جزاءات.

وقد كانت فاتحة هذا الاتجاه الحكم الصادر في قضية Lebon والتي تخلص وقائعها كما بينا من قبل في أن مدرسا بأكاديمية تولوز عوقب بالفصل من وظيفته على أساس قيامه بتوجيه إشارات وحركات غير لائقة إلى الفتيات اللاتي يقوم بالتدريس لهن. فقد انتهى المجلس إلى اعتبار الفعل المرتكب خطأ وأن من شأنه تبرير عقوبة الفصل الموقعة على الطاعن، ثم أضاف المجلس قائلاً -وهنا يبدو التجديد - " أن هذه العقوبة ليست مشوبة بأي خطأ بين في التقدير"^(٢).

(١) ومن المقدمات التمهيدية أيضاً في هذا المجال صدور قانون العمل الجديد رقم ٦٨٠/٧٣ في ١٩٧٣/٧/٣١ والذي ينص على أنه لتوقيع عقوبة العزل يجب أن يكون السبب الداعي جدي وخطر بحيث يبرر عقوبة العزل. دكتور/ محمد فريد سليمان، الرقابة القضائية على التناسب - القرار الإداري، مرجع سبق ذكره، ص ٢٢٤.

(2) C.E., 9 Juin 1978, Lebon, Rec., P. 245.

En Prononçant... La Sanction de La mise à la
reraitd'office du sieur lebon,le recteur s' est livré à une
appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste"

بصدور هذا الحكم والذي وجد ترحيباً وتقديراً من جانب الفقه
الإداري، لم تعد الإدارة حرة لا في تقدير مدى أهمية وخطورة الوقائع التي
تدعيها لقراراتها التأديبية، ولا في اختيار العقوبة الملائمة أو المناسبة لتلك
الوقائع، وإنما أصبحت خاضعة في مثل هذا التقدير لرقابة صارمة من
جانب القضاء. الأمر الذي يحقق العدالة والإنصاف في إطار الوظيفة
العامة؛ إذ ليس من العدل في شئ كما يقول جانب من رجال الفقه^(١)، وأن
تترك السلطة الإدارية المختصة لتضرب بحرية تامة على بيانو الجزاءات -
Clavier des sanctions وتختار من بينها ما تراه محققاً للنجمة التي
ترغب في سماعها؛ فهذا من شأنه الإخلال أو الانتقاص الخطير من
ضمانات وحقوق الموظفين المشروعة.

من هنا تبدو أهمية التطور أو التجديد القضائي المتمثل في إعمال
رقابة الخطأ البين في المجال التأديبي؛ حيث أصبح على الإدارة بموجب هذا
التطور أو التجديد، أن تستخدم سلطاتها التأديبية استخداماً معقولاً Un
usage raisonnable أو كما يقول الأستاذ (R.) Chapus أنه أصبح
مفروض عليها ألا يكون اختيارها للجزاء التأديبي معيياً بخطأ بين في
التقييم^(٢).

(1) Modern (F.), op. cit., P. 636.

(2) Droit administratif général, T.2éd, 1988,p. 240. voir aussi, Lorhe
(J.C.) observations sous L'arrêt du C.E., M.Felix, 27 sept. 1991,
AJ.D.A. 1992 P.529.

"L'autorité disciplinaire ne doit pas entacher le choix de la sanction d'erreur manifeste d'appréciation"

هذا ويلاحظ أن القضاء الإداري لا يتطلب عند إعماله لتلك الرقابة ضرورة أن يكون هناك تناسب صارم أو دقيق بين الخطأ المرتكب والعقوبة التأديبية الموقعة، وإنما يتطلب فقط ألا يكون التفاوت بين هذا وتلك صارخاً أو معبراً عن عدم تناسب بين Une disproportion manifeste فإن كان التفاوت كذلك أي صارخاً قضى بإلغاء القرار الصادر بالعقوبة التأديبية وهو ما حدث في قضية Vinolay ، حيث لا حظ أن التفاوت بين الأخطاء المسندة للموظف وهي القسوة والصرامة في معاملته لمؤوسيه، وبين عقوبة العزل من الخدمة ، بعد تفاوتاً صارخاً أو بيناً، إذ يقول المجلس في هذه القضية^(١):

"Si les manquements aux règles d'une bonne administration qui lui sont imputés étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle de peines".

بل لقد وجد لها القضاء تطبيقات في مجال الوظيفة العامة المحلية la fonction publique comunale، حيث قضى مجلس الدولة بمناسبة توقيع عقوبة العمل على سكرتير عملية إحدى القرى الصغيرة، بأن الأخطاء

(1) C.E, 27 Juil., 1978, sieur, vinolay, Rec., p.315, A.J.D.A.,1978, P.576.

المنسوبة لهذا السكرتير لا ترد على الإطلاق توقيع عقوبة الفصل والتي تعد من أشد العقوبات التأديبية^(١).

أما إذا كان التفاوت أو عدم المناسب مقبولا ولا يشكل خروجاً على المؤلف، فإن مجلس الدولة يقضي بانتفاء أي خطأ بين في التقييم. ففي حكمه الصادر بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٩١ يقول: إن قرار وزير الداخلية بفصل الشرطي M. Felix من الخدمة نتيجة سرقة جاكيت من إحدى المحلات التجارية غير مشوب بأي خطاب بين في التقييم^(٢).

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن رقابة الخطأ البين في المجال التأديبي لا تقتصر على الحالات التي تكون فيها الجزاءات متسمة بالغلظة أو الفظاظة، وإنما تباشر أيضاً في حالة ما إذا كان هناك تساهل وتسامح ملحوظ في العقاب من جانب الإدارة تجاه أخطاء أو وقائع لا تتلاءم البتة وهذا التساهل أو التسامح، فقد ألغي مجلس الدولة مثلاً في أحد أحكامه الجزاء التأديبي الموقع على سائق حافلات بإحدى القرى نظراً لعدم تناسب هذا الجزاء مع خطورة الذنب المقترف، إذ تبين له من التحقيق أن هذا السائق كان يقود إحدى سيارات البلدية تحت تأثير المشروبات الكحولية Qu'il était en état d'ébriété caractérisé par un taux

-
- (1) "Les Fautes alléguées par l'autorité disciplinaire, eu égard aux circonstances atténuantes de l'espèce, ne justifiaient pas une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions" C.E., Dame B. Nauron, 7 nov. 1979, Rec. P.471, note Auby (T.M.) R.D.P., 1980, P.1456; C.E., 22 oct. 1982, Goubard, R.D.P., 1983 P.1116; 22 nov. 1985, Doucet, Rec. P.331, R.F.D.A., 1987, P.88 note, Roux.
- (2) "Con si dérant qu'il résulte de l'instruction qu'en prononçant à l'encontre de M. Felix la sanction de la révocation, Le ministre de l'intérieur.. n'a pas entaché Sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation...." A.D.A., 1992 p.529 précité.

d'alcoolémic وهو سلوك يشكل في حقيقته - كما يقول المجلس - خطأ تأديبيا على درجة كبيرة من الخطورة مما يتنافى وما اتسم به قرار السلطة التأديبية من تساهل أو تسامح مفرط^(١) Indulgence exvessive.

الفرع الثاني

إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب ورقابة الخطة البين

أولاً: الاتجاه التقليدي للقضاء الإداري في رقابة إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب:

تعد إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب من أهم المجالات التي كان مجلس الدولة الفرنسي يعترف للإدارة في خصوصها بسلطة تقديرية واسعة، حتى أن تقييم أو تقدير الإدارة لتلك الإجراءات لم يكن يخضع طوال القرن الماضي لأية رقابة قضائية، حيث كانت تدخل في إطار نظرية الأعمال التقديرية كما بينا من قبل.

ولكن مع زوال هذه النظرية الأخيرة، بدأت رقابة القضاء الإداري تمتد الى هذه الإجراءات وإن كانت قد تجسدت في بداية الأمر فيما يسمى بالرقابة الدنيا *contrôle minimum* والتي تتمثل في فحص مدى صحة وجود الوقائع التي يستند إليها الإجراء الضبطي الخاص بالأجانب مادياً، كما تتمثل أيضاً في رقابة مدى شرعية التبريرات التي تدعيها الإدارة لاتخاذ مثل هذا الإجراء الضبطي، للتحقق مما إذا كانت تندرج في إطار التبريرات التي نص عليها القانون لهذا الغرض من علمه، ولهذا فقد تطلب مجلس الدولة لطرده أو استبعاد أجنبي عن الأراضي الفرنسية مثلاً أن يكون هذا الإجراء

(1) O. Schrameck, L'erreur manifeste du conseil Superieur de la Fonction publique territorial, A.J.D.A., 1987, P. 628.

مستنداً إلى اعتبارات مستمدة من النظام أو الأمن العام الميلاد؛ كما تطلب لمنع نشر أو عرض مطبوعات أجنبية في فرنسا أن يكون هذا المنع الأسباب قانونية مثل المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة أو من أجل الدفاع عن البلاد.

فالرقابة الدنيا على هذا التحرر أو الرقابة المزدوجة للأسس المادية والقانونية لقرارات الضبط الخاصة بالأجانب كانت تشكل إذن أول مرحلة من مراحل تقييد سلطة الإدارة التقديرية في هذا المجال، بحيث لم يعد للإدارة - والحال هكذا - من حرية في التقدير إلا فيما وراء ذلك . مما يعني أن هذه الحرية أصبحت تباشر فقط للتحقق مما إذا كانت الوقائع التي يستند إليها الإجراء الضبطي من طبيعة أو ذات مدى وخطورة تبرر اتخاذها، فحرية وزير الداخلية مثلاً لمنع نشر أو توزيع مطبوعات أجنبية في الإقليم الفرنسي، أصبحت مقتصرة فقط مع تقدير أو تقييم مضمون محتوى هذه المطبوعات للوقوف على مدى إخلالها أو انتهاكها للنظام أو الأخلاق العامة في المجتمع الفرنسي^(١).

ومع ذلك يلاحظ أن مجلس الدولة كان يتطلب من سلطات الضبط الإداري عند مباشرتها لإجراءات الضبط الخاصة بالأجانب كافة ما يتطلبه من رجل الإدارة بصفة عامة حينما يباشر سلطانه التقديرية في مختلف المجالات الإدارية الأخرى؛ فقد تطلب منها مثلاً ألا يكون التقدير للوقائع

(1) "Seuls des motifs tirés de la protection de l'ordre public, de La moralité et de la défense du pays... pouvaient servir de Fondement à interdiction de publication étrangère"
C.E., 10 Janv. 1964, société olympia press, Rec. P. 959, R.D.P, 1964 P. 854.

في ذاته تقديراً سورياً أو وهمياً، بل يجب أن يكون تقديراً حقيقياً. أي نتيجة فحص أو بحث جدى لكافة الظروف المحيطة بالدعوى^(١).

ولهذا فقد قضى في عام ١٩٦٢ بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع مطبوعات أو مؤلفات ذات مصدر أجنبي من الدخول إلى الأراضي الفرنسية على أساس أن قرار المنع هذا قد أشار بشكل عام إلى كافة المطبوعات التي تصدر عن بعض المكتبات أو دور النشر، في حين أنه كان من الواجب على الإدارة قبل أن تتخذ مثل هذا القرار - كما يقول مجلس الدولة - أن تقوم بفحص جدى وخاص لكل حالة على حدة^(٢)، واستناداً إلى هذا السبب أيضاً فقد أصدرت المحكمة الإدارية بليون عام ١٩٦٩ حكماً بإلغاء قرار مستعجل بطرد أحد الأشخاص لانتمائه إلى الجنسية الجزائرية، إذ تقول المحكمة في هذا الحكم: "إن القرار المطعون فيه وقد اتخذ على وجه الاستعجال لم يؤسس على فحص أو بحث دقيق ومتأن لظروف هذا الشخص"^(٣).

إلى جانب القيود السابقة والتي أتى بها مجلس الدولة للحد من سلطة الإدارة التقديرية في مجال إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب فإنه يجب أن نضيف إليها كذلك كل من قيدي الاختصاص والشكل، حيث كان القاضي الإداري يبحث عند نظر كافة منازعات تلك الإجراءات، فيما إذا كانت قواعد الاختصاص والشكل قد روعيت من جانب الإدارة في خصوصها من عدمه.

-
- (1) Megret, del'obligation pour l'administration de procéder a un examen particulier des circonstances de l'affaire, E.D.C.E, 1953, p.77, 1992, la procédure administrative non contentieuse, paris, P.493.
(2) CE(sect),16 nov. 1962, Dolbeau, Rec, p. 614; R.D.P., 1963, p.355.
(3) Trib. adm, lyon, 11 avr, 1969, Rec., P. 630, A.J.D.A., 1969, P 317, note chabanol.

ففيما يتعلق مثلاً بالأجانب الحائزين على كارت الإقامة *carte de séjour* حيث لم يكن من الممكن طردهم من البلاد إلا بعد سماع أقوالهم أمام لجنة خاصة وذلك باستثناء حالة الاستعجال، فإن مجلس الدولة قد باشر رقابة قصوى على مدى احترام الإدارة للقواعد الإجرائية المقررة في هذا الصدد، بل ومنذ عام ١٩٥٥ أصبح يباشر رقابته للوقوف على ما إذا كانت حالة الاستعجال المبررة لتجاهل وزير الداخلية لمثل هذه القواعد الإجرائية، قد تحققت في الواقع العملي من عدمه^(١).

إن القيود التي أوردها مجلس الدولة على سلطة الإدارة التقديرية في المجال الذي نحن بصددده وإن كانت تشكل في الواقع تطوراً هاماً في هذا المجال، إلا أنها لم تمس مع ذلك جوهر تلك السلطة والمتمثل فيما تسبغه الإدارة من مدى قانوني على وقائع الإجراء الضبطي، ذلك أن القاضي الإداري كان يرفض دائماً أن يباشر رقابته على مدى التناسب أو التلاؤم بين طبيعة وخطورة الوقائع المدعاة من جانب الإدارة ومقتضيات أو متطلبات القانون، إذ كان يكتفى بالتحقق من أن الإجراء محل الطعن قد اتخذ: من قبل سلطة مختصة (وهو أقل ما يجب أن ينتظر منه) وطبقاً للإجراءات أو الأشكال المحددة قانوناً (وهي محدودة في المجال الذي نبحث فيه كما أنها لا تتسم في الغالب بالإلزام أو الإيجاب بالنسبة للإدارة)، وانطلاقاً من وقائع صحيحة (وهوما يشكل الحد الأدنى في الرقابة) وعلى أساس من سند قانوني صحيح (وإن كان الادعاء بالإخلال بالنظام العام ليس أمراً صعباً) ودون أن يكون قد اتخذ شكل إجراء منهجي أو نمطي (حتى يبدو على الأقل من حيث الظاهر أنه احترام قاعدة الفحص الجدي والخاص لظروف الدعوى).

(1) C.E, Assemblée, 18mars 1955, Hamou Ben Brahim, Rec. P. 168; C.E. 16 Janv. 1970, Mihoubi Mohand tayebe, Rec., P.25; Pacteau (B.), note à propos de l'interdiction d'une publication étrangère, Gaz. Palais, 1974, 1, 100.

وفيما عدا ذلك فإن الإدارة كانت تستطيع بحرية واستقلالية تامة أن تسبغ على سلوكيات أو مواقف الأجانب، أو على مضمون ومحتوى المطبوعات الأجنبية الوصف الذي تراه مبرراً لإجراء الطرد أو المنع، وذلك تحت غطاء أو مظلة النظام أو الأمن أو الأخلاق العامة؛ فقد كان يكفي وزير الداخلية لكي يتخذ إجراء من إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب دون خطر التعرض للإلغاء من جانب القضاء، مجرد الاحتجاج بوقائع مادية صحيحة ومبادئ قانونية سليمة وليس مهما بعد ذلك ما قد يسيغه على تلك الوقائع من مبالغة أو تجارز في تقديره لمدى أهميتها أو خطورتها، مقارنة بالخلل أو التهديد الحقيقي الذي تحدثه أو تسببه بالنظام العام.

ومما يؤكد ذلك قلة عدد الأحكام الصادرة بالإلغاء في مجال إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب، بل وقلة الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة ضد هذه الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالإبعاد أو الطرد من فرنسا. فمن بين حوالي (١٣٠٠٠) أجنبي صدر ضدهم قرارات بالإبعاد خلال الفترة من ١٩٦٨ وحتى عام ١٩٧٣، لم يتقدم بالطعن ضد هذه القرارات سوى عدد محدود للغاية. وقد يرجع ذلك إضافة إلى ما سبق إلى أن المبعدين ذاتهم غالباً لا تكون لديهم من الناحية العملية الرغبة أو الاستعداد لتقديم مثل تلك الطعون، خاصة وهم يعلمون جيداً أنه يجب عليهم مغادرة البلاد بمجرد تقديمهم إياها، ومن ناحية أخرى إلى إحساسهم بأن القضاء الإداري الفرنسي غالباً ما يتركهم أمام التقديرات التي تجريها الإدارة للوقائع المدعاة ضدهم مجردين من كل سلاح فعال لدحض مثل تلك التقديرات^(١).

(1) "La pauvreté dece contentieux tient sans doute à ce que l'expulsé n'est plus guère en mesure matériellement d'exercer un recours une fois qu'il a dû quitter la France, mais probablement aussi au découragement des requérants devant une jurisprudence qui les laisse désarmés devant l'appréciation que le ministre a pu faire de leur comportement" pacteau (B.) art. Précité, P. 20.

ولهذا فقد ثار التساؤل حول سبب هذا الاتجاه القضائي لمجلس الدولة الفرنسي، ذلك المجلس الذي يدرك تماماً مدى أهمية وخطورة منازعات الضبط الخاصة بالأجانب لتعلقها في الأغلب الأعم بحقوق وحرّيات فردية أو شخصية، هو حريص منذ نشأته على حمايتها والدفاع عنها، خاصة أنه لا يمكن أن يكون السبب هو مجرد الصعوبات التي قد تواجه القافي الإداري في رقابته للتقدير الذي تجريه الإدارة للوقائع التي تستند إليها فيما تتخذه في هذا الشأن من إجراءات ؛ إذ ليس من الصعب مثلاً أن يجرى مجلس الدولة تقييماً لمضمون أو لمحتوى إحدى المؤلفات أو المطبوعات الأجنبية ليقرر بعد ذلك ما إذا كانت مخلة بالنظام أو الآداب العامة من عدمه، تماماً كما فعل حينما قبل رقابة أحد الأفلام السينمائية للوقوف على مدى تأثيرها السلبي على النظام أو الآداب العامة في إحدى القرى، فالحجة المستمدة إذن من الطابع الفني أو التقني للوقائع، والتي يقال بها عادة لتبرير سلطة الإدارة التقديرية في بعض المجالات الإدارية ، لا تصلح هنا لأن تكون سبباً مقنعاً للاتحاد القضائي السابق الإشارة إليه^(١).

لقد أجاب مفوضوا الحكومة على التساؤل السابق قاتلي إن السبيل الحقيقي للاتجاه القضائي المشار إليه يكمن أساساً في أن القاضي الإداري كان يعتقد أو كان يبدو له أنه يحقق بهذا المسلك رغبة المشرع وإرادته في عدم منح الأجانب من الضمانات الهامة والفعالة كالتى يمنحها للمواطنين من أهل البلاد؛ هذه الرغبة أو تلك الإرادة التي تتضح من الاختصاصات المفروطة أو المبالغ فيها التي قررها المشرع لسلطات الضبط الإداري تجاه الأجانب إبان فترة الحرب الجزائرية^(٢). كما قد يكمن أيضاً في

(1) op. cit., P. 20.

(2) Conclusions Galmot sous C. E (sect) 5 fev. 1965, Association comité d'entente pour L Algérie Française, Rec. P. 73, conclusions Rigaud sous C.E. (sect) 6 dec. 1968, Bachex, R.D.P., 1969, P. 709.

أن مجلس الدولة كان يعتبر دائماً أن إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب لها تأثيرها في علاقات الحكومة الفرنسية بحكومات الدول الأخرى الأمر الذي رأى معه أنه من الأفضل أن يترك للإدارة في خصوصها سلطة تقديرية واسعة^(١).

إضافة إلى ما سبق فقد قيل إن القاضي الإداري كانت لديه دائماً حساسية معينة تجاه الجوانب السياسية المحتملة لإجراءات الضبط الخاصة بالأجانب، ولهذا فإنه وإن لم يعد ينظر إليها كما كان يفعل خلال القرن التاسع عشر على أنها إجراءات علي Haute pelice لا يجوز المساس بها، فإنه أصبح على الأقل يعتبرها من المجالات التي يجب أن تمارس طبقاً لاعتبارات الملاءمة التي يجب أن يترك للإدارة في خصوصها قدر من الحرية، خاصة فيما يتعلق بتقييم الظروف المحيطة بالإجراء الضبطي وكذلك متطلبات الوقت والمكان^(٢).

ثانياً

الاتجاه الحديث للقضاء الإداري في رقابة إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب

في الواقع من الأمر لم تكن الحجج السابقة والتي قبل بها لتبرير امتناع القاضي الإداري عن رقابة إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب، أكثر من مجرد حجج أو تفسيرات تاريخية . ولهذا لا يجب أن يعول عليها أو أن ينظر إليها على أنها تجسد أسساً موضوعية للاتجاه القضائي الذي نحن

(1) Conclusion Heuman Sous, C.E., (sect), 22 avr. 1955, Association Franco-russe dite Rousky-Dome, Rev. adm., 1955, P. 404.

(2) Conclusions Baudouin, sous.C.E (sect) 6 nou. 1970, Guyé, R.D.P., 1971, P.517; conclusions Braibant, sous C.E (sect) 13 nov 1970, Lambert, inédit. Extr. In chronique de jurisprudence.

بصدده. فالسلطة التقديرية في مجال إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب قد تكون من الناحية العملية مبررة إلا أنها لا تشكل بحال من الأحوال جزءاً من طبيعة هذا الاتجاه القضائي، فهي ليست في حقيقتها ملازمة له أو مرتبطة به لدرجة يصعب أو يستحيل معها الفصل بينهما.

ولهذا لم يتردد القاضي الإداري - أمام المستجدات والمتغيرات المعاصرة من أن يعدل أو يغير من اتجاهه السابق، خاصة أنه كان اتجاهاً منتقداً ليس فقط من جانب رجال الفقه السياسي والدستوري وإنما أيضاً من جانب مفوضي الحكومة ذاتهم. فقد كان في الواقع مسلماً مخيباً للآمال حيث كان يتجاهل - كما بينا - ما يجب أن يكون لطائفة اجتماعية معينة تعيش في المجتمع الفرنسي من ضمانات وحقوق، خاصة في دولة تعرف بين دول العالم أنها دولة القانون أو دولة الحريات^(١).

من هنا وفي إطار حرصه على تحقيق التوازن بين دواعي المصلحة العليا *Raison d'état* من ناحية وبين توفير رقابة فعالة للأجانب في فرنسا من ناحية أخرى فقد عمل مجلس الدولة في وقت حديث نسبياً على إدخال فكرة الخطأ البين في رقابته لإجراءات الضبط الخاصة بهؤلاء الأجانب.

وقد كانت فاتحة هذا التطور الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بباريس عام ١٩٧١ والتي ألغت بموجبه قراراً بمنع أحد الأجانب من دخول الأراضي الفرنسية على أساس أن تقدير الإدارة للوقائع في هذه الحالة كان مشوباً بخطأ بين^(٢).

(1) Notes Pacteau (B.) sous, C.E, 4 fev. 1981, Konté, Recueil Dalloz sirey, 1981, p. 353 etss. Louis Dubouis, Le juge administrative français et les mesures de polices prises à l'encontre des étrangers a propos de trois décisions recentes. Rev. crit. dr. intr. pri., 1976 p. 303.

(2) T.A., Paris, gtuin 1971, Schaerman, Rec., P. 862

وفي عام ١٩٧٣ صدر حكم يعد في الواقع نقطة التحول الحقيقي في اتجاه مجلس الدولة حول تبني نظرية رقابة الخطأ البين في مجال منازعات الأجانب، وهو الحكم الخاص بقضية مكتبة François Maspero ضد وزير الداخلية^(١)، وتخلص وقائع هذه القضية في أن "مكتبة فرانسوا ماسبيرو" تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة تطلب فيه إلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ ٢٧ يناير سنة ١٩٦٩ والقاضي بمنع نشر وتوزيع وبيع مجلة القارات الثلاث^(٢) "Tricontinental" التي تصدرها هذه المكتبة مستندة في ذلك الى أن تقدير الوزير لخطورة المجلة المذكورة على النظام العام ليس تقديرا صحيحا. وقد كان على مجلس الدولة طبقا لقضائه المستقر في هذا الصدد أن يقضى برفض مثل هذا الطعن وأن يردد عبارته المألوفة في مثل هذه الحالة والتي قالت بها المحكمة الإدارية بباريس في ذات القضية التي نحن بصددھا، العبارة هي: "أن تقدير مدى خطورة إحدى المطبوعات على النظام أو الأخلاق العامة، وكذلك مدى ملاءمة الإجراءات المتخذ في هذه الحالة ليس من شأنه أن يناقش أمام القضاء الإداري".

"L'appréciation du danger que pouvait presenter pour l'ordre public (ou eventuellement pour la moraine publique) la publication (en cause), ni l'opportunité de prendre la mesure

(1) Concl. Braibant, J.C. P., 1974. II. 17642, Gerard (F.), l'expulsion des étrangers et la juge adm. en droit Français, A.J.D.A., 1978, P. 261; Alain (P.), D. 1974, P.432.

(٢) تصدر هذه المجلة بلغات عديدة، وقد أنشئت على أثر انعقاد مؤتمر هافانا عام ١٩٦٦ والذي نظمته منظمة تضامن شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والنشرة الفرنسية لهذه المجلة تحمل نفس العنوان الذي تحمله في كوبا وهو: الناطق النظري للسكرتيرية التنفيذية لمنظمة التضامن لشعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

"L'organe Théorique du secrétariat executif de l'organisation de solidarite des peuples d' Afrique, d' Asie et d' Amérique latine".

incriminée, ne sont susceptibles d'être discurtées devant la juridiction administrative"

إلا أن مجلس الدولة قد خرج على هذا القضاء المستقر وتناول بالبحث والدراسة تقدير الوزير لمدى خطورة مجلة القارات الثلاث السابقة على النظام العام، وانتهى إلى القول بأن "هذا التقدير ليس مشوباً بخطأ بين"^(١).

حقيقة أن هذا الحكم قد انتهى إلى رفض الطعن بإلغاء قرار وزير الداخلية المشار إليه، إلا أن أهميته تكمن (وهذا هو ما يهمنا) في درجة الرقابة التي أقرها للقاضي الإداري تجاه القرارات الفردية الصادرة في مجال منازعات حرية الصحافة الأجنبية أو ذات المصدر الأجنبي، تلك الدرجة التي أحاطت هذه الحرية بضمانات فعالة ضد تعسف أو تسلط الأجهزة الإدارية المختصة، مما يعني في ذات الوقت تراجعاً وتقييداً لسلطة الإدارة التقديرية في مجال إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب . إذ بصدور حكم Maspero، لم يعد وزير الداخلية يتمتع - كما كان في السابق - بحرية واستقلالية تامة في تقدير أضرار أو خطورة إحدى المجالات الأجنبية على النظام العام، أو في تقديره الإجراء الواجب اتخاذه في هذه الحالة سواء بمنعها من الصدور أو النشر أو التوزيع أو غير ذلك، حيث أصبح مقيداً

(١) يقول مجلس الدول في هذا الحكم:

"Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 29 janv. 1969, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de cette revue, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, que, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste, l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'intérieur du danger que la revue présentait pour l'ordre public ne peut pas être discutée devant la juridiction administrative".

بأن يكون هذا التقدير أو ذاك غير مشوب بخطأ بين، وإلا كان قراره باطلاً ومن ثم جديراً بالإلغاء.

وهذا هو ما انتهى إليه مجلس الدولة بالفعل في حكم لا حق له صدر بتاريخ ١٧ أبريل ١٩٨٥ في قضية مشابهة لقضية Maspero ، فقد أصدر وزير الداخلية قراراً بمنع دخول وتوزيع مجلة Signal لمساهمتها في نشر المذهب الاشتراكي والأفكار النازية. وبعد أن ألغى هذا القرار من قبل محكمة باريس الإدارية، تأيد هذا الإلغاء أمام مجلس الدولة على أساس أن "قرار وزير الداخلية السابق مشوباً بخطأ بين في تقادي مخاطر نشر المجلة المذكورة على النظام العام"^(١).

إضافة إلى المنازعات المتعلقة بالمطبوعات والصحف فقد طبقت أيضاً رقابة الخطأ البين في خصوص منازعات طرد الأجانب Expulsion de étrangers، إذ أصبح القاضي الإداري يقضى في خصوص هذه المنازعات الأخيرة ببطلان ومن ثم إلغاء قرارات الطرد إذا كانت مشوبة بخطأ بين، ففي إحدى الدعاوى والتي تدور وقائعها حول قرار صادر من وزير الداخلية بطرد أحد الأجانب، قضى مجلس الدولة ببطلان هذا القرار لاستناده إلى وقائع مشوبة بخطأ بين في التقدير، فقد تلاحظ للمجلس أن الطاعن المعنى بقرار وزير الداخلية قد تحسنت سلوكياته منذ سنوات عديدة ، كما أنه توقف أو تخطى بصفة خاصة عن مباشرة كافة العادات الذميمة، والتي كانت في السابق محل نظر من جانب رجال البوليس، مما يعني أن بقاءه في فرنسا لم يعد يشكل خطراً على النظام العام". "ومن ثم فإن وزير الداخلية

(1) C.E, 17 Avr 1985, Ministre de l'interieur, R.D.P., 1985, concl C.G Bernard strin, p. 1362, A.J.D.A., 1985, P.508.

برفضه سحب قرار الطرد -يقول مجلس الدولة - يكون قد استند في ذلك الى خطأ بين في تقييم ظروف ووقائع الدعوى^(١).

Le Ministre de l'interieur à Fait une appréciation manifestement erronée de circonstances de l'espèce.

وقد تأكد الاتجاه السابق بقضاء مجلس الدولة في حكمه الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٧٦ والذي أيد فيه حكم المحكمة الإدارية لـ Strasbaurgs برفض طلب المدعى إلغاء القرار الصادر بإبعاده ومنع دخوله الإقليم الفرنسي وذلك لعدم وجود خطأ بين في تقدير وزير الداخلية لظروف المدعى^(٢). وفي الاتجاه نفسه أيضا ألغت المحكمة الإدارية لمدينة Grenoble بتاريخ ٢٥ يناير سنة ١٩٧٨ قراراً بإبعاد المدعو Beng haline Ben Abd Eslarn على أساس أن تقدير وزير الداخلية لخطورة استمرار إقامة هذا المدعو على الإقليم الفرنسي قد استند إلى خطأ بين في تقدير الوقائع التي قام عليها قرار الإبعاد^(٣).

بل لقد وضع مجلس الدولة من خلال أعماله لنظرية رقابة الخطأ البين في مجال المنازعات التي تنثيرها قرارات إبعاد الأجانب، مبادئ على جانب كبير من الأهمية حيث قرر في إحدى الدعاوى المتعلقة بواحد من تلك القرارات أن الجرائم الجنائية التي يرتكبها شخص أجنبي لا يمكن بمفردها أن تبرر إجراء الطرد، إذ يجب على السلطات المختصة البحث في

(1) C.E, 3 Fev. 1975, Pardov, A.J.D.A, 1975 P. 131, chr. Franc et Boyon.

وفي نفس المعنى أنظر:

C. E, 6 mai 1988, Abdul, Rec., P. 182; C.E. 27 sep. 1989, M. Tache, R.D.P, 1000 No 8955S, P, 893.

(2) Rec., P. 429, C.E, 7 nov, 1990, M. Harrou, A,J. D. A, 1991, P.49.

(3) Rec., P. 867.

مجموع الظروف والمعطيات التي تحيط بهذا الشخص للوقوف على ما إذا كان في بقاءه على الإقليم الفرنسي تهديد للنظام أو الأمن العام من عدمه وإلا كان قرار الطرد مشوباً بخطأ بين في التقدير^(١).

كما قرر في دعوى أخرى أن السلوك السياسي بمفرده لا يصلح كسبب مبرر لإبعاد الأجنبي أو طرده من البلاد ، إذ يجب على السلطات المختصة - كما ذكر في الحكم السابق - البحث في مجموع الظروف والمعطيات التي تحيط بهذا الأجنبي للوقوف على ما إذا كان بقاءه على الإقليم الفرنسي تهديد للنظام أو الأمن العام من عدمه ، وإلا كان قرار الإبعاد مشوباً بخطأ بين في التقدير^(٢).

وفي مجال إجراءات تسليم المجرمين mesures d'extradition ، فإن القضاء الإداري بعد أن كان يرفض وحتى عام ١٩٣٧ قبول أي طعن

(١) تخلص وقائع هذه الدعوى في أن المدعى وهو تونسي الجنسية صدر ضده حكم جنائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة السرقة والنصب. لذلك فقد أصدر وزير الداخلية قراراً بطرده من البلاد، فطعن التونسي في هذا القرار أمام محكمة ليون الإدارية التي قضت بإلغائه لاستناده إلى تقدير مشوب بخطأ بين. فطعن الوزير في هذا الحكم أمام مجلس الدولة الذي رأى أن الوزير لم يتجاهل في بحثه لوقائع القرار كافة الظروف المحيطة بالمدعى وأنه لم يرتكب خطأ بيناً في التقدير، ومن ثم فقد ألغى حكم محكمة ليون. وتبدو فائدة هذا الحكم كما ذهب البعض - بحق - أنه يؤكد من ناحية على أن مجرد اقرار جريمة جنائية لا يجب أن يكون مبرراً حتمياً للطرد، كما يؤكد من ناحية أخرى أن على الإدارة التزام ببحث كافة الظروف والمعطيات المحيطة بالدعوى. فالجريمة الجنائية وإن كانت تترك أثراً ملموساً في عالم الواقع لما تشكله من تهديد للنظام العام وتكون السبب الغالب لقرارات الطرد، إلا أن ذلك لا يوجب التلازم بينها وبين قرار الطرد بشكل تلقائي، وإنما يتعين لشرعية هذا القرار أن يقوم على سبب مستقل يكون وليد بحث الظروف الخاصة بالحالة ثم يأتي دور الجريمة لتدعم تساند هذا السبب لتبرير عملية الطرد.

Pacteau (B.) J.C.P., 1981 , N. 1912 observation sur C.E., 20Juil.1980
Touami Ben Abdeslam, A.J.D.A., 1977, chr. Michel Naurvelaers et
laurent Fabuis, mans, p.133.

وانظر كذلك رسالة الدكتور/ محمود سلامة جبر، السابق الإشارة إليه، ص ٣٩١ وما بعدها.

(2) C.E., 13 mai 1977, Sieur Perrepeaux, P. 187.

ضد المراسيم المتعلقة بهذه الإجراءات حيث كان يكتفى آنذاك بفحص الشرعية الخارجية لها^(١)، فإن قضاءه تغير منذ تاريخ حديث نسبيا (١٩٧٧)، إذ أصبح يراقب التكييف القانوني للوقائع التي يستند إليها إجراء تسليم المجرمين وما يكون قد انطوى عليه هذا التكييف من خطأ بين^(٢).

(1) C.E., 28 mai 1937, Decerf, Rec., P. 534.

(2) C. E, 24 Jain 1977, Astudillo Calleja, Rec, p. 290, D. 1977, P, 659 concl. Genevois, R.D.P., 1978, p. 263, note, Robert (J).

هذا ويلاحظ أن رقابة التكييف القانوني للوقائع على هذا النحو والتي تتم بالنظر إلى قانون الدولة طالبة التسليم لا تثير في الواقع أية صعوبات أو مشاكل رئيسية ذلك أن القاضي الإداري لا يباشر في هذه الحالة وعلى أساس مبدأ ثنائية أو ازدواجية التجريم، سوى مراجعة أو تدقيق للشروط ذات السمة الموضوعية، إضافة إلى أنه حتى وإن امتنع عن تقييم ومراجعة حقيقة الإدعاءات أو الجرائم المواجه بها الشخص المطلوب، فإن إمكانية رقابته للتأكد من أنه ليس هناك أي خطأ بين قد ارتكب في هذا الشأن لا تثير بدورها أية مشاكل أو صعوبات. إن المشاكل أو الصعوبات تبدأ في الواقع في الظهور إذا كانت المخالفة المطلوبة تسليم الشخص من أجلها ذات طابع سياسي حيث يباشر القاضي الإداري في هذه الحالة تقدير شخصياً ذاتياً للوقوف على حقيقة هذا الطابع السياسي للمخالفة والصعوبة تكمن في الواقع في أنه بتقييمه للوقائع المعيبة والمسندة إلى شخص أجنبي بالقياس إلى ما يقرره القانون الجنائي الفرنسي في هذا الشأن، أخذاً في الاعتبار مدى خطورة تلك الوقائع إنما يبحث فيما إذا كانت هذه الظروف مجتمعة تكفي لأن ينظر إلى الوقائع المعيبة على أنها تشكل مخالفة ذات طابع سياسي من عدمه، حقيقة أن القاضي الإداري لم يظهر في مثل هذه الحالة التزامه بمبدأ الفحص الدقيق أو الشخصي للمبررات والأدلة المقدمة ضد الأشخاص المطلوبين للتسليم، إلا أنه يعمل دائماً من ناحية أخرى على تأكيد السمة الحمائية لرقابته في هذا الخصوص حيث أصبح يباشر رقابة تكاد أن تقارب في حقيقتها الرقابة القصوى للتقييم الفعلي للوقائع وهي ما يقال لها بقارة النسبية كما بينا من قبل.

Le contrôle de proportionnalité, C.E., 7 Juin 1985, Raemaers, Rec., P. 177; C.E., 29 sept. 1989, M. Saia, A.J.D.A., 1989, P. 773. Chr. E. Hoorat et E. Baptiste; C.E., 27 Juin 1979 salati, Rec., P. 333, Gaz. Pal., 1979, 1 le sem., P. 686, note lafferrière H. L ABAYLE, Le Jue administratif et le contrôle contentieux de l'extradition, R.F.D.A., 1985, P. 183, C.E., 10 mars. 1989, M. Aldazabal Goizuetz, R.D.P., 1990, P. 905, note O. Gohin, Stavroula, (K.), op. cit., P. 116 etss.

أخيراً وفي مجال آخر من المجالات التي تتمتع الإدارة في خصوصها بسلطة تقديرية واسعة وهو مجال تجنس الأجانب La naturalization des étrangers ، فإنه يلاحظ أن قاضي تجاوز السلطة يعمل جاهداً على بسط رقابته على الوقائع المتعلقة بهذا المجال. إذ بعد أن كان يقتصر في البداية على مجرد فحص الوقائع التي تمس فقط حق الدخول ثانية Le droit à reintégration في الجنسية الفرنسية وكذلك تلك التي تمس فقد هذه الجنسية، أصبح يعمم هذا الفحص يتناول كافة الوقائع المتنازع فيها حول التجنس ليصل من وراء ذلك إلى الوقوف على مدى التباعد الواضح أو البديهي منها ومن القرار المتخذ في هذا الشأن مستخدماً لذلك قاعدة المعقولة Le règle du raisonnable التي تستند إليها فكرة الخطأ البين كما أوضحنا من قبل.

ففي إحدى الدعاوى مثلاً نجد أن مجلس الدولة يقضى - بعد أن أشار إلى الشروط القانونية للتجنس - بأن سلوك وتصرفات الشخص الأجنبي التي يستدل منها على رغبته في الاحتفاظ بصفة المهاجر في فرنسا - تعد سبباً في فقد الجنسية الفرنسية، ومن ثم فإن قرار الإدارة في هذا الشأن ليس مستنداً إلى خطأ بين في التقييم^(١).

وهكذا يمكن القول إنه قد بات من المؤكد أن القاضي الإداري في فرنسا أصبح يبسط رقابته من خلال تبنيه لنظرية الخطأ البين على الوقائع والأسباب المتعلقة بإجراءات الضبط الخاصة بالأجانب، ما نحا هؤلاء الآخر

(1) C.E., 25 Juil. 1986, Melle Benyoucel, Rec., P. 209, A.J.D, 1986, P.599; C.E. 26 Fev 1988, Martins, R.F.D.A., 1989, p. 178 concl. ch. vigouroux.

بذلك مزايا وضمانات لحماية حقوقهم وحرياتهم باعتبار أنهم أكثر العناصر ضعفاً في مجتمع ديمقراطي.

ومع ذلك فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن تبنى رقابة الخطأ البين في مجال الإجراءات السابقة، وإن كان أمراً له أهميته وتقديره، إلا أنه لا يمثل في الحقيقة والواقع تقدماً في مجال الرقابة القضائية بقدر ما يمثل علاجاً لتقصير مجلس الدولة وتقاعسه فترة من الزمن عن تحقيق العدالة في هذا الميدان، مقارنة باتجاهاته التحررية *ses orientations liberales* في ميادين أخرى عديدة، ذلك العلاج الذي كثيراً ما كان منتظراً منه، إذ لم يكن وضعاً طبيعياً - يضيف هذا الجانب الفقهي - إلا يتمتع الأفراد الأجانب أو الأنشطة الأجنبية في فرنسا، تجاه السلطات الواسعة للأجهزة المعنية بهم خاصة السلطات التي تمس حقوقاً فردية والتي من الواجب احترامها وتقديسها، إلا بضمانات قضائية غاية في الضعف^(١).

المطلب الثاني

المجالات الحديثة لنزاعات العمل الإداري ورقابة الخطة البين

بجانب المجالات التقليدية لنزاعات العمل الإداري السابق بيانها، توجد مجالات أخرى حديثة لتلك النزاعات، وهي المجالات التي ظهرت - كما ذكرنا - على أثر سيادة المذهب الاجتماعي أو المذهب التدخلی ومثالها: المجالات الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية... إلخ. فقد ألقى ذلك

(1) Odent (B.) La politique immobilière et le juge administrative thèse, paris, 1974, p. 1572, Drago (R.), note sur C.E, 2 nov. 1973, Maspero, J.C.P., 1974, P. 17642; Pacteau (B.) note sur C, E, 4 Fev. 1981, Konaté, précité, p. 355 et ses obsetrvati sous, C.P., Maspero, Gaz. Pal, op. cit., P. 21.

المذهب على عاتق الإدارة، نظراً لما يتسم به من إعلاء للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أو بمعنى آخر من تقديم لمصلحة الجماعة على مصلحة الفرد -ألقي على عاتقها التزاما بضرورة القيام بدور هام وأساسي في المجتمع.

الأمر الذي أصبح معه من المنطقي أو البديهي أن يعترف لها بحرية أكبر في التصرف، أو بسلطة تقديرية أوسع في مختلف هذه المجالات الحديثة: إلا أنه مهما اتسع نطاق هذه السلطة التقديرية فإنه لا يجب من ناحية أخرى أن تترك الإدارة عند مباشرتها دون رقابة فاعلة والا تحولت - كما ذكرنا مراراً - إلى سلطة مطلقة، تتسم في الغالب بالتحكم أو الاستبداد غير المبرر.

من هنا يبدو أو يبرز دور مجلس الدولة كعنصر رقابي هام يمنع مثل هذا التحكم أو الاستبداد، وقد انتهج لهذا الغرض أساليباً وأنماطاً تتلاءم مع ما يسود أنشطة تلك المجالات من قيم معينة، ومع ما تتطلبه من مرونة في التعامل وسرعة في الحسم، ومن ذلك أن القاضي الإداري بعد أن يحيط بكافة الوقائع التي تجسد هذه الأنشطة ، أصبح يركز على كيفية تقييم أو تقدير الإدارة لهذه الوقائع دون إهمال لظروف ومعطيات كل نزاع على حده ، للوقوف على ما يكون قد شاب هذا التقييم أو ذلك التقدير من خطأ بين، كان له أثره إما في تقدير الوقائع في ذاتها وإما في صحة تكييفها القانوني وإما - كذلك - في مدى التناسب بين أهمية الوقائع المذكورة وبين الإجراء المتخذ على أساسها.

فقد رأينا مثلاً كيف أعمل القاضي الإداري هذا النمط الرقابي في المجال الاقتصادي، وذلك عندما باشر رقابته على تقييم الإدارة وتقديرها لخطورة استعمال الجمهور لمنتج طبي معين. إذا بعد أن أحاط بكافة الوقائع

التي استندت إليها الإدارة في هذا الصدد وكيفية تقييمها وتقديرها لهذه الوقائع، انتهى إلى إلغاء قرار وزير الصحة بمنع تداول هذا المنتج الطبي حيث تبين له أن هذا التقييم أو ذلك التقدير كان مشوباً بخطأ بين، مما أثر على صحة أو شرعية القرار المطعون فيه^(١)، وهو ما انتهجه أيضاً في خصوص تقدير الإدارة لما إذا كانت "الزبادي" المحفوظة تحت درجة عالية من التبريد تعادل في قيمتها الغذائية "الزبادي" الطازجة^(٢). بل وفي تاريخ حديث نسبياً أعمل القاضي الإداري الرقابة القصوى للخطأ البين في واحد من المجالات التي نحن بصددھا، وذلك حينما قضى بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية برفض السماح بافتتاح مختبر تحاليل Laboratoire de biologie، استثناء من القواعد المنظمة لمثل هذه المسائل، حيث باشر في هذا الصدد تقييماً شخصياً لكافة الظروف الاقتصادية التي استندت الإدارة إليها لتبرير هذا الرفض، ومنها عدد الأفراد الذين سيستفيدون من هذا المختبر - مساحة القرية المراد إقامة المختبر فيها - المسافة بين تلك القرية وأقرب مختبر تحاليل مماثل... الخ. وانتهى المجلس في حكمه إلى القول بأن تقييم الوزير لهذه الوقائع الاقتصادية كان، مشوباً بخطأ بين ومن ثم فقد ألغى قرار الرفض^(٣).

وفي مجال تخطيط أو تنظيم المدن Le domaine de l'urbanisme، فإن القاضي الإداري يراقب دائماً الوقائع التي تستند إليها القرارات المنفذة للسياسات المتعلقة بهذا التخطيط أو ذلك التنظيم، وهو في رقابته تلك لا ينظر إلى المبادئ النظرية التي يستند إليها مصدر القرار

(1) C.E, 28 Avr. 1967, F.N.S.P.F., Précite, Rec P. 180, C120, mai 1988, S.L.T.M., A.J.D.A., 1988, P. 403

(2) C. E, 26 Avr. 1985, Société Smonor, Quot. jurd, No 45, P.14.

(3) C. E, 30 sep. 1987, cohen, Rec, p. 296 S.14.

لتطبيق هذه السياسات، وإنما يهتم بشكل مباشر بظروف الواقع العملي ذاته وما يسود فيه من قيم اجتماعية معينة. بمعنى أنه يراقب قرارات تخطيط أو تنظيم المدن من منظور بيئي، أي في إطار البيئة الاجتماعية التي صدرت فيها. وهنا تلعب رقابة الخطأ البين دوراً أساسياً، وذلك إما لغياب النصوص التشريعية في هذا المجال، وإما لعدم وضوح ودقة هذه النصوص.

ففيما يتعلق مثلاً "بمنح رخص البناء permis de construire أصبح القاضي الإداري يراقب الخطأ البين الذي قد ترتكبه الإدارة عند تقييمها لمدى توافر الشروط القانونية المطلوبة بمنح هذه الرخص ، فقد أعلن مثلاً " أن المحافظ قد ارتكب خطأ بينا في تقييمه لشروط السلامة Conditions de salubrité الواجب مراعاتها قانوناً في تشييد البناء موضوع الرخصة الممنوحة^(١). كما أعلن في حكم آخر أن المحافظ الذي منح رخصة بناء، يرتكب خطأ بينا في التكييف القانوني للشروط التي تتطلبها المادة الثانية من مرسوم ٣٠ نوفمبر عام ١٩٦١ والتي تنص على جواز منح رخصة البناء، إذا كانت الإنشاءات المزمع إقامتها ليست من طبيعتها أن تسبب اعتداء على الصحة أو الأمن العام^(٢).

إضافة إلى ذلك فإن قضاء مجلس الدولة الصادر في ١٣ ديسمبر ١٩٧٦ في قضية Association Les amis de L'tie de Griox يعد

(1) C. E, 13 Juill. 1968, Sieur Mendelssohn, A.J.D.A, 1968, P.651.

(2) C. E, 13 mars 1989 Bousquet et autres, D., 1989, ZR., p.126 "que le prefet qui a delivré le permis de construire n' a pas commis d'erreur manifeste de qualification au regard de la disposition de l'art 2 du decret du 30 nov. 1967, qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions speciales si les constructions, par leur Situation ou leur dimensions, sont de nature à portée atteinte à la salubrité ou à la securité publiques".

تطبيقاً لهذا الاتجاه. ففي هذه القضية طالبت الجمعية المذكورة إلغاء حكم محكمة Rennes الإدارية برفض الطلب الذي تقدمت به لإلغاء قرار مدير منطقة Morbihan بمنح ترخيص إنشاء للشركة المدنية العقارية Groix vacances، وقد رفض المجلس الطعن مقررّاً أنه يتضح من معاينة الموقع التي قام بها نائب القسم القضائي في حضور الأطراف وممثل الإدارة ، أن العقار المزمع انشاؤه ليس من شأنه الإضرار بالمناظر الطبيعية أو مصالح وطابع الأماكن المجاورة. ولذا فإن تقدير المدير في هذه الحالة ليس مشوباً بخطأ بين^(١).

بل لقد مد مجلس الدولة مجال تطبيق الخطأ البين في التقدير إلى نطاق القرارات المتعلقة باختيار المواقع وحمايتها. تلك القرارات التي تستهدف حماية المواقع لاعتبارات بيئية - حضارية - تاريخية -جمالية -أثرية...الخ، مع ملاحظة أنه سواء أكانت المواقع محل الحماية حضارية كتلك التي نظمها القانون رقم ١٩٦٢/٩٠٣، و ٣١ ديسمبر ١٩٧٦ أو مواقع طبيعية وهي التي نظمها أخيراً مرسوم ٧ يوليو ١٩٧٧، فإن فكرة الخطأ البين في التقدير حظيت بتطبيقات لها في هذا المجال كما سعى مجلس الدولة إلى ضبط وتوسيع مفهوم الأسرار بالمواقع الأثرية والحضارية كما أوضحنا من قبل، وكذلك توفير الحماية المواقع البيئية ومتوغلاً في صميم التقدير الإداري في هذا المجال كما سنرى في الفقرة التالية .

وأخيراً ففي مجال البيئة وهو المجال الذي أصبح حديث الساعة وموضع اهتمام من جانب العالم أجمع، حيث تعقد من أجله المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية، وتتخذ في خصوصه التوصيات والقرارات، فإن

(1) Concl. genevois, J.C.P.,1977, P.18529.

القضاء الإداري لم يكن في الواقع بعيداً عن هذه الأحداث، حيث بدأ يعطى للمنازعات المتعلقة بهذا المجال اهتماماً متزايداً، خاصة وأن التنظيمات القانونية المتعلقة به لا زالت في متخلف بلدان العالم تقريباً حديثة العهد ومحدودة التطبيق، الأمر الذي يلقي على عاتق هذا القضاء دوراً أكبر من أجل حماية أفضل للبيئة.

ومن المعروف أن للبيئة جانبين^(١)، أحدهما إقليمي aspect territorial وهو الجانب المرئي أو المحسوس والملموس للإنسان، وهو في الواقع جانب جمالي، ولهذا يطلق على حمايته الحماية الجمالية La protection de l'esthétique والجانب الآخر، جانب الطبيعة ذاتها أو ما يطلق عليه جانب التعادل أو التوازن البيولوجي l'équilibre biologique وهو الجانب الذي يشكل الإطار الحياتي للإنسان، ولهذا فالحماية المقررة له تسمى "حماية الطبيعة La protection de La nature" ومع ذلك تجدر الإشارة أنه لا يجب أن ننظر إلى أي من هذين الجانبين استقلاً عن الجانب الآخر.

فهما في الواقع وجهين لعملة واحدة، ولذا يلاحظ أن سياسة الدولة العقارية La politique immobilière de l'Etat لم تعد تهتم فقط - كما كان الحال في الماضي - بالمسائل المتعلقة بحماية حق الملكية الخاصة بالأفراد ومنع أي اعتداء قد يقع على هذا الحق ، وإنما أصبحت تهتم كذلك بكافة المسائل ذات العلاقة بنوعيه أو جودة الحياة البيئية. ومعنى ذلك أن الدولة أصبحت حريصة على أن تؤكد للمواطنين أن لهم الحق كذلك في أن تكون البيئة التي يعيشون فيها بيئة نظيفة وصحية. ولهذا فقد ظهر في

(1) Stavroula (K.) l'évolution du contrôle juridictionnel op.cit (1) P. 205.

معظم دول العالم تقريبا حق جديد لصالح الأفراد يعرف بـ " الحق في البيئة
.Le droit de l'environnement

وتحقيقا لهذه السياسة وتدعيما لهذا الحق فقد عمل مجلس الدولة من
جانبه ومن خلال البناء القضائي الجديدة؟ "قابة الخطأ البين، على حماية
جانبى البيئة المشار إليها آنفا^(١). فقد سبق أن أشرنا إلى أن القاضي الإداري
قد حقق بشكل فعال التلاؤم بين حماية الحق في الملكية الخاصة وحماية
التراث أو الإرث القومي وهو ما يخص الجانب الأول من جانبى البيئة الذي
يقال له الجانب الإقليمي أو الجانب الجمالى كما ذكرنا، وذلك من خلال
رقابته لكافة المنازعات التي تثور في هذا الصدد وهي عديدة من بينها مثلا
حكمه بعدم اعتبار La place Beauveau بمثابة منظر أثرى^(٢)، أو على
العكس اعتبار كل من Le place de l'Etoile^(٣)، La parc de la
Muette^(٤)، La place de l'opera^(٥)، بتاريخ حديث نسبياً L'église
saint jean Baptiste de Neuilly sur- seine^(٦) بأنها تمثل مناظر
أثرية، وثم فهي جديرة بالحماية. وهى رقابة تنصب كما بينا من قبل على
التكليف القانوني الذي تضيفه الإدارة على الوقائع التي تستند إليها قراراتها في
تلك المجالات وما يكون قد أصاب هذا التكليف من خطأ بين.

أما عن الجانب الآخر وهو جانب حماية الطبيعة أو الجانب المتعلق
بالتعادل البيولوجي فيلاحظ أن القاضي الإداري جعل من رقابته هنا عنصراً

(1) Coulet (W.) la protection de l'environnement dans le contentieux de
l'urbanisme, Droit et ville, 1979, No 8, P. 209.

(2) C. E, 4 avr 1914, Gome 1, Rec. P.488.

(3) C.E, 1 er août 1914, wiriot, Rec. P.1011.

(4) C. E, 24 mars 1922, Levy et Michel, Rec., P.281

(5) C. E, 2 dec., 1932, société des établissements copin et autres, Rec. P.
1038.

(6) C. E, 17 mars 1978 société Affichage Giraudy, Rec. P.135.

لصالح الإجراءات التي تهدف إلى حماية البيئة، حتى وإن كانت تحمل في ذات الوقت اعتداء على حق الملكية الخاصة^(١)، ذلك أنه بعد أن كان مقتصرًا في بداية الأمر على مجرد تعويض الأضرار البيئية التي كانت تصيب الأفراد أصبح يتبنى (في إطار سياسة عقارية جديدة تهتم بالبيئة كما ذكرنا) مسألة التعادل أو التوازن البيولوجي *L'équilibre biologique*، ولهذا فقد أصبح يعمل على كبح جماح الاختيار التعسفي للإدارة في هذا المجال عن طريق الاستعانة بمفاهيم وأفكار مرنة، يحدد هو بذاته مضمونها على أساس من روح التشريعات الخاصة بحماية البيئة^(٢).

وقد عبر مجلس الدولة عن هذا الاتجاه صراحة في حكم حديث نسبيًا، حينما قضى بأنه يتبين من فحص ملف الدعوى أن البناء المزمع تشييده ليس من شأنه أن يعرض للخطر حمايه موقع أثرى أو أن يخل بالتنظيم الجمالي للمدينة، أو أن يتنافى مع الرغبة في وجود مساحات بيئية خضراء أو أن يؤدي إجمالاً إلى نتائج سلبية أو مؤسفة على البيئة، فتقدير الإدارة لكافة هذه العاصر لم يكن مشوباً بخطأ بين^(٣).

-
- (1) "... en se prononçant plutôt favorablement à la protection de l'environnement". Stavroula (K)... op. cit. P.208.
 - (2) "Il a alors essayé de maîtriser les choix arbitraires de l'administration dans ce domaine, à l'aide des notions souples dont il a fixé lui-même le contenu, conformément à l'esprit de la législation protectrice de l'environnement". de lanversin (J.), contrubition du juge au développement du droit de l'environnement, in melanges, M. Waline, L.G.D.J., 1974, T. II, p. 521; Romi (R.) le droit de l'environnement vers la maturité? R.D.P., 1990, P.1121,
 - (3) que.... ne soit pas " de nature a compromettre la conservation d'un site. archéologique, à favoriser une urbanisation disperse incompatible avec la vocation des espaces verts environnements ou à entrainer des conséquences dommageables pour l'environnement" C. E, 28 janv. 1987, société anonyme delama, A.J.D.A, 1987, p. 281

بل وفي الحالات التي يصعب فيها على القاضى الإدارى إجراء تقييم حقيقى لكثير من المعطيات أو العناصر التي يتضمنها ملف الدعوى فإنه أصبح يباشر تقييما شخصيا لهذه المعطيات أو تلك العناصر ومن ذلك أنه اعتبر فى أحد أحكامه أن قرار محافظ باريس بمنح رخصة بناء لتشييد مركز طبى للرياضات المتعددة، لم يكن مستندا إلى تقييم مشوب بخطأ بين النتائج التي قد يتسبب بناء هذا المركز فى حدوثها على البيئة أو حتى على الأماكن المجاورة أو الأراضى أو المناظر الطبيعية أو الحضرية أو على المناظر الأثرية^(١).

وتأكيدا لهذا الاتجاه فإن القاضى الإدارى يقوم أحيانا بزيارة للأماكن التي ستقام عليها الانشاءات موضوع رخص البناء المتنازع فى خصوصها ليتثبت بنفسه من وجود أو عدم وجود خطأ بين فى التقييم الذي أجرته الإدارة^(٢) كما أوضحنا من قبل.

إضافة إلى ذلك فقد ظهر بحث القاضى الإدارى أو تقييمه الشخصى على هذا النحو بشكل أوضح عند رقابته للنزاعات التي يحاول فى صوصها التوفيق بين مصالح اقتصادية متعارضة فى مجال البيئة، كذلك التي وجدت على أثر النزاع حول السماح بإنشاءات لإنتاج الطاقة النووية، حيث قضى مثلا بأنه بإعطائه الإذن المطعون فيه، فإن المحافظ - نتيجة مراعاته لكافة الشروط القانونية اللازمة للإنشاءات القانونية اللازمة للإنشاءات النووية ولا اعتبارات سلامة و حماية البيئة - فإنه لم يرتكب خطأ بينا فى التقييم^(٣).

concl. vigouroux (ch.), C. E, 21 Juil 1989, M, violete, A. J. D. A., 1990, P.72.

(1) C. E, 4 mars 1983, Association S.O.S. Paris Rec. P.94.

(2) C.E, 7 nov. 1980 Ministre de l'environnement et du cadre de vie et S.C.I. Alvarado, A.J.D.A. 1982, p. 495, note Toulemonde (B.) et Loquet (P.).

(3) C.E, 20 Juin 1984, Association les amis de la terre, Rec. P.233.

ومن التطبيقات الأخرى لمجلس الدولة بشأن حماية البيئة أو بمعنى أدق حماية جانب الطبيعة ذاتها، حكمه الصادر في ٢ مارس ١٩٨٣ في قضية Association dite comite Vuire Courbevoie التي تخلص وقائعها في أن الجمعية المدعية طعنت أمام مجلس الدولة في الحكم الصادر من محكمة باريس الإدارية برفض طلبها إلغاء قرار مدير desttauls des Seine الصادر بمنح شركة الدراسات والبيوع العقارية S.E.E.R.J. رخصة انشاء بناء مع وقف تنفيذ هذا القرار.

وقد أشار المجلس في حكمه إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون ١٠ يوليو ١٩٧٦ المتعلق بالحماية الطبيعية للمواقع، والتي توجب ضرورة اجراء دراسات سابقة لإنشاء المواقع وإعدادها لما لذلك من أهمية في معرفة آثارها وما يمكن أن ترتبه من نتائج ضارة على البيئة الطبيعية أو على الجانب البيولوجي لهذا البيئة وقد رفض المجلس الطعن وطلب وقف التنفيذ . وقرر في هذا الحكم أن المكان الذي يوجد به العقار الصادر بشأنه الرخصة محل النزاع ذو طابع قديم وأن قرار المدير بمنح الرخصة لم يشبه أي خطأ بين في التقدير^(١).

حاصل القول إذن، أن القضاء الإداري الذي يهدف في حقيقة الأمر إلى إقامة أو تشييد نظام عام بيئي d'un ordre public écologique إنما يستند أو ينطلق لهذا الغرض من ذات المبادئ التي تحكم منازعات الضبط الإداري السابق بيانها في أكثر من موضع. ومعنى ذلك أن حق كل فرد في التمتع ببيئة طبيعية -صحية - خالية من كافة أشكال التلوث... وهو ما يجسد مضمون النظام العام البيئي المشار إليه، يجب أن يقدم أو تكون له الأولوية عند التعارض مع المصلحة الخاصة ، تلك المصلحة التي

(1) C. E, 2 mars 1983, Association dite comite viure a courbevoie, Rec., P.113.

لا يجب من ناحية أخرى أن تكون هدفا لأي إجراء يمس بها أو ينتقص منها، إلا إذا كان هذا الإجراء - كما هو الحال في الضبط الإداري - لازماً وضروريا لحماية البيئة أو لحماية ما يسمى بالنظام العام البيئي، أو أن ما يتضمنه هذا الإجراء من اعتداء على هذه الحرية الخاصة يجب أن يكون متناسبا أو متلائما نما مع درجة الخطورة أو التهديد الذي ترغب في أن نجنب هذا النظام إياه^(١).

وهكذا فإن القاضي الإداري من خلال تكتيك الخطأ البين أصبح، يأخذ في اعتباره عند تقديره أو تقييمه الشخصي لوقائع المنازعات المتعلقة بالبيئة أو الطبيعة، ضرورة تغليب أو إعلاء المصلحة العامة، أو بمعنى آخر تغليب أو إعلاء كل ما هو من شأنه حماية البيئة على المصالح الفردية أو الخاصة بحيث يمكن القول إن مبدأ عاماً قد ظهر في عالم القانون العام من مقتضاه ضرورة احترام قواعد حماية البيئة في كافة الظروف والأحوال سواء بشكل مستقل، أم في حالة تعارضها مع الحق في الملكية الخاصة^(٢).

"Le respect des règles de l'écologie, en toutes circonstances; indépendamment et même à L'encontre du droit de propriété privée".

(1) Lamarque, Droit de la protection de la nature et de l'environnement, Paris, L.G.D.J., 1973, p. 578 etss Stavroula (K.) op. cit. P.211.

(2) Stavroula (K.), op. cit., P. 211.

المبحث الثالث

موقف مجلس الدولة المصري من رقابة الخطأ البين

بعد أن تناولنا نظرية رقابة الخطأ البين في القضاء الإداري الفرنسي سواء من حيث الظهور والتطور، أم من حيث المعنى والمضمون ، أم أخيراً من حيث التطبيقات المتعددة لها، لنا أن نتساءل عن موقف مجلس الدولة المصري من تلك النظرية؟ وما إذا كان قد أعملها في قضائه بذات الصورة التي رأيناها في أحكام مجلس الدولة الفرنسي من عدمه؟

نبادر بداءة إلى القول أنه بمراجعة أحكام مجلس الدولة المصري سواء في ذلك الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، أم من المحكمة

الإدارية العليا لم نجد لهذه النظرية تطبيقات قضائية توحى بتبنى القضاء الإداري المصري لها، وذلك بالمفهوم والمعنى أو الشمول التي هي عليه في القضاء الإداري الفرنسي^(١).

(١) ومع ذلك يلاحظ أن الدكتور/ محمود سلامه جبر يقول في رسالته السابقة ص ٤٥٩- في هذا الصدد أنه "إذا كان مجلس الدولة المصري لم يستعمل تعبير الغلط البين (وهو ما نقول له الخطأ البين) صراحة في معظم التطبيقات القضائية إلا أنه توصل إلى النتائج التي بلغها مجلس الدولة الفرنسي في تطبيقه لنظرية الخطأ البين في التقدير، الأمر الذي يوضح أن مجلس الدولة المصري كان سابقاً إلى أعمال مضمون تلك النظرية ونتائجها في بعض المجالات حتى قيل أن يبتدعها مجلس الدولة الفرنسي. إلا أن سيادته يعود ليقرر في ذات رسالته المشار إليها ص ٥٨٨ وذلك بعد أن ينتهي من عرض نظرية الغلو في القضاء الإداري المصري كتطبيق لنظرية الخطأ البين في القضاء الإداري الفرنسي، يقرر "أن الأحكام التي تعرض فيها القضاء الإداري المصري لفكرة الغلو ليست على قدر ذاته من الوفرة والغزارة التي صادفتنا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي في خصوص نظرية الخطأ البين. ولعل ذلك مرجعه إلى عمومية تطبيق نظرية الخطأ البين وامتدادها لجميع القرارات الإدارية في الوقت الذي انحصرت فيه نظرية الغلو في المجال التأديبي ، الأمر الذي يفسر ما حظيت به نظرية الخطأ البين من دراسات فقهية عديدة قرابة ربع قرن مما أثري الفقه الإداري الفرنسي وجعل من الخطأ البين عيباً مستقلاً يقوم إلى جوار العيوب الأخرى لإلغاء القرار الإداري!!؟"

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك تطبيقاً قضائياً فريداً في تلك الأحكام يمكن أن يكون قريباً أو متشابهاً إلى حد ما مع واحد من تطبيقات النظرية التي نحن بصدها. أقصد بذلك التطبيق الذي يطلق عليه في الفقه والقضاء المصريين " قضاء الغلو " في مجال التأديب. مع ملاحظة أن هذا القضاء قد ظهر في أحكام مجلس الدولة المصري قبل أن يعرف نظيره الفرنسي نظرية رقابة الخطأ البين. إذ بينما عرفت هذه النظرية الأخيرة وكما أوضحنا من قبل بدءاً من عام ١٩٦١، نجد أن محكمة القضاء الإداري أقرت في أحكامها قضاء الغلو منذ عام ١٩٥١.

حقيقة أنها أقرته كاستثناء، وخروج على ما كان مستقراً من قواعد قضائية في هذا الصدد^(١). حيث لم يكن تطبق إلا على طوائف محددة هي طوائف العمد والمشايخ والطلبة دون بقية الطوائف الأخرى^(٢)، إلا أنه يعد

(١) فقد كانت رقابة تلك المحكمة في المجال التأديبي وحتى هذا التاريخ قاصرة على التحقق من قيام الوقائع مادياً، وصحة الوصف القانوني لها. أما بخصوص رقابة مدى تناسب الجزاء الموقع للمخالفة المقترفة أو للجريمة التأديبية، فهذا كان أمراً متروكاً لمحض تقدير الإدارة تجرية دون رقابة قضائية، ومن طلائع أحكامها في هذا الصدد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/١/١٩٤٨ (قضية رقم ٣٣١ لسنة ١ ق .. المجموعة س٢ ص ٣٧٧) والذي تقول فيه ... لا تعقيب على لجنة التأديب من محكمة القضاء الإداري في تقديرها الموضوعي للوقائع وما يناسبها من عقوبات تأديبية في حدود السلطة المخولة لها قانوناً مادام لم يثبت أن قرارها قد انطوى على عيب سوء الإستعمال السلطة أو تجاوزها ... " . وفي حكم آخر صدر بتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٩٤٨ (قضية رقم ٣٥٨ لسنة ٢ ق. مجموعة س٣ ص ١٧٠) تقول فيه ".... ليس لهذه المحكمة أن تعقب على مقدار الجزاء التأديبي الموقع ما دام يدخل في الحدود القانونية المقررة إذ أن تناسب الجزاء مع موضوع التأديب أو عدم تناسبه مما تترخص المجالس التأديبية في تقديره..".

(٢) أرجع البعض هذا الاستثناء في قضاء مجلس الدولة المصري إلى أن هذه الطوائف الثلاث (العمد - المشايخ - الطلبة) كانت تعتبر من الأعمدة الحزبية في ذلك الوقت، وأن الجهات الإدارية كانت تمنع في القسوة وتسرف في الجزاءات التأديبية بالنسبة لهذه الطوائف الثلاث بالذات. فالحكومات آنذاك كانت حكومات حزبية، وكان كل حزب يتولى الحكم يحاول النيل من منافسيه وخاصة العمد والمشايخ والطلبة المناوئين له والمشايخين لخصومه. فكان أن تدخلت بفرض رقابتها على التناسب بين الجريمة والجزاء لدرء ما قد يقع من عسف الإدارة على تلك الطوائف وذلك استثناء من الأصل العام. المستشار عبد

مع ذلك تجديداً في نطاق القضاء الإداري المصري المصري فقط . ولهذا فقد ذهب البعض بحق إلى القول بأن نظرية قضاء الغلو تمثل واحدة من أبرز ملامح القضاء والإداري كما أنها تعد من مبتكراته... ولعل من أبرز خصائصها أنها مصرية في أصلها ومنبتها، فلم يستعرها قضاؤنا من القضاء الفرنسي أو غيره كما هو شأن معظم نظرياتنا القانونية^(١).

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن العبرة ليست بمن سبق الآخر في ظهور نظريته، وإنما العبرة بمن سبق الآخر في تطوير وتجديد نظريته، إذ يلاحظ أن القضاء الإداري المصري ورغم سبقة في تبني نظرية قضاء الغلو إلا أنه حصر نطاق تطبيقها منذ أن ظهرت وحتى الآن فقط في المجال التأديبي، وهو مجال محدود إذا ما قيس ببقية مجالات العمل الإداري الأخرى، في حين أن مجلس الدولة الفرنسي ورغم حداثة تبنيه لنظرية رقابة الخطأ البين، إلا أنه وصل بها لدرجة أصبحت معها نظرية عامة في فقه وقضاء القانون العام. فقد أصبحت تطبق بالنسبة لسائر القرارات الإدارية بل وأياً كان المجال الذي تصدر فيه تلك القرارات.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن لنظرية رقابة الخطأ البين - كما بينا من قبل - ثلاثة مستويات: المستوى الأول خاص بالأخطاء التي تقع في تقييم الوقائع ذاتها أو في الوصف القانوني لتلك الوقائع إذا لم تكن هناك نصوص قانونية أو أن هذه النصوص كانت غير واضحة أو محددة. أما المستوى الثاني فهو رقابة الخطأ البين في التكييف القانوني للوقائع وذلك عندما تكون هناك نصوص قانونية واضحة ومحددة ويصعب لأسباب فنية

الوهاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات التأديبية إدارياً وقضائياً للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخاصة، مجلة مجلس الدولة ص ٢٣٦.
(١) دكتور/ محمد مرغني خيرى، نظرية التعسف في استعمال الحقوق الإدارية، دكتوراه، جامعة عين شمس، ١٩٧٢، ص ٤٠٣.

إعمال الرقابة العادية Comtrole normal في خصوصها كما هو الحال في منازعات رخص البناء كما بينا . وأخيرا فإن رقابة الخطأ البين تطبق حينما يشوب هذا الخطأ مدى التلاؤم أو التناسب بين سبب القرار ومحلّه وهو ما رأيناه في مجال التأديب . في حين أن نظرية قضاء الغلو ليس لها في الواقع سوى مستوى واحد من التطبيق وهو المستوى الثالث المشار إليه، حيث لا تطبق إلا حينما يكون هناك عدم تناسب بين أو عدم ملاءمة ظاهرة بين الخطأ المرتكب والجزاء الموقع، أي بين سبب القرار ومحلّه.

ونظراً لأننا أتينا من قبل على نظرية رقابة الخطأ البين في القضاء الإداري الفرنسي، فإنه يحسن بنا أن تلقى بعضاً من الضوء على نظرية قضاء الغار أمام مجلس الدولة المصري حتى يتبين لنا بشكل أوضح ما بين النظريتين من نقاط التقاء وكذلك من نقاط اختلاف.

فقد ظهرت نظرية قضاء الغلو^(١) في أحكام مجلس الدولة المصري عام ١٩٥١ وذلك حينما قضت محكمة القضاء الإداري في حكم لها بتاريخ ١٩٥١/ ٢٦/ ١ بأن "تدرج الجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم ٢٤ من قانون العمد والمشايخ إنما يدل على أن المشرع قد قصد من وراء ذلك ضرورة قياس الجزاء بما يثبت من خطأ. مما يعني عدم الالتجاء إلى عقوبة الفصل وهي أشد الجزاءات إلا في حالة ارتكاب العمدة أو الشيخ أعمالاً جسيمة تتناسب مع هذه العقوبة"^(٢).

(١) والغلو كما درجت المحكمة الإدارية العليا على تعريفه هو: عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري الذي ارتكبه العامل وبين نوع ومقدار الجزاء الذي وقعته الإدارة عليه، أي أنه صورة صارخة من صور عدم التناسب بين سبب القرار ومحلّه، تباشر المحكمة من خلالها رقابتها الصريحة على مدى ملاءمة القرار التأديبي. دكتور/ ثروت عبد العال أحمد، الرقابة القضائية....، مرجع سبق ذكره، ص ٢٨٥.

(٢) ق ٥٣٦، س ٤، مجموعة السنة الخامسة، ص ١٠٩٦.

وتطبيقاً لهذا القضاء انتهت ذات المحكمة في حكم آخر لها عام ١٩٥٣ إلى القول بأنه "إذا كان من الثابت أن قرار الفصل المتخذ بحق العمدة من لجنة الشياخات كان قد اتخذ بحقه لمجرد مهاترة متبادلة بين العمدة وبين معاون البوليس، فإنه بذلك يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة لعدم الملاءمة الظاهرة فيه بين الخطأ والجزاء^(١)".

وقد سلكت المحكمة نفس المسلك بالنسبة لقرارات تأديب الطلبة، حيث قضت "بأن القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٢ الخاص باللائحة الأساسية للكلية الحربية لم يبين الجرائم التأديبية التي تستوجب محاكمة الطالب تأديباً على سبيل الحصر، ولم يفرد لكل جريمة عقوبة خاصة بها، وإنما اقتصر على بيان العقوبات التأديبية وتحديد الجهة التي توقعها، وأن المشرع قد قصد بهذا التدرج في العقوبات أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ، فلا يفصل الطالب مهما تكن التهمة الموجهة إليه، وإنما يجب قياس الجزاء بمقياس الخطأ الذي وقع منه^(٢)".

وبصرف النظر عما قبل حول عدول محكمة القضاء الإداري عن هذا الاتجاه أم عن استقرارها عليه، ومن ثم استمرارها في رقابة التناسب في المجال التأديبي، فإن ما يهمننا في هذا الخصوص هو أن المحكمة الإدارية العليا التي أنشئت عام ١٩٥٥ قد أنت في هذا الصدد، بحكم حاسم لا يدع مجالاً للشك حول تبني القضاء الإداري المصري لنظرية الغلو في تقدير الجزاءات التأديبية لا للطوائف الثلاثة المشار إليها من قبل، وإنما كذلك لكافة الطوائف الأخرى، بل ولكافة أنواع الجزاءات التأديبية، سواء ما صدر

(١) ٢٢ مارس ١٩٥٣، ق ٧٤٣، س ٥، مجموعة السنة السابعة، ص ٧١٧.

(٢) الحكم الصادر بتاريخ ٢٩ نوفمبر عام ١٩٥٣، ث ١١٥٠، س ٧، مجموعة السنة الثامنة، ص ١٣٩.

منها عن السلطات الرئاسية، أم عن مجالس التأديب، أم عن المحاكم التأديبية. ولهذا فقد اعتبر جانباً من الفقه أن هذا الحكم "مما يدخل في سلسلة الأحكام الكبيرة لقضائنا الإداري... لا يقل أهمية من الناحية العملية عن الحكم الذي قررت به محكمة القضاء الإداري لأول مرة رقابتها على دستورية القوانين"^(١).

كما وصفه البعض الآخر بأنه بمثابة "شعلة مضيئة وضعتها المحكمة الإدارية العليا في طريق الحق والعدل، وزينت به صدر قضائنا الإداري"^(٢).

تقول المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم "إنه ولئن كانت للسلطات التأديبية، ومن بينها المحاكم التأديبية، سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطات شأنها في ذلك شأن أية سلطة تقديرية أخرى، ألا يشوب استعمالها غلو، ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره... ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب، والهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقه صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى احجام عمال المرافق العامة عن حمل المسؤولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والأفراط المسرف في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين؛ فكل على طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير

(١) دكتور/ عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، ١٩٦٤، ص ٢٨٢.
(٢) دكتور/ جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، ١٩٦٧، ص ٤١٧.

المرافق العامة وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمى إليه القانون من التأديب، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية لنطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة، ومعيار عدم المشروعية ليس معياراً شخصياً وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وغنى عن البيان أن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية في الصورة المذكورة مما يخضع أيضاً لرقابة هذه المحكمة^(١).

هذا وقد رددت المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك المبادئ التي تضمنها هذا الحكم في مجموعة متتالية من الأحكام التي طبقت بمقتضاها نظرية قضاء الغلو سواء أخذ هذا الغلو معنى القسوة والشدة أم أخذ معنى الإسراف المفرط في الشفقة ومن أمثلة النوع الأول من الغلو تقول المحكمة في أحد أحكامها "إن أخذ المتهم بمنتهى الشدة وتوقيع العقوبات المقررة عليه، دون مراعاة لمختلف الظروف التي أحاطت بارتكاب المخالفة على الوجه السالف بيانه، مما يجعل الجزاء مشوباً بعدم التناسب الظاهر، وبالتالي يخرج عن حد المشروعية ويبطله..."^(٢).

وفي المعنى الثاني للغلو تقول ذات المحكمة أنه "لا جدال في أن جرائم الاختلاس من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والتي تفقد العامل الذي يرتكبها سمعته والثقة فيه، وتؤدي عند الحكم فيها جنائياً إلى فصله بقوة القانون، ولا يمكن أن يؤدي قيام المتهم برد المبالغ التي اختلسها وبالتالي قيام النيابة العامة بإحالة الموضوع إلى الجهة الإدارية لمجازاته عما ثبت في

(١) الحكم الصادر في ١١ نوفمبر عام ١٩٦٦، ق ٥٦٣، س ٧، مجموعة السنة السابعة، ص ٢٧.

(٢) مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة التاسعة عشرة، ص ٤١٢.

حقه تأديبيا إلى تغيير طبيعة الذنب الذي ارتكبه، فإذا ما أضيف إلى ما تقدم أن للمذكور سجلاً حافلاً بالجزاءات على نحو ما هو ثابت بالأوراق فإن الجزاء الحق لمثله هو الفصل من الخدمة"^(١).

وعلى الرغم من استقرار القضاء الإداري في مصر على هذا الاتجاه واستمراره حتى الآن في تطبيق نظرية الغلو في المجال التأديبي، إلا أن فقه القانون العام لازال مختلفا فيما بينه حول أساس هذا القضاء. وقد يرجع السبب في ذلك إلى صياغة بعض الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص وذلك على النحو التالي:

أولاً: فقد أرجعت بعض الأحكام الصادرة سواء من محكمة القضاء الإداري أم عن المحكمة الإدارية العليا أساس قضاء الغلو، أو أساس الرقابة الصريحة على ملاءمة القرارات التأديبية، إلى التدرج التشريعي للجزاءات التأديبية. إذ تقول المحكمة الإدارية العليا وكما بينا من قبل. "... أن هذا التدرج إنما قصد به الشارع أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ، فلا يفصل الطالب مهما تكن التهمة الموجهة إليه، وإنما يجب أن يقاس الجزاء بمقياس الخطأ الذي وقع منه..."^(٢).

كما تقول ذات المحكمة أيضا في حكم آخر بتاريخ ٨ يناير ١٩٦٣ "... وأما من حيث تقدير العقوبة على هذا الفعل فإن الجزاء يجب أن يكون متناسبا مع الجرم، وإلا اتسم بعدم المشروعية، والقانون إذ تدرج في قائمة الجزاءات... فإنه يكون قد هدف من هذا التدرج في إنزال العقاب إلى وجوب الملاءمة بينه وبين الجرم الذي يثبت في حق الموظف..."^(٣).

(١) مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة التاسعة عشرة، ص ٩٨.

(٢) الحكم الصادر في ٢٩ نوفمبر ١٩٥٩، سبقت الإشارة إليه.

(٣) مجموعة أبو شادي، ص ٣٢٤. وفي نفس المعنى الحكم الصادر في ٢٢ يونيو ١٩٦٣، ث ٣٣١، س ٨، مجموعة السنة الثامنة، ص ١٣٥٩.

واستناداً إلى هذه الأحكام، ذهب جانب من الفقه إلى تأسيس قضاء الغلو على أساس "مخالفة القانون في روحه ومعناه، باعتبار أن المشرع وقد نص على عدد من الجزاءات، وليس على جزاء واحد، إنما قصد أن تختار السلطة التأديبية من بينها ما يناسب صدقاً المخالفة المرتكبة"^(١).

ومع احترامنا وتقديرنا لهذا الاتجاه، فإننا لا نرى في هذا التبرير سنداً صحيحاً لقضاء الغلو، ذلك أن مخالفة القانون إنما تفترض بداهة أن اختصاص الإدارة، اختصاص مقيد. وليس هذا هو الحال في المجال التأديبي. أو بمعنى أدق في اختيار العقوبة التأديبية للخطأ الذي ارتكبه الموظف، إذ بعد ذلك - دون خلاف - من إطلاقات الإدارة، والذي تتمتع في خصوصه بسلطة تقديرية واسعة، كما أن القول بأن أساس قضاء الغلو يكمن في مخالفة القانون لا يستقيم ومسلك المحكمة الإدارية العليا، إذ لو كان الأمر كذلك لسلكت ذات مسلك محكمة النقض الجنائية التي لا تملك أن تعيد النظر في العقوبة التي توقعها المحكمة الجنائية مهما كانت غير ملائمة أو شابها غلو، ما دامت من بين العقوبات التي يجوز توقيعها على المتهم بالنسبة إلى الجريمة الثابتة قبله^(٢).

إذ يلاحظ أن المحكمة الإدارية العليا بعد أن تقوم بنقض الحكم إلغاء الجزاء، تتولى هي بذاتها اختيار الجزاء الذي تراه أكثر تلاؤماً مع المخالفة

(١) الدكتور/ عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص ٢٨٢، ص ٢٨٣. ومن هذا الرأي أيضاً استاذنا المرحوم الدكتور/ فؤاد العطار، القضاء الإداري، طبعة ١٩٦٦، ص ٨٤٥، ومبادئ القانون الإداري، طبعة عام ١٩٧٢، الجزء الأول، ص ١٥٧، حيث كان يرى رحمه الله "أن الشارع حين تدرج في الجزاءات التي يجوز للجنة الشياخات أن توقعها على العمدة أو الشيخ - عملاً بأحكام القانون - لم يهدف بذلك أن تنفرد اللجنة بتوقيع الجزاء بلا تعقيب عليها، وإنما قصد بهذا التدرج أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ، أي أن يكون هناك تناسق بين التهمة والعقاب.

(٢) الدكتور/ سليمان الطماوي، قضايا التأديب، طبعة ١٩٨٧، دار الفكر العربي، ص ٧٣١.

المرتكبة، وبما يحقق التناسب المنشود، أي أن المحكمة الإدارية العليا تقوم هي بالحكم بتشديد أو تخفيض الجزاء دون الرجوع مرة أخرى للسلطات التأديبية. فقد قضت مثلاً "بعقوبة الخصم من المرتب لمدة شهرين بدلاً من عقوبة العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة التي قضت بها المحكمة التأديبية^(١).

وعلى أية حال وكما يقول أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوى أن هذا التبرير إنما هو تبرير فاسد من أساسه ويقوم على عدم فهم الجريمة التأديبية والتي لا تخضع - على عكس الجريمة الجنائية - لقاعدة "لا جريمة إلا بناء على نص"، بل ويجوز لسلطة التأديب أن ترى - تحت رقابة مجلس الدولة - في أي عمل يرتكبه الموظف جريمة تأديبية إذا كان لا يتفق وواجبات المهنة وبالتالي لا يمكن حصر الجرائم التأديبية مقدماً، بحيث يكون لكل من هذه الجرائم عقوبة من حد واحد أو من حدين كما هو الشأن في الجرائم الجنائية.

غير أن المشرع ورغبة منه في عدم ترك الإدارة حرة في أن توقع أية عقوبة تشاء، فقد حدد نوع العقوبات التي يجوز لها توقيعها. وقد التزم المشرع في ذلك بطبائع الأمور حيث بدأ بأبسط العقوبات وانتهى بالأشد منها، إذ لا يعقل أن يورد العقوبات دون ترتيب. وعلى هذا الأساس فالتدرج في ذكر العقوبات لا يعبر بذاته عن أى شىء^(٢).

(١) الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٨/١٩٦٢، القضية رقم ١١٣٦ ش ق مجموعة السنة الثامنة، ص ٢١٩.

(٢) النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة السادسة، ١٩٩١، مرجع سابق ذكره، ص ٨٧؛ الدكتور/ محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص ١٨٠؛ الدكتور/ محمد ميرغني خيرى، رسالته السابق الإشارة إليها، ص ٤١١.

ثانياً: كما ربطت بعض أحكام مجلس الدولة بين قضاء الغلو وبين الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها. إذ تقول محكمة القضاء الإداري بعد أن تبين لها عدم التناسب بين الخطأ التأديبي الثابت في حق الموظف وبين العقوبة الموقعة عليه "أن في ذلك عدم ملائمة ظاهرة في القرار مما يجعله مشوياً بعيب الانحراف بالسلطة...^(١). كما تقول في حكم آخر: "... ومن أجل ذلك تبدو عدم الملائمة الظاهرة بين التهم المنسوبة للمدعى والعقوبة التي تضمنها القرار المطعون فيه ، مما يجعله مشوياً بعيب الانحراف وسوء استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه"^(٢). كما أن المحكمة الإدارية العليا ذهبت في ذات الاتحاد حيث قضت بأن " تقدير العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف هو أيضاً من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا اتسم بعدم الملائمة الظاهرة أي بسوء استعمال السلطة"^(٣).

وانطلاقاً من تلك الأحكام ذهب جانب من الفقه إلى إدراج الرقابة القضائية على الغلو في تقدير الجزاءات التأديبية في وجه الطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة. بل لقد ذهب أستاذنا الدكتور / سليمان الطماوي في هذا الصدد إلى حد القول بأن "كلمة الغلو" التي تستعملها المحكمة الإدارية العليا هي في الحقيقة بديل عن كلمة التعسف أو الانحراف"^(٤).

(١) الحكم الصادر في ٢٢ مارس ١٩٥٣، ق ٧٤٣، س ٥، مجموعة السنة السابعة، ص ٧١٧.

(٢) القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٦ق، مجموعة السنة الثامنة، ص ٤٥٠.

(٣) الحكم الصادر في ٥ يناير ١٩٦٣، القضية رقم ٩٨٧، س ٨، مجموعة السنة الثامنة، ص ٣٩٨.

(٤) قضاء التأديب، المرجع السابق، ص ٧٢٩. ومن هذا الرأي أيضاً الزميل الدكتور/ سامي جمال الدين، حيث يرى أن الغلو أو عدم التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة الموقعة، يعد قرينة على التعسف أو سوء استعمال السلطة، أو بمعنى آخر "يعد قرينة مؤكدة على ثبوت عيب الغاية في القرار التأديبي، ومن ثم يجعله مشوياً بعيب الانحراف وسوء استعمال السلطة وهو أحد أوجه إلغاء القرار الإداري". قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة، مرجع سبق ذكره، ص ٢٩٩. انظر كذلك الدكتور/ محمد مصطفى حسن، إذ يقول: "والقضاء

ومن جانبنا لا يمكن التسليم بمثل هذا القول وذلك لما بين قضاء الغلو وعيب الانحراف بالسلطة من فروق عديدة :-

-أولها، فارق في الطبيعة، إذ بينما يعتبر الغلو في تقدير الجزاءات التأديبية عيب ذو طابع موضوعي قوامه الخطأ في تقدير أهمية الوقائع المكونة للذنب الإداري، فإن الانحراف بالسلطة عيب ذو طابع شخصي أو ذاتي أو كما تقول المحكمة الإدارية العليا: أنه من " العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة"^(١).

ومعنى ذلك أن الإدارة إذا غالت في تقدير الجزاء، فإن ذلك لا يكون مرجعه فيه الإساءة في استعمال السلطة. بل قد يكون المرجع الحرص على المصلحة العامة. في حين أن الانحراف بالسلطة لا يتحقق إلا إذا استهدف مصدر القرار تحقيق غاية أخرى غير تلك التي شرعت السلطة من أجل تحقيقها، ولهذا تؤكد المحكمة الإدارية العليا أن معيار عدم المشروعية في حالة الغلو "ليس معياراً شخصياً، وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وهو تقدير يتم بطبيعة الحال بمعزل عن نيات الإدارة ودوافعها الكامنة"^(٢).

الإداري في حالة الغلو لا يلغي القرار لعدم التناسب ولكنه يستند في إلغائه إلى عيب من عيوب تجاوز السلطة وهو إساءة استعمال السلطة (الانحراف بالسلطة) والمعيار هنا موضوعي وهو عدم تحقق المصلحة العامة من وراء القرار، أما عدم الملاءمة الظاهرة فهو ليس معياراً لعيب الانحراف كما ذهبته المحكمة الإدارية العليا، بل هو قرينة على العيب يكملها بحث ما إذا كان القرار بحالته يحقق حسن المرافق العامة ومقتضيات المصلحة العامة" المرجع السابق، ص ٢٢٨.

(١) الحكم الصادر بتاريخ ٥ يناير ١٩٨٥، ق ٤٨٤، س ٢٦، مجموعة السنة الثلاثون، ص ٣٢٠.

(٢) الدكتور/ السيد محمد إبراهيم، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية، تعليق على أحكام المحكمة الإدارية العليا، مجلة العلوم الإدارية، السنة الخامسة، العدد الثاني، ديسمبر ١٩٦٣، ص ٢٧٣.

-الفرق الثاني : يتمثل في أن عيب الانحراف لا يتعلق إلا بالهدف أو الغاية من العمل الإداري ولا ينصرف إلى غيره من الأركان التي يقوم عليها، أما رقابة الغلو فإنها تنصب على تقدير الإدارة لمدى التناسب بين سبب القرار المتمثل في الخطأ الذي ارتكبه الموظف ومحل هذا القرار وهو الجزء الذي وقعت عليه الإدارة.

إضافة إلى ذلك فإن هناك اعتباراً أساسياً يحول دون إلحاق عيب الغلو في المجال التأديبي بعيب الانحراف بالسلطة، خاصة بعد تصميم تطبيق نظرية الغلو لتشمل إضافة إلى القرارات الصادرة - السلطات التأديبية، الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، ذلك أنه إذا جاز أن ننسب هذا العيب الأخير إلى السلطة الإدارية عند ما تباشر اختصاصاتها التأديبية فإنه يتعذر نسبة هذا العيب إلى أحكام المحاكم التأديبية في ضوء غلبة العنصر القضائي في تشكيلها^(١).

وهكذا أسهمت أحكام القضاء الإداري في التأثير على اتجاهات وآراء فقه القانون العام وذلك على الرغم من ثبات واستمرارية تلك الأحكام فيما أتت به من مبادئ أو قواعد. فمثلاً نرى أن المحكمة الإدارية العليا تقول في حكم لاحق للأحكام السابقة "أن تقدير العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف هو من سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا اتسم بعدم الملاءمة الظاهرة، (أو) بسوء استعمال السلطة"^(٢) . فمثل هذا الحكم يظهر في "الواقع رغبة هذه المحكمة في إبراز استقلالية قضاء الغلو على عيب الانحراف بالسلطة إذ استبدلت أداة الربط التي استخدمتها في حكمها

(١) الدكتور/ عبد الفتاح حسن، محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة دبلوم العلوم الإدارية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ١٩٦٣، ص ٢١٣ وما بعدها.

(٢) الحكم الصادر في ٢٤ ديسمبر ١٩٦٦، ق ١٠٢٦، س ١، مجموعة السنة الثانية عشر، ص ٤٨٧.

السابق الإشارة إليه وهي (أي) التي تفيد التكرار والترادف في المعنى بأداة أخرى هي (أو) التي تفيد الاستقلال في المعنى^(١).

من هنا فقد ذهب جانب آخر من الفقه إلى البحث عن تبرير أو سند آخر لقضاء الغلو، فاتجه البعض صوب آراء الفقيه الفرنسي waline في تفسير الرقابة القضائية على الملاءمة ، وقد سبقت الإشارة إليها ، والتي من مقتضاها أن القاضي الإداري يراقب المشروعية وهو ما يلزمه في بعض الحالات بمراجعة الملاءمة عندما تكون شرطاً من شروط مشروعية القرار الإداري، ومن ثم فقد انتهى هذا الجانب إلى القول " إن القضاء في مثل هذه الحالات (حالات عدم الملاءمة الظاهرة أو الغلو) يراقب الملاءمة فعلاً ولكن الملاءمة في هذه الحالات تصبح وفقاً لأحكام القضاء عنصراً من عناصر المشروعية. بمعنى أن سلطة الإدارة في هذا الشأن تتحول من سلطة تقديرية إلى سلطة مقيدة^(٢).

بينما اتجه البعض الآخر صوب آراء الفقيه الفرنسي VEDEL في تفسير الرقابة القضائية على الملاءمة والذي يرى أن للقضاء دور إنشائي، ومن ثم يمكن "أن يضع عن طريق هذا الدور من القواعد القانونية ما يغير به الحدود الفاصلة بين الملاءمة والمشروعية، وذلك بأن يجعل بعض عناصر الملاءمة شرطاً للمشروعية، واستناداً إلى هذا الرأي ذهب الدكتور/ عصام عبد الوهاب البرزنجي إلى القول بأن "أساس رقابة القضاء الإداري على الملاءمة في موضوع التأديب إنما يتمثل - حسبما نرى - في القاعدة القانونية التي وضعها القضاء والتي من مقتضاها اشتراط تناسب الجزاء مع الذنب المرتكب، بحيث لا يكون هناك ثمة لغو في تقدير أهمية الوقائع من

(١) الدكتور/ ثروت عبد العال، المرجع السابق، ص ٣١٦.

(٢) الدكتور/ وهيب عياد سلامة، الفصل بغير الطريق التأديبي، ١٩٧٤، ص ٧٧٣.

ناحية، وفي اختيار الجزاء من ناحية أخرى^(١).

وتأييداً لهذا الرأي يقول استاذنا الدكتور/ محمد حسنين عبد العال أنه "إذا كانت رقابة المحكمة على الغلو في تقدير الجزاء لا تستند إلى التشريع على هذا النحو، فإننا نخلص إلى أننا بصدد قاعدة قانونية من صنع القضاء الإداري نفسه، فنحن بصدد إحدى الحالات التي مارست فيها محكمتنا الإدارية العليا دورها الإنشائي في بناء قواعد القانون الإداري، وهي قد صاغت بخصوص قضاء الغلو، قاعدة عامة مؤداها ، أنه يشترط لشرعية الجزاء التأديبي ألا يشوب تقديره غلو، فنحن في مواجهة قاعدة قانونية من صنع القضاء الإداري ذاته"^(٢).

واضح من العرض السابق لمختلف الآراء التي قيلت من أجل إيجاد تبرير أو سند شرعي لقضاء الغلو في المجال التأديبي أن هذه الآراء تنطلق من نقطة واحدة وهي أن القاضي الإداري لا يراقب سوى مشروعية القرارات الإدارية، أو أن سلطة الإدارة التقديرية "تخضع لأية رقابة قضائية، وقد سبق لنا تنفيذ هذا القول في مناسبات سابقة عديدة وانتهينا إلى أنه لا تعارض على الإطلاق بين أن يكون للإدارة سلطة تقديرية وبين أن يراقب القاضي الإداري كيفية مباشرة الإدارة لهذه السلطة، خاصة أن هذه الرقابة تعد الضمان الوحيد لعدم تحول السلطة التقديرية إلى سلطة استبدادية، فهي وحدها التي تفرق ما بين السلطة التقديرية للإدارة والسلطة التحكيمية أو الاستبدادية لها.

ومن ثم يمكننا القول إن قضاء الغلو أو عدم الملاءمة الظاهرة في المجال التأديبي إنما يجد سنده وتبريره في رقابة القاضي الصريحة على

(١) رسالته السابق الإشارة إليها، ص ٤٤٠.

(٢) رسالته السابق الإشارة إليها، ص ١٨٨.

الملاءمة تماماً كما يباشر رقابته على المشروعية، وهذا هو الاتجاه الذي عليه أغلب الرأي في فرنسا في خصوص رقابة القاضي الإداري للخطأ البين كما أوضحنا من قبل.

فالقاضي الإداري في كلتا الحالتين، أي في حالة قضاء الغلو في مصر، وحالة الخطأ البين في فرنسا إنما يراقب عنصر الملاءمة في القرارات الإدارية. بل ولا تجاوز الحقيقة إذا قلنا أن ابتداع القضاء الإداري في البلدين لهذا الأسلوب وذاك في الرقابة ما هو إلا تجسيد أو تعبير عن رغبة أو سياسة قضائية فاعلة لمواجهة حالات السلطة التقديرية، وذلك بإخضاعها لرقابة جادة، ضماناً لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.

ولهذا نأمل أن يمد القاضي الإداري في مصر رقابة الغلو أو رقابته للملاءمة في المجال التأديبي إلى بقية القرارات الإدارية التي تصدر بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية في مختلف مجالات العمل الإداري تماماً كما فعل نظيره الفرنسي حينما همم تطبيق نظريته في الرقابة على الخطأ البين لنتناول مختلف قرارات الإدارة التقديرية كما أوضحنا من قبل.

الفصل الثانى

نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

La théorie du Bilan: cout-avantages

لقد كانت نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار - كأسلوب جديد في الرقابة على القرارات الإدارية - ثمرة مطالبة رجال الفقه للقضاء بضرورة تبني اتجاهات ومبادئ أخرى جديدة لمواجهة تزايد تدخل الإدارة في المجالات الحديثة، خاصة ذات الصلة بالأموال والعقارات، وذلك على أساس أن هذه المجالات إنما تحكمها في الغالب نصوص قانونية ولائحية تقتصر إلى التحديد والوضوح، بل وتتسم في الغالب بالمرونة أو عدم الثبات؛ الأمر الذي يعني ليس فقط أن تتمتع الإدارة بحالها بسلطة تقديرية واسعة ، وإنما يعني أيضا أن القاضي الإدارى يصبح تجاه تلك السلطة مجرداً من كل سلاح فعال ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ما يلي:

- أن المبادئ العامة التقليدية للقانون، وليدة الدولة التحررية والتي كانت تجد أساسها في النصوص السياسية، مثل إعلان حقوق الإنسان، ومقدمات الدساتير وغيرها، لم تعد تسمح للقاضي الإدارى - كما كان الحال في السابق - بإكمال النقص الذي قد يعتور التشريعات القائمة. فقد أصبحت هذه المبادئ في الواقع غير متلائمة بل وأحيانا متعارضة مع النظم الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، وليدة الدولة المتدخلة والتي تحكمها مبادئ مغايرة مثل: مبدأ النفعية - المنافسة - الاقتصاد المختلط أو الموجه - الانتاجية...إلخ.

- أن الإدارة لا تلتزم بحال القرارات التي تصدر في المجالات التي نحن بصدددها، كما هو الحال في معظم المجالات الإدارية الأخرى، بتسبيب تلك القرارات، إلا إذا كان هناك نص صريح يقضى بذلك. وهكذا أصبح لزاماً

على القاضي الإداري أن يتخذ موقفا إيجابيا للحد من احتمالات التعسف والتسلط من جانب الإدارة حينما تباشر سلطاتها التقديرية في تلك المجالات. فتبنى بداءة نظرية رقابة الخطأ البين السابق الإشارة إليها ثم بادر إلى خلق وابتداع بناء قضائي جديد يتسم بالجرأة والإقدام، هذا البناء يتمثل في النظرية التي نحن بصدددها: نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

فما هو مفهوم هذه النظرية؟ وما هي المجالات التي تباشر فيها؟
بل وما هو مدى تلك النظرية في عالم القانون الإداري؟ وأخيراً ما هو موقف مجلس الدولة المصري منها؟

هذا ما نبنيه تباعا بتناولنا للموضوعات العالية مخصصين لكل موضوع منها مبحثاً مستقلاً.

أولاً: مضمون نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

ثانياً: مجالات اعمال نظرية الموازنة بين المنافع والاضرار.

ثالثاً: نظرية الموازنة بين المنافع والاضرار ورقابة الخطأ البين.

رابعاً: تقدير رقابة الموازنة بين المنافع والاضرار.

خامساً: موقف مجلس الدولة المصري من نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

المبحث الأول

مضمون نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ومعيار أعمال تلك الموازنة

المطلب الأول

مضمون نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

ينصب تطبيق نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار أساساً على محل القرار الإداري، أي على موضوع أو مضمون هذا القرار، وبمعنى أكثر دقة ينصب على الأثر القانوني الذي تنتجه الإدارة إلى إحداثه^(١). مع ملاحظة أن هذا التطبيق لا يكون إلا إذا كانت الإدارة تتمتع في هذه الخصوص بسلطة تقديرية.

وهي تتمتع بهذه السلطة في حالتين :-

- إذا أتاح المشرع لها قدراً من حرية الاختيار بين عدة حلول في خصوص مسألة معينة.
- إذا تخلى المشرع من وضع أية حلول، مكتفياً بتحديد الغاية أو الهدف من القرار.

وكما هو واضح تكمن في الحالة الثانية التي يكون للإدارة فيها حرية

(١) هذا الأثر قد يتمثل في إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغائها. وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي الذي يكون دائماً نتيجة مادية واقعية. فالقرار الصادر بترقية موظف يكون محله وضع هذا الموظف في المركز القانوني الذي تحدده القوانين التي تحكم هذه الترقية باعتبار أن ذلك يمثل الأثر القانوني الذي اتجهت فيه الإدارة إلى تحقيقه. وعلى ذلك إذا لم يكن للقرار محل أو بالأحرى أثر قانوني معين كان منعداً، ألا يكون أصلاً أم قرار إداري. إذ لا يتصور في الواقع أن يكون هناك قرار إداري دون محل. فالمحل إذن يمثل ركناً أساسياً للقرار الإداري لا يقوم بدونه، وإذا وجد المحل فإنه يجب لصحة أو مشروعية القرار الإداري أن يكون هذا المحل ممكناً وحائزاً قانوناً وإلا كان القرار باطلاً.

مطلقه في اختيار ما تراه مناسباً وملائماً من حلول لتحقيق الهدف أو الغاية التي يرمي إليها المشرع، تكمن خطورة السلطة التقديرية للإدارة، إذ يرى جانب من الفقه أن حرية الإدارة في اختيار مضمون القرار على هذا النحو قد تؤدي إلى نتائج خطيرة ليس فقط بالنسبة للنشاط أو العمل الإداري ذاته والذي يتأثر سلباً بطبيعة الحال، إذا ما كان هذا المضمون غير متلائم مع متطلبات أو مقتضيات المصلحة العامة *L'entérêt générale*، وإنما أيضاً بالنسبة للأفراد المخاطبين بالقرار إذا ما كان المضمون المشار إليه منطوياً على أضرار أو نتائج بالنسبة لهم أو كن قد بلغ درجة ملحوظة من عدم التعادل أو التوازن^(١).

Si elle comporte trop d'inconvénients ou est atteinte d'un déséquilibre trop marqué.

وإزاء عجز الوسائل الرقابية الأخرى التي يملكها القضاء الإداري لمواجهة مثل هذه الحالات على ما بينا، فقد ابتدع هذا القضاء النظرية التي نحن بصددنا - تلك النظرية التي تتيح له في واقع الأمر أن يأخذ في اعتباره عند تقييم مضمون قرار ما لكافة الجوانب المتعلقة بهذا المضمون، أو على الأقل، كل ما يعتقد أن له أهمية خاصة في هذا الصدد، سواء فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عنه، أم بالمزايا المترتبة عليه، بحيث يتمكن بعد ذلك من إجراء عملية معايرة أو موازنة بين هذه وتلك من ناحية، وبين الغاية أو الهدف من ذلك القرار من ناحية أخرى، فإذا انتهت عملية المعايرة أو الموازنة هذه إلى ترجيح الأضرار يتعين عليه الحكم بإلغاء القرار؛ أما إذا كانت المزايا هي المرجحة أعلن عن صحة ومشروعية ذلك القرار.

(1) Alain BOCKEL, contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'administration A.J.D.A., 1978, P.366.

هذا ولما كانت أولى تطبيقات نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار قد أجريت في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، فقد صيغت هذه النظرية على النحو التالي.

"لا يمكن قانوناً اعتبار عملية نزع الملكية محقة للمنفعة العامة، إلا إذا كانت الأضرار التي تلحق الملكية الخاصة من جرائها وما تتطلبه من تكاليف مالية وكذلك ما يحتمل أن ينتج عنها من مضار اجتماعية، لا تتجاوز بشكل مبالغ فيه المزايا أو المنافع التي يمكن أن تترتب عليها".

une opération peut être Légale Si les atteintes à La propriété privée, Le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente⁽¹⁾.

إن مثل هذا القول إنما يعبر في الواقع عن تطور هام أصاب الرقابة القضائية في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث كان القاضي الإداري يقتصر في بادئ الأمر على التأكد فقط من أن هناك مصلحة أو منفعة عامة سوف تتحقق نتيجة نزع الملكية، أي أنه كان يراقب ما إذا كانت عملية نزع الملكية منطقية أو متضمنة في ذاتها منفعة عامة، تلك المنفعة التي كان ينظر إليها والحال هكذا كفكرة "abstrait" أو مطلقة "absolu".

وعلى ذلك إذا كان للقاضي الإداري أن يراقب الوجود المادي للحالة الواقعية التي تشكل سبب قرار المنفعة العامة، فإن هذه الرقابة كانت لا تتعدى هذا الإطار، أي أنها كانت تجد حدها عند قول الإدارة بأن هذه الحالة

(1) CE, 28 mai 1971, Leb., P.409, concl. Braibant A.J.D, A., 1971, P.463, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, No. III.

الواقعية تمثل منفعة عامة تبرر تدخلها باستخدام وسيلة نزع الملكية، فالقاضي الإداري كان يتمتع عليه والحال هكذا، أن يزن مدى المنفعة العامة التي يتطلبها أو يقتضيها سد هذه الحاجة الواقعية. ومعنى ذلك أن الإدارة إذا ما انتهت إلى مثل هذا القول أي بوجود منفعة عامة لمشروع معين مما يستلزم نزع ملكية عقار، أو جزء من عقار بعينه دون غيره، فإنه كان يتمتع على القاضي رقابة الإدارة أو مناقشتها فيما تدعيه أو تقرره في هذا الصدد، وما كان عليه سوى التسليم بتوافر هذه المنفعة.

حاصل القول إذن أن رقابة القاضي الإداري في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، كانت تقتصر فقط على رقابة الوجود المادي للوقائع، وما إذا كانت هذه الوقائع تبرر أو لا تبرر قرار المنفعة العامة^(١).

أما الآن وبعد أن تبني القاضي الإداري نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، فإن رقابة قرارات المنفعة العامة لم تعد قاصرة فقط على التحقق من العنصرين السابقين [الوجود المادي للوقائع - التكييف القانوني لهذه الوقائع]، وإنما أصبحت تتناول بالإضافة إلى ذلك مضمون هذه القرارات وما يشتمل عليه - كما ذكرنا - من منافع وأضرار وذلك في ضوء كافة الاعتبارات أو المعطيات البيئية والاجتماعية والمالية والاقتصادية وغيرها من المعطيات السائدة وقت تقدير أو تقييم هذا المضمون.

وهكذا أصبحت رقابة القاضي الإداري لقرارات المنفعة العامة، طبقاً للنظرية التي نحن بصددھا، تمر بثلاث مراحل على النحو التالي:

المرحلة الأولى: وفيها يتأكد القاضي الإداري من أن هناك منفعة

(1) C.E., 20 Juillet 1932, Roche, S., 1933, 3.32; Waline, Droit administratif, 7ème éd., Paris 1957, P.796.

عامة تبرر نزع الملكية، وهنا يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد وسع من مفهوم ونطاق المنفعة العامة لدرجة أنه أصبح ينظر إلى كل عمل من شأنه تحقق المنفعة مصلحة عامة *intérêt général* ، على أنه كافيا بذاته للدلالة على تحقق المنفعة العامة التي تبرر نزع الملكية^(١). ولهذا اعتبر من قبيل المنفعة العامة: إقامة ملاعب رياضية^(٢)، إقامة مساكن اقتصادية لمحدودي الدخل^(٣)، إقامة أحد بيوت الشباب^(٤).

فدور القاضي الإداري في هذه المرحلة يتجسد إذن في مجرد التأكد من أن عملية نزع الملكية التي تطالب بها الإدارة ليس لها من هدف سوى تحقيق المنفعة العامة، فإذا تثبتت من ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية: وفيها يتأكد القاضي الإداري من أن نزع الملكية للعقار الذي تطالب بها الإدارة أمر حتمي ولازم لتحقيق المنفعة العامة، بمعنى أن القاضي الإداري يراقب ما إذا كان المشروع المزمع إقامته لن يحقق منفعة عامة إلا إذا أقيم في ذات موقع العقار الذي ستنزع ملكيته، فالأرض المطلوبة مثلا لبناء مدرجات لطلاب الجامعة في إحدى الكليات؛ يصبح واجبا نزع ملكيتها إذا كانت ملاصقة أو مجاورة لمبنى الكلية، إذ يترتب على ذلك حتما تحقيق منفعة عامة. في حين أنه لا يصبح واجبا نزع ملكيتها إذا كانت بعيدة تماما عن هذا المبنى حيث لن يتحقق من وراء ذلك

-
- (1) Ch Debbasch, J. Bourdon , J.M. pontier J.C. Ricci : institutions et droits administratifs, Bien , expropriations, travaux publics, Thémis , P.U.F, paris 1978, p.233 et ss .; Gustave peiser, Droit administratif, 6ème éd., Paris, 1981 , P.52 et ss
- (2) CE, 14 Nov, 1923, Ferges Rec, P.144.
- (3) C.E , 10 NOV . 1951, Lacaze, Rec ., P.543.
- (4) C.E, 10 dec . 1938, combiéro, Rec ., P. 602 , D. Paris , 1939 , 111, 15, concl . Josse.

أية منفعة عامة^(١).

وهنا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد خلص إلى قاعدة مؤداها:
العمل نفسه قد يعتبر من قبيل المنفعة العامة في حالة معينة وقد لا يعتبر
كذلك في حالة أخرى^(٢).

"une même opération peut être d'utilité publique dans un cas
et pas dans un autre"

ومعنى ذلك أن القاضي الإداري لم يعد يراقب فكرة المنفعة العامة في
ذاتها كفكرة مجردة أو مطلقة - كما ذكرنا من قبل - وإنما أصبح يراقب هذه
الفكرة في ضوء الظروف والمعطيات التي حدت بالإدارة إلى القول بوجود
منفعة عامة.

المرحلة الثالثة: وتمثل قمة تطور الرقابة القضائية على قرارات
الإدارة المتضمنة منفعة عامة، حيث لم يعد القاضي الإداري يكتفى برقابة ما
إذا كان المشروع الذي تطلب به الإدارة يحقق نفعا عاما، أو يندرج في إطار
مفهوم المنفعة العامة، كما لم يعد يكتفى برقابة ما إذا كان العقار اللازم لهذا
المشروع هو الذي يحقق في الواقع المنفعة العامة التي تدعيها الإدارة ، وإنما
أصبح يراقب إضافة إلى ذلك، ما إذا كان المشروع الذي تطالب الإدارة نزع
الملكية من أجل إقامته يحقق مزايا وفوائد تفوق ما قد يترتب عليه من عيوب
ومضار .

-
- (1) C.E,29 Juin,1979, Malardel, Rec. P.294, A.J.D.A., P.20,R.D. P.1980.
P.1167; C.E.19 mai, 1983, Dame Baronnet, Rec. P.207; C.E,3 Avril,
1987, Metayer, Rec. p.121
(2) C.E.10 Fev., 1980, Rec .P.210 ; C.E, 4 Fev., 1981 Dame Borderie,
Rec. P.116.

قلم يعد القاضي يكتفى إذن بأن تكون العملية المدعاة من جانب الإدارة تجسد في ذاتها منفعة عامة، وإنما يجب أن تكون الفوائد والمزايا المترتبة عليها تفوق العيوب والأضرار الناجمة عنها، وهو ما يقال له رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار. Le controle du Bilan: cout. Avantages، وهي رقابة تجسد كما هو واضح رغبة القاضي الإداري وحرصه على الوصول إلى هدف أسمى، هدف طالما سعى نحو تحقيقه، ألا وهو "عقلنة الاختيارات التقديرية للإدارة"^(١).

"de rationalizer les coix Discretionnaires de l'administration"

المطلب الثاني

معيار الموازنة بين المنافع والأضرار

يقصد بمعيار الموازنة بين المنافع والأضرار، ذلك المعيار الذي يستعين به القاضي الإداري كي يتمكن من الوقوف على مزايا وعيوب عملية ما، أو نتائج تصرف إداري معين. ففي مجال عملية نزع الملكية للمنفعة العامة مثلاً، يتجسد هذا المعيار في الأسس والمعطيات التي تبرز المزايا المترتبة على هذه العملية وكذلك الأضرار أو المساوئ التي قد تتجم عنها، بحيث يستطيع القاضي بعد ذلك إجراء عملية الموازنة بين هذه وتلك ليقرر أي الكفتين أرجح. وهنا يلاحظ أن مفوض الحكومه Braibant قد انتهى في تعليقه على الحكم الشهير ville nouvelle est والذي أرسى - كما سنرى - النظرية التي نحن بصددتها إلى أن هناك بعضاً من المعايير المحددة سلفاً في هذا الخصوص والتي لها تأثيرها أو يجب أن تؤخذ في

(1) J. LEMASURIER, vers un nouveau principe général du droit?, le principe, "Bilan" cout- avantages", in Mélanges M. Waline, L.G.D.J., 1974, T. 11, P. 554.

الاعتبار عند تقدير الموازنة بين المنافع والأضرار الناجمة عن العملية التي تطالب الإدارة بإجرائها.

- وأول هذه المعايير التكاليف المالية للعملية *cout Financier d'opération*، إذ يجب على القاضي الإداري أن يأخذ في حسبانته عند تقييم عملية ما، التكاليف التي ستتحملها الجهة المنفذة للمشروع وما إذا كانت هذه الجهة قادرة فعلا على التنفيذ من عدمه. فإن مشروعا ما قد يكون مثلا صالحا للتنفيذ على مستوى إقليم أو مدينة كبرى، حيث تستطيع الجهة القائمة على التنفيذ أن تتحمل بتكاليف إنشائه دون أن يصيبها إرهاب مالي؛ هذا المشروع قد لا يكون صالحا للتنفيذ في قرية صغيرة ذات موارد محدودة، حيث يسبب لها مثل هذا التنفيذ أعباء مالية تفوق قدراتها.

فالقاضي الإداري إذن لا يكتفى عند تقدير أو تقييم التكاليف المالية للمشروع بما قد ينفق على إنشائه فقط، وإنما يأخذ في حسبانته أيضا المقدرة المالية للجهة القائمة على التنفيذ. ولهذا فقد قضى الماء مشروع بإنشاء مطار *un aérodrom* في إحدى القرى عندما وجد أن التكاليف المالية اللازمة لهذا المشروع لا تتناسب البتة مع المصادر المالية لتلك القرية. فقد اعتبر أن ذلك من شأنه أن يسبب أضرارا للاقتصاد المحلي تفوق بكثير الفوائد التي قد تترتب على إنشاء المطار حيث يقول في هذا الحكم^(١).

"Le coût serait "hors de proportion avec les ressources Financières de la commune "

- ومن المعايير أيضا معيار حق الملكية الخاصة، إذ يقارن القاضي الإداري طبقا لهذا المعيار بين الأضرار التي يمكن أن تصيب هذا الحق

(1) C.E., 25 octobre, 1973, Grassin, Rec., P. 592.

نتيجة نزع الملكية وبين الفوائد التي قد تترتب على المشروع المزمع إقامته ، وعلى أساس ما يرجحه منها يصدر حكمة في الدعوى المنظورة أمامه، وهو ما فعله في خصوص القضية الشهيرة ville nouvelle est والتي سنبينها تفصيلاً فيما بعد، حيث انتهى في هذه القضية، بعد أن تحقق من أن مشروع إقامة منطقة جامعية للطلاب والذي يتطلب نزع ملكية عدد كبير من المباني المسكونة لا يتضمن اعتداء على حقوق الملكية الخاصة بأصحاب تلك المباني تفوق الفوائد التي قد تترتب على إقامة هذا المشروع، انتهى بعدم إلغاء قرار الإدارة بإعلان المنفعة العامة.

- وإلى جانب معيار - التكاليف المالية ومعيار حق الملكية الخاصة، هناك معيار آخر لا يقل أهمية في هذا الشأن، وهو معيار التكلفة الاجتماعية للمشروع، أو بمعنى أدق الآثار الاجتماعية التي قد يتسبب هذا المشروع في إلحاقها سواء بالأفراد أم بالبيئة، أم بإطار الحياة الاجتماعية بصفة عامة. ففي قضية تخلص وقائعها في صدور قرار بإنشاء طريق سريع autorout شمال مدينة نيس، لربط هذه المدينة وما يحيط بها من مناطق بدولة إيطاليا ، وكان من شأن هذا الطريق المقترح إزالة جزء من مستشفى خاص بالأمراض النفسية أو العصبية تعرف باسم Sainte Marie ، وكان المستشفى الوحيد بهذا التخصص في المنطقة. في هذه القضية وازن مجلس الدولة بين مصلحتين هما: المحافظة على الصحة العامة من ناحية، وإنشاء طريق سريع وما يترتب عليه من سهولة وسيولة في المرور من ناحية أخرى، ثم انتهى بترجيح المصلحة الأولى، ومن ثم إلغاء القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة، نظراً لما قد يترتب على هذا القرار من مضار ومساوئ تتمثل في هدم مبنى يحتوى على ٨٠ سريراً وحرمان المستشفى من المساحات الخضراء المحيطة بها وكذلك من أماكن انتظار السيارات ، تفوق

الفوائد المحتملة لإنشاء الطريق السريع^(١).

وترتبيا على ذلك يمكن القول إن مجلس الدولة يبحث كل حالة على حده ليوافق بين منافع العملية، والأضرار الناجمة عنها وذلك في ضوء مختلف المعايير السابقة . مما يعني أن أحكامه لا تأخذ دائما مسلكا واحدا، وإنما توافقت وبتفاوت ظروف ومعطيات المكان والزمان والإمكانات المادية والتكاليف الاجتماعية وغيرها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة غالبا ما تضع تسلسلا أو تدرجا للمعايير السابقة، أو بمعنى آخر ، لمختلف القيم التي تتضمنها تلك المعايير وذلك تبعا لتقديرها لمدى أهمية كل معيار منها ، بحيث يصبح هذا التسلسل أو ذلك التدرج بمثابة مرشد أو موجه لها عند اتخاذ قرار بإعلان المنفعة العامة.

وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كان القاضي الإداري يلتزم - عند نظر نزاع يدور حول تقدير مزايا وعيوب عملية ما - بهذا التسلسل أو ذلك التدرج والمعد سلفا من قبل رجل الإدارة.

لقد أجاب الفقيه S. Rials على هذا التساؤل بالنفي، إذ يرى أن القاضي الإداري لا يلتزم، بل ولا يجب عليه أن يلتزم بما تجرته الإدارة من تسلسل أو تدرج للقيم ، والذي على أساسه تتخذ قرارها بإعلان المنفعة العامة، وإنما عليه أن يطابق هذا التسلسل أو ذلك التدرج مع حقيقة الواقع الاجتماعي السائد في وقت نظر النزاع، ليقرر بعد ذلك (حسب عقيدته ومدى اقتناعه) أي من هذه المعايير أو تلك القيم يجب أن تكون له الأولوية، بحيث

(1) C.E, 20 oct., 1972 , Société civile sainte marie de l'assomption, Rec. P.657. concl. Morisot, A.J.D.A, 1972, P. 576; cabanes et léger, J.C.P., 1973 , 11 , 17475 , Note B. odent.

ينتهى هو ذاته بوضع تسلسل أو تدرج للمعايير والقيم التي يتخذها أساسا لتقدير وتقييم منافع ومضار عملية ما، ومن ثم إجراء الموازنة والترجيح بينها^(١).

فالعبارة إذن لا بما تدعيه الإدارة من تسلسل وتدرج للمعايير والقيم، وإنما بما يقرره القاضي تبعا لاقتناعه وعقيدته المستوحاة من حقيقة الواقع الاجتماعي، بأنه هو التسلسل أو التدرج الواجب الاتباع عند تقدير وتقييم قرارات الإدارة بإعلان المنفعة العامة.

وهكذا يوازن القاضي الإداري بين مزايا وعيوب قرارات الإدارة بإعلان المنفعة العامة تبعا للمعايير أو القيم التي يرى هو أنها تلائم حقيقة الواقع الاجتماعي، بحيث يقضى بإلغاء مثل هذه القرارات كلما رجحت لدية كفة العيوب والمساوي، بينما يقضى بصحتها إذا ما كانت كفة المزايا و الفوائد هي الراجحة.

ولكن متى تعتبر العيوب أو الأضرار سببا في إلغاء قرارات الإدارة بإعلان المنفعة العامة، أو العكس متى تعتبر الفوائد أو المزايا سببا في الحكم بصحة هذه القرارات؟ ولمزيد من الإيضاح يمكننا القول، هل القاضي الإداري يأخذ في اعتباره كل تفاوت بين المزايا والأضرار حتى ولو كان هذا التفاوت بسيطا أو محدودا؟

يقول André de laubadere في هذا الصدد أن رقابة الموازنة تباشر بذات الأسلوب أو النمط الذي تباشر به رقابة قرارات الضبط الإداري المحلي والتي أرسى مبادئها قضاء Benjamin السابق الإشارة إليه . إذ

(1) Extrait du Repertoire de contentieux administratif; paris, 1935, Tome 2, P.2.

طبقا لهذا القضاء يتم الحكم على مدى صحة الإجراء الضبطي بتقييم أمرين أساسيين:

الأول: الفوائد والمزايا المترتبة على قرار الضبط الإداري المحلي (الحيلولة دون الخطر الذي يتهدد النظام العام).

الثاني: الأضرار أو العيوب الناجمة عن هذا القرار (الاعتداء على حريات المواطنين).

بحيث لا يعتبر الإجراء الضبطي صحيحا إلا إذا كان من شأنه تحقيق توازن بين هذين الأمرين^(١).

ومعنى هذا القول أن القاضي الإداري يأخذ أو يجب أن يأخذ في اعتباره في خصوص قضاء الموازنة كما هو الحال في قضاء الضبط الإداري المحلي ، كل تفاوت ولو كان بسيطا بين المزايا والأضرار المترتبة على القرارات الصادرة في إطاره.

ومن جانبنا لا نتفق ورأى الفقيه الكبير Laubadère ، حيث نرى أن قياس قضاء الموازنة على قضاء Benjamin إنما هو قياس مع الفارق ذلك أنه في حالة الرقابة على قرارات الضبط الإداري المحلي لا يسمح القاضي الإداري بوجود أي تفاوت بين المزايا المترتبة على الإجراء الضبطي والأضرار أو العيوب الناجمة عنه. بمعنى أنه لا يتجاهل أولا يجب عليه أن يتجاهل في هذه الحالة أية اعتداءات يتسبب فيها الإجراء الضبطي على حريات المواطنين إذا لم تكن هذه الاعتداءات لازمة وضرورية لحماية النظام العام مما يتهدده من اضطرابات أو أخطار ؛ في حين أنه في حالة قضاء

(1) Le contrôle Juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans la Jurisprudence recente du conseil d'Etat Français ,in melanges waline, P. 531 etss.4

الموازنة، فإن القاضي الإداري لا يراقب كل تفاوت بين مزايا وعيوب مشروع الإدارة أو قرارها بإعلان المنفعة العامة ، وإنما فقط التفاوت الجسيم أو الواضح، أو بمعنى آخر لا يراقب سوى عدم التعادل المفرط أو المبالغ فيه بين المزايا والأعباء.

فالممنوع هنا إذن التفاوت الغير منطقي أو الغير معقول *Dérisonnable* أما إذا كان التفاوت مما يتقبله المنطق والعقل، امتنع على القاضي الإداري محاسبة الإدارة عما تتخذه من أنماط وأساليب، أو عما تجريه من اختيارات فحينما تفاضل الإدارة مثلاً بين عدة رسومات أو تخطيطات لإنشاء طريق سريع *une autoroute* فإن القاضي الإداري لا يتدخل في مثل هذا التفاضل أو الاختيار ، أي أنه لا يراقب ما اذا كان اختيار الإدارة لواحد من هذه الرسومات أو تلك التخطيطات يمثل الاختيار الأمثل أو الأفضل، فهذا مما يمتنع عليه طالما أنه اختيار غير مؤسس أو غير ناتج عن تقييم أخرق أو مخالف للصواب^(١).

وبمعنى آخر يمكن القول إن مجلس الدولة يترك للإدارة - من حيث المبدأ - سلطة تقديرية في اختيار مضمون قرار إعلان المنفعة العامة، إلا أنه يشترط عليها من ناحية أخرى أن تباشر هذه السلطة بشكل منطقي ومعقول *rationnelle*. بهذا يفرض عليها والحال هكذا التزاماً بضرورة تحكيم العقل والمنطق عال مباشرة سلطاتها التقديرية في اختيار مضمون وأنماط قراراتها الإدارية الخاصة بإعلان المنفعة العامة ، أو التزاماً بضرورة مراعاة التناسب بين المزايا والعيوب المترتبة على هذا المضمون أو تلك الأنماط^(٢).

(1) C.E., 22 Fev. 1974, Adam, R.D.P., 1975, P. 486.

(٢) وهو ما عبر عنه أحد الفقهاء الفرنسيين قائلاً:

المبحث الثاني

مجالات إعمال نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

نتناول في مطلب أول المجال الذي ظهرت فيه لأول مرة النظرية

"cette jurisprudence (Bilan) laisse subsister le pouvoir discrétionnaire dans le choix du contenu de la décision, mais exige qu'il en soit use de façon rationnelle; elle impose un usage raisonnable du pouvoir discrétionnaire de choisir le contenu ou les modalités des décisions administratives" Alain Bockel, op. cit. P.366.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن جانباً من الفقه المصري يري أنه لا علاقة بين مبدأ التناسب وبين نظرية الموازنة وذلك على أساس (أن مبدأ التناسب وإن كان من المبادئ القانونية العامة إلا أن مقتضاه وجوب مراعاة التناسب بين محل القرار وسببه، في حين أن مقتضى مبدأ الموازنة - وهو بدورة من المبادئ القانونية العامة - وجوب مراعاة عدم رجحان أضرار القرار الإداري، ولا علاقة لها البتة بعنصر السبب وعلي ذلك لا يسوغ الخلط بين مبدأ التناسب والتوازن. دكتور/ سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة...، مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٤. هذا القول لا يجد له في الواقع سنداً من المنطق أو القانون، ذلك أن مبدأ التناسب ليس قصراً على أمور بعينها وإنما هو مبدأ مطلوب في كل شيء فالتناسب مطلوب بين عيوب ومزايا مضمون محل القرار، والتناسب مطلوب كذلك بين أهداف أو غايات هذا القرار الإجراءات المتخذة لتحقيق هذه الأهداف أو تلك القضايا كما أنه مطلوب بين محل القرار وسببه... وهكذا ولذا لا ندري سبباً لتخصيص مبدأ التناسب وقصره على العلاقة بين محل القرار ومسببه وهذا ما أكدته مفوض الحكومة G.Braibant حينما قال:

Une analyse plus poussée conduit en réalité à considérer ' que la proportionnalité ne s'apprécie pas seulement en fonction de deux, éléments, les moyens et le but; il faut y ajouter la situation de fait à laquelle s'applique la décision administrative.... c'est donc à l'ensemble situation -décision- qu'on applique le principe de proportionnalité.

Le principe de proportionnalité, in melang Waline, P. 298.

التي نحن بصدددها وهو مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، ثم في مطلب ثان نبين المجالات الأخرى التي تطبق في خصوصها هذه النظرية.

المطلب الأول

نزع الملكية للمنفعة العامة ورقابة الموازنة

بين المنافع والاضرار

لقد كان مولد وظهور نظرية الموازنة - كما ذكرنا - في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة . وقد يرجع السبب في ذلك إلى ما لاحظته مجلس الدولة الفرنسي من أن الإدارة تتمتع في هذا المجال بسلطة تقديرية واسعة، لا سيما فيما يتعلق بتقرير وتحديد فكرة المنفعة العامة ؛ حيث لم يكن يحدها في هذا الشأن سوى عيب الانحراف بالسلطة أو عيب إساءة استعمال هذه السلطة؛ ذلك العيب الذي يتسم بطبيعته بصعوبة في الإثبات، خاصة في المجال الذي نحن بصددده وهو مجال نزع الملكية للمنفعة العامة . إذ من المعروف أن هذا العيب كما تقول المحكمة الإدارية العليا من العيوب القصدية في السلوك الإداري، فهو يشوب الغاية في ذاتها....^(١).

كما قد يرجع السبب في ظهور هذه النظرية في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة كذلك إلى ما لاحظته مجلس الدولة من أن فكرة المنفعة العامة ذاتها فكره مرنة تتسم بعدم التحديد أو بعدم الوضوح لدرجة أنها أصبحت مترادف - كما ذكرنا من قبل - فكرة المصلحة العامة، الأمر الذي أدى بالإدارة إلى استخدامها لا لصالح السلطات العامة فحسب وإنما أيضا لصالح

(١) حكمها الصادر في ٩ مايو ١٩٥٩، المجموعة، السنة الرابعة، ص ١٢٠٧؛ انظر نقد الدكتور/ سليمان الطماوي لهذا التعريف: القضاء الإداري، الكتاب، الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، ١٩٨٦، ص ٨٦٦ وما بعدها.

مصالح خاصة متى كانت هذه الأخيرة تؤدي إلى تحقيق منفعة عامة^(١).

من هنا فقد عمل مجلس الدولة على كبح جماح الإدارة في هذا المجال، خاصة بعد أن ازداد تدخل الدولة في المسائل الاقتصادية والعقارية، وذلك بأن ابتدع نظرية الموازنة ليبسط من خلالها رقابته القضائية على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، وكان ذلك مناسبة إحدى الدعاوى التي تخلص وقائعها في أن وزير التخطيط والإسكان أصدر بتاريخ ٣ أبريل سنة ١٩٦٨ بإقامة مجمع جامعي وآخر سكني لإقامة الطلاب خارج مدينة "ليل" الأمر الذي تطلب نزع ملكية عدد ٨٨ منزلاً، وما يقرب من ٥٠٠ هكتار من الأراضي.

لذلك فقد طعنت "جمعية الدفاع عن منازل السكان المراد نزع ملكيتهم" في القرار السابق بالإلغاء، مستندة في ذلك إلى التكاليف الباهظة للمشروع وما يؤدي إليه من نزع ملكية وإزالة هدد كبير من المنازل كان بعضها حديث البناء، بل إن بعضاً منها كان قد أقيم وفقاً لتراخيص بناء لم يمس عليها أكثر من عام.

وعلى أثر هذا الطعن قام مجلس الدولة ببحث كافة الجوانب المتعلقة بموضوع النزاع، وانتهى إلى صياغة نظريته الجديدة في الموازنة بين النفقات أو التكاليف التي ستترتب على المشروع وبين المزايا التي سيحققها، وذلك على النحو السالف بيانه. الأمر الذي لهدت معه سلطات القاضي الإداري في الرقابة على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة أكثر اتساعاً وتحريراً عن ذي قبل، حيث أصبح لا يكتفي بالنظر إلى المنفعة العامة التي يحققها قرار

(١) دكتورة/ نبيلة عبد الحليم كامل، دور القاضي في الرقابة على شروط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية (الاتجاه الحديث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا)، دار النهضة العربية، ١٩٩٣، ص ١٩.

نزع الملكية نظرة مجرة IN ABSTRACTO، وإنما نظرة موضوعية IN CONCRETO تسمح له بتقييم كافة المعطيات أو الظروف الموضوعية في الميزان والتي تحيط بتلك المنفعة.

وإعمالاً لهذه النظرية فقد انتهى المجلس في الدعوى السابقة إلى رفض الطعن حيث وجد أن الموازنة أو المعاييرة بين المنافع التي ستترتب على المشروع (إقامة مجمع جامعي وبناء سكني للطلاب) وبين المخاطر أو العيوب التي ستنتج عنه والمتمثلة في الاعتداء على الملكية الخاصة - التكلفة المالية التي يتطلبها المشروع - الأضرار الاجتماعية المحتملة له...؛ هذه الموازنة كانت لصالح المنافع أكثر من كونها لصالح المخاطر أو العيوب . ولذلك فقد قرر أن هذه المخاطر أو تلك العيوب ليس من شأنها أن تنفي عن المشروع سمة المنفعة العامة^(١).

وفي تعليقه على هذا الحكم والذي وضع لأول مرة - كما ذكرنا - مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار في مصاف المبادئ التي قررها القضاء لحد من سلطة الإدارة التقديرية يقول الفقيه waline : أن القاضي الإداري قد اعترف لنفسه بحق تقييم كافة مزايا وعيوب العملية التي تطالب الإدارة بها ، ووازن بينها بشكل أقرب إلى العملية الحسابية ، وأنه لم يعط الضوء الأخضر للإدارة إلا عندما تأكد أن العملية ذات رصيد إيجابي، أي أنه لم

(1) C.E,28 mai 1971, Ministre de l'équipement contre Fédération des personnes concernées par le projet "ville nouvelle est," p.409,concl.Braibant; Rev.dr.pub., 1972, P.454, note waline; A.J.D.A. 1971, P. 404,chron.jurispr.labetoulle et cabanes; D.1972, 194 note Jeanne Lemasurier ;J.C.P.1971, 11, No16873,note homont; Gilli, le rôle du juge administratif en matière d'expropriation A.J.D.A., 1973,p.73;de lanversin, le contrôle juridictionnel de l'utilité publique ,AJ.propriété immobilière, 1974,p.790;holleaux, la jurisprudence du Bilan,Rev.Adm., 1980, P.593.

يعطى لها هذا الضوء إلا عندما تبين له رجحان كفة أو جانب المزايا على كفة أو جانب العيوب والأضرار^(١).

فمجلس الدولة يقوم إذن بتطبيق مبدأ التناسب وذلك بالموازنة بين ما يتضمنه نزع الملكية من تكاليف ومساوئ اجتماعية وما يحققه المشروع من مزايا، فإن رجحت كفة المزايا فليس هناك محل للإلغاء ، وإذا رجحت كفة التكاليف والعيوب حتى المحتملة منها، فإن مجلس الدولة يلغى القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة.

ومن الدعاوى التي أصدر فيها مجلس الدولة أحكاما بإلغاء قرارات نزع الملكية لرجحان كفة العيوب على كفة المزايا نذكر على سبيل المثال ما يلي:

- دعوى ضد قرار صادر من الإدارة بنزع الملكية، بهدف إنشاء موقف سيارات حيث لم يتبين للمجلس أن ضرورات المرور بالقرية تبرر إنشاء مثل هذا الموقف^(٢).

- دعوى ضد قرار محافظ مدينة Dijon بتقرير المنفعة العامة على مساحة من الأرض بقصد إقامة مجمع إسكاني يتضمن فقط مجموعه من الفيلات، حيث تبين للمجلس أن المزايا التي سوف يحققها قرار المنفعة العامة محدود للغاية إذا ما قورنت بالأضرار الناجمة عنه، خاصة أنه لا توجد مشكلة إسكان في المنطقة^(٣).

(1) Mote Précité, P. 454.

(2) Exproportion destinée à un parc de stationnement alors" qu' il n'est pas établi que les nécessités de la circulation dans la commune justifient la creation" d'untel parc (C.E,16 janv.1976 Guillet Rec. P.946 ; C.E 11 mars 1981, Mmer wincent, Rec.p.770).

(3) C.E,17 Dec. 1980 ;T.adm.Nantes 29 nov.1984 Mme Demis, A.J.P.I., 1986, P.540.

- الدعوى السابق الإشارة إليها والمقامة ضد قرار محافظ مدينة نيس بإعلان المنفعة بهدف إنشاء طريق سريع شمال المدينة، حيث قدر أن المضار الناتجة عنه والتي تتضمن إلحاق ضرر ببعض المؤسسات الصحية، تفوق المزايا التي يمكن أن تترتب عليه.

فالقاضي الإداري يقوم إذن بتطبيق مبدأ التناسب من خلال إعماله لنظرية الموازنة، على كافة ما تثيره قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة من منازعات، للتحقق من مدى سلامة وصحة تلك القرارات، وذلك عن طريق إجراء مقارنة بين ما يتكلفه المشروع الذي ترغب الإدارة في إقامته (مع ملاحظة أن التكلفة هنا لا تتعلق فقط بالمسائل المالية وإنما أيضا بالمسائل الاجتماعية والبيئية وكذلك بحقوق الملكية الخاصة)، وبين المزايا التي تترتب عليه ليقرر بعد ذلك ما إذا كانت هناك فعلا منفعة عامة تبرر إجراءات منع الملكية.

المطلب الثاني

المجالات الأخرى التي تطبق فيها نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

إذا كان مجال نزع الملكية للمنفعة العامة هو المجال الذي يستأثر بمعظم أحكام مجلس الدولة الخاصة بقضاء الموازنة، إلا أنه لا يمثل مع ذلك المجال الوحيد لتلك الأحكام، إذ هناك في الواقع مجالات أخرى عديدة طبق فيها مجلس الدولة هذا القضاء. ومن أهم هذه المجالات تلك المتعلقة بالتخطيط أو التنظيم العمراني، وعلى وجه الخصوص المجالات الخاصة بتراخيص المباني التي تصدر بالمخالفة أو على سبيل الاستثناء "Dérogation" من قواعد هذا التخطيط أو ذلك التنظيم.

وقبل أن نبين كيف يباشر مجلس الدولة قضاء الموازنة في هذه المجالات، تجدر الإشارة إلى أن مسألة تخطيط أو تنظيم المدن "L'urbanism" أمر يتسم أو يجب أن يكون متسماً بالمرونة وعدم الثبات حتى يكون دائماً متلائماً، أو قادراً على التكيف مع ما قد يحدث في المجتمع من تطورات أو تغيرات اجتماعية واقتصادية وبيئية أو غيرها. ومن ثم يمكن القول أنه إذا لم تكن القواعد القانونية التي تحكم هذا التخطيط أو ذلك التنظيم متسمة بالمرونة في التطبيق ، فإنها تصبح حجر عثرة أو عائقاً أمام هذا التلاؤم أو ذلك التكيف.

هذه المرونة لا تتحقق في الواقع إلا إذا أجازت القواعد القانونية ذاتها والخاصة بتخطيط أو تنظيم المدن إمكانية مخالفتها أو الخروج على مقتضياتها إذا ما كان ذلك أمراً لازماً وضرورياً، وهو ما نلاحظه في الواقع العملي إذ يندر أن نجد قواعد قانونية من هذا النوع لا تتضمن مواداً أو نصوصاً تسمح للإدارة بملاءمة خطة تنظيم المدينة مع كافة التغيرات أو الاحتياجات الاجتماعية وذلك عن طريق ما يسمى "الإجراء الاستثنائي" "Le procédé de la dérogation".

هذا الإجراء الاستثنائي يصبح والحال هكذا من إطلاقات الإدارة حيث تباشره بحرية تامة وطبقاً لما تتمتع به من سلطة تقديرية ، خاصة أن النصوص التي تقرره غالباً ما تكتفى بإقراره دون أن تضع شروطاً محدده لمنحه أو لمنعه تاركة مطلق الحرية في ذلك للإدارة . بل وفي حالة وضع مثل هذه الشروط ، فإنها تضعها بصورة إجمالية أو فضفاضة بحيث تترك للإدارة أيضاً سلطة تقديرية واسعة لبيانها أو تحديدها ، الأمر الذي ينفى معه إمكانية إجراء رقابة قضائية دقيقة وفاعلة في هذا المجال.

ولذلك وحتى لا تتقلب أو تتحول مثل هذه الحرية المتروكة للإدارة

إلى إجراء تعسفى أو تحكمى، فإن القضاء الإداري حرص على البحث عن وسيلة يحد بها من سلطة الإدارة التقديرية في هذا الشأن وهو غالبا ما يجد نفسه في هذه الحالة مواجهها بأمرين متناقضين أو يبدوان على الأقل من حيث الظاهر كذلك:

الأمر الأول: مصلحة الأفراد أو الفرد الذي يطالب بتمتعته بالاستثناء من قواعد التنظيم العمراني، وهي مصلحة تجسد في واقع الأمر حق الملكية الخاصة الواجب حمايته من قبل القضاء.

الأمر الثاني: مصلحة كافة المواطنين في تنظيم عمراني معين، وهي مصلحة تتضمن ضرورة الاعتراف بحق هؤلاء المواطنين في التمتع ببيئة حضرية ملائمة ، أو بمستوى معين من الحياه الاجتماعية في هذه البيئة.

إن الوسيلة القضائية المشار إليها تمثلت بادئ ذي بدء في مجال الإثبات، إذ كان القاضي الإداري يطلب من الإدارة في هذه الحالة ضرورة الافصاح عن الأسباب التي استندت إليها لمنح أو رفض الإجراء الاستثنائي لقواعد التنظيم العمراني ، بحيث يمثل عدم إجابة الإدارة على هذا الطلب، أو عدم إتيانها بأسباب منطقية، حجة عليها، مما يعني - بمفهوم المخالفة - أن إدعاءات طالب لإجراء الاستثنائي تصبح متحققة أو يجب أن ينظر إليها كذلك *Les allégations des requérants Doivent être regardées comme établies*، مؤكدا في هذا الصدد أن كل إجراء استثنائي يجب أن يؤسس على أسباب مستمدة من التشريعات التي تحكم التخطيط أو التنظيم العمراني^(١).

(1) C.E, 26 juin, 1987, M. Moulis, A.J.D.A., 1988. p.69; C. BLUMANN, le contrôle juridictionnel des dérogations en matière d'urbanisme, R.D.P., 1957, P.34 .

"Toute dérogation doit être Fondée sur des motifs tirés de la législation d' urbanisme"

ولهذا يلاحظ أن القاضي الإداري في حالة عجز الإدارة عن الإفصاح عن أسباب منح أو رفض الإجراء الاستثنائي لقواعد التنظيم العمراني، إنما يقوم من تلقاء نفسه بفحص كافة تلك القواعد والتي لم تحدد بشكل دقيق الشروط المبررة للإجراء الاستثنائي، ويستخلص منها هذه الشروط والتي يطلق عليها - كما ذكرنا من قبل - الشروط القضائية لمباشرة السلطة الاستثنائية *Les onditions jurisprudentielles de l'exercice du pouvoir dérogatoire*.

وهكذا يمكن القول أن دور القاضي الإداري في هذا الخصوص ومدى حرصه على ألا تكون سلطة مخالفة قواعد التنظيم العمراني - إلا لأسباب مستمدة من التشريعات العمرانية ذاتها - إنما يشكل في واقع الأمر قيداً يحذب ه من حرية الإدارة العامة حينما تباشر سلطتها التقديرية في هذا المجال^(١).

ومع ذلك يلاحظ أن هذا الدور والذي التزم فيه القاضي بالتفسير الجامد للسبب القانوني أو الشرعي الذي يجب أن يؤسس عليه الإجراء الاستثنائي لم يعد يتلاءم والواقع العملي لسياسات التنظيم العمراني ، خاصة وأن المنفعة العامة التي كان يحاول الوصول إلى إثباتها أو الوقوف على كنهها ، غالباً ما تكون منفعة مجردة وليست حقيقية أو واقعية ، ولهذا فقد بدأ في البحث

(1) D.labetoulle ,le povuir discrétionnaire en matière d'urbanisme et d'interventionnisme économique ,in " la pouvoir diserétionnaire et le juge administratif ,cahiers de l' I.F.S.A. éd. .cujas, No16, 1977, P.33.

عن وسيلة أخرى يحد بها من سلطة الإدارة التقديرية في هذا المجال. وسيلة تتلاءم مع المتطلبات العصرية للسياسة العمرانية أو الحضرية.

هذه الوسيلة تمثلت في وضع نموذج قضائي Standard Jurisprudential ويلجأ إليه كلما التزم المشرع بالصمت ، أو لم يرغب في الإفصاح عن إرادته في مجال التنظيم العمراني . هذا النموذج وهو ما سبق له تطبيقه في المجالات السابقة إنما يتمثل في "نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار".

فقد طبق القاضي الإداري هذه النظرية في مجال الإجراءات الاستثنائية لقواعد التنظيم العمراني ، كقيد أمثل يحد به من سلطة الإدارة التقديرية في هذا الشأن. وقد كان ذلك بمناسبة إحدى الدعاوى القضائية المعروضة عليه، والتي تتطلب منه ضرورة بحث ورقابة مدى المنفعة العامة المعلنة من قبل الإدارة لإجراء استثنائي معين . ففي هذه الدعوى والمعرفة باسم دعوى مدنيه ليموج Ville de Limoges انتهى القاضي إلى وضع مبدأ هام يتمثل في أنه لا يمكن السماح قانوناً بأي إجراء استثنائي على قواعد التنظيم العمراني، إلا إذا كانت الأضرار التي يلحقها هذا الإجراء بالمنفعة العامة والتي تحميها هذه القواعد، ليست مفرطه أو مبالغ فيها ، وذلك بالنظر إلى المنفعة العامة التي يرتبها الإجراء الاستثنائي ذاته^(١).

"Une dérogation aux règles prescrites par un règlement d'urbanisme, ne peut légalement être autorisée que si les atteintes qu' elle porte à l'intérêt général, que ces prescriptions ont pour objet de protéger, ne sont pas

(1) C.E, 18 juil, 1973, Ville de limoges, Rec., P.530, R.D.P., 1974, P.262 not waline.

excessives eu égard à l'intérêt général que presente la
Dérogation"

ومعنى ذلك أن القضاء الإداري يفترض في هذه الحالة أن هناك
منفعتين عامتين، تكونان في الغالب متعارضتين : المنفعة التي ترمي إليها
قواعد التنظيم العمراني ، والمنفعة التي يرمي إليها الإجراء الاستثنائي. وهنا
يجب ألا يمنح هذا الإجراء - من حيث المبدأ - لتحقيق مصلحة أو منفعة
خاصة لصاحب الشأن فحسب، بل يجب إضافة إلى ذلك أن تكون الأضرار
التي يترتبها على المنفعة العامة والتي تحميها القواعد الأولى أقل بكثير من
الأضرار التي ستترتب، إذا تم رفضه من جانب الإدارة.

وهكذا يتضح لنا مدى حرص مجلس الدولة على الحد من سلطة الإدارة
التقديرية في المجال الذي نحن بصددده ، إذ عن طريق تطبيق نظرية
الموازنة بين المنافع والأضرار ، يؤكد دوماً أن الإجراء الاستثنائي لقواعد
التنظيم العمراني لا يمكن أن يمنح إلا إذا أظهر رصيذا إيجابيا لصالح
المنفعة العامة. ولهذا فقد قضى بأن بناء فندق من ثلاثة غرفه على أساس
من إجراء استثنائي لقواعد التنظيم العمراني ، في وسط مدينة ليس بها
فنادق، تحقق منفعة عامة أكثر من تلك التي يحققها إعداد أو تهيئة تسعة
مواقف سيارات تتضمنها خطة التنظيم العمراني لهذه المدينة^(١).

وعلى النقيض من ذلك فقد قضى بأن تفاقم المضار الناجمة عن
عملية توسيع مصنع على المناطق المجاورة ، يجعل تلك العملية خير محقة،
للمنفعة العامة وذلك على الرغم من الفوائد التي قد تنتج عنها لسكان هذه

(1) C.E., 8 dec. 1976,Ministre de l'equipement ,Rec.p.538 ;27
juil., 1979,confiserie azurienne ,R.D.P., 1980, P.255

المناطق^(١).

ومن المجالات الأخرى التي طبقت فيها نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار مجالات حماية البيئة. اذ يلاحظ أن القاضي الإداري لا يتردد في تطبيق هذه النظرية على الإجراءات التي تتخذها الإدارة في تلك المجالات وذلك تطبيقاً للقانون الصادر عام ١٩٧٦ الخاص بحماية الطبيعة^(٢). فقد نص هذا القانون ليس فقط على حق كل فرد في الطبيعة ، وإنما أيضاً على واجب كل فرد في السهر من أجل حماية هذه الطبيعة أو الإرث الطبيعي Partimoine naturel الذي يعيش في كنفه، مما يعني أنه يرمى إلى ضرورة التوفيق بين المصلحة الفردية أو الخاصة ومصلحة الجماعة ككل أو المصلحة العامة لأفراد المجتمع.

ولهذا فإن القاضي الإداري يبحث من خلال إعمال نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار عما إذا كانت الإجراءات التي ترغب الإدارة في اتخاذها أو التي اتخذها بالفعل لحماية الطبيعة أو ذلك الإرث الطبيعي تحقق التوازن بين الحق والواجب المشار إليهما، أو بين المصلحة الفردية أو الخاصة ومصلحة الجماعة ككل . بمعنى آخر يبحث فيما إذا كانت الأضرار أو التكاليف المترتبة على تلك الإجراءات تتجاوز بشكل مفرط المزايا أو الفوائد الناجمة عنها لحماية الطبيعة أو الإرث الطبيعي مما قد

(1) C.E., 20 oct. 1976, Le grand, R.D.P., 1977, P. 893; 15 dec. 1976, A.J.D.A., 1978, P. 172, Note L. Balmond et Y. Luchaire.

(٢) تم تعديل هذا القانون في ١٢ يولية ١٩٨٣ يقصد إعادة تنظيم إجراءات حماية البيئة وجعلها أكثر فعالية لمواجهة المتغيرات التي طرأت في هذا المجال. الجريدة الرسمية الصادرة في ١٣ يولية ١٩٨٣، ص ٢١٦. حول هذا القانون وتعديلاته انظر:

L'environnement J. Caillosse, enquete publique et protection de, A.J.D.A., 1987, P. 484.

يؤثر سلباً على الحق المقرر للأفراد في الملكية الخاصة لكل منهم^(١).

إضافة إلى المجالات السابقة، فقد طبق مجلس الدولة نظرية الموازنة كذلك على القرارات الصادر بالاستيلاء على العقارات للمنفعة العامة . ففي حدث حكم حديث نسبي ، قضت المحكمة الإدارية لمدينة نيس بأن الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية أو بالمساحات الخضراء نتيجة إقرار المجلس المحلي للمدينة خطة عامة للاستيلاء على هذه الأراضي وتخصيصها للإسكان المستقبلي، ولإنشاء نادي رياضي وكذلك لإقامة بعض المؤسسات ذات النفع العام ، ليست أضراراً مبالغاً فيها أو مفرطة مقارنة مع الفوائد أو المنافع التي ستعود على سكان المدينة من جراء تنفيذ تلك الخطة^(٢).

هذه هي معظم المجالات التي طبق فيها مجلس الدولة الفرنسي نظريته الحديثة في الموازنة بين المنافع والأضرار، وكما رأينا فإن مجلس الدولة لا يقضى لصالح قرارات الإدارة الصادر في تلك المجالات ، إلا اذا كانت الفوائد أو المنافع المترتبة عليها تفوق الأعباء والتكاليف الناجمة عنها، مع ملاحظة أن القاضي الإداري يأخذ في اعتباره عند تقييم هذه المنافع أو تلك الأعباء كافة المعطيات والظروف المحيطة بالقرار محل الطعن، تماماً

(1) C.E., 8 Juill.1977,Dame Rie et autres, R.D.P.,1977 p.1180, note M. Auby.

(2) T.A. de Nice, 17 dec. 1987, Rev., Fr. Droit adm. 6 (2), 1992, P. 247.
تقول المحكمة في هذا الحكم:

"qu, ainsi, en classant en zones constructibles ou d'urbanisation future des terrains situés dans la plaine du var et dont la superficie est somme toute limitée, en dépit des inconvénients qui peuvent en résulter pour l'agriculture, le plan d'occupation des sols de la ville ne porte pas aux intérêts et activités agricoles une atteinte excessive en considération de l'ensemble des intérêts généraux que le règlement a pour objet de préserver; qu' au nombre de ces derniers, Figurent notamment les activités sportives".

كما يفعل في حالة رقابته للخطأ البين كما بينا من قبل.

ولهذا يثور التساؤل هنا حول أوجه الشبه أو الاختلاف بين هذين النمطين من أنماط الرقابة التي يباشرها قاضي تجاوز السلطة للحد من سلطة الإدارة التقديرية؟

هذا ما نبينه فيما يلي.

المبحث الثالث

الموازنة بين المنافع والأضرار ورقابة الخطأ البين

رغم أن كلا من هذين النمطين من أنماط الرقابة القضائية يندرج - كما أوضحنا من قبل - في إطار التطور الذي أصاب تلك الرقابة ، ورغم أن نظرية الخطأ البين أصبحت على عكس نظرية الموازنة ، نظرية عامة حيث تطبق في كافة المجالات التي تثار في خصوصها منازعات إدارية، في حين أن نظرية الموازنة لم تصل بعد إلى هذه العمومية في التطبيق ، نقول رغم ذلك إلا أن جانبا من الفقه الإداري يرى أنه لا فرق بينهما على أساس أن مجالات أعمال كل منهما متطابقة ومن ثم فإن يمكن - كما يقول أنصار هذا الرأي - أن يحل النزاع المعروض على القاضي الإداري طبقا لهذه النظرية أو تلك^(١).

ويعبرون عن ذلك كما يلي:

"Que leurs champs d'application respectifs coïncident, et par suite que l'on suggère que l'une ou l'autre pourraient aussi bien résoudre une affaire posée "

بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بضرورة التمييز بين كل من نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ونظرية رقابة الخطأ البين، على أساس أن النظرية الأولى تتعلق فقط بمشروعية العمل الإداري لا بملاءمته، فهي رقابة للتكييف القانوني للمنفعة العامة، في حين أن نظرية

(1) Waline, le rôle du juge administratif dans la détermination de l'utilité publique justifiant l'expropriation, in Mélange waline, p.811; R.Hostiou, note sous C.E, 5mars 1976, tarlier, A.J.D.A., 1976, P. 211.

الخطأ البين تتعلق برقابة التقييم الذي تجريه الإدارة بما لها من سلطة تقديرية، أي أنها تتعلق بملاءمة العمل الإداري لا بمشروعيته^(١)، ويعبرون عن ذلك كما يلي:

La technique du bilan constitue un contrôle de la qualification juridique de l'intérêt général, alors que le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation intervient dans l'examen de l'appréciation discrétionnaire de l'administration.

نبين إذن فيما يلي كل من هذين الاتجاهين الفقهيين ثم نرد فهما برأينا في الموضوع.

المطلب الأول

التقارب أو التشابه بين النظريتين

Convergence de deux constructions juris prudentielles

ذهب جانب من الفقه إلى القول^(٢) بأنه إذا كانت هناك محاولة للترقية أو التمييز بين النظريتين المشار إليهما، فإن هذه المحاولة قد انتهت عملاً إلى الخلط بينهما، ومن ثم إلى إحداث نوع من الغموض أو اللبس حول طبيعة أو كنه كل منهما.

من هنا يرى - أنصار هذا الرأي - ضرورة تجنب مثل هذه

(1) M. GUIBAL, De la proportionnalité, A.J.D.A., 1978, p.485 et ss. j.de LANVERSIN, le contrôle juridictionnel de l'utilité publique, tentative d'explication d'un renouvellement jurisprudentiel A.J.P.I., 1974, P.790,

(2) Lemasurier (J.) note sous C.E; 28 mai 1971, D, 1972. P, 194; waline (J.) le rôle du juge administratif dans la détermination de l'utilité publique justifiant l'expropriation, mélanges wiline, 1974, P.822.

المحاولة، والنظر إلى كل من نظرية الموازنة والخطأ البين على أنهما من طبيعة واحدة ويؤديان وظيفه مشتركة لدرجة أنه يمكن أن تحل كل منهما محل الأخرى، أو يستعان بها معا ، للحد من تجاوزات سلطة الإدارة في المجالات الإدارية.

On considère la fonction de l'un comme un moyen substitutif à l'autre, ou encore que l'un concourt à l'autre de manière que les deux agissent à la Fois pour limiter les excès de pouvoir de l'administration.

ويدلل هذا الجانب الفقهي على وجهة نظره بحجتين أساسيتين:

الحجة الاولى: وحدة مجال وتكنيك التطبيق لكل من النظريتين:

فمن ناحية يرى أنصار هذا الاتجاه أنه لا اختلاف في المجال الذي تباشر فيه كل من نظرية الموازنة ونظرية الخطأ البين، حيث تطبق كل منهما في مجال السلطة التقديرية للإدارة ، أي تطبق على القرارات التي تتخذها الإدارة بما لها من سلطة تقديرية^(١).

Les deux juris prudences concernent... des decisions administratives prises en vertu d'un pouvoir discrétionnaire.

ومن ناحية أخرى يرون أن التكنيك الذي تباشر به كل من النظريتين لا اختلاف فيه حيث تباشران ليس فقط الرقابة كيفية ممارسة الإدارة لهذه السلطة التقديرية وإنما أيضا لرقابة التقدير الذي تجريه الإدارة في ذاته مع ما يتضمنه ذلك من إمكانية إحلال القاضي الإداري لتقديره محل

(1) A. de laubadère, le controle juridictionnel....art.précité, P. 538.

هذا التقدير الأخير^(١).

الحجـه الثانيـة: قيام النظريـتين على أساس من فكرة مشتركة:

ومؤدى هذه الفكرة والمستوحاة من الفقه الإنجليزى، أن للإدارة "حقاً في الخطأ Droit à l'erreur"، بمعنى أن للإدارة ، حينما تباشر سلطاتها التقديرية، الحق في أن تخطئ في تقييمها أو تقديرها ، ولكن يشترط لذلك ألا تتجاوز بهذا الحق حدوداً معينة، الأمر الذي يعني أن كلا من نظرية الخطأ البين ونظرية الموازنة، يشتركان في أنهما يسمحان للإدارة بقدر من الخطأ ولكن في حدود معينة هذه الحدود تكمن فيما يسمى "لجلاء" أو "البدهة" L'évidence^(٢).

وهنا يثور التساؤل حول معيار هذا الجلاء أو تلك البدهة، أو بمعنى آخر حول معيار الخطأ الجلى أو الخطأ البديهي والذي بدونه لا يصلح لا الخطأ البين طبقاً للنظرية الأولى ولا الموازنة السلبية طبقاً للنظرية الثانية، لأن تكون سبباً للإلغاء.

لقد سبق لنا تناول هذه المسألة تفصيلاً، ولكن نظراً لارتباطها بالموضوع الذي نحن بصدد، فإننا نوجز الإجابة على هذا التساؤل بالقول إن الفقه لم يحاول البحث عن هذا المعيار مكتفياً بالقول بأن على القاضي الإداري أن يراقب في مثل هذه الحالات التجاوزات التي تقتربها الإدارة حين مباشرة سلطاتها التقديرية والتي قد تبدو أو تتجسد في: Demesure

(١) وفي هذا يقول الفقيه Laubadère في مقالته السابقة، ص ١٤٠، ص ١٤١:

dans le cadre des deux jurisprudences... et dans les cas où il en est fait application à des décisions prises en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, le contrôle du juge porte sur l'exercice même de ce pouvoir...et selon la formule bien connue ,le juge se reconnait là le droit de substituer son appréciation à celle de l'administrateur.

(2) Lemasurier (J.) art. Prec., P. 194.

- اللامعقولية - Deraisonable - الافراط الشديد Excessif ...ألخ.

وبهذا ينتهي أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن رقابة القاضي الإداري في كلتا النظريتين تتجسد في البحث عن السلوك المعقول Le comportement raisonnable ، في تصرفات الإدارة، لا فرق في ذلك بين هذه النظرية أو تلك.

ومما يدعم هذا القول - يضيف أنصار الاتجاه الذي نحن بصدد - أنه يلاحظ، أن هناك تردداً في معظم القضايا التي تثار أمام مجلس الدولة حول ما إذا كان على القاضي الإداري أن يحكم في النزاع المعروض عليه طبقاً لنظرية الخطأ البين أم طبقاً لنظرية الموازنة.

ففي قضية Vill nouvelle est نجد أن مفوض الحكومة Braibant يقترح على مجلس الدولة أن يقضى في النزاع المعروض طبقاً لنظرية الخطأ البين، في حين أن مجلس الدولة انتهى إلى الحكم في هذا النزاع طبقاً لنظرية الموازنة^(١). بل وفي قضيته Ville De limoges ، يلاحظ أن مفوض الحكومة Rougevin - Baville كان متردداً في المطالبة بالإلغاء على أساس نظرية الموازنة، قائلاً أنه لا يرغب في أن يضيف إلى التعسف الإداري تعسفاً آخر من جانب القاضي^(٢).

qu'on n'ajoute pas à l'arbitraire de l'administration un arbitraire a posteriori du juge.

(1) Note de j lemasurier sur l'arrêt ville nouvelle est op.cit.p.194; notion d'utilité publique, contrôle de juge de l'excès de pouvoir, chronique de jurisprudence de labetoulle et cabanes, A.J.D.A, 1971, P.405.

(2) Concl. sur ville de limoges, précitées.

وفي عام ١٩٧٩ يشير La betoulle مفوض الحكومة في تعليقه على حكم Commun De Bouchemaine ، أن مجلس الدولة يلجأ أحيانا إلى رقابة الخطأ البين وأحيانا أخرى إلى رقابة الموازنة وذلك في دعاوى متشابهة إلى حد ما^(١). إضافة إلى ذلك فإن المحكمة العليا قد قضت في منازعات مما يدخل أساسا في إطار نظرية الموازنة كالتقييم المالي للمنفعة العامة^(٢)، واختيار مكان عملية نزع الملكية^(٣)، على أساس من نظرية الخطأ البين؛ الأمر الذي يؤكد أن التقارب بين النظريتين قائم ويصعب بالتالي التفريق أو التمييز بينهما . فالاختلاف بينهما إذن وكما يذهب أنصار الاتجاه الذي نحن بصددده هو اختلاف في الدرجة وليس اختلاف في الطبيعة، لأن القاضي لا يلغى - وفقا لنظرية الموازنة - القرار المطعون فيه إلا إذا كانت الأضرار المترتبة عليه لا تتناسب بشكل واضح مع المزايا أو المنافع الناجمة عنه وهذا هو جوهر نظرية الخطأ البين.

وهكذا يخلص هذا الاتجاه إلى القول بأن كل من نظرية الخطأ البين ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ، باعتبارهما أنماطا رقابية تهدف أساسا إلى حث الإدارة على ترشيد وعقلنة أعمالها في مختلف المجالات، ليستا نظريتين متميزتين كل منهما عن الأخرى ، كما أنهما ليستا نظريتين متعارضتين^(٤).

(1) Concl sur l'arret du 23 mars 1979, Rec.p.129.il dit: "Le conseil d'Etat a manirecours tantôt à la technique du bilan, tantôt á celle de l'erreur feste, dans des affaires à peu près comparables".

(2) C.E,19 Janv.1983, ministre de l'agriculture c./Rousselot.t. P.617; 20 juin1984, F.F.S.P.N. Rec. P.235.

(3) C.E,9 avr.1975, Meyer, T.P,1085; 24 oct.1984, ministre du temps libre C./C.I. du domaine de sermaize, Rec. P.336.

(4) M. Guibal, De la proportionnalité, A.J.D.A.,1978, P.485.

"erreur manifeste et bilan:coût-avantages,ne se distinguent pas nettement et, en tous cas,ne s' opposent pas"

المطلب الثاني

التباعد بين النظريتين

Divergence de deux constructions

Jurisprudentielles

يفرق أنصار هذا الاتجاه بين كل من نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ونظرية الخطأ البين على أساس طبيعة الرقابة التي تتيحها كل منهما للقاضي الإداري. إذ يرون أن النظرية الأولى إنما تتعلق برقابة le contrôle de légakité des الأعمال الإدارية .actes administratifs.

في حين أن نظرية الخطأ البين تتعلق برقابة الملائمة le contrôle de l'opportunité لتلك الأعمال.

ويستندون للقول بأن رقابة الموازنة تندرج في إطار رقابة المشروعية على أن هذه الرقابة تجسد رغبة القاضي الإداري في التحقق من مطابقة أو ملائمة مدى سلطة الإدارة في التقدير أو التقييم ، مع رغبة وإرادة المشرع ، إذ يحاول القاضي الإداري . كلما عرض عليه نزاع مما يدخل في إطار تلك النظرية . أن يستخلص أولا الروح السائدة "esprit dominant" للقاعدة القانونية التي تبين أو تحدد هذا المدى. ولهذا فإنه يعمل جاهدا ، قبل أن يتعرض للنزاع المطروح للوقوف على الإرادة المعلنة أو الضمنية للمشرع في هذا الخصوص، مستخدما في ذلك معيارا قانونيا هو ما يطلق عليه "الموازنة

بين المنافع والأضرار^(١).

وهكذا . يضيف أنصار هذا الاتجاه . فإن القاضي الإداري ببنائه لتلك النظرية، قد وضع معيارا أو قاعدة قانونية من خلقه يباشر على أساسها رقابة التكييف القانوني للمنفعة العامة^(٢).

"c'est ainsi qu'en élaborant des règles jurisprudentielles, sous la forme du standard u Bilan, le juge procède à une qualification de l'intérêt general".

تلك الرقابة التي تعد والحال هكذا، رقابة مشروعية.

ولمزيد من الإيضاح يمكن القول إن أنصار هذا الاتجاه يذهبون إلى أن رقابة الموازنة، إنما تتدرج في إطار رقابة المشروعية استنادا إلى الدور الذي يباشره القاضي الإداري في هذه الحالة، حيث يرون أن هذا الدور لا يتجاوز مجرد ضبط أو تحديد مفهوم المنفعة العامة، تلك المنفعة التي تعد معيارا لشرعية كافة الأعمال الإدارية المستندة إليها كالأعمال المتعلقة بنزع الملكية مثلا أو بإجازة المخالفة لخطة التنظيم العمراني، أو بأعمال الاستيلاء... وغيرها . ذلك أن مفهوم المنفعة العامة هذا إما أن يكون محددا بدقة من قبل المشرع ومن ثم ينعدم كل دور للقاضي الإداري في هذا الشأن، وإما ألا يكون كذلك ، أي مصاغا بشكل عام أو متسع en terme très vagues، مما يضيف عليه طابعا من المرونة والاتساع، الأمر الذي يتطلب في حالة النزاع حوله، ضرورة تدخل القاضي الإداري لضبطه وتحديده .

(1) J. de Lanversin, op. cit., P. 792.

(2) L. di qual, competence liée, L.G.D.J., Pais, 1944, p 128.

وهنا تبدو أهمية نظرية الموازنة، حيث يلجأ إليها القاضي الإداري لهذا الغرض، إذ عن طريق مقارنته بين التكاليف والأعباء لعملية ما و بين المنافع والمزايا المترتبة على تلك العملية، يستطيع أن يقرر ما إذا كانت هناك منفعة عامة من عدمه.

إن قرار القاضي الإداري أو نتيجة بحثه لهذه المسألة تعد والحال هكذا بمثابة معيار قانوني يقاس على أساسه أو يقارن به التكييف القانوني الذي أسبغته الإدارة على قراراتها. أو بمعنى آخر يعد بمثابة قاعدة مرجعية تتيح له مباشرة رقابة التكييف القانوني للوقائع المبررة للعمليات العقارية، ليقرر بناء على ذلك مدى شرعية أو عدم شرعية هذا التكييف.

فموازنة القاضي الإداري بين المنافع والأضرار على هذا النحو تعد شرطاً لمشروعية القرار الإداري بإعلان المنفعة العامة؛ ومن ثم فإن رقابته هنا - كما يقول أنصار الاتجاه الذي نحن بصدد - إنما هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة، خاصة أنه لا يحل محل الإدارة في اتخاذ القرار الملائم في هذا الشأن، وإنما يعيد الأمر إليها لإعادة التقدير مرة أخرى؛ فهو لن يفرض على الإدارة أن تبني حاجتها من العقارات في شمال المدينة أو غربها، ولن يجبرها على أن يمر الطريق في هذا الاتجاه أو ذاك، أو عبر منطقة معينة بذاتها، ولن يشير عليها بنزع ملكية قطعة أخرى محددة من الأرض بدلا من المتنازع عليها، وبذلك فإنه سيحتفظ للإدارة، رغم حكمه بإلغاء القرار الإداري، بسلطانها التقديرية في هذا الشأن... ويبقى مؤكداً بالتالي أن هذه النظرية تزود القضاء الإداري بسلاح فعال لحماية المشروعية^(١).

(1) J.P. Gilli, le rôle du juge administratif en matière d'expropriation, A.J.D.A., 1973, P. 15.

بل ويعيب الأستاذ di qual على العديد من المعلقين والفقهاء الذين وصفوا رقابة الموازنة بأنها رقابة ملائمة، مشدداً على أن الفكرة تتطلب مزيداً من الفهم والإيضاح ، حيث تتسم ببعض التعقيدات التي يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الفهم الصحيح للمشاكل الإدارية، وعلى كيفية إجراء الرقابة القضائية عليها^(١).

خلاصة هذا الاتجاه إذن تكمن في أن الرقابة القضائية للأعمال الإدارية من خلال نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، إنما تتدرج في إطار الرقابة على المشروعية، حتى وإن كان للقاضي الإداري، بناءً على تلك النظرية، دور في بحث مدى الملاءمة في محل القرار الإداري ، ذلك أن مثل هذا البحث - كما يذهب البعض - ليس سوى وسيلة للتأكد من مشروعية قرار إعلان المنفعة العامة بمطابقته لمبدأ الموازنة باعتباره من المبادئ القانونية العامة التي تلتزم الإدارة باحترامها وإلا بات قرارها المخالف لأي منها غير مشروع^(٢).

المطلب الثالث

راينا في الموضوع

إذا كان الاتجاه الأول قد أصاب عندما أشار إلى أن هناك تقارباً أو تشابهاً بين كل من نظرية الموازنة بين النافع والأضرار، ونظرية الخطأ البين، على أساس أنهما يتعلقان برقابة ملائمة العمل الإداري ، أو أنهما

دكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٢٣٧.

(1) "la notion appelle quelques précisions, car elle révèle une complexité qui la rend extrêmement dangereuse pour la compréhension claire des problèmes administratifs et de leur contrôle juridictionnel" op. cit., P.128.

(٢) دكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٢٣٦.

يطبقان معا في مجال السلطة التقديرية للإدارة، وبأنهما يشكلان كذلك سياسة جديدة في مجال الرقابة القضائية لحث الإدارة وإجبارها على ضرورة ترشيد وعقلنة أعمالها في مختلف المجالات الإدارية ، وأيضا على أساس أنهما يتفقان في ضرورة أن يكون هناك مبالغة في التقدير أو إفراط في التفاوت بين الأعباء والمزايا، أو بمعنى آخر يتفقان على عدم اعتبار الأخطاء التافهة أو التفاوت البسيط والمعقول سببا للإلغاء وذلك على التفصيل السابق بيانه، نقول إذا كان هذا الرأي قد أصاب في ذلك كله ، إلا أنه قد جانب الصواب من ناحية أخرى وذلك بعدم إظهاره لحقيقة طبيعة وجوهر كل من النظريتين في الرقابة على أعمال الإدارة.

أو بمعنى آخر بعدم إظهاره للدور الحقيقي الذي تتيحه كل منهما لقاضي تجاوز السلطة في رقابته لأركان القرار الإداري . إذ بينما يكمن هذا الدور في حالة الخطأ البين في تقدير وتقييم الوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتها، نجد أن هذا الدور يتجسد في حالة الموازنة بين المنافع والأضرار في تقدير وتقييم مضمون هذه القرارات والتي تستند إلى تلك الوقائع.

فرقابة الخطأ البين تتعلق إذن بأسباب القرار الإداري بينما تتعلق رقابة الموازنة بمحل ذلك القرار وذلك على التفصيل السابق بيانه ، وهذا من شأنه أن يوجد اختلافا بين النظريتين، بحيث يصعب القول بأن أيا منهما يصلح لحل النزاع بدلا من الآخر.

وإذا كان قد حدث لبس أو خلط من هذا النوع عند تطبيق نظرية الموازنة لأول مرة بمناسبة قضية ville nouvelle est ، فذلك لا لشيء إلا لأنها كانت البداية، فأمر طبيعي في الواقع أن يطالب مفوض الحكومة Braibant بحل النزاع في هذه القضية على أساس نظرية الخطأ البين حيث

لم تكن نظرية الموازنة قد ظهرت بعد ، أو قد عرفت تطبيقا سابقا على تلك القضية ؛ إذ من المعروف - كما ذكرنا - أن مجلس الدولة هو الذي أعلن عن تلك النظرية لأول مرة في القضية المذكورة، الأمر الذي جعل منها حدثا جديدا سواء بالنسبة لمفوضى الحكومة أو بالنسبة لغيرهم من رجال الفقه الإداري الذين بدأوا بعد ذلك بالمطالبة بتطبيقها في مجالات أخرى مشابهة دون الخلط بينها وبين نظرية الخطأ البين.

بل ومما يؤيد أن هناك اختلافا بين النظريتين أن لكل منهما مسمى أو مصطلحا خاصا بها يختلف عن المسمى أو المصطلح الخاص بالأخرى. فهذه نظرية "الخطأ البين" وتلك نظرية "الموازنة بين المنافع والأضرار"، كما أن المجالات التي تطبق فيها كل من النظريتين يختلف نوعا ومدى كما بينا من قبل.

أما عن الرأي الثاني والذي يميز بين النظريتين على أساس ما تتيحه كل منهما لقاضي تجاوز السلطة من إمكانيات رقابية ، حيث تتيح له نظرية الموازنة رقابة المشروعية في القرارات الإدارية، بينما تتيح له نظرية الخطأ البين رقابة الملاءمة في تلك القرارات، فإنه يلاحظ أنه وإن كان قد أصاب فيما يقول به بالنسبة لنظرية الخطأ البين والتي يباشرها القضاء ليس فقط في رقابته على كيفية مباشرة الإدارة للسلطة التقديرية، وإنما أيضا على التقدير الإداري ذاته، وذلك باعتراف معظم المعلقين والكتاب الفرنسيين وكذلك مفوضى الحكومة، ويكفي أن نشير إلى ما قاله (G.) Braibant في هذا الشأن من أن رقابة الخطأ البين تباشر حينما تتجاوز الإدارة حدود المعقولة في تقييمها لعناصر الملاءمة⁽¹⁾:

(1) Concl. sous C.E, 13 novembre 1970, Lambert citées par MM. Labettoulle et Cabanes, A.J.D. A., 1971, P.35.

"que l'erreur manifeste apparait lorsque l'administration est allée au-delà des limites du raisonnable dans le jugement qu'elle a porté sur des éléments d'opportunité"

نقول إن الاتجاه الذي نحن بصددّه وإن كان قد أصاب في هذا الخصوص، إلا أنه جانب الصواب فيما ذكره عن طبيعة وكنة رقابة الموازنة والتي اعتبرها - كما رأينا - تتدرج في إطار الرقابة على المشروعية ، ذلك أن أسلوب الموازنة بين المنافع والأضرار في الرقابة إنما يتعلق في واقع الأمر بمجالات تباشر فيها الإدارة سلطة تقديرية، كما يتعلق كذلك بعناصر الملاءمة في القرارات الإدارية التي تصدر في تلك المجالات وذلك على التفصيل التالي:

أولاً: نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار تطبق في مجالات تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية :

هناك في الواقع كثير من المجالات التي تتمتع الإدارة في خصوص ما تصدره في إطارها من قرارات بسلطة تقديرية سواء فيما يتعلق باختيار مضمون تلك القرارات، أو فيما يتعلق بتحديد أنماطها، بحيث لا يحدها في هذا الصدد سوى ضرورة التزامها باحترام معايير عليا تحكم تلك المجالات مثل معيار المنفعة أو المصلحة العامة أو معيار النظام العام وغيرها.

ومن ثم يمكن القول إن التزام الإدارة باحترام هذه المعايير العليا يعد شرطاً لمشروعية تلك القرارات، هذه المشروعية إنما تعني في حقيقة الأمر أن اختصاص الإدارة من هذه الزاوية يكون اختصاصاً مقيداً ، وأن الرقابة عليه تتدرج بالتالي في إطار رقابة المشروعية. في حين أن الحرية التي تتمتع بها الإدارة في هذا الشأن والخاصة باختيار مضمون وأنماط القرارات

الإدارية إنما تندرج في إطار الملاءمة، وكان من المفروض أن تكون في مأمن من رقابة القاضي الإداري، إلا أنه نظرا لما قد تؤدي إليه هذه الحرية من نتائج سلبية سواء في خصوص العمل الإداري ذاته وذلك عندما لا تكون تلك القرارات ملائمة أو مناسبة ، أم في خصوص الأفراد المخاطبين بها أو ما تهدف إليه من تحقيق للمنفعة العامة وذلك عندما تتضمن عيوباً أو مساوئ غير مقبولة أو لا تتناسب البتة مع المزايا الفوائد المترتبة عليها ، فقد ظهرت نظرية الموازنة لتضع حدا لتلك الحرية، الأمر الذي يعني أن هذه النظرية تتعلق بما تباشره الإدارة من سلطة تقديرية في هذه المجالات لا بما تباشره من سلطة مقيدة في خصوصها.

ففي مجال نزع الملكية للمنفعة العامة يلاحظ أن القاضي الإداري، وإن كان ملتزماً برقابة مدى مشروعية قرار المنفعة العامة الذي تتخذه الإدارة لإجراء عملية نزع الملكية (اختصاص مقيد) إلا أنه يراقب أيضاً ما تتمتع به الإدارة في هذا الشأن من اختصاص تقديري كحريتها مثلاً في اختيار الموقع الذي ترى أنه يحقق هذه المنفعة العامة وذلك بفضل تبني نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، إذ قبل ظهور هذه النظرية . كانت الإدارة تتمتع في هذا الصدد بسلطة تقديرية واسعة لدرجة يمكن معها القول - وكما كان مستقراً في القضاء السابق - أنه لا يسمح من أحد الادعاء بأن ما تراه الإدارة محققاً للمنفعة العامة، لا تتحقق معه هذه المنفعة ، أو أن العقارات التي رأت أن تنزع ملكيتها ليست لازمة لتحقيق المنفعة العامة، أو أن هناك عقارات أخرى سوف تتحقق بنزع ملكيتها المنفعة العامة المدعى بها، أو أن جزءاً من عقار يزيد عن القدر اللازم نزع ملكيته لتحقيق المنفعة العامة...وهكذا.

أما بعد ظهور نظرية الموازنة، فإنه يصعب القول ببقاء حرية الإدارة

على هذا النحو، فقد أتاحَت هذه النظرية للقاضي الإداري - وكما بينا من قبل - إلغاء أي قرار إداري يصدر بإعلان المنفعة العامة لعملية ما ، إذا ما ثبت له أن تكاليف هذه العملية مالياً أو اجتماعياً أو بيئياً تفوق ما قد يترتب عليها من منافع وفوائد.

ولهذا فقد ذهب G. braibant إلى القول بأن الإدارة وإن كانت حرة في اختيار موقع المشروع الذي ترغب في إقامته (شق طريق مثلاً)، إلا أن هذه الحرية أو ذلك الاختيار لا يجب أن يكون منطوياً على عيوب ومساوئ مفرطة، كما لو كان سيؤدي إلى هدم عدد كبير من المساكن أو إلى إفساد وتلوث البيئة وذلك مقارنة بالمزايا أو الفوائد المنتظرة من ورائه^(١).

"si l'administration est libre de choisir l'emplacement d'un ouvrage qu'elle veut construire tel qu'une autoroute, elle ne doit pas ce choix prendre une solution que presente des inconvenients excessifs par rapport aux avantages attendus"

حقيقة أن القاضي الإداري لا يفرض على الإدارة هنا رأياً معيناً باختيار هذا الموقع أو ذاك، ولكنه يستطيع في رأينا أن يصل إلى هذه النتيجة أو أن يجعل الاختيار على الأقل اختياراً موفقاً أو معقولاً عن طريق إعماله نظرية الموازنة، إذ بإصراره على ألا يكون الاختيار لموقع معين منطوياً على تفاوت مفرط بين أعباء ومنافع عملية نزع الملكية، طبقاً لما تقول به تلك النظرية، يكون قد حقق هدفه وذلك بإجبار الإدارة على الاختيار الأمثل لهذا الموقع، بل ويكون قد باشر رقابته في مجال تتمتع فيه الإدارة بسلطة تقديرية.

(1) Le droit administratif français, Dalloz, 1985, P. 241.

ومما يؤكد هذا القول بل ويظهره بشكل أكثر وضوحا إعمال تلك الرقابة في مجال الاستثناءات التي تقررها الإدارة بالمخالفة لقواعد أو خطط التنظيم العمراني، إذ رغم ما تتمتع به الإدارة في هذا الصدد من سلطة تقديرية واسعة في منح هذه الاستثناءات، إلا أن مجلس الدولة قد مد رقابته من خلال نظرية الموازنة إلى تلك السلطة التقديرية، مقررًا في هذا الصدد - وكما رأينا من قبل - أن منح أي من هذه الاستثناءات لا يكون مبررا إلا إذا كانت المزايا أو المنافع المترتبة عليها تفوق ما قد ينجم عنه من تكاليف وأعباء، أو بمعنى آخر تفوق المزايا والمنافع التي تحميها القواعد أو الخطط الأساسية للتنظيم العمراني.

ولهذا يقول السيد: claude Blumann في تعليقه على حكم Ville de Limoges^(١):

"Désormais, non seulement toute dérogation devra se fonder sur des motifs d'intérêt général, mais le juge sera compétent pour apprécier l'existence de cet intérêt général".

وهكذا نستطيع القول دون تردد بأن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار تطبق في مجالات تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية.

ثانيا: نظرية الموازنة تمتد إلى رقابة الملاءمة:

contrôle de l'opportunité

لم يقتصر تطبيق نظرية الموازنة فقط على كيفية مباشرة الإدارة لاختصاصاتها في المجالات التي تتمتع في خصوصها بسلطة تقديرية - كما

(1) le contrôle juridictionnel des dérogations en matière d'urbanisme, R.D.P., 1991, P.22.

رأينا • وإنما امتد تطبيق هذه النظرية كذلك إلى رقابة هذه السلطة التقديرية ذاتها، أي إلى رقابة عنصر الملاءمة ذاته، مما يجعل منها وسيلة لما يسمى "الرقابة القصوى" *controle maximum* لأعمال الإدارة التقديرية.

فقد ذكرنا في الفقرة السابقة أن هناك شرطا قانونيا يجب تحققه في عمليات نزع الملكية أو في استثناءات التنظيمات العقارية أو غيرها من المجالات التي تدخل في إطار تطبيق نظرية الموازنة ، حتى تكون القرارات الإدارية الصادرة في خصوصها مشروعة قانونا ، هذا الشرط القانوني يتمثل في المنفعة العامة "l'intérêt général" ولهذا فقد ذهب أنصار الاتجاه الأول السابق الإشارة إليه إلى القول بأن وجود مثل هذا الشرط القانوني يجعل اختصاص الإدارة اختصاصا مقيدا ، ويجعل بالتالي رقابة القاضي هنا رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.

والرد بعدم سلامة هذا القول سهل ميسور ، فقد سبق لنا أن رأينا أنه في مجال الضبط الإداري المحلي ورغم أن هناك شرطا قانونيا يجب تحققه من وراء كافة الإجراءات الإدارية التي تتخذ في هذا الإطار، وهو شرط المحافظة على النظام العام أو إعادته إلى سيرته الأولى ، الأمر الذي كان يجب أن يجعل من اختصاص الإدارة اختصاصا مقيدا ومن رقابة القاضي لتلك الإجراءات رقابة مشروعية ، إلا أن الفقه والقضاء مستقر على أن رقابة القاضي الإداري في هذه الحالة هي رقابة منصبة على عنصر الملائمة في إجراءات الضبط الإداري ، أي أنها رقابة حقيقية لملاءمة العمل الإداري^(١):

il s'agit alors d'un véritable contrôle de l'opportunité de l'action administrative.

(1) Auby et Drago, Traité de contentieux administratif, L.G.D.J., 2ème, éd, R.11, Paris, 1975, P. 403.

ذلك أن مجلس الدولة لا يكتفى بالنسبة لهذه الإجراءات - كما ذكرنا من قبل - بالتحقق من وجود الوقائع وصحة تكييفها القانوني ، وإنما يقوم فضلا عن ذلك بمراجعة الإدارة في تقديرها لأهمية وخطورة الحالة الواقعية التي بررت تدخلها ومدى التناسب بينها وبين إجراءات الضبط المتخذة ، وهذا ما يفعله القاضي الإداري تماما في خصوص رقابة الموازنة ؛ حيث لا يكتفى بمجرد إعلان الإدارة للمنفعة العامة لإجراء معين و إنما يتحقق بذاته من هذا الإعلان وذلك برقابة وتقدير كافة الظروف والمعطيات المحيطة بهذا الإجراء، والوقوف بالتالي على الأعباء المترتبة عليه سواء كانت أعباء مادية أو غير مادية ومقارنتها بالمزايا التي سوف يحققها حتى يتثبت بعد ذلك من مدى ملاءمته لتحقيق المنفعة العامة المنشودة؛ الأمر الذي Alain Bockel أن القاضي هنا يصدر حكما على معنى كما يقول التقييم الذي أجرته الإدارة والذي سمح لها باختيار مضمون القرار محل النزاع^(١).

"c'est-à-dire qu'il porte un jugement sur l'appréciation faite par l'administration qui lui a permis d'arrêter le contenu de la décision contestée"

لا اختلاف إذن بين قضاء إجراءات الضبط المحلي وقضاء الموازنة من حيث طبيعة الرقابة التي تباشر على أساسهما، وبالتالي فإنه لا مجال للتمييز بينهما من هذه الزاوية والقول بأن الرقابة الأولى إنما هي رقابة ملاءمة، والرقابة الثانية أي رقابة الموازنة ، رقابة مشروعية ، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه الرقابة الأخيرة ، تماما كرقابة إجراءات الضبط الإداري، تمكن القاضي الإداري من أن يحل تقديره الشخصي محل تقدير

(1) op. cit., P. 366.

رجل الإدارة وهو ما يؤكد Auby et Drago حيث يقولان^(١):

"il s'agit là d'un contrôle quasi exclusif de l'opportunité et, le juge est en train subjectives à celles de l'administration"

ومن جانبها تقول Mme Jeanne lemasurier: أن قضاء الموازنة بين المنافع والأضرار يعكس في الواقع اتساعا ملحوظا في سلطات القاضي الإداري حيث يتيح له ليس فقط إجراء رقابة مادية على الأسباب الواقعية، وإنما أيضا إجراء رقابة على مدى ملاءمة الإجراء الإداري بالنسبة لهذه الأسباب؛ الأمر الذي يعني أن القاضي يحل قراره الذاتي في هذا الشأن محل قرار الإدارة^(٢).

حاصل القول إذن أن رقابة الموازنة بين المنافع والأسرار وإن كانت تتميز عن رقابة الخطأ البين في كونها تتعلق بمضمون أو محل القرار الإداري، في حين أن الرقابة الأخيرة تتعلق بأسباب هذا القرار، إلا أنها لا تختلف عنها من حيث الطبيعة، حيث تباشر كل من الرقابتين على ملاءمة الأعمال الإدارية، أي على التقييمات التي تجريها الإدارة بمالها من سلطة تقديرية، حينما تتسم هذه التقييمات باللامعقولية أو المبالغة، أو حينما تكون ذات رصيد سلبي في ميزان التكاليف والمزايا^(٣).

(1) op. cit., P. 404.

(2) la règle "bilan: coût-avantages " consacre, en effet, une extension caractérisée des pouvoirs du juge. Elle le conduit, non seulement, à excercer un contrôle normal, sur les motifs de fait, mais à contrôler l'adéquation de la mesure administrative à ces motifs de fait, c'est-à-dire à substituer sa propre décision à celle de l'administration" op.cit. p.560.

(٣) وهذا ما يوضحه بدقة الأستاذ BOCKEL في مقال السابق الإشارة إليه، ص ٣٦٨ حيث يقول:

المبحث الرابع

تقدير نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

إذا كنا قد انتهينا في المبحث السابق إلى القول بأن رقابة الموازنة تندرج في إطار الرقابة على ملاءمة الأعمال الإدارية ، ومن ثم تصبح بهذه المثابة قيّدا هاما للحد من احتمالات التعسف أو التسلط من جانب الإدارة في خصوص هذه الأعمال ، إلا أن هناك جانبا من الفقه الإداري ينتقد مثل هذا القول على أساس ما قد يترتب عليه من نتائج تؤثر سلبا على كفاءة وحسن إدارة المرافق العامة.

لذلك وللوقف على حقيقة ما يدعيه هذا الجانب الفقهي نتناول فيما يلي الموضوعين التاليين:

- أهم الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.
- تنفيذ الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

المطلب الأول

أهم الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار

لقد انتقد جانب من رجال الفقه الإداري - كما ذكرنا - إدراج رقابة الموازنة في إطار الرقابة على الملاءمة، مرددين في هذا الشأن ذات الأسباب أو

ces deux jurisprudences ont donc chacune un champ d'application nettement spécifique,.... l'une (erreur manifeste) porte essentiellement sur les motifs, l'autre (bilan) sur le contenu des décisions...il n'y a pas entre ces deux contrôles une différence de nature..... seules les appréciations discrétionnaires déraisonnables sont censurées (ou les soldes nettement négatifs de la "balance coût-avantages").

الحجج التي يقال بها عادة لنقد الرقابة القضائية لسلطة الإدارة التقديرية. ولهذا فهم يرون أن اعتبار رقابة الموازنة مما يندرج في إطار رقابة الملاءمة من شأنه أن يؤدي بالقاضي إلى التدخل في تقديرات الإدارة ومن ثم إمكانية إحلال تقديراته الشخصية محل تلك التقديرات، وبهذه المثابة فإنه يخرج عن دوره كقاضي مشروعية ليصبح رئيسا إداريا أعلى، بما يتضمنه ذلك من افتئات على استقلال رجل الإدارة، ومن اعتداء على ما يباشره من اختصاصات تقديرية؛ إضافة إلى ذلك فإن هذه الاختصاصات الأخيرة إنما تخضع في المجالات التي تطبق فيها النظرية التي نحن بصددنا لتحقيق مسبقه ودراسات متأنية من قبل أجهزة وهيئات متخصصة؛ ولهذا يخشى من أن يباشر القاضي الإداري من خلال تلك النظرية دورا رقابيا لا على أساس هذه التحقيقات أو تلك الدراسات، وإنما على أساس مجرد ما يقع تحت بصره من أوراق وملفات، وينتهي به الأمر - بعد زمن قد يطول - بأن يضيف إلى تحكم الإدارة تحكما من جانب القضاء.

que statuant sur pièces, et longtemps après, il ne vienne ajouter à l'arbitraire de l'administration, un arbitraire à posteriori du juge.

ولهذا يتساءل الأستاذ waline في هذا الخصوص عما إذا كان مجلس الدولة يذكرنا بهذه النظرية بنظام المحاكم البرلمانية وما كانت تباشره من تجاوزات تجاه الإدارة^(١).

ومن أوجه النقد الأخرى التي قيل بها في هذا الشأن ، أنه نظرا لكون معيار الموازنة بين المنافع والأضرار، معيارا شخسيا للقاضي وليس معيارا

(1) Note sur l'arret du 22 mai 1971, R.D.P., 1973, P. 454.

موضوعيا، فإن المتقاضين لا يستطيعون الوقوف مقدما على ما سيكون عليه الحل في النزاع المطروح، إذ الأمر يتوقف والحال هكذا على التقديرات الشخصية التي يجريها القاضي الإداري لهذا النزاع، مما يعني من ناحية أخرى إمكانية اختلاف الحلول القضائية في النزاعات المتشابهة لا لشيء إلا لمجرد اختلاف وجهات نظر أشخاص القضاة المختصين بالفصل في تلك النزاعات وهو ما يتنافى مع قواعد العدالة التي هي من أساسيات القضاء الإداري^(١). لذلك فقد أطلق البعض - كما يقول أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي - صيحته التحذيرية، ودق البعض الآخر أجراس الإنذار من هذا المسلك الجديد لمجلس الدولة.

المطلب الثاني

تفنيذ الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الموازنة

بين المنافع والأضرار

بينما في المطلب السابق أهم الانتقادات التي قيل بها في خصوص نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، وإذا أردنا أن نفند هذه الانتقادات فلنا أن نتساءل بداءة عن السبب الذي دعا البعض إلى إطلاق الصيحات التحذيرية أو إلى دق أجراس الخطر والإنذار ؟

إن السبب في ذلك كما يبدو لنا أن قاضي تجاوز السلطة ، الذي

(1) "le danger d'une telle évolution est qu'elle confère une incertitude complète à la solution des litiges portés devant le juge administratif, les justiciables ne pouvant jamais savoir ce que sera la solution dès lors qu'elle dépend d'appréciations qui peuvent varier selon les affaires et la composition de la juridiction un développement de cette jurisprudence conduirait à mettre en cause jusqu'aux fondements de la juridiction administrative."

Auby et Drago, op.ct. P.404.

يجب أن تقتصر رقابته فقط - كما يدعى هذا البعض - على مشروعية القرارات الإدارية، قد مد تلك الرقابة لتتناول كذلك ملاءمة تلك القرارات، مع أنه ليس في ذلك ما يدعو إلى كل هذه الصيحات أو تلك الأجراس.

فقد بينا من قبل أنه لا تعارض على الإطلاق بين الشرعية والملاءمة، وإنما التعارض فقط بين الشرعية وعدم الشرعية، أو بين الملاءمة وعدم الملاءمة، ولهذا فقد انتهينا في هذا الخصوص إلى أن القاضي الإداري، وإن كان قاضيا للمشروعية، إلا أنه ليس هناك ما يم، من رقابته للملاءمة إذا كانت شرطا لهذه المشروعية. وهذا ما هو متحقق كما بينا في الفقرة السابقة في قضاء الموازنة بين المنافع والأضرار تماما كما هو متحقق في قضاء إجراءات الضبط الإداري المحلي وهو قضاء كلاسيكي.

فالقاضي الإداري حينما يمنع عملية أشغال عامة une operation de travaux publics، لأنها تتضمن اعتداء مبالغا فيه على المصالح أو المنافع ذات العلاقة بها، فإنما يصدر حكما قيما un jugement de valeur، من ذات طبيعة الأحكام التي يصدرها حينما يراقب مدى تلازم إجراء من إجراءات الضبط الإداري مع الظروف التي اتخذ على أساسها، لكي يتحقق من أن هذا الإجراء لا يتضمن بشكل غير مبرر، اعتداء على الحرية العامة كحرية الاجتماع مثلا. فالرقابتين هنا يجسدان في الواقع رقابة الملاءمة للاختيارات الإدارية والتي يجريها القاضي الإداري وفقا لمفاهيمه أو معايير الخاصة به، والتي يستمدّها بطبيعة الحال من المعطيات والظروف المحيطة بالإجراء محل الرقابة. ولهذا يقال إن هذه الرقابة تتضمن أحكاما قيمية أو شخصية. تلك الأحكام التي تشكل في حقيقتها معيارا لمعقولية الأعمال الإدارية، وذلك على غرار قاعدة الصواب أو الحكمة le règle de raison والتي اعتاد القضاء الأنجلو سكسوني على تطبيقها.

إذن ليس في قضاء الموازنة بين المنافع والأضرار ما هو مغاير أو شاذ عما كان ولا زال متبع في قضاء الضبط الإداري. ولهذا يتساءل الأستاذ Alain Bocklet ، إذا كنا قد استطعنا أن نؤسس رقابة الملاءمة في القضاء الكلاسيكي على ضرورة حماية الحقوق المشروعة كحق الملكية وحق الاجتماع، فلماذا إذن لا نستطيع اليوم أن نفعل ذات الشيء ؟ بمعنى نستطيع اليوم أن نؤسس رقابة الملاءمة على ضرورة حماية الحقوق الجديدة أو المستحدثة في عالمنا المعاصر مثل الحق في الطبيعة أو الحق في الاجتماعية ملائمة..الخ.^(١)

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القول بأن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار تؤدي بالقاضي الإداري إلى رقابة ملاءمة الأعمال الإدارية، الأمر الذي ينقص من استقلال رجل الإدارة ، أو يتضمن اعتداء على اختصاصاته قول يتنافى مع الواقع والحقيقة ، حتى ولو لم تكن الملاءمة محل الرقابة شرطا لأية مشروعية . ذلك أن القاضي الإداري بإعماله لتلك النظرية في مثل هذه الحالات ، وإن كان يحل تقديره الشخصي لملاءمة التصرف محل تقدير رجل الإدارة لتلك الملاءمة ، وذلك عندما يكون هذا التقدير مشوبا بالمبالغة أو اللامعقولية ، إلا أنه لا يحل ذاته محله؛ أي أن القاضي الإداري في رقابته للملاءمة لا يحل نفسه محل جهة الإدارة^(٢)، سواء في اتخاذ القرار الذي يرى أنه أكثر ملاءمة، أم في تعديل

(1) Et si l'on pouvait fonder le contrôle de l'opportunité effectué dans le jurisprudence classique sur la nécessité de protéger des droits confirmes (droit de propriété, droit de réunion ...etc), pour quoi n'en pas de même aujourd'hui?

Op. cit., 369.

(2) Chevallier, **l'interdiction** pour le juge administratif de faire acte d'administration, A.J.D.A., 1972, P 67, Pasbecq, de la frontière

مضمون القرار المطعون فيه مع الإبقاء عليه، فمثل هذه الأمور متروكة تماما لحرية رجل الإدارة، فأني انتقاص إذن من استقلال هذا الأخير وأي اعتداء على اختصاصاته!!؟

ولهذا نرى أنه كان أجدر بأنصار الرأي السابق بدلا من أن يواجهوا نقدهم ولو مهم إلى القضاء حينما قال بنظرية الموازنة ، بين المنافع والأضرار، أن يتوجهوا بدلا من ذلك إلى الإدارة ناصحين ومرشدين إياها، بأن تكون قراراتها رشيدة ومتسمة بالعقلانية والمنطق، وأن تكون محققة المتوازن المنشود بين مختلف المصالح المرتبطة بها ، حتى لا تكون عرضة للإلغاء من قبل القضاء !! وهذا ما يؤكد الأستاذ Waline حينما قال : إننا إذا كنا نخشى من جرأة القاضي الإداري بما يمنحه لنفسه من سلطات في هذا الصدد، فإنه يجب الاعتراف في ذات الوقت، بأن أخطاء الإدارة وقصورها في أعمالها هي التي تبرر مثل هذه الجرأة^(١).

si l'on s'effraie des pouvoirs que se reconnaît ainsi le juge administratif, il convient d'admettre que ce sont les fautes et les carances de l'administration, qui parfois justifient ses audaces"

أما عن القول بأن قضاء الموازنة لا يسمح للمتنازعين - نظرا لارتكازه على معيار شخصي للقاضي - بالوقوف مقدما على الحلول المتوقعة للنزاع المطروح ؛ هذا القول ليس صحيحا على إطلاقه ، ذلك أن المتنازعين لا يستطيعون في الغالب الوقوف على الحلول المتوقعة لنزاعاتهم

entre la légalité et opportunité dans la jurisprudence du juge de l'excès de pouvoir, R.D.P, 1981, P,807.

(1) Note précitée précit. R.D.P., 1972, P. 46.

سواء أُلجأ القاضي الإداري في خصوص تلك النزاعات إلى قضاء الموازنة أم إلى أي قضاء آخر ، إذا لو كان الأمر على خلاف ذلك ، أي إذا لو كان بإمكان المتنازعين معرفة حلول نزاعاتهم مقدما ، ما لجأ أي منهم إلى القضاء ، بل ولما كان هناك في الأصل نزاع يعرض على هذا القضاء .

وأخيرا فإن القول بأن المعيار الشخصي للقاضي الإداري قد يؤدي إلى اختلاف الحلول في النزاعات المتشابهة ، وهو ما يتنافى مع قواعد العدالة التي هي من أساسيات القضاء الإداري . إن مثل هذا القول يتطلب في الواقع بعضا من الإيضاح ، ذلك أن القاضي الإداري ، لا يباشر رقابته على أعمال الإدارة ، سواء كانت رقابة ملاءمة أم رقابة مشروعية ، بشكل عشوائي ، أو دون دون مراعاة أية ضوابط أو مرتكزات ، كما أنه لا يباشر تلك الرقابة انطلاقا من موقف عدائي تجاه الإدارة . إنه يباشر الرقابة باعتباره واحدا من السلطات العامة في المجتمع وأنه لا يستهدف من وراء عمله . تماما كما هو مفترض في بقية السلطات الأخرى ومن بينها الإدارة . سوى تحقيق المصلحة أو النفع العام لكافة أفراد المجتمع ، وذلك في إطار مبدأ الدولة القانونية .

فالتقدير الشخصي للقاضي الإداري لمدى ملاءمة التصرف ، والذي يباشره إعمالا لنظرية الموازنة ، لا يعني بحال من الأحوال أنه يقوم على أساس من نزوة شخصية أو رغبة ذاتية لديه . وفي هذا المعنى يقول الفقيه J.RENAULD ، أن الوصول إلى حلول عادلة ، وإن كان يعتمد على إدراك وبديهية القاضي ، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الأخير يطلق العنان لآرائه الشخصية أو الذاتية في هذا الصدد ، بحيث تكون له حرية مطلقة في التقيد أو الاعتداد بتلك الآراء . إن الحلول العادلة تعتمد أو يجب أن تعتمد على البحث في مصادر موضوعية تكمن في الوسط الاجتماعي - في

الضمير الأخلاقي السائد - في الحس المشترك - في المعنى الاجتماعي للعدالة... إلخ^(١). وهذا يتطلب بطبيعة الحال النظر إلى كافة المعطيات والظروف التي تحيط بالتصرف موضوع النزاع.

فإذا أضفنا إلى ذلك أن القاضي الإداري تربطه بالإدارة صلات خاصة تمكنه - كما سبق أن بينا - من الإحاطة بمستلزمات حسن الإدارة، وكيفية تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح العامة، لأمكن القول بأن تقدير القاضي للملاءمة تطبيقاً لنظرية الموازنة، إنما هو تقدير موضوعي وإن اتصف بسمه الشخصية أو الذاتية^(٢).

حقيقة أنه قد تختلف الحلول في قضاء الملاءمة، إلا أن ذلك ليس مرجعه - كما ذهب أنصار الرأي السابق - الاختلاف في أشخاص القضاة الذين يقررون تلك الحلول، وإنما مرجعه طبيعة الملاءمة ذاتها، فهذه الملاءمة لا تتعلق في الواقع بمضمون التصرف فقط وإنما تتصل كذلك بوقت ومكان اتخاذ هذا التصرف وبالظروف والمعطيات التي تأخذ على

(1) "si la construction des solution d'équité fait appel à l'intuition du juge, ce la ne signifie point que ce dernier puisse donner libre cours à sa subjectivité, à son sens, le juge d'équité doit chercher des references "objectives" dans "l'opinion sociale" ou dans la "conscience morale" de son époque ou encore dans le "commun sense" ou dans le "Sens social du juste"

Principes généraux du droit et équité, in mélange Ganshof van der Meersch, Bruylant, Bruxelles, 1972, T.II. P.888.

(٢) وفي هذا المعنى يقول أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي، "إن قضية الإدارة لن يكون العامل الأساسي فيها البحث عن الحكم السليم للقانون ولكن عن نقطة التوازن بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة وهذه مهمة تحتاج بجوار الإلمام بالقانون إلى الإحاطة بمستلزمات حسن الإدارة وبتفاصيل الوسائل الإدارية التي تلجأ إليها الإدارة لمواجهة ما يصادفها من عقبات، وهذا ما يحققه القضاء الإداري على أكمل وجه نظراً لتشكيله وصلاته الخاصة بالإدارة.

النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص ٣٤.

أساسها، الأمر الذي يعني أن ذات التصرف قد يكون ملائماً في وقت ومكان وفي ظل ظروف ومعطيات معينة ولا يكون كذلك في وقت ومكان أو في ظل ظروف ومعطيات أخرى^(١).

من هنا يمكن القول أنه اختلاف الحلول في قضاء الملاءمة - إن وجد - إنما يكون أمراً طبيعياً ، بل ولا تجاوز الحقيقة إذا قلنا أنه يعتبر في كثير من الأحيان بمثابة علامة صحة تجسد عدالة هذا القضاء.

وهكذا نخلص مما سبق إلى أن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار لا علاقة لها، باختلاف التقديرات الشخصية للقضاة، فهذا أمر خارج عن طبيعة تلك النظرية والتي لا تعد . شأنها شأن أية نظرية أخرى من هذا النوع أكثر من مجرد وسيلة يلجأ إليها القاضي الإداري للوقوف على مدى ملاءمة تصرف إداري معين، وذلك بالنسبة لما يحيط بهذا التصرف من معطيات وظروف خاصة به.

إذا كنا قد انتهينا من تفنيد معظم الحجج التي قيل بها للاعتراض على نظرية الموازنة ، فإن ما تجدر الإشارة إليه من ناحية أخرى، أن هناك جانباً آخر من الفقه يرى أن هذه النظرية تستحق كل تقدير واحترام ، معتبرين إياها من أهم ضمانات حقوق الأفراد بل ومن أكثرها فعالية في مواجهة الإدارة^(٢)، وذلك على أساس أنها تتيح للقاضي الإداري مراجعة ومن ثم إلغاء القرارات التعسفية أو الغير معقولة ، وكذلك القرارات التي اتخذت على عجل، أي دون دراسة متأنية ووافية ، كما أنها تلزم الجهات

(1) Dubisson, la distinction entre la légalité et l'opportunité dans la théorie du recours pour excès de pouvoir, op. cit., P. 36 etss.

(2) M. Waline, note précité, R.D.P., 1972, P. 454, J.P. Gilli, op. cit., A.J.D.A., 1973, P. 13.

الإدارية من جهة أخرى، أن تقدم للمواطنين أولاً ثم للقاضي بعد ذلك - إذا لزم الأمر - المبررات الجادة والمقبولة لمختلف أعمالها أو مشروعاتها التي تمس حقوق وحريات هؤلاء المواطنين^(١).

إن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار تعتبر بحق من المستجدات أو الاتجاهات الأكثر تطوراً في قضاء مجلس الدولة الفرنسي ذلك أنها وإن كانت وسيلة كبقية الوسائل الأخرى التي أوجدها القضاء الإداري، للحد من التعسف أو الاستبداد في التصرفات التي تأتيتها الإدارة بما لها من سلطة تقديرية، إلا أنها تتميز عن تلك الوسائل بانطوائها على منهج مغاير لتحقيق هذا الغرض، منهج يتفق أو يجسد في الواقع رمز العدالة ذاته، ألا وهو "الميزان"، حيث يقوم القاضي الإداري طبقاً لهذه النظرية - وكما ذكرنا من قبل - بوضع كافة أعباء التصرف الإداري المطعون فيه سواء أكانت أعباء مادية - اجتماعية - بيئية... إلخ، في إحدى كفتي ميزان العدالة، وفي الكفة الأخرى يضع المزايا أو الفوائد المتوقعة لهذا التصرف؛ مما يعني أنه يحيط أو يجب عليه أن يكون محيطاً بعناية قبل أن ينطق بحكمه على تصرف ما بكافة المعطيات أو الظروف والملازمات التي تتعلق بهذا التصرف، وهو ما تتحقق به ومعه العدالة. لا العدالة المطلقة أو المثالية *la justice absolue ou ideale* والتي تكمن في البحث عن التناسب المطلق *la proportionnalité absolue* بين منافع وأضرار القرار الإداري؛ وإنما العدالة النسبية *la justice proportionnelle* التي تكمن في البحث عن التناسب المعقول *la proportionnelle*

(1) Daniel labetoulle, le pouvoir discrétionnaire en matière d'urbanisme d'interventionnisme économique, paris, cujas, 1978, p.27 etss, cont. Baibant, sur l'arrêt, ville nouvelle est, précitée.

proportionnalité raisonnable بين هذا للأضرار وتلك المنافع؛ لذا فإن القاضي الإداري لا يلغى التصرف - كما ذكرنا - إلا إذا كانت الأضرار المترتبة عليه تتسم بالإفراط أو المبالغة في التقدير وذلك بالنظر إلى المنافع المتوقعة من ورائه^(١).

فنظرية الموازنة تتبنى إذن القاعدة التي تسود اليوم عالم القضاء الإداري والتي يهدف من ورائها إلى حث الإدارة على ترشيد وعقلنة أعمالها الإدارية بصفة عامة والتقديرية منها بصفة خاصة ، وهي قاعدة المعقولية في التصرفات الإدارية la règle de raisonnable des actes administrative.

ومعنى ذلك أن هذه النظرية تخفى بين طياتها رسالة موجهة إلى رجل الإدارة ك يتصرف دائما وأبدا كإداري واع أو إداري جيد bon administrateur.

ومن هنا فقد طالب كثير من رجال الفقه الإداري بضرورة التوسع في أعمالها بحيث لا تقتصر على مجالات بعينها، خاصة بعد ما حدث من تطور هائل في وظائف الدولة المعاصرة، وتدخلها في كافة مجالات الحياة. وإذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتساءل عن موقف مجلس الدولة المصري من هذه النظرية؟ وهو ما نبينه فيما يلي.

(1) Par la technique du Bilan, le juge de l'excès de pouvoir ne pretend pas établir une stricte proportionnalité, en l'absence de norme precise de reference le juge se place sur le plan du contrôle de la proportionnalité raisonnable et recherche le caractère excessif de la mesure critiquée au regard des intérêt qu'elle vise à satisfaire.
M. GUIBAL, la justification des atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie, A.J.D.A., 1972 PP, 482 et 487,

المبحث الخامس

موقف مجلس الدولة المصري من نظرية الموازنة

بين المنافع والأضرار

على الرغم من أن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ، تعد من المستجدات أو من الاتجاهات الأكثر تطورا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي؛ وعلى الرغم من أن هذه النظرية قد لاقت ترحيبا وتقديرا من معظم الأوساط الفقهية والقضائية المهمة بضرورة تحقيق ضمانات فاعلة للمواطنين بقصد حماية وصيانة حقوقهم وحررياتهم ضد احتمال تعسف أو تسلط الإدارة حينما تباشر اختصاصاتها المتعلقة بهذه الحقوق أو تلك الحريات بما لها من سلطة تقديرية؛ نقول رغم ذلك ، فإن قضاءنا الإداري ممثلا في مجلس الدولة لم يأخذ أو يتبنى بشكل حاسم تلك النظرية ، حيث يبدو من أحكامه التي أصدرها أو المجالات التي أعمل في خصوصها مجلس الدولة الفرنسي نظرية الموازنة، خاصة تلك التي ظهرت فيها لأول مرة وهي مجالات نزع الملكية للمنفعة العامة ، يبدو أنه لا زال على عهده القديم ، وفيما للمبادئ المستقرة في هذا الشأن. فقد رفض مثلا أن يمد رقابته إلى عنصر الملاءمة في القرارات الخاصة بها مكتفيا في هذا الشأن برقابة مدى صحة الوقائع المادية، تاركا للإدارة بذلك حرية تكاد أن تكون مطلقة في المسائل التالية:

١- تقرير المنفعة العامة التي تبرر التجاؤها إلى نزع ملكية عقارات الأفراد:

إذ تقول المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، أن كل ما اشترطه القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ لإجازة نزع الملكية هو أن تكون ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء ذلك ؛ وقد أطلق القانون مجال التقدير في هذا الشأن للسلطة التنفيذية التي لها طبقا للمادة ٢٢ من القانون أن تحدد

العقارات اللازمة مباشرة للمشروع الأصلي الذي قررت له صفة المنفعة العامة. وكذلك العقارات التي ترى أنها مكملات لأغراض المشروع^(١).

وعلى ذلك "متى صدر قرار نزع ملكية العقار متوافقة فيه شروط إصداره فإنه ينتج آثاره"^(٢).

٢ - تحديد المساحات اللازمة لتحقيق الغاية التي من أجلها لجأت إلى نزع الملكية :

لذلك فقد قضى بأن « للجهة الإدارية سلطة تقدير حالة الأجزاء الباقية من عقار استمكت جزءا منه، من حيث صلاحيتها للانتفاع بها من عدمه حتى إذا ما رأت أنها غير صالحة للانتفاع بها حق عليها استملاكها؛ وإن رأت غير ذلك فلا تجبر على استملاكها ، وقد جعل المشرع قرارها في هذا الشأن مبرما أي باتا ؛ بمعنى أن رقابة المحكمة تكون مقصورة في هذه الحالة على التحقق من قيام القرار على وقائع صحيحة تؤدي إليه، وأنه صدر غير مشوب بعيب الانحراف أو سوء استعمال السلطة^(٣).

٣ - اختيار موقع العقارات التي ترى نزع ملكيتها :

حيث تقول المحكمة الإدارية العليا في حكم أصدرته عام ١٩٧٩ أنه " من المقرر قانونا أن لجهة الإدارة سلطاتها في اختيار الموقع وتحديد العقارات التي يشملها التخصيص للنفع العام بما تراه محققا للمصلحة العامة، وبما يجتمع لها من مقومات الخبرة والدراية وينعقد لها من أسباب

(١) مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا في ١٥ عاما (١٨٦٥ - ١٩٨٠)، الجزء الرابع، ص ٤٢٤١، رقم (١).

(٢) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ١٩٨٧/٥/٢، القضية رقم ٩٩٠، س ٣٠ق، ج ٢، ص ١١٩٣.

(٣) حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ ١٩٦١/٥/١١، مجموعة أبو شادي (الإدارية العليا في عشر سنوات ١٩٥٥ - ١٩٦٥)، ص ٢٣٢٢.

الاختصاص الصحيح. ومثل هذا الاختيار مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية وينأى عن تعقيب القضاء الإداري ما دام أن رائده الصالح العام، وأنه لا ينهض من الشواهد ما ينبئ عن أنها انحرفت به عن غاياته، فتتكتب وجه المصلحة العامة أو اتخذته بباعث منبت الصلة بها^(١).

وتقول محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن أيضا: إن "اختيار المكان اللازم للمشروع المراد إجراؤه أمر تقديري للإدارة وليس للمحكمة أن تعقب على هذا الاختيار"^(٢).

د - تحديد الزمان الذي تراء أكثر مناسبة لنزع الملكية:

فقد قضى بأن الإدارة بمالها "من سلطة تقدير مناسبات القرار الإداري تتعين الوقت الملائم لإصداره بلا معقب عليها في هذا الشأن من المحكمة بشرط ألا يكون القانون قد عين لها ميعادا يتحتم إصدار القرار فيه"^(٣).

وهكذا تتمتع الإدارة في مصر بسلطة تقديرية واسعة في القول بتوافر المنفعة العامة من عدمه، وأن القضاء لا يراقبها في هذا الصدد إلا في حالة إساءة استعمال السلطة؛ أو كما يقول أستاذنا الدكتور / سليمان الطماوي : "إن تقدير المصلحة العامة التي تبرر نزع الملكية هو وفقا للفقهاء والقضاء والتشريع من المسائل التي تستقل الإدارة المختصة بتقديرها. وعلى هذا الأساس تملك الإدارة أن تقرر بمنتهى الحرية تحقيق المنفعة العامة التي تبرر التجائها إلى نزع الملكية لعقار مملوك لفرد من الأفراد"^(٤).

(١) القضية رقم ٥٧١ لسنة ١٨ق، المجموعة، السنة ٢٤، ص ١١١.

(٢) الحكم الصادر بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٥٣، القضية رقم ١٣٣١، ص ٥ق.

(٣) حكم مجلس الدولة الصادر بتاريخ ١٠ مايو سنة ١٩٥٠، السنة الرابعة، ص ٧٣٥. أشار

إليه دكتور/ عزت صديق طنبوس، المرجع السابق، ص ٣٦٧.

(٤) القانون الإداري، الكتاب الثالث، ص ٢٧٩.

ومع ذلك يلاحظ أن هناك أحكاما متفرقة صدرت عن مجلس دولتنا الفتى، تشير من قريب أو بعيد إلى فكرة الموازنة بين المنافع والأضرار، أو بين المصالح المتعارضة، وإن لم يذكر هذا المجلس صراحة تبينه للنظرية السائدة الآن في القضاء الإداري الفرنسي.

نفى عام ١٩٥٤ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في مجال التراخيص تقول فيه: إنه " متى استبان للمحكمة أن المدعى شيد مصنعا للطوب وعول في استغلاله على الأتربة التي رخص له فيها وبالتكاليف المعتدلة التي يحققها له طوب المصنع المرخص له في أخذ الأتربة منه، وأن هذا المصنع يعمل في إنتاج الطوب بالفعل، فإن إلغاء تفتيش الرى للترخيص الذي منحه للمدعى استنادا إلى أن المناطق الأخرى المقول بأن المدعى يمكنه من أن يستولى منها على باقي الأتربة اللازمة له بدون ترخيص، أو بأنه يمكن الترخيص له في أخذ الأتربة منها ، غير جائز لأنها أبعد من المنطقة التي ألغي ترخيصه فيها بالقرار المطعون فيه، ولأن هذا يكبده نفقات أكبر في النقل، بل والوقت والجهد فضلا عن اضطراب العمل، مما يخرج عما قدره في حسابانه وقت حصوله على الترخيص وإقامته المصنع ويلحق به أضرارا لا تبررها علة تستند إلى الصالح العام..."^(١).

يتضح من هذا الحكم إذن أن المحكمة قارنت ووازنت بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الطاعن في بقاء الترخيص على ما هو عليه لما يحققه ذلك من قلة في التكاليف ووفرة في الوقت والجهد وكذلك من انتظام للعمل في المصنع، ومصلحة الإدارة (تفتيش الرى) في إلغاء هذا الترخيص ونقل الطاعن إلى منطقة أخرى للحصول على الأتربة اللازمة

(١) الحكم الصادر بتاريخ ١٩٥٤/٣/٣، القضية رقم ١١٧ لسنة ٧ق، المجموعة، السنة ٨، ص ٨٤٤.

لإدارة المصنع، وانتهت من هذه المقارنة أو الموازنة إلى ترجيح مصلحة الطاعن على مصلحة الإدارة معتبره أن هذه المصلحة الأخيرة لا تبررها "علة تستند إلى الصالح العام".

وفي عام ١٩٩٢، أي بعد حوالي مرور أكثر من ثمانية وثلاثين عاما على الحكم السابق، أصدرت ذات المحكمة حكما آخر في نفس المجال وهو مجال التراخيص. وقد كان ذلك بمناسبة القضية المعروفة باسم قضية "سوق روض الفرج" والتي تتعلق بإلغاء تراخيص مزاولة نشاط تجاري (بالجملة) في سوق روض الفرج، وذلك رغبة من الإدارة في أن تنقل نشاط الجملة إلى السوق الجديد التي أقامتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بموجب قرار محافظة القاهرة رقم ١٦٤ لسنة ١٩٩٢ بتاريخ ١٩٩٢/١/٢٨^(١).

وهنا نجد المحكمة أيضا تقارن وتوازن بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الطاعنين في القرار المذكور (التجار) في بقاء السوق بذات المكان الذي هو عليه الآن (منطقة روض الفرج) والتي تتجسد في كونهم يزاولون نشاطهم فيه منذ زمن بعيد طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ومن ثم فقد اكتسبوا مراكز قانونية تعطيهم الحق في الاستمرار لمزاوله نشاطهم باعتبارهم تجارا مرخص لهم بشغل سوق روض الفرج واستعماله واستغلاله بما يحقق مصالحهم والمصلحة العامة ، وبين مصلحة الإدارة في شغل سوق العبور وما يترتب على ذلك من زيادة في الموارد المالية للدولة تحقيقا للصالح العام نظرا لما يعود على المجتمع من خدمات إضافية نتيجة هذه

(١) وقد نص القرار المذكور في مادته الأولى على أن ينهي نشاط تجارة الجملة للخضر والفاكهة والدواجن والأسماك بسوقي روض الفرج وغمرة، وتلغي كافة تراخيص مزاوله النشاط بهما اعتبارا من يوم ١٩٩٢/٤/٥، تاريخ بدء العمل بسوق الجملة بالعبور.....

الزيادة المالية.

وانتهت المحكمة بعد هذه المقارنة أو الموازنة إلى القول بأنه "في هذه الحالة يتعين أن يكون مناط الرقابة منصبا على حق الجهة الإدارية في استعمال سلطاتها التقديرية، حيث تكون مرتبة الاختيار بين عدة أغراض وأهداف مما تتدرج تحت مدلول المصلحة العامة... . فإذا كانت هناك عدة أهداف من شأنها تحقيق مصلحة عامة، فإن للإدارة أن تختار من بين هذه الأهداف، ولكنها ليست مطلقة الحرية في هذا الاختيار ، إذ يجب عليها أن تختار الهدف الأكثر تحقيقا للمصلحة العامة... كما هو الحال، عندما يكون في زيادة الموارد المالية للدولة تحقيقا للصالح العام... غير أنه إذا كانت هذه الزيادة لا تتحقق إلا بتقييد بعض الحريات العامة والحقوق الفردية فقد يكون من الأجدى تحقيقا للمصلحة العامة أيضا الاستغناء عن تلك الزيادة المالية المتوقعة من التصرف الإداري في سبيل المحافظة على حقوق الأفراد والحريات العامة، ويجب المفاضلة والموازنة بينهما لتحديد أيهما أكثر تحقيقا لمصالح العام، أو بالأحرى أيهما يحقق المصلحة العامة الحقيقية فعلا.... وأنه ولئن كانت المصلحة العامة تقضى بحق جهة الإدارة بإنشاء أسواق جديدة المحملة خارج الكتلة السكانية وتحديد التاريخ الذي تراه مناسبا لتشغيله، فإن من مقتضى تحقيق التوازن بين تلك المصلحة العامة، وما قد ينجم عن تلازم ذلك الإنهاء الفوري للنشاط بالأسواق القائمة بالفعل بمناسبة الافتتاح من أضرار بالغة قد تلحق العديد من المواطنين، مما يوصهم القرار المطعون فيه بعدم الملاءمة التي تعد شرطا من شروط المشروعية وعنصرا لازما يكشف عن مدى مشروعية عمل الإدارة"^(١).

(١) الحكم الصادر في ١٩٩٢/٤/٢، الدعاوى أرقام ٢٧٩٠، ٣٤٥٢، ٣٧١٧، ٣٩٤٩، ٣٨٤٤، السنة ٤٦ ق، حكم غير منشور. انظر دكتورة/ نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع السابق، ص ٦١ وما بعدها.

إضافة إلى الحكّمين السابقين، فقد صدر بتاريخ ٩ / ٣ / ١٩٩١ حكم آخر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقام ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤ والذي تقول فيه: " أنه وإن كان من المسلم به قانوناً... أن للجهة الإدارية حق إزالة ما يقع من تعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري إلا أن سلطتها في ذلك وإن كانت سلطة تقديرية ، فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري... إن الأصل في نشاط الإدارة أن يستهدف الصالح العام، ويكون جوهر وظيفة الإدارة هو إشباع الحاجات العامة تحقيقاً لهذا الهدف، وبالتالي فإنه يجب على جهة الإدارة أن تصدر تصرفاتها بما يراعي الصالح العام ويناسبه وإن استهدف القرار المطعون فيه مصلحة عامة لا ريب فيها ، قوامها الحفاظ على ملك الدولة إلا أنه في الجانب الآخر، فإن القرار المطعون فيه في استهدافه تحقيق ذلك الوجه للمصلحة العامة فإن القرار قد ضحى بوجه مصلحة عامة آخر يتمثل في وجوب عدم تشريد عدد كبير من المواطنين بأسرهم ومنقولاتهم ومتعلقاتهم، إذ سيجد ذلك العدد الضخم من المواطنين نفسه، من جراء تنفيذ القرار وقد فقد مأواه وحمل متاعه وساق أسرته إلى غير مقر... (١).

ومن جانبها تقرر المحكمة الإدارية العليا كذلك: أنه لا يكفي للقول بأن القرار الإداري غير مشروع أن يكون قد جانب غايات الصالح العام الذي يحددها القانون وإنما يكون أيضاً كذلك أي غير مشروع "إذا استند إلى غاية من غايات الصالح العام يكون ظاهراً أو مؤكداً أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات وصور قومية أسمى وأجدر بالرعاية..." (٢).

(١) دائرة منازعات الأفراد والهيئات، الدعوى رقم ١٦٨١ السنة ٨٣ ق (غير منشور).
(٢) الطعن رقم ١٨٧٥، ١٩١٤، السنة ٣٠ ق (غير منشور)، دكتورة/ نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع السابق، ص ٥٨.

وكما هو واضح، لم يصدر هذا الحكم في مجال نزاع الملكية للمنفعة العامة، وإنما في مجال آخر هو التعديات على أرض مملوكة للدولة حيث تدور وقائعه حول القرار الذي أصدره محافظ القاهرة لصالح شركة - المعادى للتنمية والتعمير" يقضى بتسليم الأرض المملوكة للدولة المعروفة "بعزبة خير الله" بمنطقة دار السلام، وإزالة التعديات على هذه الأرض، وهدم ما عليها من منشآت ومبان يبلغ عددها ما يقارب عشرين ألف مسكن ويقطن بها ما يقرب من خمسين ألف نسمة".

وقد كان القضاء الإداري مستقرا في هذا الشأن على أنه "عندما تبسط المحكمة رقابتها على مشروع القرار الصادر بإزالة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة لا تفصل في النزاع حول الملكية ولا تتغلغل في فحص المستندات المقامة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها لإثبات الملكية. أساس ذلك أن القضاء المدني يفصل في موضوع الملكية. مؤدى ذلك أن رقابة المشروعية التي تسطها محكمة القضاء الإداري على هذه القرارات تجد حدها الطبيعي في التحقيق من أن سند الجهة الإدارية هو سند جدى له شواهد المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدي إداريا"^(١).

إلا أن القضاء الإداري قد خرج بالحكم المشار إليه (عزبة خير الله) عن هذه المبادئ المستقرة. إذ بعد أن تأكد له ثبوت ملكية الدولة للأرض المعتبرة عليها، بدأ يبحث في المصالح المتعارضة والتي يمسها القرار المطعون فيه، مصلحة الحفاظ على أرض مملوكة للدولة ومصلحة المواطنين القاطنين على هذه الأرض من التشريد نتيجة هدم منازلهم وجعلهم بالتالي دون مأوى يلجأون إليه؛ مرجحا في النهاية هذه المصلحة الأخيرة

(١) احكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بتاريخ ١١/٧/١٩٨٧، الطعن رقم ١٣٣٦ لسنة ٣٠، ج ١، ص ١٥٤، ص ٢١.

على المصلحة الأولى باعتبار أنها أولى بالرعاية والعناية ، الأمر الذي يدعو إلى القول - على الأقل من حيث الظاهر - بأن القضاء الإداري يطبق نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار في مجال التعديلات على أملاك الدولة.

حقيقة أن هذا القضاء كان حريصا على التأكيد بأن رقابته في هذه الحالة، إنما هي رقابة للغاية من القرار حيث تقول محكمة القضاء الإداري في وحكم خير الله: "إن القرار المطعون فيه قد شابته عوار في الغاية يبدو معها متنكبا صحيح حكم القانون". وتشاركها المحكمة الإدارية العليا هذا الرأي إذ تقول: "إن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعدم المشروعية لانحرافه عن الالتزام بغايات الصالح العام القومي بما يرجح معه إلغاؤه عند الفحص في طلب الإلغاء....".

وهذا يدل - كما أوضحنا من قبل - على أن الرقابة هنا هي رقابة مشروعية، بل وهو ما حرصت على تأكيده المحكمة الإدارية العليا، إذ تقول في حكمها السابق (عزبة خير الله): إن القاضي الإداري يظل في مثل هذه الحالات في نطاق رقابة "المشروعية" ولا ينتقل إلى ممارسة رقابة الملائمة، غاية الأمر أنه في هذه الحالات تختلط مناسبة العمل بمشروعيته ويلزم دائما ليكون العمل مشروعاً أن يكون ملائماً ومناسباً وهو ما تتبسط عليه رقابة المشروعية من القضاء الإداري... وذلك دون أن يكون ذلك إقحاماً للقضاء في السلطة التقديرية للإدارة..."، وهو ذات التأكيد الذي حرصت على إبرازه أيضاً محكمة القضاء الإداري في قضية "سوق روض الفرج" حيث تقول كما رأينا: "... مما يوصم القرار المطعون فيه بعدم الملائمة التي تعد شرطاً من شروط المشروعية وعنصراً لازماً يكشف عن مدى مشروعية عمل الإدارة".

واضح من هذه الأحكام جميعها أن القضاء الإداري المصري لم

يجهل تماما نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ، أو كما يقول البعض أن هذه النظرية ليست غريبة عن القضاء الإداري في مصر^(١). أن هذا القضاء قد "مال للأخذ بنظرية الموازنة بين المصالح المتعارضة، وترجيح بعضها على البعض الآخر، متى قام بينها تعارض في صورة آثار القرار من حيث ما يترتب عليه من منافع وما ينجم عنه من أضرار ، مستندا في ذلك إلى ما قد يؤدي إليه القرار المطعون فيه من أضرار اقتصادية واجتماعية..."^(٢).

بل لقد ذهب جانب من الفقه إلى حد القول بأنه بمطالعة حيثيات وأسانيد الحكم الصادر في قضية سوق روض الفرج السابق الإشارة إليه يتبين بوضوح كامل أن مجلس الدولة المصري قد طبق نظرية الموازنة التي استخدمها مجلس الدولة الفرنسي في ٢٨ مايو ١٩٧١ في قضية Ville nouvelle Est^(٣).

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الأحكام السابقة للقول بأن القضاء الإداري المصري قد اعتنق بشكل حاسم نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار وذلك بالكيفية التي هي عليها في أحكام مجلس الدولة الفرنسي.

فمن ناحية ، لم تطبق هذه النظرية حتى الآن - على حد علمنا في مجال نزاع الملكية للمنفعة العامة، وهو المجال الذي ولدت وترعرعت فيه في القضاء الإداري الفرنسي كما أوضحنا من قبل.

ومن ناحية أخرى ، فإن مجلس الدولة المصري حريص على أن

(١) دكتور/ سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص ٢٤٠.

(٢) دكتورة/ نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع السابق، ص ٥٠.

(٣) الدكتور/ محمود سلامة جبر، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين، مرجع سبق ذكره، ص ١٩٢.

يؤكد في أحكامه التي يوازن أو يقارن فيها بين مصالح متعارضة على أن الرقابة في هذه الأحكام لا تتجاوز مجرد رقابة المشروعية ، وأنها تتعلق فقط بالغاية من القرار الإداري، في حين أن رقابة الموازنة تتعلق - كما بينا ذلك تفصيلا - بمضمون أو بمحل القرارات الإدارية وكذلك بعنصر الملاءمة في هذه القرارات.

ولهذا يتساءل البعض من الفقه عما إذا كان حكم قضية "عزبة خير الله" يمثل بداية اتجاه جديد لمجلس الدولة في مصر؟ وقد أجاب على ذلك قائلا أنه "يبدو أن الإجابة على هذا التساؤل تعد سابقة لأوانها فالحكم وبما أتى به من مبادئ، وما تضمنه من أحكام يعد و فريدا من نوعه، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده للقول بأنه يمثل "اتجاها جديدا ، للقضاء الإداري في مصر..."^(١).

إن اتجاه مجلس الدولة المصري على النحو السابق وإن كان لازال متواضعا ولا يمكن أن يستدل منه على موقف حاسم في هذا الشأن ، إلا أنه يمثل في نظرنا خطوة هامة وجادة على الطريق الصحيح ، نأمل أن يدعمها بخطوات أخرى في هذا الاتجاه، مقتديا في ذلك بما حققه مجلس الدولة الفرنسي من تطور في هذا الشأن ، خاصة في المجالات التي أصبحت تهم الأفراد كثيرا في أيامنا هذه كالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حتى لا يصبح هؤلاء الأفراد دون حماية فاعلة في تلك المجالات ، وهي مجالات جديدة دون شك بالاهتمام والرعاية؟

(١) دكتورة/ نبيلة عبد الحليم كامل، المرجع السابق، ص ٦١.

خاتمة

خاتمة

من العرض السابق لكل من الاتجاهات التقليدية والحديثة في القضاء الإداري سواء في فرنسا أم في مصر للحد من سلطة الإدارة التقديرية، يتضح لنا أن مجلس الدولة في كل من البلدين خاصة في فرنسا قد عمل منذ إنشائه على تطوير رقابته في هذا المجال كلما سنحت الظروف السياسية والاجتماعية له بذلك، إدراكا منه أن هذه السلطة التقديرية هي التي تكمن فيها شبهة التعسف والاستبداد ، وأنه لا ملجأ للأفراد في مواجهة هذا أو ذاك سوى القضاء الإداري، خاصة أن الإدارة العامة تعمل من جانبها بكافة السبل على الاحتفاظ بأكبر قدر من حرية التقدير.

من هنا يمكن القول إن التطور الذي أصابته الرقابة القضائية في هذا الشأن إنما يجسد حقيقة الصراع بين الإدارة وما ترغب في أن يعترف لها به مجلس الدولة من حرية في التقدير وبين ما يريده هذا الأخير من تقليص لهذه الحرية ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم.

وقد ظهر جليا من دراستنا السابقة أن هذا التطور لم يحدث بين عشية وضحاها، وإنما منذ أمد بعيد بل ولم ينته بعد، إذ كلما خطا مجلس الدولة خطوة إلى الأمام في هذا الميدان وجد أن التطورات التي أصابت أنشطة الدولة ووظائفها قد اتسعت، واتسعت معها بالتالي سلطة الإدارة التقديرية، فيتبع الخطوة السابقة بخطوة أخرى ثم خطوة ثالثة وهكذا، سعيا منه للوصول الى نقطة التوازن المثلي والتي تتمكن الإدارة عندها من ناحية بتسيير مرافقها بما يحقق الصالح العام ويجد الأفراد فيها من ناحية أخرى ضمانا لحقوقهم وحرياتهم.

وقد استهل مجلس الدولة الفرنسي هذا التطور بإسقاط كافة حدود

السلطة المطلقة للإدارة والتي كانت تتجسد فيما يعرف بقرارات الإدارة البحتة وقرارات الإدارة التقديرية. فقد أصبحت كافة القرارات الادارية قابلة للطعن القضائي أمام مجلس الدولة إما لعيب في الاختصاص او لعيب في الشكل أو للعييبين معا.

ثم اخترق بعد ذلك حواجز السلطة التقديرية برقابة الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها بعد أن كان يتخذ تجاه هذه الوقائع موقفا سلبيا، إذ كان يعتبر نفسه قاضيا للمشروعية وليس قاضيا للملاءمة، أو أنه قاضيا للقانون لا قاضيا للوقائع. وقد بدأ ذلك برقابة صحة الوجود المادي لتلك الوقائع معمما رقابته هذه على كافة القرارات الإدارية دون استثناء. ثم خطا بعد ذلك خطوة أخرى إلى الأمام حينما بسط رقابته على التكييف القانوني للوقائع المشار اليها وإن كان قد أورد على هذه الرقابة استثناءات عديدة تمثلت في مجالات معينة كالضبط الاداري والمجالات ذات السمة الفنية أو التقنية تاركا للإدارة في هذا الخصوص حرية إجراء عملية التكييف القانوني دون أن يفرض رقابته عليها فيها

وبعد أن استقرت هذه الرقابة وخضع بالتالي الجانب الأكبر من أنشطة الإدارة التقديرية لرقابة القاضي الإداري اتجه مجلس الدولة نحو بسط رقابته على الملاءمة، أي رقابته على تقدير الإدارة لأهمية وخطورة الوقائع التي تدعيها لقراراتها ومدى تناسب الإجراء المتخذ مع هذا التقدير. مع ملاحظة أن مجلس الدولة لم يجعل من هذه الرقابة قاعدة عامة كما هو الحال في خصوص رقابة التكييف القانوني ، وإنما جعل منها استثناء يرد على القاعدة التي كانت سائدة في قضائه آنذاك وهي امتناع القضاء عن التدخل في هذا المجال.

أربع خطوات إذن أسقط بها مجلس الدولة الفرنسي أربعة حواجز

كانت تفصل بين النشاط التقديرى للإدارة وبين خضوع ذلك النشاط للرقابة القضائية: أولها إخضاع ذلك النشاط ذاته والتي كان يتجسد - كما ذكرنا - فيما يعرف بقرارات الإدارة البحتة والقرارات التقديرية لهذه الرقابة، وثاني هذه الخطوات رقابة الوجود المادي للوقائع والخطوة الثالثة رقابة التكليف القانوني للوقائع وأخيرا رقابة الملاءمة.

هذه الخطوات تمثل في رأينا الاتجاهات التقليدية للقضاء الإداري لحد من سلطة الادارة التقديرية، مع ملاحظة ان الوضع لم يختلف أمام مجلس الدولة المصرى عنه أمام نظيره الفرنسي ، حيث انتهج منذ إنشائه عام ١٩٤٦ ما انتهى إليه هذا الأخير من تطورات في هذا الشأن.

وإذا كانت الاتجاهات التقليدية على هذا النحو تتلاءم وبساطة الحياة الادارية وبعدها عن الشعب والتعقيد، فانه مع ظهور الوظائف الحديثة للدولة نتيجة تدخلها في مختلف الميادين وعلى كافة الأصعدة، الأمر الذي يعطى للإدارة مبررا للتوسع في سلطاتها التقديرية ولو على حساب حقوق الأفراد وحياتهم ، فإنه يصعب القول في الواقع بقدرة هذه الاتجاهات التقليدية في الحفاظ على التوازن عند النقطة التي تحقق التكافؤ بين طرفي المعادلة السابق الإشارة إليها . وبمعنى آخر يمكن القول إن تزايد نشاط الدولة وتطور وظائفها ومن ثم تعدد مجالات العمل الإداري ، أظهر ضعف وقصور أساليب وأنماط الاتجاهات التقليدية في الرقابة القضائية.

لقد أدرك مجلس الدولة الفرنسي هذا الوضع، مما دفعه في وقت حديث نسبيا، نحو اعادة النظر في هذه الأساليب وتلك الأنماط لمواجهة التوسع في مجالات السلطة التقديرية للحيلولة دون خطر انحرافها او التعسف في استخدامها، بل وحتى يستطيع ان يعيد التوازن إلى نصابه ويوفر بالتالي الحماية القضائية الحقوق الأفراد وحياتهم.

وفي سبيل تحقيق ذلك ابتدع مجلس الدولة نظرية رقابة الخطأ البين ليواجه بها أولاً المجالات التي امتنع في خصوصها عن رقابة التكيف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها، ثم مدها بعد ذلك إلى كافة مجالات العمل الإداري بل ونفذ من خلالها إلى صميم التقييم أو التقدير الذي تجريه الإدارة في تلك المجالات وذلك لكي يؤكد - كما أوضحنا مرارا خلال دراستنا المتقدمة - أنه لم يعد قاضيا للمشروعية فحسب وإنما أيضا قاضيا للملاءمة وقد أعمل المجلس هذه النظرية على كافة مستويات رقابته لأسباب القرارات الإدارية. فيما يتعلق بالرقابة الدنيا ، لم يعد يكتفى القاضي الإداري بمجرد إجراء الرقابة الثلاثية المعروفة وهي رقابة الوجود المادي للوقائع والخطأ في القانون وتجاوز السلطة أو الانحراف بها ، وإنما أضاف إلى ذلك الرقابة التي نحن بصدها وهي رقابة الخطأ البين والتي تتطلب من الإدارة - حيث تكون حرة في تقييم وتقدير الوقائع - أن يكون هذا التقدير أو التقييم معقولا ومنطقيا، أو بمعنى آخر ألا يكون مشوبا بخطأ جسيم أو خطأ واضح وجلي.

كما أنه مد هذا الوجه الحديث من أوجه الرقابة إلى مستوى الرقابة العادية وهي رقابة التكيف القانوني للوقائع، وكذلك إلى مستوى الرقابة القصوى والتي تتناول أهمية وخطورة الوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتها ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها.

على أن الوقوف على حقيقة هذا البناء القضائي الوليد اقتضى تحديد ماهيته وبيان مضمونه ومعياري أعماله خاصة أن أحكام مجلس الدولة الفرنسي قد حلت من وضع تعريف له أو بيان مختلف تلك العناصر، وهو ما تمت معالجته من خلال دراستنا هذه وقد انتهينا في هذه المسألة إلى أن الخطأ البين في التقدير هو الخطأ الذي يرى فيه القاضي الإداري من خلال

بحثه لملف الدعوى ولمختلف الظروف التي جرى فيها هذا التقدير، تجاوزا لحدود المعقولية، ووضوحا لدرجة البدهاة، ومن ثم فإن المعيار المعتمد للوقوف على هذا الخطأ إنما يجمع بين المعيار اللغوى والمعيار الموضوعي.

وهكذا نجح القاضي الإداري من خلال تلك النظرية في تحجيم الإدارة وحثها دوما عند اتخاذها لقرارات بمقتضى ما تتمتع به من سلطة تقديرية، أن تكون حذرة ويقظة من أن تقع في خطأ بديهي أو بين وإلا كان جزاؤها بطلان وإلغاء تلك القرارات. وبذلك وضع مجلس الدولة حدا جديدا يضاف إلى الحدود التقليدية السابقة على سلطة الإدارة التقديرية ويسهم به في توسيع نطاق الشرعية ورقابة القضاء على أعمال الإدارة.

ثم ما لبث أن بادر مجلس الدولة إلى خلق وابتداع بناء قضائي جديد يتسم بالجرأة والإقدام وهو ما يعرف بنظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. تلك النظرية التي تتيح للقاضي الإداري أن يأخذ في اعتباره عند تقييم مضمون قرار ما كافة الجوانب المتعلقة بهذا المضمون ، أو على الأقل كل ما يعتقد أن له أهمية خاصة في هذا الصدد سواء فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عنه، أم بالمزايا المترتبة عليه، بحيث يتمكن بعد ذلك من إجراء عملية معاييرة أو موازنة بين هذه وتلك من ناحية وبين الغاية أو الهدف من ذلك القرار من ناحية أخرى، فإذا انتهت عملية المعاييرة أو الموازنة هذه إلى ترجيح الأضرار، تعين عليه الحكم بإلغاء القرار، أما إذا كانت المزايا هي الراجحة أعلن عن صحة ومشروعية ذلك القرار.

وبهذه النظرية أوجد مجلس الدولة الفرنسي كذلك قيادا جديدا يحد من سلطة الإدارة التقديرية وإن كانت لم تباشر بعد إلا في خصوص قرارات إدارية معينة كالتى تتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة أو بحماية البيئة أو بالتخطيط والتنظيم العمراني، وذلك على عكس رقابة الخطأ البين التى

أصبحت تمثل نظرية عامة في فقه وقضاء القانون العام . إضافة إلى أن هذه النظرية الأخيرة تتعلق أساساً بأسباب القرار الإداري أو بالوقائع التي تستند إليها تلك القرارات في حين أن نظرية الموازنة تتعلق بمحل أو مضمون القرار الإداري.

وهكذا يعمل مجلس الدولة جاهداً على أن يكسب أرضاً جديدة في مواجهة الإدارة وذلك بتقييد سلطاتها التقديرية، أو بالحد من تلك السلطة إذ كلما خطا في هذا المجال خطوة تبعها بأخرى تأكيداً لاستمراره في هذا الاتجاه، الأمر الذي دعا كثيراً من رجال الفقه الإداري إلى التساؤل حول مصير السلطة التقديرية للإدارة، وما إذا كانت هذه السلطة قد انتقلت إلى القاضي الإداري؟ أم أنها في طريقها إلى الزوال؟

إننا نؤكد في خاتمة هذا البحث أن السلطة التقديرية باقية للإدارة ولن تزول إلا بزوال هذه الإدارة، كل ما في الأمر أن القاضي الإداري برقابته لتلك السلطة سواء عن طريق فكرة الخطأ البين أو فكرة الموازنة بين التكاليف والمزايا، إنما أوجد توازناً جديداً لهذه السلطة، حيث استطاع عن طريق هذه الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية أن يضع معايير جديدة لكيفية مباشرتها، ومن ثم الحد من إساءة استخدامها. أو بمعنى آخر استطاع أن يضع معايير جديدة تساعد رجل الإدارة على استخدام هذه السلطة استخداماً معقولاً أو استخداماً لا يتنافى مع الصالح العام، وبمعنى أعم استخداماً يتلاءم مع ما يجب أن يتسم به التوازن بين هذا الصالح وبين حقوق الأفراد وحرياتهم من تكافل وتعادل.

بل وإذا قيل بأن الاتجاهات القضائية الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي تؤدي بالقاضي إلى رقابة الملاءمة، الأمر الذي ينقص من استقلال رجل الإدارة أو يتضمن اعتداء على اختصاصاته ، فإن مثل هذا القول إنما يتنافى

مع الواقع والحقيقة حتى ولو لم تكن الملاءمة شرطا لأية مشروعية، ذلك أن القاضي الإداري بإعماله لتلك الاتجاهات وإن كان يحل تقديره الشخصي لملاءمة التصرف محل تقدير رجل الإدارة لتلك الملاءمة ، عندما يكون هذا التقدير مشوبا بخطأ بين أو بالمبالغة واللامعقولية، إلا أنه لا يحل ذاته محل رجل الإدارة، سواء في اتخاذ القرار الذي يرى أنه أكثر ملاءمة، أم في تعديل مضمون القرار المطعون فيه مع الإبقاء عليه، فمثل هذه الأمور متروكة تماما لحرية جهة الإدارة . فأى انتقاص إذن من استقلال رجل الادارة وأي اعتداء على اختصاصاته؟!

ولهذا نرى أنه كان أجدر بأنصار الرأي السابق بدلا من أن يوجهوا نقدهم ولومهم إلى القضاء الإداري حينما تبني الاتجاهات الحديثة في الرقابة أن يتوجهوا بدلا من ذلك إلى الإدارة ناصحين ومرشدين إياها، بأن تكون قراراتها رشيدة ومتسمة بالعقلانية والمنطق، وأن تكون محققة للتوازن المنشود بين مختلف المصالح المرتبطة بها حتى لا تكون عرضة للإلغاء من جانب القضاء . وهذا ما يؤكد الفقيه الكبير قالين حينما قال: إننا اذا كنا نخشى من جرأة القاضي الإداري بما يمنحه لنفسه من سلطات في هذا الصدد فإنه يجب الاعتراف في ذات الوقت بأن أخطاء الإدارة وقصورها في كيفية مباشرة أعمالها هي التي تبرر مثل هذه الجرأة.

وإذا كان مجلس الدولة المصري قد تبني منذ نشأته - كما ذكرنا - الاتجاهات التقليدية التي استقرت في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، إلا انه لم يساير هذا الأخير في الاتجاهات الحديثة له حيث لم يطبق حتى الآن بشكل حاسم لا نظرية رقابة الخطأ البين في التقدير ولا نظرية الموازنة بين المنافع والاضرار . حقيقة أنه سبق مجلس الدولة الفرنسي في ابتداعه لنظرية لقضاء الغلو، ولكنه اقتصر في تطبيقها على المجال التأديبي فقط

دون أن يجعل منها نظرية عامة في فقه وقضاء القانون العام على غرار نظرية الخطأ البين في التقدير.

ولهذا نأمل ألا يتأخر مجلس دولتنا الفتى عن مساهمة ركب التطور الذي أصابه نظيره الفرنسي في الرقابة على قرارات الإدارة الصادرة منها بمقتضى مالها من سلطة تقديرية باعتباره الحصن الأمين لضمان وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم ضد عسف وتسلط الإدارة . ومما لا شك فيه أن التطبيقات القضائية العديدة التي أوردناها لمجلس الدولة الفرنسي في إطار الاتجاهات القضائية الحديثة له، وكذلك الضوابط النظرية والعملية لتلك التطبيقات، سوف تلقى المزيد من الضوء حول هذه الاتجاهات، الأمر الذي قد يهيئ لمجلس الدولة المصرى السبيل نحو تبنيها أو الإسراع في تطبيقها في كافة المجالات الإدارية التي تصدر عن الإدارة بمالها من سلطة تقديرية.

بحمد الله وتوفيقه،،

المراجع

- ১০০ -

.

المراجع

اولا: باللغة العربية:

احمد كمال الدين موسى:

نظرية الاثبات في القانون الاداري، رسالة، جامعة القاهرة، ١٩٧٧.

احمد كمال ابو المجد:

الدور الانشائي للقضاء الاداري بين المذاهب الشكلية والمذاهب الموضوعية في القانون، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثانية والثلاثون، العدد الثالث، ١٩٦٢.

السيد محمد ابراهيم:

- الرقابة على الوقائع في قضاء الالغاء، رسالة، جامعة الاسكندرية.
- الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية تعليق على حكم المحكمة الادارية العليا في ١١ نوفمبر ١٩٦١، مجلة العلوم الادارية، السنة الرابعة، العدد الثاني، ديسمبر ١٩٦٢.
- مبدأ الفصل بين الهيئات الادارية والقضائية، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الخامسة عشر، ١٩٧٠.

أيمن محمد حسن:

المشروعية الادارية وحدود رقابة الملاءمة، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الثامنة والعشرون، يناير، ومارس ١٩٨٤.

بكر القباني:

العرف كمصدر للقانون الاداري ، القاهرة.

توفيق شحاته:

مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٥٤-
١٩٥٥.

ثروت بدوى:

- الدولة القانونية، مجلة قضايا الحكومة، السنة الثالثة، العدد الثالث،
يوليو ١٩٥٩.

- مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٨٤.

ثروت عبد العال احمد:

الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية، رسالة، جامعة اسيوط،
١٩٩٢.

حمدى ياسين عكاشة:

القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، ١٩٨٧.

رمزى الشاعر:

تدرج البطالان في القرارات الإدارية، القاهرة، ١٩٦٨.

سعاد الشرقاوى:

- الانحراف في استعمال السلطة وعيب السبب، تعليق على احكام
المحكمة الادارية العليا، مجلة العلوم الادارية، السنة الحادية عشر،
العدد الثالث، ديسمبر ١٩٦٩.

- القضاء الإداري، القاهرة ١٩٨٤.

سليمان الطماوي:

- نظرية التعسف في استعمال السلطة، الطبعة الثانية، ١٩٦٦، والطبعة الثالثة، ١٩٧٨.
- النظرية العامة للقرارات الادارية، الطبعة السادسة ١٩٩١.
- القضاء الاداري، الكتاب الأول، قضاء الالغاء، طبعة ١٩٧٩.

طعيمه الجرف:

- مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، القاهرة ١٩٦٣.
- القانون الاداري ، القاهرة ١٩٧٨.
- القضاء مصدر انشائي للقانون الاداري، مجلة ادارة قضايا الحكومة، السنة السادسة، ١٩٦٢، العدد الرابع.

عبد الحميد صدقي:

- مدى رقابة محكمة القضاء الاداري على سلطة الادارة التقديرية، مجلة مجلس الدولة، السنة الخامسة ١٩٥٤.

عبد الحميد كمال حشيش:

- مبادئ القضاء الاداري، القاهرة ١٩٧٧.

عبد الرزاق السنهوري:

- تقديم العدد الأول لمجلة مجلس الدولة، السنة الاولى ، يناير ١٩٥٠.

عبد الفتاح حسن:

- التأديب في الوظيفة العامة، القاهرة ١٩٦٤.
- محاضرات في الوظيفة العامة لطلبة دبلوم العلوم الادارية، كلية

الحقوق، جامعة القاهرة ، ١٩٦٣.

عصام عبد الوهاب البرزنجي:

السلطة التقديرية والرقابة القضائية على أعمال الإدارة، رسالة جامعة القاهرة، ١٩٧١ .

على سمير صفوت:

مجلس الدولة، قاضي الوقائع ، مجلة مجلس الدولة، السنة الخامسة ١٩٥٤.

عمر فؤاد بركات:

مبادئ القانون الاداري، ١٩٨٥.

فؤاد العطار:

- القضاء الاداري، القاهرة ١٩٦٦.

- مبادئ القانون الاداري ، القاهرة ١٩٧٢.

اجد راغب الحلو:

القضاء الاداري، الاسكندرية، ١٩٨٥.

محسن خليل:

القضاء الاداري ورقابته لأعمال الإدارة، ١٩٦٨.

محمد اسماعيل علم الدين:

التزام الإدارة القانوني في ممارسة السلطة التقديرية، في الفقه والقضاء الفرنسي، مجلة العلوم الادارية، العدد الثالث، السنة الثالثة عشر، ديسمبر ١٩٧١.

محمد انس قاسم جعفر:

الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري، ١٩٨٧.

محمد حسنين عبد العال:

فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء، رسالة، جامعة القاهرة،
١٩٧١.

محمد عبد الجواد حسين:

بين سلطة الإدارة التقديرية واختصاصها المقيد مجلة، مجلس الدولة،
السنة الرابعة، ١٩٥٣.

محمد عبد الحليم شوقي الخطيب:

الدور السياسي للقاضي الإداري في مصر، رسالة، جامعة اسيوط،
١٩٨٨.

محمد عبد الحميد أبو زيد:

الطابع القضائي للقانون الإداري، دار النهضة العربية، ١٩٨٤.

محمد عصفور:

مذاهب المحكمة الإدارية العليا في الرقابة والتفسير والابتداع، القاهرة،
١٩٥٧.

محمد فريد سيد سليمان:

الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، رسالة، جامعة
المنصورة، ١٩٨٩.

محمد فؤاد مهنا:

دروس في القانون الاداري، ١٩٥٦ - ١٩٥٧.

محمد كامل ليله:

- مبادئ القانون الاداري، الطبعة الاولى، ١٩٦٨.

- الرقابة على اعمال الادارة ، بيروت، ١٩٦٨.

محمد متولى صبحي:

حدود رقابة قضاء الالغاء، مجلة ادارة قضايا الحكومة، السنة ١٨،
العدد الثاني.

محمد ميرغنى خيرى:

- نظرية التعسف في استعمال الحقوق الادارية، رسالة جامعة عين
شمس، ١٩٧٢.

- المبادئ العامة للقانون الاداري المغربي، الطبعة الثالثة، ١٩٨٢.

محمود حلمي:

حق القضاء في تعديل القرار الاداري، مجلة العلوم الادارية السنة،
السادسة، العدد الثاني، ١٩٦٤.

محمود عاطف البنا:

حدود سلطات الضبط الاداري، القاهرة، ١٩٨٠.

محمود سلامه جبر:

- الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الالغاء، مجلة ادارة قضايا

الحكومة، العدد الرابع، السنة الثامنة والعشرون، ١٩٨٤.

- رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكييف الوقائع وتقديرها
في دعوى الإلغاء، رسالة، جامعة عين شمس ١٩٩٢.

مصطفى ابو زيد فهمي:

القضاء الاداري ومجلس الدولة، ١٩٧٩.

مصطفى حسن:

السلطة التقديرية في القرارات الادارية، رسالة جامعة عين شمس،
١٩٧٤.

مصطفى كامل:

مجلس الدولة، الطبعة الاولى، القاهرة، ١٩٥٢.

مصطفى كمال وصفي :

النظرة الحديثة للمشروعية، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص بمناسبة
اليوبيل الفضى للمجلة عن السنوات من العشرين الى الخامسة
والعشرين.

نبيله عبد الحليم كامل:

دور القاضي الإداري في الرقابة على شروط المنفعة العامة في حالة
نزع الملكية (الاتجاه الحديث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا)، دار
النهضة العربية، ١٩٩٣.

ثانيا: المراجع الفرنسية:

OUVRAGES GENERAUX

AUBY (J. M.), DRAGO (R):

Traité de contentieux administratif, 3e éd., Paris,
L.G.D.J., 2 Tomes, 1984.

BENOIT (F. P.):

Le droit administratif français, Dalloz, 1968.

Barthelemy (J.):

traité élémentaire de droit administratif, 1926.

BRAIBANT (G.):

Le droit administratif français, Dalloz, Paris, 1984.

CHAPUS (R.):

Droit administratif général, Montchrestien, Paris, t.1,
1985, t II, 1988.

DEBBASCH (Ch.):

contentieux administratif, 4e éd., Paris,Dalloz, 1985.

DUGUIT (L.):

Traité de droit constitutionnel, Ancienne Librairie
Fontemoing et Cie, Paris, tome 1 et tome II, 1923.

DUPUIS (G.), GUEDON (M. J.):

Institutions administratives droit administratif, Armand Colin, Paris, 1986, 2e éd., 1988.

EISENMANN (Ch.):

Cours de droit administratif, Paris, L. G. D. J., tome I, 1982, et tome II, 1983.

HAURIOU (M.):

Précis de droit administratif, Sirey, 11e éd., 1927, 12e éd., 1933.

LAUBADÈRE (A. de.):

Traité de droit administratif, Paris, L. G. D. J., t. I, 9e éd., mise à jour par VENEZIA (J. C.) et GAUDEMET (Y.), 1984, 10e éd., 1988.

LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.):

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 8e éd., Paris, Sirey, 1984.

ODENT (R):

Contentieux administratif, fasc. VI, Les Cours de Droit, Paris, 1981.

RIVERO (J.):

Droit administratif, 11e éd., Paris, Dalloz, 1985, Les libertés publiques, 4e éd., Paris, P. U. F., 1984.

VEDEL (G.), DELVOLVE (P.):

Droit administratif, 7e éd., Paris, P. U. F., 1980.

WALINE (M.):

Précis de droit administratif, Montchrestien, 1969.

OUVRAGES SPECIALISES ET THESES

ALIBERT (R.):

Le contrôle juridictionnel de l'Administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, Payot, Paris, 1926.

ATIAS (Ch.), LINOTTE (D.):

Le remembrement rural, Paris, LITEC, 1980.

AUBY (J. B.), PERINET (H.):

Droit de l'urbanisme et de la construction, Paris, Montchrestien, 1987.

BOURGOIS (J. P.):

L'erreur manifeste d'appréciation, l'Espace Juridique, Université de Lille, 1988.

BRAIBANT (G.):

QUESTIAUX (N.), WIENER (C.) Le contrôle de l'Administration et la protection des citoyens, Cujas, 1973.

CASTAGNE (J.):

Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de police administrative, thèse, Paris, L.G.D.J., 1964.

CHATEAUREYNAUD (Ph.):

Le contentieux de l'expropriation, thèse, Paris. 1977.

CHERIGNY (B.):

Le juge administratif, gardien de la moralité des administrés, thèse, 2 vol., Poitiers, 1968.

CHEVALLIER (J.):

L'élaboration historique de la juridiction administrative et de l'Administration active, thèse, Paris, L.G.D.J., 1970.

CHEVALIER (J. P.):

La crise du principe d'égalité dans ses rapports avec l'interventionnisme économique en droit public français, thèse, 2 vol., poitiers, 1968.

CHRETIEN (P.):

L'utilisation de la méthode analytique par le juge de l'excès de pouvoir, thèse, Paris, 1979.

DIQUAL (L.):

La compétence liée, L.G.D.J., 1964. DRAN (M.), Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, thèse, Montpellier, L. G. D. J., 1968.

DUBISSON (M.):

La distinction entre la légalité et l'opportunité dans le recours pour excès de pouvoir, thèse, Paris, L.G.D.J., 1957.

DUPUIS (G.):

Les privilèges de l'Administration, thèse, Paris, 1962.

FRAYSSE DRYESNE (Gh.):

La lutte contre l'arbitraire en droit public français, thèse, Paris, 1977.

GAUDEMET (Y.):

Les méthodes du juge administratif, thèse, Paris, L. G. D. J., 1972.

GOLDENBERG (L.):

Le Conseil d'Etat juge du fait, thèse, Paris, Dalloz, 1932.

HAMSON (C. J.):

Pouvoir discrétionnaire et contrôle juridictionnel de l'Administration, A. Cocâtre, L.G.D.J., 1958.

IMBERT (L.):

L'évolution du recours pour excès de pouvoir (1872-1900), Paris, Dalloz, 1952.

IVAINER (Th.):

L'interprétation des faits en droit, thèse, Paris, L.G.D.J., 1988.

JOLLIOT(M.):

Les insuffisances du contrôle des actes de l'Administration par le juge administratif, thèse, Paris, 1975.

KOUTOUPA (E.):

Le pouvoir discrétionnaire de l'Administration interventionniste en droit français, thèse, 2 vol., Paris, 1987.

LAGASSE (D.):

L'erreur manifeste d'appréciation en droit administratif,
Bruylant, Bruxelles, 1986.

LAMARQUE (J.):

Droit de la protection de la nature et de l'environnement,
Paris, L. G. D. J., 1973.

LANDON (P.):

Histoire abrégée du recours pour excès de pouvoir des
origines à 1954, L. G. D. J., 1962.

LEBRETON (G.):

Le pouvoir discrétionnaire exercé par l'administration
française sur ses agents (évolution depuis le XVIIIe
siècle), thèse, Paris, 1988.

LODOVICI (J.):

L'évolution de la notion de pouvoir dis-
crétionnaire, thèse, Lille, 1973.

LOSCHAK (D.):

Le rôle politique du juge administratif, français, thèse,
Paris, L.G.D.J., 1972.

ODENT (B.):

La politique immobilière et le juge administratif, thèse, Paris, 1974.

PACTEAU (B.):

Le juge de l' excès de pouvoir et les motifs de l'acte administratif, Travaux et recherches de la faculté de Droit et de la Science Politique de l'Université de Clermont, L. G. D. J., 1977.

PICARD (E.):

La notion de police administrative, thèse, Paris, L.G.D. J., 1984.

KOUTOUPA-RENGAKOS (E.):

Le pouvoir discrétionnaire de l'administration, interventionniste en droit Français, paris, 1987.

PIALS (S.)

Le juge administratif français et la technique du standard (essai sur le traitement juridictionnel de l'idée de normalité), thèse, Paris, L.G.D.J., 1980.

ROUSSEAU (D.):

Le contrôle de l'opportunité de l' action administrative par

le juge administratif, thèse, 2 vol., Poitiers, 1979.

SAVY (R.):

Droit de l'urbanisme, Paris, P. U. F., 1981.

STAVROULA (K.):

L'évolution du contrôle juridictionnel des motifs de l'acte administratif, thèse, Paris, L.G.D.J., 1991.

TERRE (F.):

L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications, thèse, Paris, L.G.D.J., 1956.

VALLERY-RADOT (M.):

Remembrement rural et jurisprudence du Conseil d' Etat, OCEP COUTANÉS, 1981.

VEDEL (G.):

Essai sur la notion de cause en droit administratif français, thèse, Toulouse, Sirey, 1934.

VENEZIA (J. C.):

Le pouvoir discrétionnaire, thèse, Paris, L.G.D.J., 1958.

VERRIER (P.):

Le contrôle des motifs en droit administratif, thèse, Paris, 1976.

WEI-TENG-LIN:

Le pouvoir discrétionnaire de l' administration et le contrôle juridictionnel en droit français, thèse, Lyon, 1944.

WELTER (H.):

Le contrôle juridictionnel de la moralité administrative, thèse, Nancy, Sirey, 1929.

ARTICLES ET CHRONIQUES

BAGUERNARD (J.):

Le contrôle par le juge administratif de la légalité des dérogations en matière d'urbanisme, *Gez. Pal.*, 1974, 1^{er} sem., p. 316.

BERNARD (M.):

Le contrôle du Conseil d'Etat sur l' appréciation par l'Administration de l' aptitude professionnelle ou physique des fonctionnaires; *E. D. C. E.*, 1957.

BIASCA (P.):

- Les dérogations en matière d' urbanisme et de construction; *Gaz. Pal.*, 1967, 1^{er} sem., p. 61.
- La notion d' utilité publique et son contrôle; *Gaz. Pal.*,

1972, 2e sem., p. 497.

BLUMANN (C.):

Le contrôle juridictionnel des dérogations en matière d'urbanisme; R. D. P. 1975, p. 5.

BOCKEL (A.):

- Contribution à l'étude du pouvoir discrétionnaire de l'Administration; A. J. D. A., 1978 p. 355.
- Actualité et perspectives du contrôle de l'interventionnisme économique; A. J. D. A., 1983 p. 8.

BOLLE et DELCROS:

La règle de l'équivalence dans le contentieux du remembrement rural; A.J.D.A., 1976 p. 122.

BONNARD (R.):

Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir, R.D.P., 1923. p. 362.

BOUYSSOU (F.):

Le contentieux administratif des plans d'occupation des sols; E.D.C.E., 1983, p. 81.

BRAIBANT (G.):

- Développement du contrôle exercé par le Conseil d'Etat sur les expropriations; Rev. adm., 1971, P. 42.
- Le principe de proportionnalité; in Mélanges M. WALINE, LG. D. J., 1974, t. II, p. 297.

BUNIET (C):

Contribution à l'étude du régime contentieux des polices administratives spéciales; R.D.P., 1981, p. 1017.

CHABANOL (D.):

Contrôle de légalité et liberté de l'Administration; A.J.D.A., 1984.

CHAPUISAT (L.J.):

Le droit administratif à l'épreuve de l'urbanisme dérogatoire; A. J. D. A., 1974.

CHEVALLIER (J.):

- L'interdiction pour le juge administratif de faire acte d'administrateur; A. J. D. A., 1972,
- La dimension symbolique du principe de légalité; R.D.P., 1990, p. 1651.

CINTURA (P.):

L'usage et la conception de l'équité par le juge administratif; R.I.D.C., 1972.

CORAIL:

Le juge administratif et la qualification des interventions de l'Etat dans le domaine de l'économie; in Mélanges Ch. EISENMANN, Cujas, 1977.

COSTA (J.P.):

Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence du conseil d'Etat; A.J.D.A., 1988.

COULET (W):

La protection de l'environnement dans le contentieux de l'urbanisme; Droit et ville, 1979,n8.

DEBBASCH:

Le droit administratif face à l'évolution de l'Administration française; in Mélanges M. WALINE, L.G.D.J., 1974, t. II.

DELMAS-MARSELET (J.):

- Le contrôle juridictionnel des interventions économiques de l'Etat ; E.D.C.E., 1969, N 22.

- Existe-t-il un contrôle de l'opportunité ? Intervention au colloque des 21 et 22/1/1988 au Sénat, L.G.D.J., Montchrestien, 1988.

DOMESTICI – MET (M.J.):

Utilité publique et privée dans le droit de l'expropriation;
D. chr. 1981.

DRAGO (R.):

- Le défaut de base légale dans le recours pour excès de pouvoir; E.D.C.E., 1960.
- Aspects du contrôle exercé par le juge administratif sur la politique économique ; in Mélanges GANSHOF van der MEERSCH, L.G.D.J., 1972, t. III.

DREYFUS (F.):

Les limitations du pouvoir discrétionnaire par l'application du principe de proportionnalité : à propos de trois jugements du Tribunal administratif de l'o.I.T.; R.D.P., 1974.

DUPEYROUX (J.J.), GARAGNON (J.):

Le contentieux de la notoriété médicale; D.chr. 1962.

DUPUIS (G.):

Les motifs des actes administratifs;

E.D.C.E., 1975.

FINKEL (G.):

L'expulsion des étrangers et le juge administratif en droit français ; A.J.D.A., 1978.

FRANC et BOYON:

A propos de la police administrative et la presse; chronique générale de jurisprudence administrative; A.J.D.A., 1973.

FROMONT (M.):

Le contrôle de l'appréciation des faits économiques dans la jurisprudence administrative; A.J.D.A., 1966.

GABALLERO (F.):

Le Conseil d'Etat, ennemi de l'environnement? Rev. jur. environnement, 1984.

GALABERT et GENTOT:

Le contrôle de l'erreur manifeste par le juge de l'excès de pouvoir ; chronique générale de jurisprudence administrative; A.J.D.A., 1962.

GANDOLFI (A.):

Les motifs déterminants dans le recours pour excès de

pouvoir; J.C.P., 1964, 1835.

GEORGEL (J.):

Les sanctions administratives; J.C.A., 1986, t. II, fasc. 202, 11.

GILLY (J.P.):

- Le rôle du juge administratif en matière d'expropriation; A.J.D.A., 1973.
- Le nouveau droit du permis de construire, Revue de droit immobilier, Sirey, 1984, n° H.S.,

GIRAUD (E.):

Etude sur la notion de pouvoir discrétionnaire; R.G.A., 1924.

GVIBAL:

De la proportionnalité; A.J.D.A., 1978.

GREVISSE (S.):

Pouvoir discrétionnaire et opportunité des décisions administratives; étendue et limites du contrôle juridictionnel – Rapport français; E.D.C.E., 1976.

HARDY (J.):

Le statut doctrinal de la jurisprudence en droit

administratif français; R.D.P., 1990.

HAURIOU (A.):

Le pouvoir discrétionnaire et sa justification; in Mélanges
R. CARRE DE MALBERG, Sirey, 1933.

HENRY (J.P.):

Une nouvelle fonction pour l'erreur manifeste; A.J.D.A.,
1979.

HEUMANN, NAUWELAERS, FABIUS:

Dix ans de jurisprudence du Conseil d'Etat (1967-1976);
E.D.C.E., 1976.

HOLLEAUX (A.):

La jurisprudence du bilan; Rev. adm., 1980.

HOSTIOU(A.):

L'évolution du contrôle juridictionnel de la notion d'utilité
publique en matière d'expropriation; A.J.P.I., 1973.

HUET (ph.):

La juridiction administrative, gardienne de la liberté
individuelle; A.J.D.A., 1973.

JACQUOT(H.):

Les directives d'urbanisme et d'aménagement du

territoire; in Mélanges E.CHARLIER, éd.de 1, Université et de l'enseignement moderne, Paris, 1981.

KAHN (J.):

Le pouvoir discrétionnaire et le juge administratif; Cahiers de l'I.F.S.A., Cujas, 1978, n° 16.

KERCHOVE(M.van der):

Jurisprudence et rationalité juridique; in Archives de philosophie du droit, Sirey, 1978, t.XXIII.

KORNPROBST(B.):

La compétence liée; R.D.P., 1961, L'erreur manifeste; D.chr. 1965.

LABAYLE(H.):

Le juge administratif et le contrôle contentieux de l'extradition; R.F.D.A., 1985.

LABETOULLE(D.):

- Le pouvoir discrétionnaire en matière d'urbanisme et interventionnisme économique; Cahiers de l'I.F.S.A., n°16, 1978.
- Le contentieux du nouveau droit de l'urbanisme: analyse prospective; Revue de droit immobilier, Sirey, 1984, n° H.S.

LABETOULLE et CABANES:

- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- erreur manifeste d'appréciation; chronique de jurisprudence, A.J.D.A., 1971.
- Notion d'utilité publique, contrôle du juge de l'excès de pouvoir; chronique de jurisprudence, A.J.D.A., 1971.

LACHAUME(J.F.):

Remarques sur quelques aspects récents du renforcement jurisprudentiel de la compétence de la juridiction administrative; in Mélanges M. WALINE, L.G.D.J., 1974, t.II.

LAFERRIERE(F.J.):

L'évolution récente du droit français de l'extradition; R.D.P.1979.

LANVERSIN(J.de):

Contribution du juge au développement du droit de l'environnement; in Mélanges M. WALINE, L.G.D.J., 1974, 1.1.

LASKI(H.):

Le pouvoir discrétionnaire; Annuaire de l'Institut International de Droit public, Sirey, 1936.

LAUBADERE(A.dE):

Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans la jurisprudence récente du Conseil d'Etat; in Mélanges M.WALINE, L.G.D.J.,1974,t.II.

LAUN(M.R.):

Le pouvoir discrétionnaire; Annuaire de l'Institut International de Droit public, Sirey, 1936.

LEMASURIER(J.):

Expropriation-"Billan: coût- avantages" et nécessité publique; Rev.adm.,1979.

LETOURNEUR(M.):

- L'apparition de nouveaux éléments subjectifs dans le recours pour excès de pouvoir ;E.D.C.E.,1935.
- L'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir;E.D.C.E.,1962.
- L'évolution récente de la jurisprudence administrative pour la protection des droits des citoyens; R.I.S.A.,1965.
- L'erreur manifeste d'appréciation dans la jurisprudence du Conseil d'Etat; in Mélanges GANSHOF van der MEERSCH,t.III.

LIET-VAUX(G.):

L'âge du pouvoir discrétionnaire, progrès du contrôle des motifs; Rev. adm., 1966.

LOSCHAK(D.):

Les étrangers face au pouvoir discrétionnaire de l'administration, in de pouvoir discrétinnair et le juge adminstratif"; Cahiers de l'I.F.S.A.,Cujas, 1978,n 16.

MASSOT et DEWOST:

Urbanisme et aménagement du territoire b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir; cas où l'administration se fonde sur plusieurs motifs: pouvoir discétionnaire; chroniques de jurispru dence, A.J.D.A.,1968.

MESTRE – Contrôle des motifs;

in Encyclopédie Dalloz, Contentieux administratif,t.II, Dalloz,1985,mise à jour 1989.

MICHOUD(L.):

Etude sur le pouvoir disctétionnaire de l'Administration, in Annales de l'Université de Grenoble, Gauthier-Villars, paris, 1913 t.XXV. ett.XXVI, 1914.

MODERNE(F.):

L'extension du contrôle juridictionnel à la corrélation
faute disciplinaire mesure disciplinaire dans le droit de la
fonction publique; Rev.adm., 1978.

MOUSSA(H.):

- Aspects de l'erreur manifeste d'appréciation et des
pouvoirs discrétionnaire et lié.Prétendu droit de
l'administration à l'erreur non manifeste et présomption
quasi-irréfragable de légalité;chronique de
jurisprudence, le"quotidien juridique", 1987,nos 45, 46
et47.
- Expropriation pour cause d'utilité publique;chronique de
jurisprudence,le"quotidien juridique", 1978.nos 62 et63.

PASBECQ(CH):

De la frontière entre la légalité et l'opportunité dans la
jurisprudence du juge de l'excès de pouvoir; R.D.P.,
1980.

PEISER(G.):

Le juge administratif et les dérogations; inMélanges M.
WÄLINE,L.G.D.J., 1974, t. II.

PERROT(R.):

Le rôle du juge dans la société moderne; Gaz.Pal.,
1977,1er sem.

PLOUVIN(J.Y.):

Les audaces du contrôle de l'expulsion des étrangers
par le juge administratif; Dr.socil.

RAUX(J.):

L'examen des faits par le juge administrative dans le
contrôle de la légalité interne de la procedure
d'expropriation; A.J.D.A., 1967

REGLADE(M.):

Du prétendu contrôle juridictionnel de l'opportunité en
matière de recours pour excès de pouvoir;
R.D.P.,1925.

REYDELLET(M.):

Le contrôle de la gravité des sanctions OMDIVUA AB
disciplinaires; in annuaire européen d'Administration
publique, C.N.R.S., 1979.

RIALS(S.):

- Sur une distinction contestable et un trop réel déclin (à

propos d'un récent article sur le pouvoir normatif du juge); A.J.D.A., 1981.

- Les standards, notions critiques du droit; études publiées par Ch. PERELMAN et R.VANDER ELST, ylant, Bruxtelles, 1984.
- Pouvoir discrétionnaire; in Encyclopédie Dalloz ontentieux adiministratif, T.11, Dalloz, 1985, mise à jour 1989.

Ouverture:

L'office du juge; "Droits", 1989.

ROBERT(J.):

Le juge administratif et la liberté indivi- delle; in Mélanges m.WALINE,L.G.D.J.,1974,t.II.

RODO(L.):

Le pouvoir discrétionnaire de l'Administration, évolution doctrinale et jurisprudentielle; R.D.P.,1953.

ROMI(R.):

Le droit de l'environnement vers la maturité? R.D.P.,1990.

ROUVIERE(J.):

Réflexions sur l'erreur manifeste;E.D.C.E.,1988.

SAUVIGNON (Ed.):

La pluralité des motifs dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de vant le juge de l'excès de pouvoir; A.J.D.A., 1971.

SCHRAMECK(O.):

L'erreur manifeste du conseil supérieur de la fonction publique territoriale; A.J.D.A., 1987.

SINAY(H.):

Le contôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires au regard des fautes commises: dualité de jurisprudence administrative et judiciaire; Dr.social, 1979.

SOUDET(P.):

Nécessité et limites du contrôle cinématographique; E.D.C.E., 1978.

TIMSIT(G.):

Compétence liée et principe de légalité;D.chr.1964.

VALLERY-RADOT(M.):

Les règles de fond du remembrement rural et la jurisprudence du Conseil d'Etat;A.J.D.A., 1969.

VEDEL(G.):

Discontinuité du droit constitutionnel et continuité du droit administratif:le rôle du juge;in Mélanges M. WALINE,L.G.D.J.,1974, t.II.

VIDAL(R.):

Détournement du pouvoir dans la jurisprudence administrative Influence du contrôle des motifs;R.D.P., 1952.

VIGOR(P.):

Du contrôle juridictionnel de l'expulsion des étrangers; Revue politique et parlementaire, 1956.

VINCENT(J.Y.):

- L'erreur manifeste d'appréciation; Rev .adm., 1971,p.407.
- La réform de l'expulsion des étrangers par la loi du 29-10-1981;J.C.P.1982,3054.

WALINE(J.):

- Le rôle du juge administratif dans la détermination de

l'utilité publique justifiant l'expropriation; in Mélanges M.
WALINE, L.G.D.J., 1974, t. II.

- L'évolution du contrôle de l'Administration; R.D.P., 1984.

WALINE(M.):

- Le pouvoir discrétionnaire de l'Administration et sa limitation par le contrôle juridictionnel; R.D.
- L'autolimitation du pouvoir discrétionnaire par des "directives"; R.D.P., 1971.
- Etendue et limites du contrôle du juge administratif sur les actes de l'Administration; E.D.C.E., 1956.

WEIL(P.):

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux: politique jurisprudentielle ou jurisprudence politique? in Annales de la faculté de Droit d'Aix-en-Provence, 1959.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥	مقدمة
	فصل تمهيدي
١٧	أحكام عامة حول السلطة التقديرية
٢١	المبحث الأول: مراحل ظهور السلطة التقديرية في المجالات الإدارية
٢٢	المطلب الأول: مرحلة اختفاء كل تقدير للإدارة.....
	المطلب الثاني: مرحلة اختفاء كل تقييد للإدارة مع ظهور قرارات
٢٤	الإدارة البحتة.....
	المطلب الثالث: مرحلة اختفاء قرارا الإدارة البحتة مع ظهور
٢٩	قرارات الإدارة التقديرية.....
	المطلب الرابع: مرحلة اختفاء القرارات التقديرية مع ظهور السلطة
٣٤	التقديرية للإدارة
	المبحث الثاني: تعريف السلطة التقديرية للإدارة والأساس القانوني
٣٧	لها.....
٣٧	المطلب الأول: تعريف السلطة التقديرية
٣٧	أولاً: التعريف الإيجابي للسلطة التقديرية
٤١	ثانياً: التعريف السلبي للسلطة التقديرية
٤٣	ثالثاً: رأينا في تعريف السلطة التقديرية
٤٧	المطلب الثاني: الأساس القانوني للسلطة التقديرية

- ٤٧ أولا: فكرة تدرج القواعد القانونية
- ٤٨ ثانيا: نظرية الحقوق الشخصية
- ٥١ ثالثا: فكرة المشروع
- المبحث الثالث: مبررات السلطة التقديرية للإدارة وموضوعها في
- ٥٤ القرار الإداري
- ٥٤ المطلب الأول: مبررات السلطة التقديرية للإدارة
- ٥٨ المطلب الثاني: موضوع السلطة التقديرية في القرار الإداري

الباب الأول

- الاتجاهات التقليدية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للح د من
- ٦٩ سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها

الفصل الأول

- ٧٥ رقابة ماديات الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها
- المبحث الأول: ظهور الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها
- ٧٧ الإدارة لقراراتها في مصر
- المطلب الأول: ظهور الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها
- ٧٧ الإدارة لقراراتها في فرنسا
- المطلب الثاني: ظهور الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها
- ٨٢ الإدارة لقراراتها في مصر
- المبحث الثاني: أساس الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها
- ٨٦ الإدارة لقراراتها في فرنسا ومصر
- المطلب الأول: أساس الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها

- ٨٦الإدارة لقراراتها في مصر
- المطلب الثاني:** أساس الرقابة على ماديات الوقائع التي تدعيها
- ٩٦الإدارة لقراراتها في مصر

الفصل الثاني

- ١١١ **رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها**
- المبحث الأول:** مدلول التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها وموقف القضاء الإداري في كل من فرنسا
- ١١٣ومصر منه
- المطلب الأول:** مدلول التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها
- ١١٣الإدارة لقراراتها
- المطلب الثاني:** موقف القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر من التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها
- ١١٧لقراراتها
- المبحث الثاني:** استثناءات قاعدة رقابة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها
- ١٢٩لقراراتها
- المطلب الأول:** الحالات التي امتنع فيها القضاء الإداري عن إجراء رقابة التكييف القانوني للوقائع
- ١٣٠لقراراتها
- المطلب الثاني:** موقف الفقه من استثناءات قاعدة رقابة التكييف القانوني على الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها
- ١٤٠لقراراتها
- المبحث الثالث:** طبيعة التكييف القانوني للوقائع التي تدعيها الإدارة
- ١٤٥

- لقراراتها.....
- المطلب الأول: رقابة التكيف في حلة السلطة التقديرية للإدارة
- ١٤٦ رقابة مشروعية.....
- المطلب الثاني: رقابة التكيف في حالة السلطة التقديرية رقابة
- ١٤٩ ملاءمة.....
- المطلب الثالث: رأينا في طبيعة رقابة التكيف في حالة السلطة
- ١٥١ التقديرية.....
- الفصل الثالث**
- ١٥٥ رقابة تقدير أهمية وتناسب الوقائع التي تدعيها الإدارة لقراراتها
- المبحث الأول: الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري أمام
- ١٥٨ مجلس الدولة الفرنسي.....
- المطلب الأول: مجالات الضبط الإداري التي باشر مجلس الدولة
- ١٥٨ في خصوصها رقابة الملاءمة.....
- المطلب الثاني: مجالات الضبط الإداري التي امتنع مجلس الدولة
- ١٦٤ في خصوصها عن رقابة الملاءمة وأسباب ذلك
- أولاً: مجالات الضبط الإداري التي امتنع مجلس الدولة في
- ١٦٥ خصوصها رقابة الملاءمة.....
- ثانياً: أسباب امتناع القاضي الإداري عن رابة الملاءمة في
- ١٦٧ بعض مجالات الضبط الإداري.....
- المبحث الثاني: الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري أمام
- ١٧١ مجلس الدولة المصري.....

- المطلب الأول: رقابة قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية ١٧٢
- المطلب الثاني: رقابة قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية..... ١٧٥
- المبحث الثالث: موقف الفقه من الرقابة على الملاءمة في مجال الضبط الإداري..... ١٨٣
- المطلب الأول: المشروعية أساس رقابة الملاءمة في مجال الضبط الإداري..... ١٨٥
- المطلب الثاني: السياسة القضائية لمجلس الدولة أساس رقابة الملاءمة في مجال الضبط الإداري..... ١٩٢

الباب الثاني

- الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منه ٢٠١

الفصل الأول

- نظرية رقابة الخطأ البين ٢٠٧
- المبحث الأول: مراحل ظهور رقابة الخطأ البين ومعياري هذه الرقابة وموقعها بين مستويات الرقابة القضائية..... ٢١٢
- المطلب الأول: مراحل ظهور رقابة الخطأ البين..... ٢١٣
- المرحلة الأولى: من عام ١٩٥٣ حتى عام ١٩٦٠..... ٢١٤
- المرحلة الثانية: من بداية عام ١٩٦١ حتى نهاية عام ١٩٦٢ ٢١٨
- المرحلة الثالثة: من عام ١٩٦٢ حتى عام ١٩٧٢..... ٢٢٠

٢٢٦	المرحلة الرابعة: من عام ١٩٧٣ حتى الآن.....
٢٣١	المطلب الثاني: معيار الخطأ البين
٢٣٤	أولاً: المعيار اللغوي للخطأ البين
٢٣٧	ثانياً: المعيار الموضوعي للخطأ البين.....
٢٤٠	ثانياً: رأينا في معيار الخطأ البين
	المطلب الثالث: موقع رقابة الخطأ البين بين مستويات الرقابة
٢٤٣	القضائية.....
٢٥٠	المبحث الثاني: نطاق تطبيق رقابة الخطأ البين.....
	المطلب الأول: المجالات التقليدية لنزاعات العمل الإداري ورقابة
٢٥١	الخطأ البين.....
٢٥٢	الفرع الأول: منازعات الوظيفة العامة ورقابة الخطأ البين
	المسألة الأولى: لمحة عن منازعات الوظيفة العامة ورقابة
٢٥٢	الخطأ البين.....
٢٥٣	١ - الالتحاق بالوظيفة العامة.....
٢٥٥	٢ - تقارير كفاية الموظفين
٢٥٦	٣ - إحالة الموظفين إلى الاستداع أو فصلهم من الخدمة
٢٥٨	المسألة الثانية: منازعات تأديب الموظفين ورقابة الخطأ البين
	أولاً: الاتجاه التقليد للقضاء الإداري في رقابة منازعات تأديب
٢٥٨	الموظفين.....
٢٦٣	ثانياً: تعدد الأسباب ومنازعات تأديب الموظفين

٢٧٢	ثالثاً: الاتجاه الحديث للقضاء الإداري في رقابة منازعات تأديب الموظفين.....
٢٧٦	الفرع الثاني: إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب ورقابة الخطأ البيان.....
٢٧٦	أولاً: الاتجاه التقليدي للقضاء الإداري في رقابة إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب.....
٢٨٢	ثانياً: الاتجاه الحديث للقضاء الإداري في رقابة إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب.....
٢٩١	المطلب الثاني: المجالات الحديثة لنزاعات العمل الإداري ورقابة الخطأ البيان.....
٣٠٢	المبحث الثالث: موقف مجلس الدولة المصري من رقابة الخطأ البيان
	الفصل الثاني
٣١٩	نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار
٣٢١	المبحث الأول: مضمون نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ومعيار إعمال تلك الموازنة.....
٣٢١	المطلب الأول: مضمون نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار....
٣٢٧	المطلب الثاني: معيار الموازنة بين المنافع والأضرار.....
٣٣٤	المبحث الثاني: مجالات إعمال نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار
٣٣٥	المطلب الأول: نزع الملكية للمنفعة العامة ورقابة الموازنة بين المنافع والأضرار.....

المطلب الثاني: المجالات الأخرى التي تطبق فيها نظرية الموازنة	
بين المنافع والأضرار.....	٣٣٩
المبحث الثالث: الموازنة بين المنافع والأضرار ومراقبة الخطأ البين	٣٤٨
المطلب الأول: التقارب أو التشابه بين النظريتين.....	٣٤٩
المطلب الثاني: التباعد بين النظريتين.....	٣٥٤
المطلب الثالث: رأينا في الموضوع.....	٣٥٧
المبحث الرابع: تقدير نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.....	٣٦٧
المطلب الأول: أهم الانتقادات التي وجت إلى نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.....	٣٦٧
المطلب الثاني: تنفيذ الانتقادات التي وجهت إلى نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.....	٣٦٩
المبحث الرابع: موقف مجلس الدولة المصري من نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.....	٣٧٨
خاتمة.....	٣٨٩
المراجع.....	٣٩٩
الفهرس.....	٤٣٥